



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

EXTRATO DE SESSÃO DE JULGAMENTO

**DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM nº 05/2016
(19957.010647/2019-97) ***

**** Sessão realizada exclusivamente por videoconferência, na forma da
Deliberação CVM nº 855, de 30 de abril de 2020.***

Data do julgamento: 03/11/2020

Relator: Diretor Henrique Machado

Acusados:

Almir Guilherme Barbassa
Dilma Vana Rousseff
Fábio Colletti Barbosa
Francisco Roberto de Albuquerque
Guido Mantega
Guilherme de Oliveira Estrella
Ildo Luís Sauer
Jorge Gerdau Johannpeter
Jorge Luiz Zelada
José Sérgio Gabrielli de Azevedo
Luciano Galvão Coutinho
Maria das Graças Silva Foster
Nestor Cuñat Cerveró
Paulo Roberto Costa
Renato de Souza Duque
Sergio Franklin Quintella
Silas Rondeau Cavalcante Silva

Ementa: Inobservância de deveres fiduciários de administradores da Petrobras na construção da Refinaria Abreu e Lima. Infração aos artigos 153, 154, §2º, “c”,

Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de Valores Mobiliários, com base na prova dos autos e na legislação aplicável, decidiu:

i) Por Maioria: pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva da CVM no que se refere à acusação em desfavor de Almir Guilherme Barbassa, Guilherme de Oliveira Estrella, Ildo Luís Sauer, José Sérgio Gabrielli de Azevedo, Nestor Cuñat Cerveró e Renato de Souza Duque, na qualidade de diretores estatutários da Petrobras, por falta ao dever de diligência ao aprovarem o Plano de Antecipação da Refinaria, em infração ao art. 153 da Lei 6.404/76.

ii) Por Maioria: pela absolvição de Almir Guilherme Barbassa, Guilherme de Oliveira Estrella, Maria das Graças da Silva Foster, José Sérgio Gabrielli de Azevedo e Jorge Luiz Zelada, na qualidade de diretores estatutários da Petrobras, da acusação de terem faltado com o dever de diligência ao aprovarem a passagem do projeto RNEST à fase IV, em infração ao art. 153 da Lei 6.404/76.

iii) Por Maioria: pela absolvição de José Sérgio Gabrielli de Azevedo, Fabio Colletti Barbosa, Francisco Roberto de Albuquerque, Guido Mantega, Jorge Gerdau Johannpeter, Luciano Galvão Coutinho, Sergio Franklin Quintella e Silas Rondeau Cavalcante Silva, na qualidade de membros do conselho de administração da Petrobras, da acusação de terem faltado com o dever de diligência ao participarem do processo de decisão que aprovou a passagem do projeto RNEST à fase IV, em infração ao art. 153 da Lei 6.404/76.

iv) Por Maioria: pela absolvição de Dilma Vana Rousseff, Guido Mantega, Fábio Colletti Barbosa, Francisco Roberto de Albuquerque, Jorge Gerdau Johannpeter, Luciano Galvão Coutinho, José Sérgio Gabrielli de Azevedo e Silas Rondeau Cavalcante Silva, na qualidade de membros do conselho de administração da Petrobras, da acusação por falta ao dever de diligência na supervisão dos controles internos da Companhia, em infração ao art. 153 da Lei 6.404/76.

v) Por Unanimidade: pela condenação de Renato de Souza Duque, na qualidade de diretor de engenharia e serviços da Petrobras, à inabilitação temporária por 15 anos, para o exercício do cargo de administrador ou conselheiro fiscal de companhia aberta, por ter violado o seu dever de lealdade, ao votar favoravelmente pela aprovação da passagem do projeto RNEST à fase IV, em troca de vantagens indevidas, em infração ao art. 154, §2º, 'c', da Lei 6.404/76, c/c o art. 155, caput, da Lei 6.404/76.

vi) Por Unanimidade: pela condenação de Paulo Roberto Costa, na qualidade de diretor de abastecimento da Petrobras:

i. à inabilitação temporária por 15 anos, para o exercício do cargo de administrador ou conselheiro fiscal de companhia aberta, por ter violado o seu dever de lealdade, ao propor e votar favoravelmente pela aprovação do Plano de

Antecipação da Refinaria, em troca de vantagens indevidas, em infração ao art. 154, §2º, 'c', da Lei 6.404/76, c/c o art. 155, caput, da Lei 6.404/76.

ii. à multa de R\$ 500.000,00, por ter violado o seu dever de lealdade, ao propor e votar favoravelmente pela aprovação da passagem do projeto RNEST à fase IV, em troca de vantagens indevidas, em infração ao art. 154, §2º, 'c', da Lei 6.404/76, c/c o art. 155, caput, da Lei 6.404/76.

vii) Por Unanimidade: pela absolvição de Maria das Graças Silva Foster, na qualidade de presidente da Petrobras, da acusação de desvio de poder.

A sessão de julgamento foi iniciada em 24.08.2020, ocasião na qual o Diretor Relator, Henrique Machado, proferiu seu voto, que consistiu na condenação de: **a)** Almir Guilherme Barbassa, Guilherme de Oliveira Estrella, Ildo Luís Sauer, José Sérgio Gabrielli de Azevedo, Nestor Cuñat Cerveró e Renato de Souza Duque, na qualidade de diretores estatutários da Petrobras, à penalidade de multa pecuniária individual no valor de R\$400.000,00 (quatrocentos mil reais), por terem faltado com o seu dever de diligência, ao aprovar o Plano de Antecipação da Refinaria, em infração ao art. 153 da Lei nº 6.404/76. **b)** Almir Guilherme Barbassa, Guilherme de Oliveira Estrella, Maria das Graças da Silva Foster, José Sérgio Gabrielli de Azevedo e Jorge Luiz Zelada, na qualidade de diretores estatutários da Petrobras, à penalidade de multa pecuniária individual no valor de R\$400.000,00 (quatrocentos mil reais), por terem faltado com o seu dever de diligência, ao aprovar a passagem do projeto RNEST à fase IV, em infração ao art. 153 da Lei nº 6.404/76. **c)** José Sérgio Gabrielli de Azevedo, Fabio Colletti Barbosa, Francisco Roberto de Albuquerque, Guido Mantega, Jorge Gerdau Johannpeter, Luciano Galvão Coutinho, Sergio Franklin Quintella e Silas Rondeau Cavalcante Silva, na qualidade de membros do conselho de administração da Petrobras, à penalidade de multa pecuniária individual no valor de R\$400.000,00 (quatrocentos mil reais), por terem faltado com o seu dever de diligência, ao participarem do processo de decisão que aprovou a passagem do projeto RNEST à fase IV, em infração ao art. 153 da Lei nº 6.404/76. **d)** Dilma Vana Rousseff, José Sérgio Gabrielli de Azevedo, Fabio Colletti Barbosa, Francisco Roberto de Albuquerque, Guido Mantega, Jorge Gerdau Johannpeter, Luciano Galvão Coutinho e Silas Rondeau Cavalcante Silva, na qualidade de membros do conselho de administração da Petrobras, à penalidade de multa pecuniária individual no valor de R\$300.000,00 (trezentos mil reais), por terem faltado com o seu dever de diligência na supervisão dos controles internos da Petrobras, em infração ao art. 153 da Lei nº 6.404/76. **e)** Renato de Souza Duque, na qualidade de diretor de engenharia e serviços da Petrobras, à penalidade de inabilitação temporária pelo prazo de 15 (quinze) anos, para o exercício do cargo de administrador ou conselheiro fiscal de companhia aberta, por ter violado o seu dever de lealdade, ao votar favoravelmente pela aprovação da passagem do projeto RNEST à fase IV, em troca de vantagens indevidas, em infração ao art. 154, §2º, c) da Lei nº 6.404/76 c/c art. 155, caput da Lei nº 6.404/76. **f)** Paulo Roberto Costa, na qualidade de diretor de abastecimento da Petrobras: i. à penalidade de inabilitação temporária pelo prazo de 15 (quinze) anos, para o exercício do cargo de administrador ou conselheiro fiscal de companhia aberta, por ter violado o seu dever de lealdade, ao propor e votar favoravelmente pela aprovação do Plano de Antecipação da Refinaria, em troca de vantagens indevidas, em infração ao art. 154, §2º, c) da Lei nº 6.404/76 c/c art. 155, caput da Lei nº 6.404/76. ii. à

penalidade de multa pecuniária no valor de R\$500.000,00 (quinhentos mil reais), por ter violado o seu dever de lealdade, ao propor e votar favoravelmente pela aprovação da passagem do projeto RNEST à fase IV, em troca de vantagens indevidas, em infração ao art. 154, §2º, c) da Lei nº 6.404/76 c/c art. 155, caput da Lei nº 6.404/76. 262. Voto também pela absolvição de Maria das Graças Silva Foster, na qualidade de presidente da Petrobras, da acusação de desvio de poder que lhe foi formulada neste processo. Em seguida o Diretor Gustavo Gonzalez pediu vistas do processo.

Presentes em 24.08.2020 os advogados Victor Leal, representando o Nestor Cerveró, Walfrido Warde, representando Dilma Rousseff, Pedro Schelbauer, representando Jorge Luiz Zelada, Luiz Antonio, Paulo Cezar Aragão, Fernanda Carneiro e Daniella Frago, representando Francisco R. de Albuquerque, Guido Mantega, Jorge Gerdau Johannpeter, Luciano Galvão Coutinho, Sergio Franklin Quintella e Silas Rondeau Cavalcante Silva, Leonardo Pereira, representando Maria das Graças Foster, Celso Mori, representando Fabio Colletti, Maria Lucia Cantidiano, representando Ildo Sauer, Nelson Eizirik, representando Almir Barbassa e Guilherme Estrella e Henrique Costa, representando José Gabrielli de Azevedo.

Presente a Procuradora Luciana Dayer, representante da Procuradoria Federal Especializada da CVM.

Participaram da Sessão de Julgamento os Diretores Gustavo Machado Gonzalez, Flávia Sant'Anna Perlingeiro e Henrique Balduino Machado Moreira, que presidiu a Sessão.

O Presidente Marcelo Barbosa declarou-se impedido no caso.

A sessão foi reiniciada em 3.11.2020, e o Diretor Gustavo Gonzalez, em sua manifestação de voto, relatou três divergências com relação ao voto do Diretor Relator, Henrique Machado, referentes i) ao alcance do art. 1º, §2º, da Lei 9.873/99, que, em caráter excepcional, substitui o prazo prescricional quinquenal ordinariamente aplicável para o exercício de ação punitiva pela administração pública federal pelos prazos previstos na lei penal “quando o fato objeto da ação punitiva da Administração também constituir crime”; ii) ao mérito da acusação de falta de diligência formulada contra os diretores e membros do conselho de administração da Petrobras que participaram das reuniões desses órgãos em que se tratou da mudança de fase do projeto RNEST. e iii) ao mérito da acusação de falta de diligência na supervisão dos controles internos da Petrobras.

O Diretor votou: **i)** pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva da CVM no que se refere à acusação em desfavor de Almir Guilherme Barbassa, Guilherme de Oliveira Estrella, Ildo Luís Sauer, José Sérgio Gabrielli de Azevedo, Nestor Cuñat Cerveró e Renato de Souza Duque por falta ao dever de diligência ao aprovarem o Plano de Antecipação da Refinaria, em infração ao art. 153 da Lei 6.404/76; **ii)** pela absolvição de Almir Guilherme Barbassa, Guilherme de Oliveira Estrella, Maria das Graças da Silva Foster, José Sérgio Gabrielli de Azevedo e Jorge Luiz Zelada, na qualidade de diretores estatutários da

Petrobras, da acusação de terem faltado com o dever de diligência ao aprovarem a passagem do projeto RNEST à fase IV, em infração ao art. 153 da Lei 6.404/76; **iii)** pela absolvição de José Sérgio Gabrielli de Azevedo, Fabio Colletti Barbosa, Francisco Roberto de Albuquerque, Guido Mantega, Jorge Gerdau Johannpeter, Luciano Galvão Coutinho, Sergio Franklin Quintella e Silas Rondeau Cavalcante Silva, na qualidade de membros do conselho de administração da Petrobras, da acusação de terem faltado com o dever de diligência ao participarem do processo de decisão que aprovou a passagem do projeto RNEST à fase IV, em infração ao art. 153 da Lei 6.404/76); **iv)** pela absolvição de Dilma Vana Rousseff, Guido Mantega, Fábio Colletti Barbosa, Francisco Roberto de Albuquerque, Jorge Gerdau Johannpeter, Luciano Galvão Coutinho, José Sérgio Gabrielli de Azevedo e Silas Rondeau Cavalcante Silva, na qualidade de membros do conselho de administração da Petrobras, da acusação por falta ao dever de diligência na supervisão dos controles internos da Companhia, em infração ao art. 153 da Lei 6.404/76 e **v)** de acordo com o Diretor Relator em relação às demais imputações.

Em seguida, a Diretora Flávia Perlingeiro apresentou manifestação de voto, acompanhando, em suas conclusões, o voto divergente do Diretor Gustavo Gonzalez.

Em seu voto, destacou aspectos específicos sobre os fatos e documentos que ampararam sua percepção a respeito da participação dos diretores estatutários e membros do conselho de administração da Petrobras, na aprovação da passagem do projeto RNEST à fase IV, e ressaltou seu entendimento sobre a análise do dever de monitoramento dos controles internos pelo conselho de administração, em uma perspectiva organizacional.

O Diretor Henrique Machado teceu considerações finais quanto à adequada interpretação da regra de decisão negocial e às alegações de inversão do ônus da prova. Em seu entendimento, a regra de decisão negocial não deve ser aplicada quando constatada a falha procedimental do processo decisório, o que, no presente caso, restaria demonstrado pela ausência de justificativa válida para decisões de investimento contrárias aos normativos internos e aos riscos apontados pelas manifestações técnicas dos órgãos da Petrobras.

Os acusados punidos terão um prazo de 30 dias, a contar da comunicação da decisão da CVM, para interpor recurso voluntário ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, nos termos do art. 70 da Instrução CVM nº 607/19.

Nos termos do disposto no art. 71 da mesma Instrução, os acusados punidos com a penalidade de inabilitação temporária poderão requerer ao Colegiado da CVM efeito suspensivo dessa decisão.

Presentes os advogados Victor Leal, representando o Nestor Cerveró, Walfrido Warde, representando Dilma Rousseff, Pedro Schelbauer, representando Jorge Luiz Zelada, Luiz Antonio, Paulo Cezar Aragão, Fernanda

Carneiro e Daniella Fragoso, representando Francisco R. de Albuquerque, Guido Mantega, Jorge Gerdau Johannpeter, Luciano Galvão Coutinho, Sergio Franklin Quintella e Silas Rondeau Cavalcante Silva, Leonardo Pereira, representando Maria das Graças Foster, Celso Mori, representando Fabio Colletti, Maria Lucia Cantidiano, representando Ildo Sauer, Nelson Eizirik, representando Almir Barbassa e Guilherme Estrella e Henrique Costa, representando José Gabrielli de Azevedo.

Presente a Procuradora Luciana Dayer, representante da Procuradoria Federal Especializada da CVM.

Participaram da Sessão de Julgamento os Diretores Gustavo Machado Gonzalez, Flávia Sant'Anna Perlingeiro e Henrique Balduino Machado Moreira, que presidiu a Sessão.

O Presidente Marcelo Barbosa declarou-se impedido no caso.



Documento assinado eletronicamente por **Gustavo Machado Gonzalez, Diretor**, em 21/12/2020, às 21:03, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **Flavia Martins Sant Anna Perlingeiro, Diretor**, em 22/12/2020, às 14:23, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **HENRIQUE BALDUINO MACHADO MOREIRA, Usuário Externo**, em 01/03/2021, às 12:18, com fundamento no art. 6º do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, informando o código verificador **1154903** e o código CRC **20376D54**.

*This document's authenticity can be verified by accessing https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, and typing the "Código Verificador" **1154903** and the "Código CRC" **20376D54**.*



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM Nº 05/2016

Reg. Col. nº 1404/2019

Acusados: Almir Guilherme Barbassa
Dilma Vana Rousseff
Fábio Colletti Barbosa
Francisco Roberto de Albuquerque
Guido Mantega
Guilherme de Oliveira Estrella
Ildo Luís Sauer
Jorge Gerdau Johannpeter
Jorge Luiz Zelada
José Sérgio Gabrielli de Azevedo
Luciano Galvão Coutinho
Maria das Graças Silva Foster
Nestor Cuñat Cerveró
Paulo Roberto Costa
Renato de Souza Duque
Sergio Franklin Quintella
Silas Rondeau Cavalcante Silva

Assunto: Apurar possível inobservância de deveres fiduciários de administradores da Petrobras na construção da Refinaria Abreu e Lima. Infração aos artigos 153, 154, §2º, “c”, 155, e 163, I, da Lei nº 6.404/76.

Diretor Relator: Henrique Machado

RELATÓRIO

I. OBJETO E ORIGEM

1. Trata-se de processo administrativo sancionador instaurado pela Superintendência de Processos Sancionadores (“SPS” ou “Acusação”) para apurar a responsabilidade de administradores da Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras (“Petrobras” ou “Companhia”) pelo possível descumprimento de deveres fiduciários na construção da Refinaria Abreu e Lima (“RNEST” ou “Refinaria”).
2. O presente processo originou-se a partir do desmembramento do inquérito administrativo (“IA”) CVM nº 04/2014, instaurado por intermédio da



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

PORTARIA/CVM/SGE/Nº 376 (fls. 10), para apurar a possível inobservância de deveres fiduciários de administradores da Petrobras decorrentes dos fatos revelados pela investigação do Ministério Público Federal denominada de “Operação Lava Jato”.

3. Em virtude da multiplicidade de pessoas e assuntos investigados, a SPS optou por desmembrar a apuração em diferentes procedimentos de modo a separá-los em função do tema investigado, buscando, com isso, obter celeridade e racionalidade nas diversas investigações em curso.

4. Em 24.03.2016, o IA CVM nº 5/2016 foi instaurado¹ para apurar a possível ocorrência de irregularidades nos procedimentos relativos à construção da RNEST, objeto do presente processo.

II. DA PRESCRIÇÃO

5. Antes de iniciar os procedimentos ordinários de investigação, a SPS analisou quais fatos poderiam ser objeto de ação punitiva por esta Autarquia, à luz dos prazos prescricionais estabelecidos pela Lei nº 9.873 de 23 de novembro de 1999. Sobre o tema, destaca inicialmente que os fatos do presente processo teriam violado, ao mesmo tempo, a legislação penal e societária, aplicando-se, por isso, o prazo prescricional da lei da penal², consoante o art. 1º, §2º, da mencionada Lei nº 9.873/99.

6. Nesse sentido, argumenta que o pagamento de propina a agentes públicos administradores da Petrobras por empresas fornecedoras de serviços seria conduta ilícita à luz do art. 317 do Código Penal de 1940³, o qual define a corrupção passiva, e também dos arts. 153 e seguintes da Lei nº 6.404/76⁴, os quais estabelecem deveres

¹ PORTARIA/CVM/SGE/Nº72 (fls.1).

² Art. 1º Prescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração Pública Federal, direta e indireta, no exercício do poder de polícia, objetivando apurar infração à legislação em vigor, contados da data da prática do ato ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado. § 2º Quando o fato objeto da ação punitiva da Administração também constituir crime, a prescrição reger-se-á pelo prazo previsto na lei penal.

³ Art. 317 - Solicitar ou receber, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida, ou aceitar promessa de tal vantagem: Pena – reclusão, de 2 (dois) a 12 (doze) anos, e multa.

⁴ Art. 153. O administrador da companhia deve empregar, no exercício de suas funções, o cuidado e diligência que todo homem ativo e probo costuma empregar na administração dos seus próprios negócios.

Art. 154. O administrador deve exercer as atribuições que a lei e o estatuto lhe conferem para lograr os fins e no interesse da companhia, satisfeitas as exigências do bem público e da função social da empresa.

(...)

§ 2º É vedado ao administrador:



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

fiduciários aos administradores de companhias abertas. Concluiu a área técnica, nesse passo, que o prazo de prescrição dos fatos objeto do presente caso deve ser o de 16 anos, conforme previsto no inciso II, do art. 109, do Código Penal de 1940⁵.

7. Como a conduta irregular dos administradores teria se iniciado em fevereiro de 2005 (fls. 477 a 479), com a assinatura do memorando de entendimento para a construção da RNEST, e as apurações no âmbito desta Autarquia teriam começado em 20.10.2014, com a instauração do Processo RJ-2014/12184 (origem do IA nº 14/2014), a Acusação asseverou que essa instauração teria interrompido o prazo prescricional.

8. Quanto à utilização do prazo prescricional penal àqueles administradores que não foram objeto da persecução penal, a SPS sustenta que a prescrição é fenômeno relacionado a fatos submetidos à investigação e, não, às pessoas, motivo pelo qual entende que o prazo prescricional da lei penal a estes também seria aplicável (fls. 5.599).

III. DOS FATOS E DA ACUSAÇÃO

III.1. PROCESSO DECISÓRIO NO ÂMBITO DA DIRETORIA

9. Segundo apurado pela SPS, as decisões da diretoria executiva ocorriam semanalmente, às quintas-feiras, de modo colegiado. Em regra, os projetos de cada diretor eram enviados até a sexta-feira da semana anterior, sob a forma de documento interno da Petrobras (“DIP”), à secretaria geral da Companhia. A secretaria propunha os assuntos da reunião para o presidente.

10. A SPS relata que a pauta era enviada, em algumas ocasiões, na mesma semana da reunião de diretoria. Outra situação narrada na peça acusatória diz respeito ao encaminhamento da pauta pelo diretor responsável pelo projeto no mesmo dia da reunião. Questionados, os administradores admitiram ambas as situações. De acordo com os administradores ouvidos pela área técnica, havia também a pauta “extra” por meio da qual eram encaminhadas, entre segunda e quarta-feira da semana da deliberação, questões supostamente urgentes e inadiáveis. E havia ainda a pauta

(...)

c) receber de terceiros, sem autorização estatutária ou da assembléia-geral, qualquer modalidade de vantagem pessoal, direta ou indireta, em razão do exercício de seu cargo.

Art. 155. O administrador deve servir com lealdade à companhia e manter reserva sobre os seus negócios, sendo-lhe vedado: (...)

⁵ Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1º do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se: II - em dezesseis anos, se o máximo da pena é superior a oito anos e não excede a doze;



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

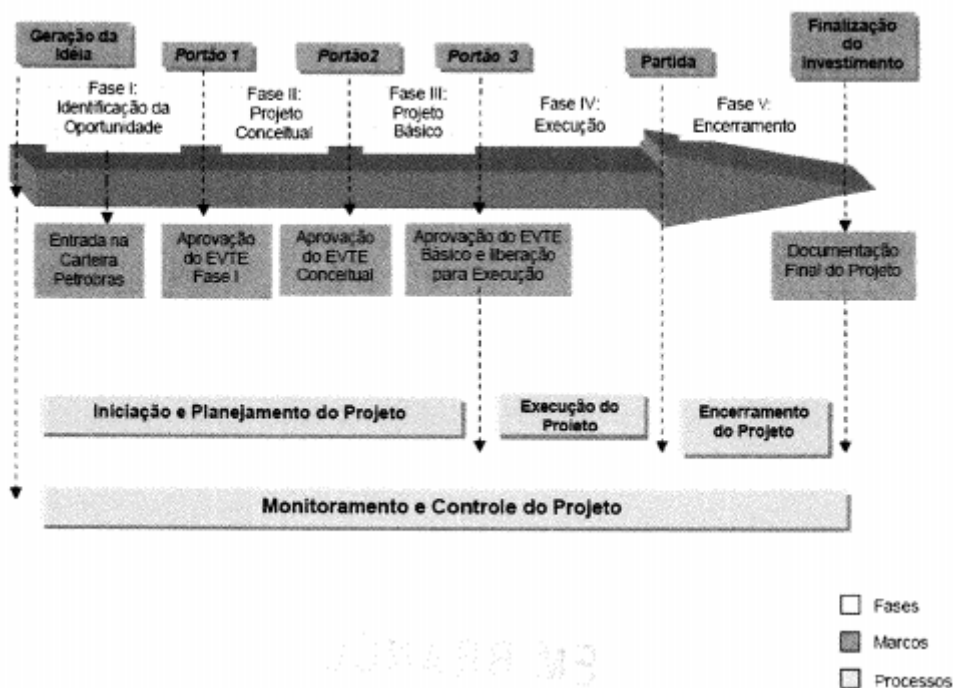
Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

“axilar”, por meio da qual assuntos eram inseridos no próprio dia da reunião, normalmente por questões de alegado sigilo.

11. Narra a Acusação que dificilmente as pautas eram recusadas, pois significaria a inépcia de sua elaboração, de modo que, mesmo com objeções, pautas eram mantidas e retiradas na própria reunião para eventuais ajustes e complementos. Após os ajustes, o assunto retornava para a deliberação dos diretores. Em algumas ocasiões, a pauta poderia não mais retornar para deliberação.

12. Noutro ponto, relata a SPS que a Sistemática Corporativa de Projetos de Investimentos do Sistema Petrobras (“Sistemática Corporativa”)⁶, aprovada em 28.03.2011, era o documento interno que fornecia as diretrizes para o planejamento, aprovação e monitoramento dos projetos de investimento, com o objetivo de padronizar os procedimentos e conceitos a serem seguidos por todas áreas do Sistema Petrobrás.

13. Consoante as diretrizes, os projetos de investimento deveriam apresentar estudo de viabilidade técnico-econômica (“EVTE”) e seguir padrões internacionais de gerenciamento de projetos. A utilização de padrões internacionais ocorria a partir da aplicação da metodologia *front-end loading* (“FEL”), com cinco fases de desenvolvimento, conforme revela a figura a seguir:



⁶ Fls. 1083 a 1160.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

14. De acordo com referida metodologia, as etapas iniciais do projeto serviriam para planejá-lo da forma adequada aos interesses finais do investimento. Em caso de alterações no projeto, as mudanças poderiam ser executadas nas etapas iniciais sem acarretar aumento excessivo nos custos. Com o avançar do projeto, menores seriam as possibilidades de alterações não impactarem fortemente os custos do projeto⁷.

15. Prossegue a SPS descrevendo que, de acordo com os controles criados para avaliar e monitorar os projetos de investimentos da Petrobras, a passagem de fase demandaria pareceres técnicos das áreas corporativas da Companhia (fls. 4.816 a 4.871.) Além disso, todos os projetos de investimento deveriam apresentar valor presente líquido (“VPL”)⁸ positivo para aprovação da mudança de fase. E os projetos acima de 3% do total da carteira de uma área específica da Companhia precisariam também, para avançar, da aprovação pela diretoria, com avaliação prévia do comitê de investimentos da Petrobras.

III.2. PROJETO RNEST

III.2.1. O INÍCIO DO PROJETO RNEST

16. Destaca a Acusação que a Petrobras começou, em 2005, o projeto para construir uma nova refinaria no Brasil e que a construção da última refinaria pela Companhia teria ocorrido na década de 1980 (fls. 970). Acrescenta que, segundo estudos da Petrobras, com a demanda por petróleo crescendo 2% ao ano até 2020 e a

⁷ As decisões tomadas nas Fases iniciais têm grande influência nos resultados do projeto, apesar do pequeno percentual de investimento alocado. Já nas Fases subsequentes, o grau de investimento é reduzido, enquanto o nível de investimento se eleva. Sendo assim, devem ser aprofundados os estudos para escolha das melhores alternativas de concepção do projeto durante as Fases I e II. A postergação de decisões e a introdução de modificações relevantes nas Fases mais avançadas, quando é alta a realização de investimentos, implicarão em altos custos e numa menor flexibilidade para atuação nas suas consequências. [...] A Sistemática Corporativa de Projetos de Investimento adota abordagem na qual a tomada de decisão final para a execução do investimento é lastreada em um processo de sucessivas análises e aprovações. Esta concepção permite obter estimativas mais precisas de seus indicadores ao longo do ciclo de vida do projeto. A diferenciação e a recomendação de planejar o projeto em três Fases, Identificação de Oportunidade, Projeto Conceitual e Projeto Básico deve-se à: 1. Busca de um maior grau de definição do projeto, de maturidade suficiente para mitigar os riscos envolvidos, evitar retrabalhos e custos adicionais em Fases posteriores; 2. Padronização dos requisitos mínimos necessários a serem apresentados ao decisor ao final de cada uma das Fases, de modo a auxiliá-lo nas análises e decisões a serem tomadas em cada portão correspondente.”

⁸ O VPL consiste na diferença entre as receitas obtidas e despesas incorridas em um projeto. Nesse sentido, funciona como um indicador de geração de riqueza: agrega valor ao negócio quando positivo e consome valor quando negativo.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

produção de petróleo excedendo a capacidade de refino na América Latina (fls. 480 a 500), o Brasil precisaria de 2,345 MBD⁹ em 2020.

17. Em 14.02.2005, a Petrobras assinou memorando de entendimentos com a Petroleos de Venezuela S.A. (“PDVSA”) para o desenvolvimento de negócios e atividades de cooperação no setor de refino, visando a atender a estratégia de processamento de petróleos pesados e extrapesados do Brasil e da Venezuela (fls. 477-479). De acordo com o memorando, cada empresa teria 50% de participação na futura refinaria (fls. 471), pois elas teriam interesse comum no processamento de óleo pesado e extrapesado.

18. Naquele primeiro momento, a Petrobras previu que o valor total do investimento seria de US\$2,3 bilhões, com VPL de US\$209,9 milhões. Aduz a área técnica que estes valores foram produzidos pela própria Companhia sem contratação de consultoria específica.

19. A diretoria aprovou, em 29.9.2005, a passagem do projeto para a segunda fase, também denominada de conceitual¹⁰ (fls. 468). Com a conclusão da etapa conceitual (fase II) no final de 2006 (fls. 1.203 a 1.223), a administração estabeleceu que a refinaria teria uma unidade de destilação atmosférica (“UDA”) de 200 MBPD e dois trens de conversão e hidrotratamento. A SPS apurou que o projeto inicial teria previsto apenas uma UDA, mas, em 2007, a Petrobras concluiu ser incompatível o processamento do óleo venezuelano com o brasileiro, forçando nova alteração no projeto para calcular a existência de duas UDA.

20. Em outra frente, a estrutura societária a ser formada entre a Companhia e a PDVSA foi delineada com a constituição da RNEST S.A., subsidiária da Petrobras, com o intuito, segundo informações obtidas pela área técnica, de isolar os custos do projeto. Neste ponto, a Acusação registra a ausência de formalização da pretendida parceria ao mesmo tempo em que o projeto tampouco prescindia da existência dela.

21. Sobre o tema, a SPS destaca que, em dezembro de 2016, o planejamento financeiro da diretoria financeira e da estratégia e desempenho empresarial (“PLAFIN”) emitiu parecer apontando o seguinte (fls. 3.861, CD- arquivo __Pauta_DE_1319-2006.pdf, pg. 35):

Está previsto o desenvolvimento do projeto na forma de parceria com a PDVSA, mas não há definição sobre a mesma até o momento. Um

⁹ A unidade MDB significa *thousand barrels oil* ou milhares de barris de petróleo. MDB foi utilizado nos documentos da Petrobras significando a taxa diária de milhares de barris de petróleo por dia.

¹⁰ Sobre a sistemática de projetos da Petrobras, vide seção **Erro! Fonte de referência não encontrada.** deste Relatório.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Memorando de Entendimentos, firmado entre Petrobras e a PDVSA, prevê a elaboração, em conjunto, de estudos para implantação da refinaria, sem, no entanto, firmar compromisso de investimentos, definir participações societárias ou estabelecer critérios de comercialização. [...]

22. Sustenta a Acusação que a perspectiva de parceria foi considerada por anos no projeto apesar da ausência de compromisso formal da PDVSA, tendo sido desconsiderada apenas em 2013, 8 anos depois, com a incorporação pela Petrobras da RNEST S/A. A falta de concretude da parceria não poderia, no sentir da SPS, ter sido negligenciada pelos administradores ao longo da condução e fiscalização do projeto, em razão de sua relevância tanto na concepção quanto na execução da construção da refinaria.

III.2.2. PLANO DE ANTECIPAÇÃO DO PROJETO RNEST

23. Em 21.12.2006, a diretoria da Petrobras aprovou o cronograma da obra da refinaria prevendo iniciar a pré-operação (“Partida Original”) no segundo semestre de 2011 (fls. 1.219 a 1.220). Para cumprir a meta, os gerentes executivos responsáveis pelo projeto apontaram a necessidade de antecipar medidas que, segundo a Sistemática Corporativa, só deveriam ser tomadas na fase de execução (fase IV). À época, o projeto se encontrava na fase de planejamento (fase III).

24. Segundo a SPS, a execução de obras durante a fase de planejamento seria contrária ao procedimento preconizado na Sistemática Corporativa, tendo em vista que ainda estava em curso fase de planejamento (Projeto Básico – Fase III). Pela sistemática correta, as obras só poderiam ser iniciadas a partir da fase IV (execução).

25. Em anexo ao DIP relativo ao tema, o PLAFIN (fls. 3.861) indicou que algumas atividades anteriormente previstas para a fase de execução (fase IV) deveriam ser antecipadas para a fase de planejamento, com o objetivo de obedecer à data prevista para a Partida Original. Sugeriu que a diretoria executiva não assumisse compromissos antes da aprovação do projeto básico e alertou sobre a indefinição da parceria com a PDVSA. Apontou que a não concretização do acordo entre as companhias implicaria diferença significativa no valor a ser investido pela Petrobras. Transcreve-se a seguir trechos do documento reproduzidos no relatório de inquérito:

Está previsto o desenvolvimento do projeto na forma de parceria com a PDVSA, mas não há definição sobre a mesma até o momento. Um Memorando de Entendimentos, firmado entre Petrobras e a PDVSA, prevê a elaboração, em conjunto, de estudos para implantação da refinaria, sem, no entanto, firmar compromisso de investimentos,



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

definir participações societárias ou estabelecer critérios de comercialização. [...]

Recomendamos que a aprovação de recursos físicos, de pessoal e financeiros, propostos para a fase FEL 3, esteja condicionada à definição do parceiro no empreendimento, bem como da criação da empresa que constituirá a refinaria, ou da criação de um mecanismo que garanta o ressarcimento desses gastos, no caso de antecipação por parte da Petrobras.[...]

As análises de sensibilidade realizadas indicaram que o resultado do empreendimento é extremamente sensível à atuação da PDVSA como *off taker* no mercado do entorno da Nova Refinaria. [...]

[Recomendava-se] Não assumir compromissos que tragam alguma irreversibilidade em relação a [sic] implantação do projeto antes da aprovação do projeto básico. Em especial, apenas realizar a aquisição antecipada dos equipamentos críticos e os gastos de terraplanagem após a conclusão do projeto básico de Engenharia. [...]

Conforme pode ser constatado, a refinaria será composta de uma destilação atmosférica [UDA] e dois conjuntos (trens) independentes das demais unidades. Tais trens separados objetivam aumentar a confiabilidade, o fator operacional e a facilidade de manutenção da refinaria.

26. Pouco tempo depois daquela deliberação, a diretoria da Petrobras aprovou¹¹, em 08.03.2007, a implementação do Plano de Antecipação da Refinaria ("PAR"), o qual propunha o mês de agosto de 2010 para o início das atividades da RNEST. Estavam presentes nesta deliberação José Gabrielli, Almir Barbassa, Guilherme Estrella, Ildo Sauer, Nestor Cerveró, Paulo Roberto Costa e Renato Duque (fls. 1237).

27. Na documentação que amparou a reunião, a gerente executiva corporativa da área de abastecimento, V.V.F., consignou que o cronograma apresentado "*não possui[ria] margem de segurança, exigindo para sua implantação priorização pelas áreas envolvidas, em especial Abastecimento, CENPES, Engenharia e Materiais.*" (fls. 3.866).

28. No sentir da Acusação, a diretoria antecipou a data de início da operação da refinaria em um ano sem ter respaldo técnico suficiente para tal empreitada, dada as incertezas que ainda permeavam a fase de planejamento do projeto. A SPS reforça sua conclusão ressaltando que o cronograma inicialmente proposto e aprovado já teria sido

¹¹ Segundo o DIP da reunião, o PAR foi solicitado por Paulo Roberto Costa e demandou priorização do projeto pelas áreas de abastecimento, centro de pesquisa e desenvolvimento, engenharia e materiais para que sua implementação se desse conforme desejado.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

objeto de alerta das áreas técnicas da Petrobras para não assumir compromissos irreversíveis, antes da aprovação do projeto básico. Do mesmo modo, os administradores teriam sido advertidos por técnicos das destacadas diferenças de investimento decorrentes da construção com e sem a parceira da PDVSA (US\$ 588 milhões versus US\$ 2,6 bilhões).

29. Ainda sobre a decisão de antecipar a operação da RNEST, a SPS trouxe à luz investigação conduzida pela comissão interna de apuração da RNEST (“CIA RNEST”), instaurada pela Petrobras, a partir das denúncias de corrupção evidenciadas pela Operação Lava Jato, para analisar os procedimentos de contratação realizados durante o projeto. Essa comissão constatou que (fls. 1.243/1.260):

5.4.4 Como consequência da aprovação do PAR pela Diretoria Executiva em 08/03/2007 [...], foi determinado ao Abastecimento, CENPES, MATERIAIS e ENGENHARIA, a elaboração de estratégia de contratação de equipamentos e serviços para viabilizar a implementação do PAR, dentre outros, que deveria ter retornado à Diretoria Executiva em até 45 dias, com a proposta definitiva, a partir de 08/03/2007. A Comissão não obteve evidência de que o assunto tenha retornado à Diretoria Executiva. [...]

A Comissão não evidenciou justificativa adequada para a elaboração do PAR, uma vez que a contratação e/ou elaboração dos projetos básicos das unidades, condições necessárias para a definição consistente do cronograma de antecipação, somente foram iniciadas a partir de março/2007, quando da aprovação do PAR [...].

A Diretoria Executiva aprovou o PAR ciente de que “o cronograma apresentado não possuía margem de segurança, exigindo para sua implementação priorização pelas áreas envolvidas” [...]

5.4.6 O desenvolvimento do projeto básico da RNEST foi realizado considerando o processamento, em uma única UDA, do óleo venezuelano (Carabobo) e do nacional (Marlin Sul 6-MLS-3B). Entretanto, apenas em dezembro/2007, foram finalizados os testes com o óleo venezuelano [...], que demonstraram a incompatibilidade do processamento desses óleos numa única UDA. Como consequência, em dezembro/2007 foi definido que a RNEST passaria a contar com duas unidades de destilação atmosférica (UDA) separadas. Ou seja, a Comissão observou que tal decisão (realizar o projeto com duas unidades de destilação, o que não estava previsto originalmente no PAR) tornou difícil o alcance dos objetivos do PAR, uma vez que o projeto básico não estava suficientemente definido.[...]

5.4.14 Sobre tais alterações de projetos o Sr. D.C., então Gerente Setorial de Equipamentos e Serviços da RNEST [...], declarou a [sic] Comissão que “no momento da elaboração do PAR não existiam as especificações dos equipamentos, projeto básico e FEED, tendo sido utilizadas as informações que estavam disponíveis na época (projeto conceitual das principais unidades).” 5.4.15 O Sr. M.A.R.R., Gerente



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Executivo de MATERIAIS, afirmou à Comissão “que o documento que encaminhou o PAR considerava a realização de processos de aquisição críticos em 14 meses e que considera esse prazo um equívoco. Que estrategicamente foram tentadas antecipações de prazos junto aos fornecedores visando o PAR. Que houve alterações nas especificações dos equipamentos durante e após a deflagração do processo licitatório.” 5.4.16 O Sr. M.G., então Diretor-Presidente da Refinaria Abreu e Lima S.A. [...], declarou à Comissão que “o PAR causou a quebra do conceito geral de EPC e a antecipação das contratações sem que o projeto tivesse um nível de maturidade suficiente, gerando aditivos e elevação dos custos.”. O Sr. W.G.R., então Gerente Geral de Implantação da RNEST [...], alegou “que o projeto básico não estava em um nível de maturidade suficiente para iniciar a fase de implantação do empreendimento.” [...]

7.1 A Comissão não obteve evidência de justificativa técnica ou empresarial para a elaboração do PAR [...]

7.3 Uma vez que os projetos não estavam suficientemente desenvolvidos, ocorreram questionamentos de licitantes quanto ao escopo dos objetos a serem contratados, necessidade de ajustes de quantitativos e de especificações técnicas durante as licitações [...]

7.4 Na execução do empreendimento, de julho/2007 a julho/2014, em decorrência de alterações no projeto e problemas decorrentes de interfaces entre os contratos, houve necessidade de aditivos contratuais para acréscimo de prazos e alterações de escopo, com consequente aumento de valores (da ordem de R\$ 3,979 bilhões, até julho/2014) [...]

30. Diante disso, a Acusação assevera que o grau de maturidade do projeto, à época da deliberação, não aconselharia a antecipação decidida pelos administradores. As consequências da antecipação do projeto teriam sido contratações atabalhoadas, com licitações de obras acontecendo concomitantemente à elaboração dos respectivos projetos básicos, e, por isso, mal especificadas, resultando em aditivos contratuais e aumento dos custos da obra.

31. Questionados sobre a decisão de antecipar o funcionamento da RNEST, os administradores declararam, em resumo, o que se segue:

- a) Paulo Roberto Costa (fls. 2.886 a 2.888): Informou que estaria de acordo com a parte técnica do projeto e que a antecipação da refinaria teria sido uma solicitação da Petrobras.
- b) Maria das Graças Foster (fls. 3.036 a 3.048): Informou que a antecipação teria modificado todo o planejamento do projeto.
- c) Sérgio Gabrielli (fls. 3.033 a 3.035): Salientou que, a despeito de não se recordar da autoria do PAR, a antecipação de um projeto seria positiva porque teria o condão de aumentar o VPL.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

d) Almir Barbassa (fls. 3023-3025): Disse não se recordar da reunião de aprovação do PAR, a despeito de presumir que o plano tivesse anuência dos diretores das áreas de abastecimento e serviços.

e) Guilherme Estrella (fls. 3011-3012): Afirmou não se recordar da reunião de deliberação do PAR, mas que acredita que a aprovação do projeto teria respaldo das áreas técnicas. Sustentou que a antecipação seria positiva por antecipar receitas.

f) Ildo Sauer (fls. 3075-3076): Informou que votou a favor da realização de estudo de antecipação e não da antecipação do projeto.

g) Nestor Cuñat Cerveró (fls. 5007 a 5009): Declarou não ter participado do projeto RNEST, embora sua assinatura constasse da ata da reunião que tratou do tema.

h) Renato Duque (fl. 4172): Afirmou que o plano teria sido considerado adequado pela diretoria por se tratar de empreendimento de alto porte. A antecipação do projeto poderia otimizar o processo de construção da refinaria.

III.2.2.1 ANÁLISE DA CONDUTA DE PAULO ROBERTO COSTA

32. Destaca a Acusação que Paulo Roberto Costa é réu confesso no âmbito da Operação Lava Jato¹², onde teria admitido o recebimento de vantagens indevidas de sociedades cartelizadas contratadas para as obras de construção da RNEST (fls. 4.774 a 4.791). Referido diretor teria confirmado perante esta Autarquia que as trocas de favores teriam iniciado logo que assumiu o cargo e que as empresas cartelizadas teriam exigido da Petrobras mais investimentos a partir de 2006 (fls. 2.887 a 2.888).

33. Diante disso, a Acusação entendeu que Paulo Roberto Costa agiu de forma desleal e em desvio de poder, valendo-se do cargo para receber vantagens indevidas, em

¹² A Acusação traz, na peça acusatória, fatos revelados na Operação Lava Jato considerados por ela importantes para a análise da conduta dos diretores da Petrobras. Neste sentido, narra que Paulo Roberto Costa e Renato Duque teriam sido denunciados pelo MPF por corrupção passiva devido à celebração de contratos superfaturados por empresas cartelizadas e aditivos a estes com o intuito de obter vantagens indevidas. Segundo salienta, o MPF apresentou provas que demonstrariam a efetiva transferência de recursos entre sociedades prestadoras de serviços e contas *offshore* controladas pelos referidos diretores da Petrobras. Nesse processo, Paulo Roberto Costa e Renato Duque teriam sido condenados por lavagem de dinheiro e corrupção passiva pelo recebimento de vantagens indevidas em contratos relativos também ao projeto de construção da RNEST (fls. 4.583 a 4.699). A SPS acrescenta que Paulo Roberto teria confessado em juízo o recebimento de propina ao celebrar acordo de colaboração homologado pelo Supremo Tribunal Federal.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

infração ao art. 154, § 2º, “c”, da Lei nº 6.404/76, combinado com o art. 155, caput, do mesmo diploma legal.

III.2.2.2 ANÁLISE DA CONDUTA DOS DEMAIS DIRETORES

34. A SPS registra que Nestor Cerveró e Renato Duque também teriam recebido vantagens indevidas em razão do exercício do cargo, na forma descrita pela apuração criminal, à semelhança de Paulo Roberto Costa. Contudo, a área técnica não teria logrado obter evidências do recebimento indevido deles quando da aprovação do PAR¹³. Desse modo, a conduta destes investigados foi examinada, assim como dos demais diretores, sob a ótica do dever de diligência.

35. Para a Acusação, diversos aspectos relacionados à aprovação do PAR conduziriam a conclusão que os diretores não teriam sido diligentes no exame da matéria.

36. Neste sentido, a SPS destacou que a proposta anterior à deliberação do PAR já teria previsto antecipações bastante arriscadas, contrárias aos procedimentos preconizados pela Sistemática Corporativa. Pondera, por outro lado, que a diretoria poderia desconsiderar aspectos da referida sistemática, desde que amparada por documentação idônea, o que não teria acontecido, vez que os critérios objetivos da referida sistemática teriam sido simplesmente ignorados.

37. A diretoria da Petrobras deliberou antecipação de etapas do projeto ainda mais desafiadoras ao aprovar o PAR, sob a justificativa de apressar o início das atividades da RNEST em um ano. A SPS ressalta que a construção teria destacada complexidade e importância para a Petrobras, a recomendar especial zelo dos administradores na condução do projeto, o que não teria sido demonstrado, vez que eles teriam ignorando os alertas das áreas técnicas.

38. Quanto ao argumento de que a antecipação seria positiva à medida que adiantaria o recebimento de receitas, com aumento do VPL, a Acusação entende que tal benefício não poderia ser esperado num contexto no qual o adiantamento do prazo não seria factível. No sentir da área técnica, o PAR tornou-se um “*programa de aumento de custo*”¹⁴, dada a baixa especificação das contratações necessárias à antecipação do projeto, obrigando a Petrobras a assinar, mais adiante, diversos aditivos contratuais que

¹³ A Acusação chegou a sinalizar para a possibilidade de provas virem a surgir no curso do processo, posto que Renato Duque teria assinado acordo de colaboração com o MPF.

¹⁴ Em alusão à declaração proferida por P.B.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

encareceram a construção em mais de R\$ 4 bilhões. E tudo isso sem lograr antecipar as operações da RNEST.

39. Para ilustrar o grau de imaturidade do projeto naquele momento, a SPS acrescenta que a antecipação das obras, com seus respectivos custos, teria ocorrido mesmo sem a concretização ou, ao menos, as garantias da participação da PDVSA no empreendimento. Neste particular, salienta que a segunda UDA teria sido incluída no projeto em 2007 justamente para refinar petróleo venezuelano.

40. A falta de cuidado da diretoria com relação à RNEST seria ressaltada pelo fato de não ter sido cobrada a apresentação sobre as contratações, cuja exibição deveria ter ocorrido 45 dias após a aprovação do PAR.

41. Diante disso, a SPS concluiu que, ao aprovar o PAR da RNEST em 08.03.2007, José Gabrielli, Almir Barbassa, Guilherme Estrella, Ildo Sauer, Nestor Cerveró e Renato Duque faltaram com a diligência deles esperada às circunstâncias.

III.2.3. APROVAÇÃO DA FASE DE EXECUÇÃO DO PROJETO RNEST

42. A passagem da fase de planejamento (fase III) para a fase de execução (fase IV) ocorreu no segundo semestre de 2009. A previsão de custo para a construção da refinaria foi modificada de US\$4,1 bilhões para US\$13,3 bilhões. Essa atualização de valores foi julgada relevante pela administração da Petrobras, que a publicou, em 26.08.2009, na forma de aviso de fato relevante (fls. 5.175 a 5.176). O mercado então foi informado que o orçamento estimado para a construção da RNEST seria de US\$ 12 bilhões, com variação de -10% a +20%.

43. Destaca a área técnica que a Sistemática Corporativa prescrevia que as mudanças de fase dos projetos de investimento deveriam ocorrer amparadas em EVTE com VPL positivo, a fim de preservar o patrimônio investido pela Petrobras.

44. Sobre o tema, a gerente executiva da diretoria de abastecimento, V.V.F., declarou (fl. 462) que, a partir do final do ano de 2008, já seria possível constatar que o custo da RNEST ficaria acima do apresentado na passagem da fase II para a fase III. Informou que na contratação da obra da “casa de força”, em dezembro de 2008, o VPL do empreendimento já estaria negativo, tendo reportado a situação a Paulo Roberto Costa. Por este motivo, a cada nova aquisição, o EVTE da RNEST era atualizado e o novo VPL incluído nos DIP suporte das solicitações para novas aquisições.

45. Disse ainda que, após apresentar o VPL negativo, teria sido exonerada do cargo e que o novo gerente executivo teria apresentado, em menos de um mês, estudo pelo qual o VPL da refinaria teria se tornado positivo em US\$76 milhões. Por fim, declarou que a diretoria e o conselho de administração da Petrobras sempre foram



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

informados sobre os problemas na RNEST, e que a decisão de continuar a obra teria sido política, vez que sempre era dito que o Presidente da República queria que fosse realizada a obra¹⁵.

46. Em 10.02.2009, a diretoria de abastecimento apresentou DIP com pedido de autorização para contratar a construção de estação de tratamento de água da RNEST, estimada em R\$774 milhões. Transcreve-se a seguir os trechos do documento destacados pela SPS (fls. 3.917):

Análise Preliminar (FEL 3)

14. Com relação às contratações e licitações relacionadas ao Projeto de Implantação da Refinaria do Nordeste, até o momento temos a seguinte situação:

14.1. Investimentos realizados até dez/08: US\$0,234 bilhão;

14.2. Compromissos assumidos (processos de aquisição de equipamentos críticos, contratos em andamento com serviços já realizados, convênios e demais custos da administração e apoio): US\$1,697 bilhão;

14.3. Pacotes com processo licitatório concluído e em fase de encaminhamento para apreciação da Diretoria Executiva (valor referente aos resultados dos processos licitatórios para a construção da ETA, dos Tanques – lotes 1 e 2, e das Edificações): US\$1,489 bilhão;

14.4. Pacotes de Esferas, Dutos, Obras Cíveis, CGE, CGA, cujas licitações encontram-se em processo de avaliação final US\$0,577 bilhão;

14.5. Pacote de processo (ETDI, UDA, UCR, Hidrorefino e Interligações), obtidas propostas que totalizam US\$9,083 bilhões. Estão sendo tomadas as providências necessárias para proceder à relicitação, uma vez que os preços obtidos do mercado superam os limites estabelecidos pela Engenharia no cálculo de suas estimativas;

14.6. Os demais pacotes e serviços que complementam o escopo para plena implantação da Refinaria do Nordeste, ainda não compromissados, representam US\$1,009 bilhão;

14.7. No momento, Abastecimento e Engenharia estão analisando aspectos contratuais, especificações de equipamentos e de materiais, e prazos intermediários com intuito de conseguir reduzir os custos do empreendimento.

14.8. Vale salientar também que é esperada redução de preços de vários insumos em função da atual situação do mercado e que, a partir

¹⁵ Quanto a esta suspeita, a SPS não obteve evidências de influência direta do então Presidente da República, chefe do Poder Executivo da União Federal, acionista controladora da Petrobras, na continuação do projeto.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

desse novo cenário, os preços de materiais, equipamentos e serviços sofram impactos.

14.9. Diante das ações acima descritas, bem como da perspectiva de mudança de patamares de preços de mercado, estabelecemos como meta que o valor do investimento fique situado na faixa de US\$ 7,949 a US\$ 10,543 bilhões, que são, respectivamente, os valores que tornam o VPL nulo para o cenário da refinaria como empresa S.A. e para o caso da refinaria assumir condição de unidade de negócio da área de Abastecimento.

47. Destaca a área técnica que os valores descritos teriam somado mais de US\$14 bilhões, muito superior ao total informado como necessário (na faixa entre US\$8,0 e US\$10,5 bilhões) para o projeto ter VPL igual a zero. Para a Acusação, em fevereiro de 2009, já seria possível, por isso, perceber que o projeto da RNEST traria prejuízo para a Petrobras. A contratação da estação de tratamento de água foi aprovada, em 12.02.2009, sem qualquer questionamento quanto às projeções apresentadas, a demonstrar, no sentir da SPS, falta de diligência dos diretores no trato da matéria.

48. Em 03.09.2009, Paulo Roberto Costa apresentou DIP à diretoria executiva propondo a mudança de fase do projeto RNEST (fls. 4.208 a 4.311), o qual, em resumo, informava o seguinte:

Em 16/07/2009, o AB-CR/PP apresentou uma atualização dos resultados do projeto à Diretoria Executiva, o qual mostrou que, para o cenário em que o investimento esperado totalizava US\$ 13,328 bilhões, considerando a ratificação da parceria societária com a PDVSA e desconsiderando os efeitos concorrentes das refinarias *PREMIUM*, o VPL [...] era de: (a) US\$ 3,06 bilhões negativos para o cenário de robustez do Abastecimento, e (b) US\$ 2,33 bilhões negativos para o cenário de referência.

7. Até Julho de 2009, do investimento estimado para o Projeto de Implantação da Refinaria do Nordeste, já foram realizados US\$ 0,454 bilhão. Os compromissos assumidos, referentes aos processos de aquisição de equipamentos críticos, contratos em andamento, convênios e demais custos de administração e apoio, somam US\$ 3,371 bilhões. [...]

9.2.1. Para o modelo de negócio considerando a implantação do empreendimento através de uma empresa independente, foram consideradas as participações de 60% para Petrobras e 40% para a PDVSA, contudo esta premissa ainda permanece em negociação entre os governos do Brasil e Venezuela.

49. A Acusação salienta que o relatório executivo anexo ao DIP (fls. 4.250) teria registrado que as UDA iriam funcionar a partir de julho e dezembro de 2012 respectivamente, ignorando o fato de o PAR aprovado pela diretoria ter considerado o segundo semestre de 2010 como o início das atividades da RNEST.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

50. O parecer do PLAFIN sobre o tema anexo ao DIP destacou que (fls. 4.260-4.268):

Está previsto o desenvolvimento do projeto na forma de parceria com a PDVSA, mas não há formalização desta parceria até o momento. Um Memorando de Entendimentos, firmado entre Petrobras e a PDVSA, prevê que a Refinaria será abastecida por 50% de petróleo venezuelano e 50% de petróleo nacional. É esperado também que a participação dos sócios no projeto será de 60% para a Petrobras e 40% para a PDVSA. [...]

CONCLUSÕES

Analisando o projeto de forma integral, este não apresenta viabilidade econômica, pois, no Cenário de Referência, obteve-se um VPL negativo de US\$ 3.067 milhões e TIR de 5,8% a.a. no Cenário de Robustez, o VPL diferencial foi negativo em US\$ 3.700 milhões com uma TIR de 4,7% a.a.

Considerando somente a participação da Petrobras no projeto (60%), a análise econômica indica um VPL negativo de US\$ 1.840 milhões no cenário de referência e um VPL negativo de US\$ 2.220 milhões pelo critério de robustez.

Na análise de sensibilidade sobre o resultado integral do projeto, identificou-se que uma redução de aproximadamente 36% do investimento previsto torna o VPL diferencial igual a zero. Além disso, a inclusão das refinarias *Premium* no EVTE degrada consideravelmente o VPL diferencial, que passa a ser de US\$ 6.137 milhões negativos, ou 100% menor em relação ao original. No nosso entendimento, o Caso Base do projeto deveria considerar a visão integrada dos projetos incluindo a perspectiva de ampliação do parque de refino. [...]

Considerando o projeto isoladamente, entendemos que o VPL negativo apresentado frente ao expressivo investimento requerido representa um ponto de atenção para a Companhia. Desta forma, sugerimos uma análise integrada (Portfólio Petrobras) do projeto para avaliar sua capacidade de geração de valor frente a outras alternativas.

51. Para a SPS, esses documentos teriam demonstrado que o projeto RNEST seria economicamente inviável.

52. Na reunião que examinou a questão, em 03.09.2009, os diretores José Gabrielli, Almir Barbassa, Guilherme Estrella, Maria das Graças Foster, Paulo Roberto Costa e Renato Duque determinaram “a reapresentação da matéria com os ajustes necessários.”

53. Em 25.11.2009, o projeto retornou à deliberação da diretoria (fls. 1.450 a 1.564), com documentação elaborada pela diretoria de abastecimento que, em resumo, afirmava:



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

9.3. A análise de atratividade do projeto foi feita considerando a implantação de uma empresa independente em sociedade com a PDVSA, com participações de 60% para Petrobras e 40% para a PDVSA. Este acordo está em fase final de negociação entre os governos do Brasil e da Venezuela, com previsão de conclusão até dezembro do corrente ano, [...]:

9.4. Dessa forma o resultado inicial projetado para o VPL do projeto no cenário de Referência é de US\$ 3,067 bilhões negativos, considerando a Refinaria como Empresa Independente e taxa mínima de atratividade (TMA) de 10,3% a.a..

9.5. Entretanto, várias ações foram tomadas a fim de aprimorar os critérios de avaliação econômica do projeto, considerando a manutenção do ativo após 25 anos de operação, o desempenho operacional da refinaria em função de sua atualização tecnológica e as condições em que foram fechadas no acordo de acionistas que permitem à Petrobras ter o controle em quase todas as decisões da sociedade.

9.6. A partir disso, em conjunto com a Estratégia e Desempenho Empresarial, Planejamento Financeiro e Risco (PLAFIN), estudos incluindo a perpetuidade (valor residual do ativo ao final do período de análise econômica, descontando o investimento), o aumento do Fator de Utilização (FUT) para 96%, bem como da TMA de 10,3% para 9,6% foram realizados. O resultado desses estudos contribuiu para a melhoria do valor do VPL em US\$ 1,169 bilhão, passando o VPL para US\$ 1,898 bilhão negativo no cenário de referência.

9.7. Adicionalmente aos estudos acima, foram adotados dois fatores para a análise de sensibilidade: desonerações tributárias e impacto da perda de mercado para terceiros [....]

9.7.1. Possíveis incentivos fiscais identificados em conjunto com o TRIBUTÁRIO e nas negociações junto a diversos Órgãos do Governo Federal e Estadual para contrapartidas tributárias, ainda em andamento, foram consideradas na Análise de Sensibilidade utilizada para o cálculo do EVTE. O total de desonerações permitiria um potencial ganho de VPL estimado em até US\$ 1,3 bilhão, onde se incluem reduções ou isenções em IPI, PIS, COFINS de bens e Serviços e Petróleo [....]

9.7.2. A Estratégia e Desempenho Empresarial realizou análise sobre o potencial impacto da perda de mercado nacional de derivados caso um terceiro construa uma refinaria semelhante nesta mesma localização. Esta análise indicou que o valor de mercado perdido, no caso da Refinaria ser implantada por um concorrente, é de US\$ 722 milhões.

9.8. Por conseguinte, considerando estes dois fatores o VPL passa a ser de US\$ 76 milhões no cenário de referência.[....]

Proposição



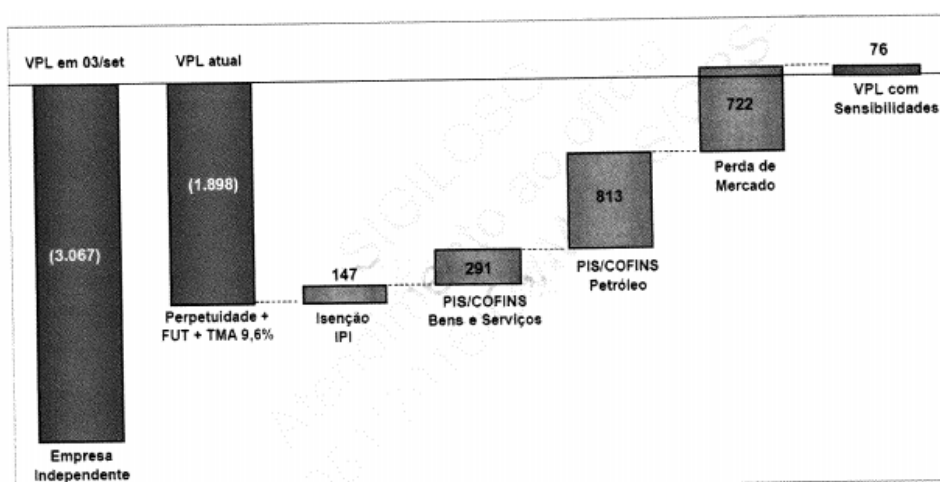
COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

14. Diante do exposto, caso V.S.a esteja de acordo, solicitamos submeter à Diretoria Executiva as seguintes proposições:

14.1. Autorizar a fase de execução (Fase IV) do empreendimento de implantação da Refinaria Abreu e Lima, nos termos dispostos no presente DIP;

54. Registra a SPS que a diretoria de abastecimento teria realizado outro EVTE de modo a elevar o VPL de US\$3 bilhões negativos para US\$76 milhões. Para tanto, teria incluído fluxos relacionados a isenções fiscais, perda de mercado com terceiros, perpetuidade, entre outros, conforme ilustra o quadro a seguir reproduzido do relatório da Acusação:



55. Por outro lado, os pareceres corporativos anexos ao DIP teriam feito destacados alertas sobre a pretensa viabilidade do projeto. Sobre os incentivos fiscais adicionados ao projeto, o setor tributário da Petrobras assim se manifestou (fls. 1.510)

4. INCENTIVOS FISCAIS ADICIONAIS

Efetuamos uma avaliação preliminar de alternativas de desoneração tributária adicionais e os respectivos impactos na avaliação econômica do projeto da RNEST. Ressaltamos que os valores apresentados foram estimados considerando os números globais do investimento e para uma futura negociação com o Governo Federal será necessário um detalhamento dos bens a serem abrangidos por tais incentivos.

Avaliamos:

1. a redução da alíquota do [...] IPI, de 5% (média) para 0%, sobre o fornecimento de todos os equipamentos, partes e componentes para construção da refinaria, o que representa cerca de US\$ 147 milhões em VPL. Esse benefício poderia ser concedido por Decreto do Poder Executivo, porém ressaltamos que provavelmente será necessário negociar com os empreiteiros contratados a cessão dos direitos de fornecimento



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

para que os fabricantes dos bens façam os fornecimentos diretamente para a RNEST.

2. redução das alíquotas das contribuições PIS e COFINS a zero sobre todos os fornecimentos de bens e serviços para a construção da refinaria, o que representaria cerca de US\$291 milhões em VPL. Neste caso, seria necessária a aprovação de lei federal para a concessão do benefício.
3. tributação do petróleo adquirido pelos novos empreendimentos com alíquota de 5,6% de PIS/COFINS com possibilidade de creditamento pelo adquirente em 9,25%, gerando um ganho de 3,65% sobre as compras. Este incentivo se encontra em fase de negociação com o Ministério da Fazenda, entretanto o cenário não é muito favorável para essa concessão. A estimativa deste benefício é de aproximadamente US\$ 780 milhões em VPL.

56. Do mesmo modo, a área de estratégia e desempenho empresarial alertou para as seguintes questões (fls. 1517):

Sob a ótica empresarial, sem considerar as análises complementares, o Projeto não apresenta atratividade econômica. O valor do investimento que torna o VPL nulo é de US\$ 10,4 bilhões, aproximadamente 22% menor do que o previsto. Considerando perpetuidade, as análises complementares de desoneração tributária e de perda de mercado evitada o Projeto apresenta VPL positivo. [...]

Considerando a concepção do Planejamento Estratégico Vigente para as Refinarias *Premium*, o Projeto sofre grande impacto negativo em seus indicadores econômicos com a entrada em operação destas refinarias, uma vez que estas são fortes competidoras em demanda por petróleo e atendimento de mercado de derivados. [...]

Quanto ao modelo de negócio, ainda sob o ponto de vista econômico, a implementação do Projeto por meio de uma parceria mostra-se desfavorável para a Petrobras.

A análise econômica considerou a compra do óleo venezuelano a preços de mercado internacional. Caso o petróleo venezuelano seja comprado a preços diferentes dos praticados no mercado internacional, o resultado econômico do Projeto poderá ser impactado.

A disponibilidade do óleo venezuelano (Mejorado) dependerá da implementação de refinarias “melhoradoras” e do desenvolvimento da produção do petróleo extra-pesado da faixa do Rio Orinoco, na Venezuela.

RECOMENDAÇÕES

Avaliar a pertinência de aprovação do Projeto, neste momento, considerando os seguintes aspectos:

- A rentabilidade apresentada nos diversos cenários e casos analisados;



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

- A existência, ou não, de alternativas mais rentáveis para a produção no País de derivados com o padrão de qualidade a ser colocado pelo projeto (Diesel padrão Europeu);
- A existência, [sic] de alternativas mais rentáveis que promovam o balanceamento entre a Capacidade de Processamento e de Produção de Petróleo da Petrobras;
- O nível do investimento já comprometido;
- A possibilidade, ou não, de implantação de novos projetos de refino no País sem impacto na Refinaria do Nordeste.

Considerar, ainda, a pertinência de reavaliar o Projeto após conclusão das negociações com a PDVSA; [....]

Avaliar a postergação da entrada da segunda unidade de destilação atmosférica, considerando a incerteza em relação à oferta do petróleo venezuelano. Caso a postergação não seja viável, buscar a colocação do petróleo pesado brasileiro na segunda unidade na ocasião de indisponibilidade do petróleo venezuelano.

57. Quanto às novas premissas incluídas no EVTE, a estratégia e desempenho empresarial da Petrobrás manifestou-se, resumidamente, da seguinte maneira (fls. 521):

ANÁLISES COMPLEMENTARES

Foram elaboradas algumas análises complementares ao caso base do Projeto Básico da Refinaria do Nordeste, as quais são apresentadas a seguir:

1) ANÁLISE DA INCLUSÃO DE PERPETUIDADE

1.1) O CONCEITO DE PERPETUIDADE

Considerar perpetuidade ao final de um fluxo de caixa significa, em outras palavras, dizer que o negócio não terá fim, ou ainda, operará até o “infinito”. Em termos práticos, significa estender indefinidamente o fluxo de caixa do projeto além dos 25 anos considerado [sic] tradicionalmente nas avaliações do Refino. [...]

Tradicionalmente, o conceito de Perpetuidade não é utilizado em projetos de investimentos. Os projetos normalmente contam com vida limitada, devido, dentre outros, a: i) vida útil finita dos equipamentos; ii) riscos tecnológicos; iii) dificuldade de previsão de futuro muito distante. [...]

11.3) RISCOS ASSOCIADO [sic] À UTILIZAÇÃO DA PERPETUIDADE

De forma geral, o valor da perpetuidade carrega um maior grau de incerteza quando com o fluxo de caixa explícito (para os anos iniciais do projeto). [...]

Conceitualmente, em mercados competitivos, a perpetuidade deve ser nula, uma vez que novos entrantes serão atraídos até o limite onde não houver mais VPL a ser capturado.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Vale ainda registrar um comentário final: o período utilizado pela Petrobras para avaliar projetos de refino é de 25 anos. Projetos que se tornam economicamente viáveis dentro deste período conferem maior segurança ao planejamento da Cia. Contar com períodos maiores para viabilização do projeto implica em maiores riscos, uma vez que são registradas maiores incertezas nas variáveis chave da projeção. [...]

6) IMPACTO DA PERDA DE MERCADO PARA TERCEIROS (PLANINV)

A análise se fundamenta na possibilidade de, caso a Petrobras não construísse a Refinaria Abreu Lima, um terceiro poderia construir e a Petrobras perderia parte de sua participação no mercado nacional de derivados. O objetivo desta análise é quantificar o impacto da entrada deste terceiro.

Para isto, assumiram-se algumas hipóteses.

- A refinaria construída por este terceiro seria idêntica à atual configuração da RNE, e este terceiro teria acesso a petróleo pesado para utilizar como carga, capturando maiores margens de refino.
- Foram eliminadas as integrações atualmente vislumbradas da RNE com outras unidades da Petrobras, como tratamento em HDTs do Diesel ATE produzido na Refinaria Clara Camarão (Guamaré).
- Admitiram-se duas datas de partida para esta refinaria, uma considerando a mesma data da RNE e outra considerando a partida desta refinaria em janeiro de 2016, data considerada viável para um terceiro que inicia este projeto em 2010.
- Admitiu-se que este terceiro teria acesso à carteira de clientes da Petrobras, desprezando-se eventuais restrições contratuais de curto prazo.
- Admitiu-se que o terceiro teria acesso à logística da Petrobras e incorreria nos mesmos custos que esta (apenas custo operacional de dutos e terminais, por exemplo, e não uma tarifa) – esta premissa tende a aumentar o valor do mercado perdido, já que aumenta a competitividade do concorrente e amplia sua área de atuação (volume do mercado atendido).
- Valorou-se este mercado utilizando paridade importação para Diesel, que seria um limite superior para estes preços – esta premissa tende a aumentar o valor do mercado perdido, já que aumenta o valor unitário do principal produto produzido por esta refinaria.

58. Em acréscimo, o PLAFIN também teria advertido sobre a utilização de tais premissas, conforme restou consignado em seu parecer a seguir reproduzido (fls. 1.539):

É importante frisar que as avaliações do PLANINV para este projeto não incluíram no Caso Base as refinarias *Premium I* e *II* do Sistema Petrobras, ou seja, não foram considerados nos indicadores deste projeto os efeitos das duas refinarias no pool da Petrobras. [...]



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

foi elaborado o fluxo de caixa diferencial do projeto, onde se inclui impostos, depreciação, retorno do ICMS, valor residual nulo e uma perpetuidade, ao final do prazo de vida útil inicial do projeto, que está sendo respaldada por reinvestimentos de US\$ 67 milhões anualmente feitos a partir do 11º ano de operação. Neste caso o VPL diferencial obtido, no Cenário Referencial, foi negativo e, US\$ 1.898 milhões com TIR de 7,4% a.a. No Cenário de Robustez o VPL diferencial foi negativo em US\$ 2.711 milhões e foi obtida uma TIR de 6,3% a.a. [...]

Considerando somente a participação de Petrobras no projeto (60%), a análise econômica indica um VPL negativo de US\$ 1.139 milhões no cenário de referência e um VPL negativo de US\$ 1.627 milhões pelo critério de robustez. [...]

Cabe mencionar que, conforme informado na reunião de apresentação do projeto, já foi captado, junto ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES, um montante de US\$ 5,2 bilhões a uma taxa de remuneração de 7,428% a.a, garantidos pela Petrobras, existindo o risco desta [sic] captação tornar-se mais cara com a entrada do parceiro no negócio.[...]

A consideração de benefícios fiscais para a refinaria, no montante de US\$ 1.252 milhões, está sob avaliação do TRIBUTARIO da companhia existindo, até o momento, uma incerteza quanto a sua materialização. Cabe ressaltar, que já foram incorporados ao VPL do Caso Base benefícios tributários no montante aproximado de US\$ 1.897 milhões.

Na sensibilidade Perda de Mercado para Terceiros, o valor mensurado de para o mercado de US\$ 722 milhões, calculado pela ESTRATEGIA, pode ser considerado uma perda máxima, que não contempla medidas mitigadoras que poderiam ser tomadas por parte da Petrobras para evitar perda de *market share*. [...]

[...] para garantir o fluxo da perpetuidade, estão sendo aprovados também os valores de Capex associados a este fluxo.

Cabe ressaltar, [sic] que a utilização de perpetuidade também traz para o projeto fatores de incerteza associados ao fluxo de caixa após o ano de 2037, tais como: as estimativas de preço para os insumos e derivados; as previsões do mercado consumidor; alterações de legislação, alterações tributárias etc. [...]

a inclusão das refinarias *Premium* no EVTE degrada consideravelmente o VPL diferencial, que passa a ser de US\$ 4.322 milhões negativos. O Caso Base do projeto deveria considerar a visão integrada dos projetos incluindo a perspectiva de ampliação do parque de refino. [...]

na análise de sensibilidade foi considerado o efeito conjunto dos benefícios tributários e [da perda] do valor de mercado, gerando um VPL para o projeto de US\$ 76 milhões. [...]



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Considerando o projeto isoladamente, entendemos que o VPL negativo apresentado frente ao expressivo investimento requerido representa um ponto de atenção para a Companhia. Desta forma, sugerimos uma análise integrada (Portfólio Petrobras) do projeto para avaliar sua capacidade de geração de valor frente a outras alternativas.

Conforme determina a Sistemática Corporativa de Projetos de Investimento, recomendamos a realização de análise de risco econômico-financeiro do projeto para que sejam fornecidas mais informações para a tomada de decisão.

59. A Acusação destaca que esses documentos teriam demonstrado o ceticismo dos técnicos da Petrobras com as alterações do EVTE, motivo pelo qual teriam feito recomendações expressas como “*avaliar a pertinência de aprovação do Projeto*” e “*avaliar sua capacidade de geração de valor frente a outras alternativas*”.

60. Em 25.11.2009, a diretoria aprovou as proposições formuladas por Paulo Roberto Costa, tendo participado da deliberação da mudança de fase do projeto RNEST José Gabrielli, Almir Barbassa, Guilherme Estrella, Maria das Graças Foster, Paulo Roberto Costa e Renato Duque (fls. 1.580 e 1.581).

61. Indagados a respeito dos fatos investigados, a SPS recolheu as informações adiante resumidas:

- a) José Gabrielli (fls. 3.033 a 3.035): “*fizemos retornar o projeto à fase anterior para fazer uma revisão do projeto de tal maneira a fazer uma reavaliação do VPL. Não foi ‘aprimorar os números do VPL’*”. Quanto às variáveis incluídas, alegou que a perpetuidade poderia ser aplicada a refinarias, a perda de mercado estaria relacionada ao monopólio da Petrobras e o incentivo fiscal teria alta probabilidade de ter sucesso, dado ao bom momento econômico.
- b) Maria das Graças Foster (fls. 3.036 a 3.037): aduziu que “*é algo incomum em relação aos atos da própria diretoria*”; “*foi muito polêmico*”, “*esse era o trabalho incessante e permanente da equipe da refinaria: era produzir elementos que reduziam gradativamente esse VPL, aproximando esse VPL de zero*”. Declarou que nunca acreditou na perda de mercado como premissa.
- c) Almir Guilherme Barbassa (fls. 3.023 a 3.025): disse não se recordar de detalhes sobre a questão.
- d) Guilherme Estrella (fls. 3.011 a 3.012): informou que o uso de perpetuidade em projetos de investimentos não era comum e que a perda de mercado se referia à quebra do monopólio para empresas estrangeiras.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

- e) Jorge Zelada (fls. 4181 a 4186 e 4384 a 4397): declarou que não haveria nenhum parecer contrário à continuidade do empreendimento e que o VPL negativo não seria garantia de prejuízo, mas apenas expectativa.
- f) Paulo Roberto Costa (fls. 2886 a 2888): afirmou não se recordar da discussão do VPL negativo da RNEST.
- g) Renato Duque (fls. 4172 a 4180): Informou que as premissas seriam factíveis.
- h) B.G.B, gerente de análise e acompanhamento de projetos de investimentos do setor de estratégia e desempenho empresarial (fls. 455e 456): Aduziu que o projeto da RNEST não teria viabilidade econômica e que análises complementares (perpetuidade, desoneração tributária e perda de mercado) teriam sido solicitadas pela diretoria e conselho de administração.
- i) H.G.S.F, gerente de avaliação de oportunidades de investimentos do setor de estratégia e desempenho empresarial (fls. 457 a 458): Alegou que a perpetuidade não seria comum em projetos de investimento da Petrobras.

III.2.3.1 ANÁLISE DA CONDUTA DE PAULO ROBERTO COSTA E RENATO DUQUE

62. A Acusação afirmou que diferentemente da deliberação do PAR, quando não se teria comprovação da participação de Renato Duque no recebimento de vantagens indevidas, tal ilícito já seria passível de comprovação no momento da aprovação da fase IV do projeto da RNEST.

63. Sobre o tema, a peça acusatória discorre a respeito da ação penal¹⁶ pela qual Renato Duque e Paulo Roberto Costa teriam sido acusados pelo crime de corrupção passiva, assim definido no art. 317, caput e §1º, do Código Penal (fls. 3.544-3.831).

64. De acordo com o *Parquet*, os dois ex-diretores, diante da oferta e promessa de vantagens indevidas feitas por agentes de empresas cartelizadas, “*não só aceitaram tais promessas e vantagens indevidas, em razão da função, como efetivamente deixaram de praticar atos de ofício com infração de deveres funcionais, e praticaram atos de ofício nas mesmas circunstâncias, tendo recebido vantagens indevidas para tanto*”. E assim “*lograram frustrar o caráter competitivo de licitações de grandes obras realizadas pela Petrobras, obtendo vantagens consistentes em impor preços maiores aos que seriam*

¹⁶ Ação Penal Nº 5036528-23.2015.4.04.7000/PR.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

obtidos em um ambiente de livre concorrência, tornar certa a contratação em um volume determinado de obras e escolher as obras que lhes eram mais adequadas conforme a região ou por conhecimento técnico, entre outras vantagens”.

65. Em sede criminal, Paulo Roberto Costa e Renato Duque foram condenados por lavagem de dinheiro e corrupção passiva pelo recebimento de vantagens indevidas em razão de contratos firmados por construtoras com a Petrobras na construção da RNEST e em outros projetos de investimento da Companhia (fls. 4.583 a 4.699, itens 1.053 e 1.055).

66. Neste contexto, a SPS ressaltou que nas reuniões de diretoria de 24.09.2009 (fls. 4.974 a 4.984) e 22.10.2009 (fls. 4.985 a 4.997), nove contratos do projeto RNEST firmados com empresas do esquema fraudulento teriam sido levados à deliberação da diretoria por Renato Duque¹⁷, beneficiado pelo pagamento de propinas.

67. Quanto a Paulo Roberto Costa, a SPS ressaltou que o Acusado teria recebido vantagens indevidas de sociedades cartelizadas contratadas pela Petrobras, inclusive na construção da RNEST. Contratos autorizados nesse período, notadamente após a determinação de retorno para ajustes no EVTE e antes da deliberação que aprovou a fase de execução do projeto, teriam beneficiado construtoras do esquema e alimentado o esquema de propinas a agentes públicos.

68. Diante disso, a Acusação concluiu que os acusados deveriam ser responsabilizados por desvio de poder e falta de lealdade, condutas ilícitas previstas no art. 154, § 2º, “c”, e no art. 155, *caput*, da Lei 6.404/76.

III.2.3.2 ANÁLISE DA CONDUTA DOS DEMAIS DIRETORES

69. Em relação à conduta dos demais diretores, a Acusação frisou os diversos elementos¹⁸ anteriormente narrados que teriam demonstrado à diretoria a inviabilidade da construção da RNEST. Segundo a SPS, os documentos anexos ao DIP teriam contraindicado a empreitada, vez que teriam expressamente manifestado que a diretoria reavaliasse a pertinência do projeto à luz do VPL negativo e do destacado investimento requerido pelo projeto, assim como das premissas que teriam tornado a construção da refinaria marginalmente lucrativa.

¹⁷ Questionado por esta Autarquia quando teria recebido vantagem indevida nos contratos da Petrobras, Renato Duque respondeu que estaria “impossibilitado de tecer qualquer comentário [...] tendo em vista que isso violaria uma cláusula de confidencialidade imposta pelo MPF” (fls. 4.178).

¹⁸ Conforme conteúdo dos pareceres anexos ao DIP AB-CR 327/2009, tratados na seção III.3.2 deste Relatório.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

70. Quanto aos argumentos apresentados na fase investigativa pelos diretores da Petrobras, a SPS consignou que a alegação de Jorge Zelada de que as áreas técnicas da Companhia teriam sido favoráveis ao projeto não seria verdadeira. Essa declaração só poderia ter sido feita por quem não tivesse lido os documentos submetidos à reunião, o que seria, no sentir da Acusação, indício de falta de diligência.

71. A área técnica concordou que o VPL negativo não seria contraindicação absoluta para a realização do projeto, conforme alegado pelos investigados. No caso do projeto apresentar VPL negativo no Cenário de Robustez, destaca a SPS, a Sistemática Corporativa exigiria complementarmente a realização de uma análise de risco quantitativa do projeto, o que tampouco teria sido feita ou exigida pela diretoria, a evidenciar mais um indício da falta de cuidado dos diretores no exercício de suas funções.

72. Pelo exposto, a SPS entendeu que José Gabrielli, Almir Barbassa, Guilherme Estrella, Maria das Graças Foster e Jorge Zelada teriam infringido o art. 153 da Lei nº 6.404/76.

III.2.3.3 ANÁLISE DA CONDUTA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

73. A peça acusatória aduz que o conselho de administração aprovou, em 19.12.2008 e 06.03.2009, aportes de R\$473 milhões e R\$192 milhões, respectivamente, na CIA RNEST (fls. 3.919 a 3.922), para suportar os gastos do projeto. Desse modo, no entender da área técnica, ainda que não deliberasse contratações ou condições específicas, o conselho teria informações sobre o desenvolvimento do projeto RNEST S.A., bem como de seu custo, à época, de pelo menos US\$ 4,05 bilhões¹⁹.

74. Menciona ainda que, em 23.01.2009, por ocasião da revisão anual do Plano estratégico Petrobras 2020 e aprovação do Plano de Negócios 2009-2013, o conselho solicitou a adoção de medidas no âmbito de todas as áreas da empresa, objetivando reduzir os custos do programa de investimentos. Tal medida deveria ser implementada no âmbito da Sistemática Corporativa da seguinte maneira: reduzir, no mínimo, 20% nos projetos em Fase I (Avaliação de Oportunidade) e Fase II (Conceitual) e de 10% para os projetos das demais fases (Fase III – Projeto Básico e Fase IV – Aprovados para Implantação) (ata CA no. 1.313, pauta 02, fls. 5.160).

¹⁹ A Acusação sugere que o conselho de administração saberia, ao menos, desse valor em razão do registro havido nas notas explicativas divulgadas em 06.03.2009 (fls. 3.117 a 3.184), embora o valor para a conclusão do projeto fosse bastante superior.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

75. Em 17.12.2009, prossegue a Acusação, com a aprovação da mudança de fase pela diretoria, a situação da construção da RNEST foi apresentada aos conselheiros da Petrobras. De acordo com o material discutido na reunião, o conselho de administração teria tido ciência sobre: **(i)** a incerteza da parceria com a PDVSA; **(ii)** o aumento de custo do projeto desde julho de 2007²⁰, totalizando R\$7 bilhões; **(iii)** a não inclusão das refinarias *premium* no cálculo dos VPL e as modificações realizadas para incrementar o valor do VPL, de modo a melhorar a atratividade do projeto. Ao final da apresentação, havia solicitação à aprovação da passagem de fase do projeto.

76. A ata da reunião registrou que “*visando elevar a rentabilidade do projeto, o Conselho de Administração emitiu orientações para a continuidade das negociações e determinou que o projeto retorne ao Colegiado para conhecimento, após a conclusão das negociações.*” (fls. 4.398 a 4.400).

77. Questionados sobre o tema, os membros do conselho de administração declararam, resumidamente, o que se segue:

- (a) Fábio Barbosa (fls. 3.077 a 3.078): o projeto não poderia continuar caso o VPL fosse negativo e seria razoável o uso de sensibilidades tais como perpetuidade, perda de mercado e desonerações.
- (b) Guido Mantega (fls. 3.090 a 3.091): o VPL negativo teria sido muito discutido no conselho de administração e que se buscava uma solução para torná-lo positivo. O custo do projeto teria aumentado por conta do aumento da capacidade de refino da RNEST.
- (c) Jorge Gerdau Johannpeter (fls. 3115 a 3116): declarou não se recordar do debate sobre o VPL.
- (d) Sérgio Franklin Quintella (fls. 4107 a 4140): afirmou que Brasil e Venezuela teriam um acordo que não poderia ser ignorado pela Companhia e que os trabalhos relacionados à RNEST estariam limitados a terraplanagem, conforme informado pela diretoria. Acrescentou que a RNEST seria a primeira refinaria construída pela Petrobras em décadas, o que dificultaria orçar o projeto, mas as alterações teriam sido justificadas. Em função do elevado endividamento da Petrobras e do aumento de investimentos na RNEST, teria ficado claro que as refinarias *premium* (Maranhão e Ceará) não seriam executadas.

²⁰ Sobre a questão, a Acusação apontou, ainda, que a informação dada nas notas explicativas das demonstrações financeiras de 2008 estavam incorretas e que o conselho de administração não tomou qualquer atitude de modo a sanar a irregularidade.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

- (e) Francisco de Albuquerque (fls. 4.092 a 4.106): afirmou que, no momento da deliberação, não haveria sinais de alerta que levantassem suspeitas sobre os funcionários da Companhia e que presumia serem verdadeiras as informações prestadas pela diretoria. Informou que o conselho teria analisado as premissas de perda de mercado e desoneração tributária “com sensibilidade”.
- (f) Silas Rondeau (fls. 4.141 a 4.151): reiterou os argumentos antes descritos.
- (g) Luciano Coutinho (fls. 4.152 a 4.157): Respaldou o uso da desoneração tributária como premissa justamente por ainda não ser concreta. Acrescentou que tal desoneração teria se concretizado em 2010, com a aprovação e regulamentação do REPENEC – Regime Especial de Incentivos para o desenvolvimento de Infraestrutura da Indústria Petrolífera nas Regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, isentando de tributos federais as atividades e os investimentos em refino naquelas regiões.
- (h) Sérgio Gabrielli (fls. 3.033 a 3.035): declarou não ser de competência do conselho de administração acompanhar a execução dos projetos e que a discussão só teria chegado ao conselho quando se passou a identificar o problema de custo. Afirmou que teria sido discutido que a refinaria seria necessária, pois o refino tinha que aumentar, mas com o melhor custo possível.

78. Com relação à afirmação dos acusados de que o projeto das refinarias *premium* não seria desenvolvido, a SPS argumentou que não teriam sido encontradas referências sobre o assunto nas reuniões da diretoria e do conselho de administração. Pelo contrário, a área técnica apurou que o projeto das refinarias *premium* só teria sido suspenso em 2014, ou seja, cinco anos após a referida deliberação, quando teria sido reconhecido prejuízo de R\$ 2,8 bilhões relativamente ao projeto das refinarias *premium* (fls. 5123).

79. Quanto ao REPENEC, a Acusação entendeu indevida a justificativa apresentada pelos administradores na medida em que a própria área tributária da Companhia teria considerado tais desonerações uma premissa incerta.

80. Diante disso, a Acusação concluiu que seria esperada uma postura crítica dos conselheiros sobre as novas premissas do EVTE, notadamente em função de elas terem sido inseridas somente para acrescentar valores à avaliação, sem alterar a sua estrutura, o que seria mais um alerta. Tal descaso seria agravado pelo conhecimento do destacado custo do projeto, em contradição com a requisição de corte nos investimentos da Petrobras deliberado pelo conselho. Do mesmo modo, a incerteza sobre a parceria com PDVSA parece não ter despertado nos conselheiros a preocupação que o tema



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

exigiria, dada a repercussão nos custos do projeto, a evidenciar, no sentir da SPS, mais um indício da falta de cuidado no trato do assunto.

81. Pelo exposto, concluiu a SPS que os conselheiros Guido Mantega, Fabio Barbosa, Francisco de Albuquerque, Jorge Gerdau, Sergio Gabrielli, Luciano Coutinho, Sergio Quintella e Silas Rondeau, ao ratificarem a aprovação da passagem de fase do projeto RNEST em 17.12.2009 ignorando os sinais de alerta a eles apresentados, teriam faltado com o dever de diligência, em infração ao art. 153 da Lei nº 6.404/76.

III.3. CONTROLES INTERNOS

82. No decorrer da investigação, a Acusação apontou possíveis deficiências nos controles internos da Companhia.

83. A Petrobras tinha comitê permanente de auditoria responsável por elaborar relatório trimestral a partir das auditorias internas e encaminhá-lo ao conselho de administração, onde as discussões e providências eventualmente tomadas eram registradas em ata. Ressalvou a área técnica que o comitê de auditoria da Petrobras somente teria se tornado órgão estatutário em julho de 2015 (fls. 5.078).

84. Sobre os achados de auditoria, destaca a SPS que, desde 2006, o comitê de auditoria registraria sua preocupação com os controles internos da Companhia, conforme relato da peça acusatória resumido a seguir:

a) Em 03.02.2006, o presidente do comitê de auditoria e membro do conselho de administração revelou aos demais conselheiros a necessidade de aperfeiçoamento dos mecanismos que visem coibir atos lesivos ao patrimônio da Companhia. Neste particular, destacou o baixo índice de respostas das diversas áreas da Companhia para as deficiências nos controles internos e respectivos planos de remediação (fls. 1.171 a 1.172).

b) Em 03.07.2008, a ata do comitê de auditoria consignou a ocorrência de erros recorrentes em atividades de contratação de serviços e indicou as principais falhas detectadas. Além disso, solicitou que o tema fosse encaminhado ao conselho de administração, a fim de tornar os administradores cientes das deficiências encontradas e para que estes pudessem aperfeiçoar o processo de contratação (fls. 5061 a 5069). O assunto foi apresentado ao conselho de administração e, em 11.08.2008,



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

quando o conselho teria determinado²¹ que “a diretoria executiva apresentasse proposta de Plano de Ação com relação ao aumento de não-conformidades na contratação na Companhia”. (fls. 1588 a 1592)

c) Em 13.04.2009, a ata do conselho de administração assinalou que os conselheiros presentes²² na sessão aprovaram a Política e Diretrizes de Controles Internos da Petrobras. Ademais, notou-se que o presidente do comitê de auditoria recomendou a centralização da área de *compliance* nas diretorias, que se encontrava dispersa (fls. 5070 a 5071).

d) Em 20.10.2009, a ata do comitê de auditoria apontou, novamente, a ocorrência de falhas nas contratações de serviços, especificamente nas atividades típicas de gestão, e ratificou as orientações previamente concedidas. Sugeriu, também, que a administração avaliasse permanentemente a adequação da estrutura da auditoria interna frente aos planos de crescimento da empresa (fls. 5.079 a 5.083). Na mesma data, o tema foi apresentado ao conselho de administração²³, oportunidade em que o presidente da Petrobras, Sergio Gabrielli, informou que a Companhia já estaria atuando no reforço dos controles internos, ficando de apresentar ao conselho as medidas que vinham sendo adotadas (fls. 1.176 a 1.179).

85. A Acusação consignou, em 30.04.2010, que o conselho de administração teria aprovado “Plano Anual de Atividades de Auditoria – Exercício 2010” sem abordar os últimos achados de auditoria destacados pelo comitê (fls. 5.074 a 5.077).

86. Sobre o tema, a SPS colheu as declarações que se seguem:

a) Fábio Barbosa (3.077 a 3.078): declarou que o comitê de auditoria fazia extrato ao conselho de administração reportando ínfima parte do que seria detectado pela auditoria.

b) Guido Mantega (fls. 3.090 a 3.091): afirmou não se recordar dos extratos de ata do comitê de auditoria, tampouco se a diretoria executiva teria tomado alguma medida de modo a melhorar os controles internos. Também

²¹ Presentes na reunião os seguintes conselheiros: Dilma Vana Rousseff, Arthur Antonio Sendas, Fabio Colleti Barbosa, Francisco Roberto Albuquerque, Guido Mantega, Jorge Gerdau Johannpeter, Luciano Galvão Coutinho, Silas Rondeau Cavalcante Silva e José Sérgio Gabrielli de Azevedo.

²² Dilma Vana Rousseff, Fabio Colleti Barbosa, Francisco Roberto Albuquerque, Guido Mantega, Jorge Gerdau Johannpeter, Luciano Galvão Coutinho, Silas Rondeau Cavalcante Silva e José Sergio Gabrielli de Azevedo.

²³ Presentes na reunião os seguintes conselheiros: Dilma Vana Rousseff, Fabio Colleti Barbosa, Francisco Roberto Albuquerque, Guido Mantega, Jorge Gerdau Johannpeter, Luciano Galvão Coutinho, Silas Rondeau Cavalcante Silva e José Sergio Gabrielli de Azevedo.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

afirmou que os controles internos eram falhos, mas que essa constatação só pôde ser feita posteriormente, e que teria havido grande melhoria a partir de 2012.

c) Jorge Gerdau (fls. 3.115 a 3.116): disse que o conselho de administração ratificava a posição do comitê de auditoria.

d) Dilma Rousseff (fls. 3.246 a 3.247): declarou que *compliance* seria mais importante que auditoria e que havia conselheiros que acompanhavam diretamente o tema. Informou que o comitê de auditoria e o conselho de administração teriam interação sistemática.

e) Francisco Albuquerque (fls. 4.092 a 4.106): declarou que os controles internos da Companhia seriam suficientes e que teria sido criada a diretoria de *Compliance* na Petrobras.

f) Silas Rondeau (fls. 4.141 a 4.151): afirmou que os controles internos da Petrobras seriam adequados e que não haveria necessidade de auditoria em projetos de investimentos.

g) Luciano Coutinho (fls. 4.152 a 4.157): declarou que os controles internos da Petrobras eram satisfatórios. Mencionou, também, a criação da diretoria de *Compliance*.

h) Sérgio Quintella (fls. 4.107 a 4.140): afirmou que os controles internos da Petrobras seriam suficientes, ainda que passíveis de melhoria e que não haveria auditoria de projetos de investimento da Petrobras, pois esta seria realizada pelo Tribunal de Contas da União (“TCU”).

87. Ao examinar tais fatos, a Acusação concluiu que seria papel do conselho de administração, para além de exigir a implementação da política de controles internos, certificar-se de que ela estaria sendo seguida. Segundo a SPS, seria patente que as deficiências nos controles internos não teriam sido consequência da falta de política, mas sim de uma execução dispersa e inadequada, como trazido à luz pelo comitê de auditoria.

88. A área técnica rechaça o argumento que tudo teria melhorado a partir de 2012, pois uma melhoria três anos depois seria insuficiente para eximir os administradores de seus deveres fiduciários. Isto só confirmaria a inépcia da “Política e Diretrizes de Controles Internos da Petrobras” de que tratou a apresentação ao conselho em 13.04.2009.

89. No entender da SPS, diante do problema, o conselho teria adotado postura reativa, e por vezes passiva, omitindo-se em se certificarem de que as falhas de



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

controles internos haviam sido sanadas, a demonstrar falta de cuidado no exercício de suas funções.

90. Pontua a SPS que, devido tal apuração não se relacionar diretamente com as contratações e condução do projeto RNEST, não se poderia aplicar a prescrição penal, motivo pelo qual somente os fatos havidos a partir de 20.10.2009 poderiam ser passíveis da ação punitiva desta Autarquia, em razão de terem ocorrido cinco anos antes do início das apurações.

91. Essa seria justamente a data da reunião do conselho em que o comitê de auditoria teria apontado, mais uma vez, o problema. Na oportunidade, o presidente e conselheiro Sérgio Gabrielli teria ficado responsável por apresentar medidas para sanar as não-conformidades, o que, segundo a Acusação, não teria ocorrido nem sido posteriormente cobrado. A omissão do conselho teria se mantido no período abarcado pela pretensão punitiva, uma vez que não teria havido cobrança pelo conselho nos meses que se seguiram e até a reunião específica sobre as atividades de auditoria,

92. Por tais razões, a Acusação concluiu que, entre outubro de 2009 e março de 2010, Dilma Rousseff, Fabio Barbosa, Francisco Albuquerque, Guido Mantega, Jorge Gerdau, Luciano Coutinho, Silas Rondeau e Sergio Gabrielli teriam sido omissos na fiscalização dos controles internos da Petrobras, em infração ao art. 153 da Lei nº 6.404/76.

III.4. COMISSÃO INTERNA DE APURAÇÃO

93. A Acusação teria verificado indícios de interferência externa quando das apurações da comissão interna de apuração para *“avaliar os procedimentos de contratação para implantação da Refinaria Abreu e Lima, desde a especificação dos serviços até a assinatura dos instrumentos contratuais”* (fls. 3.049 a 3.050), pois, segundo verificou, teria sido encontrada minuta mais extensa do que o relatório apresentado ao fim da apuração (63 páginas versus 28), inclusive com abordagem distinta (fls. 4.312 a 4.374).

94. De acordo com a SPS, trechos relativos ao EVTE da RNEST utilizado na aprovação da fase de execução do projeto e aos aditivos contratuais constantes de duas seções, (5.3) e (5.5), da minuta elaborada teriam sido suprimidos, não constando do relatório final da comissão interna.

95. A área técnica questionou os participantes da comissão, que declararam, em resumo, o que se segue:

a) Os integrantes da CIA RNEST (fls. 2.972, 2.984 e 3.001 a 3.002) confirmaram que teria havido interferência externa no relatório, com a



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

retirada de informações referentes aos aditivos dos contratos celebrados e à mudança de valor do VPL. Segundo alegam, a justificativa apresentada para essa omissão seria de que tais comentários fugiam do escopo do relatório. Ainda de acordo com os depoimentos prestados, os assessores da presidente da Companhia à época dos fatos, Graça Foster, teriam intervindo nas reuniões da CIA RNEST, apresentando minutas de relatórios comentados por ela e insinuando mudanças a serem feitas.

b) L.M.S., assessora de Graça Foster, afirmou que a presidente gostava de se inteirar dos assuntos e que, portanto, queria estar a par do que ocorria na CIA RNEST. Nesse sentido, orientou a delimitação do escopo da comissão, que tinha como objeto final a celebração dos contratos. Sendo assim, teria sugerido que os aditivos fossem deixados como anexo para, posteriormente, a continuação do trabalho de investigação pela diretoria de abastecimento. Quando questionada, a assessora afirmou não saber informar se teria havido apuração posterior das questões retiradas da minuta (fls. 3.003 a 3.004).

c) Graça Foster declarou que a participação de seus assessores na comissão seria importante, visto que daria poder aos membros de interrogar quem fosse necessário para a apuração do caso. Afirmou que, ao ler o material, encontrou diversas informações que não seriam do escopo da comissão e teceu alguns comentários na minuta, mas que não teria participado determinando ordens. Quanto às apurações posteriores, informou que saiu da Companhia logo após ao acontecimento e que, portanto, não sabia dizer se chegaram a ser realizadas (fls. 3.036 a 3.037).

96. A SPS salientou que não teriam sido encontradas menções aos aditivos, nem à questão do VPL nos anexos do relatório final da CIA RNEST (fls. 48 a 75). Além disso, ressaltou que seria de orientação interna da Petrobras a criação de uma nova comissão caso se constatassem novas questões passíveis de serem investigadas, fato que também não teria sido verificado até a saída de Graça Foster da Companhia em fevereiro de 2015 (fls. 418 a 422).

97. Diante disso, a Acusação destacou que a interferência nas comissões instauradas vai de encontro ao propósito de investigar supostas irregularidades internas e ao próprio regulamento das Comissões Internas de Apuração, o qual dispõe que:

Deve ser verificada a existência de impedimentos, suspeições ou incompatibilidade insanáveis relativamente aos integrantes da Comissão ou da Autoridade Constituinte, em qualquer tempo, com a substituição de quem lhe der causa, tais como: [...]

c) Suspeição de que os trabalhos estejam sendo influenciados.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

98. A indicação da assessora de Graça Foster para participar da comissão já seria, no sentir da SPS, evidência da falta de independência pretendida pela comissão. Não obstante, a declaração da presidente de que tal nomeação conferiria mais autonomia aos membros da CIA RNEST não restou demonstrada. A comissão, de acordo com seu regulamento, tinha como objeto a apuração da contratação de serviços e da assinatura dos instrumentos contratuais, o que não implica afirmar que somente a primeira assinatura dos contratos deveria ser analisada. Na realidade, foi justamente o processo decisório de contratações que acarretou a celebração dos diversos aditivos e causou o aumento de custo do projeto.

99. Para a SPS, a intromissão externa se torna ainda mais grave devido ao fato de que Graça Foster participou, como diretora, da aprovação da passagem do projeto RNEST à fase IV, participação essa que poderia ser objeto de investigação.

100. Desse modo, a Acusação entendeu que a intervenção de Graça Foster na comissão exorbitou suas prerrogativas de diretora presidente e extrapolou sua ascendência hierárquica sobre empregados da Companhia, indo contra os interesses da Petrobras, em violação ao art. 154 da Lei 6.404/76.

IV. DAS COLABORAÇÕES DE PAULO ROBERTO COSTA E NESTOR CERVERÓ

101. A Acusação registra que Paulo Roberto Costa e Nestor Cerveró celebraram acordo de colaboração premiada com o Ministério Público Federal, judicialmente homologado, envolvendo os processos resultantes da Operação Lava Jato. A partir desse acordo, teria sido possível obter informações sobre o recebimento de vantagens indevidas por funcionários da Petrobras, o que possibilitou a instauração de novos processos, tais como a Ação Penal 5083376-05.2014.4.04.7000/PR, que trata das contratações do projeto RNEST, e o presente processo.

102. Diante disso, a Acusação sugeriu ao Colegiado, sob a ótica da Lei nº 6.385/76, ponderar as circunstâncias fáticas na dosimetria na pena, conforme dispõe o §9º do artigo 11 da referida norma, pois a colaboração dos referidos acusados para com a Justiça Federal e os esclarecimentos prestados em atitude de cooperação invocariam a aplicação do dispositivo.

V. DAS RESPONSABILIDADES

103. Por todo o exposto, a Acusação propôs a responsabilização de:

a) **Almir Guilherme Barbassa**, na qualidade de Diretor Financeiro e de Relações com Investidores da Petrobras à época, por:



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

- i. ter votado pela aprovação do Plano de Antecipação da Refinaria, faltando com o dever de diligência, em infração ao **art. 153 da Lei nº 6.404/76**; e
 - ii. ter votado pela aprovação da passagem do projeto RNEST à Fase 4, faltando com o dever de diligência, em infração ao **art. 153 da Lei nº 6.404/76**.
- b) **Guilherme de Oliveira Estrella**, na qualidade de Diretor de Exploração e Produção da Petrobras à época, por:
- i. ter votado pela aprovação do Plano de Antecipação da Refinaria, faltando com o dever de diligência, em infração ao **art. 153 da Lei nº 6.404/76**; e
 - ii. ter votado pela aprovação da passagem do projeto RNEST à Fase 4, faltando com o dever de diligência, em infração ao **art. 153 da Lei nº 6.404/76**.
- c) **Ildo Luís Sauer**, na qualidade de Diretor de Gás e Energia da Petrobras à época, por ter votado pela aprovação do Plano de Antecipação da Refinaria, faltando com o dever de diligência, em infração ao **art. 153 da Lei nº 6.404/76**.
- d) **Jorge Luiz Zelada**, na qualidade de Diretor Internacional da Petrobras à época, por ter votado pela aprovação da passagem do Projeto RNEST à Fase 4, faltando com o dever de diligência, em infração ao **art. 153 da Lei nº 6.404/76**.
- e) **Jorge Sérgio Gabrielli de Azevedo**,
- e-a) na qualidade de Diretor Presidente da Petrobras à época, por:
- i. ter votado pela aprovação do Plano de Antecipação da Refinaria, faltando com o dever de diligência, em infração ao **art. 153 da Lei nº 6.404/76**; e
 - ii. ter votado pela aprovação da passagem do projeto RNEST à Fase 4, faltando com o dever de diligência, em infração ao **art. 153 da Lei nº 6.404/76**.
- e-b) na qualidade de membro do conselho de administração da Petrobras à época, por:
- iii. ter ignorado os sinais de alertas apresentados ao conselho de administração e ratificado a passagem do Projeto RNEST à Fase 4



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

4, faltando com o dever de diligência, em infração ao **art. 153 da Lei nº 6.404/76**.

- iv. ter deixado de se certificar que as correções necessárias às deficiências nos controles internos da Companhia estavam sendo de fato implementadas, a despeito das reiteradas manifestações do comitê de auditoria, faltando com o dever de diligência, em infração ao **art. 153 da Lei nº 6.404/76**.

f) Maria das Graças da Silva Foster,

f-a) na qualidade de Diretora de Gás e Energia da Petrobras à época, por:

- i. ter votado pela aprovação da passagem do projeto RNEST à Fase 4, faltando com o dever de diligência, em infração ao **art. 153 da Lei nº 6.404/76**.

f-b) na qualidade de Diretora Presidente da Petrobras à época, por:

- i. ter interferido indevidamente no relatório final da Comissão Interna de Apuração da RNEST, atuando em desvio de poder, em infração ao **art. 154, caput, da Lei nº 6.404/76**.

g) Nestor Cuñat Ceveró, na qualidade de Diretor Internacional da Petrobras à época, por ter votado pela aprovação do Plano de Antecipação da Refinaria, faltando com o dever de diligência, em infração ao **art. 153 da Lei nº 6.404/76**.

h) Paulo Roberto Costa, na qualidade de Diretor de Abastecimento da Petrobras à época, por:

- i. ter patrocinado e votado pela aprovação do Plano de Antecipação da Refinaria, em troca de vantagens indevidas, atuando com desvio de poder e em falta com dever de lealdade para com a Companhia, em infração ao **art. 154, §2º, c) da Lei nº 6.404/76 c/c art. 155, caput da Lei nº 6.404/76**.
- ii. ter patrocinado e votado pela aprovação da passagem do projeto RNEST à Fase 4, em troca de vantagens indevidas, atuando com desvio de poder e em falta com dever de lealdade para com a Companhia, em infração ao **art. 154, §2º, c) da Lei nº 6.404/76 c/c art. 155, caput da Lei nº 6.404/76**.

i) Renato de Souza Duque, na qualidade de Diretor de Engenharia e Serviços da Petrobras à época, por:



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

- i. ter votado pela aprovação do Plano de Antecipação da Refinaria, faltando com dever de diligência, em infração **ao art. 153 da Lei nº 6.404/76.**
 - ii. ter patrocinado, perante à diretoria executiva, propostas de contratação cuja contratada era sociedade que lhe pagava vantagens indevidas, e votado pela aprovação da passagem do projeto RNEST à Fase 4, atuando com desvio de poder e em falta com dever de lealdade para com a Companhia, em infração **ao art. 154, §2º, c) da Lei nº 6.404/76, c/c art. 155, caput da Lei nº 6.404/76.**
- j) **Dilma Vana Rousseff**, na qualidade de membro do conselho de administração da Petrobras, por ter deixado de se certificar que as correções necessárias às deficiências nos controles internos da Companhia estavam sendo de fato implementadas, a despeito das reiteradas manifestações do comitê de auditoria, faltando com dever de diligência, em infração **ao art. 153 da Lei nº 6.404/76.**
- k) **Fabio Colletti Barbosa**, na qualidade de membro do conselho de administração da Petrobras por, por:
- i. ter ignorado os sinais de alertas apresentados ao conselho de administração e ratificado a passagem do Projeto RNEST à Fase 4, faltando com o dever de diligência, em infração **ao art. 153 da Lei nº 6.404/76.**
 - ii. ter deixado de se certificar que as correções necessárias às deficiências nos controles internos da Companhia estavam sendo de fato implementadas, a despeito das reiteradas manifestações do comitê de auditoria, faltando com o dever de diligência, em infração **ao art. 153 da Lei nº 6.404/76.**
- l) **Francisco Roberto de Albuquerque**, na qualidade de membro do conselho de administração da Petrobras à época, por:
- i. ter ignorado os sinais de alertas apresentados ao conselho de administração e ratificado a passagem do Projeto RNEST à Fase 4, faltando com o dever de diligência, em infração **ao art. 153 da Lei nº 6.404/76.**
 - ii. ter deixado de se certificar que as correções necessárias às deficiências nos controles internos da Companhia estavam sendo de fato implementadas, a despeito das reiteradas manifestações



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

do comitê de auditoria, faltando com o dever de diligência, em infração ao **art. 153 da Lei nº 6.404/76**.

m) **Guido Mantega**, na qualidade de membro do conselho de administração da Petrobras à época, por:

- i. ter ignorado os sinais de alertas apresentados ao conselho de administração e ratificado a passagem do Projeto RNEST à Fase 4, faltando com o dever de diligência, em infração ao **art. 153 da Lei nº 6.404/76**.
- ii. ter deixado de se certificar que as correções necessárias às deficiências nos controles internos da Companhia estavam sendo de fato implementadas, a despeito das reiteradas manifestações do comitê de auditoria, faltando com o dever de diligência, em infração ao **art. 153 da Lei nº 6.404/76**.

n) **Jorge Gerdau Johannpeter**, na qualidade de membro do conselho de administração da Petrobras, por:

- i. ter ignorado os sinais de alertas apresentados ao conselho de administração e ratificado a passagem do Projeto RNEST à Fase 4, faltando com o dever de diligência, em infração ao **art. 153 da Lei nº 6.404/76**.
- ii. ter deixado de se certificar que as correções necessárias às deficiências nos controles internos da Companhia estavam sendo de fato implementadas, a despeito das reiteradas manifestações do comitê de auditoria, faltando com o dever de diligência, em infração ao **art. 153 da Lei nº 6.404/76**.

o) **Luciano Galvão Coutinho**, na qualidade de membro do conselho de administração da Petrobras à época, por:

- i. ter ignorado os sinais de alertas apresentados ao conselho de administração e ratificado a passagem do Projeto RNEST à Fase 4, faltando com o dever de diligência, em infração ao **art. 153 da Lei nº 6.404/76**.
- ii. ter deixado de se certificar que as correções necessárias às deficiências nos controles internos da Companhia estavam sendo de fato implementadas, a despeito das reiteradas manifestações do comitê de auditoria, faltando com o dever de diligência, em infração ao **art. 153 da Lei nº 6.404/76**.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

- p) **Sergio Franklin Quintella**, na qualidade de membro do conselho de administração da Petrobras à época, por ter ignorado os sinais de alerta apresentados ao conselho de administração e ratificado a passagem do Projeto RNEST à Fase 4, faltando com o dever de diligência, em infração ao **art. 153 da Lei nº 6.404/76**.
- q) **Silas Rondeau Cavalcante Silva**, na qualidade de membro do conselho de administração da Petrobras à época, por:
- ter ignorado os sinais de alertas apresentados ao conselho de administração e ratificado a passagem do Projeto RNEST à Fase 4, faltando com o dever de diligência, em infração ao **art. 153 da Lei nº 6.404/76**.
 - ter deixado de se certificar que as correções necessárias às deficiências nos controles internos da Companhia estavam sendo de fato implementadas, a despeito das reiteradas manifestações do comitê de auditoria, faltando com o dever de diligência, em infração ao **art. 153 da Lei nº 6.404/76**.

VI. DAS DEFESAS

VI.1. MEMBROS DA DIRETORIA EXECUTIVA

VI.1.1 NESTOR CERVERÓ

VI.1.1.1 *PRELIMINARES*

Prescrição da pretensão punitiva

104. Preliminarmente, o defendente suscitou a prescrição da pretensão punitiva em relação a seus atos, visto que a investigação teria se iniciado em 27.10.2014 e o processo administrativo sancionador teria sido instaurado somente em março de 2016, isto é, quase dez anos depois do começo das irregularidades datadas de 2005.

105. O defendente afastou o fundamento utilizado pela Acusação de que o prazo prescricional a ser aplicado no presente processo administrativo sancionador deveria ser o prazo prescricional penal, nos termos do §2º do artigo 1º da Lei nº 9.873/1999, uma vez que lhe é imputado apenas a falta com dever de diligência, fato que não constituiria crime. Nesse sentido, seria improcedente a utilização do crime de corrupção passiva, previsto no artigo 317 do Código Penal, como fundamento para a aplicação da prescrição penal.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

106. A esse respeito, alegou, inclusive, que o artigo 287, II, “b”, 2, da Lei nº 6.404/76, prevê prazo prescricional de 3 (três) anos para a ação contra administradores quando constatado danos decorrentes de fatos culposos ou dolosos de administradores, sendo o início de contagem desse prazo a data de publicação da ata da assembleia geral que aprovou o balanço referente ao exercício concomitante à infração. No caso vertente, a publicação teria ocorrido no ano de 2006, logo, segundo o defendente, teria havido o transcurso do prazo de três anos previsto para o exercício da pretensão punitiva.

107. Em seguida, arguiu que, caso se entendesse pela aplicação da prescrição administrativa regulada pelo artigo 1º da Lei nº 9.873/1999, esta também motivaria o arquivamento do processo, em razão da clara prescrição da pretensão punitiva, tendo em vista o decurso de tempo de mais de 5 (cinco) anos previsto no mencionado dispositivo legal.

108. Finalizando o tema concernente à prescrição, salientou, a título argumentativo, que a observância do prazo prescricional penal só seria possível depois de instaurada a ação penal. Nesse sentido, a defesa alegou a impossibilidade de sua aplicação, visto que o defendente não teria figurado como réu em nenhuma ação penal referente à contratação da RNEST, objeto do presente processo.

109. Com efeito, tal acusação nem poderia ser feita sob pena de descumprir princípios constitucionais. A violação que é tema do processo vertente se referiria à falta de dever de diligência, a qual não possuiria correspondência no tipo penal nos exatos termos da lei societária. Para que fosse proposta uma ação penal frente ao defendente, haver-se-ia de existir tipicidade correspondente, o que alegadamente não existe.

110. Além disso, o defendente ressaltou o caráter personalíssimo do instituto da prescrição. Nesses termos, utilizar-se do prazo prescricional aplicável aos demais acusados para o defendente como forma de possibilitar o exercício da pretensão punitiva da CVM constituiria uma ilegalidade, em consonância com jurisprudência do STJ.

Ausência de parecer individualizado

111. O defendente suscitou a nulidade do presente processo, haja vista não ter sido emitido parecer sobre o termo de acusação pela PFE antes da intimação dos acusados, conforme determina o artigo 9º da Deliberação nº 538/2008.

Ausência da devida individualização da conduta

112. Outra preliminar levantada pelo defendente se refere à ausência de individualização de conduta, conforme garantida tanto na Constituição Federal, quanto no artigo 6º da Deliberação CVM nº 538/2008. A acusação restou fundamentada apenas



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

no fato de o defendente ter votado a favor da aprovação do PAR e não ter cobrado a devida apresentação da estratégia especial de contratação, sem qualquer detalhamento da conduta tida como irregular, e impediria o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa.

113. Para o defendente, não bastaria indicar que o ilícito decorre de uma conduta colegiada, devendo, também, individualizar cada conduta. Por tais razões, o defendente afirmou que o presente processo estaria maculado por nulidade.

Princípio da culpabilidade e a impossibilidade de responsabilização objetiva

114. Por fim, sustentou que a peça acusatória não apresenta qualquer elemento capaz de demonstrar sua culpa, o que é imprescindível no presente caso, uma vez que a responsabilidade pelo ilícito administrativo é sempre subjetiva. Desse modo, requereu-se a exclusão do defendente do rol dos investigados no presente processo administrativo sem a aplicação de qualquer sanção, visto inexistir fato específico que lhe atribua responsabilidade.

VI.1.1.2 MÉRITO

115. O defendente salientou que as decisões que são objeto deste processo foram tomadas com base nas informações que possuía a época dos fatos. Assim, não seria prudente exigir deliberação de forma compatível com os dados que só se tornaram conhecidos com o decorrer do tempo.

116. No caso, o corpo técnico submetia à diretoria executiva documentos com estudos embasados e qualificados, que possuiriam presunção de veracidade e precisão. Segundo o defendente, haveria um clima de confiança interna entre as áreas da Companhia, de modo que a desconfiança de um projeto poderia causar nítido desconforto.

117. Ainda assim, afirmou ter analisado com a devida diligência os DIPs que tratavam do assunto, os quais, por sua vez, pareciam precisos e bem fundamentados em pesquisas. Por conseguinte, não haveria razão para questionamento dos dados que eram apresentados, tampouco haveria indicativos que expusessem os riscos da aprovação do PAR.

118. Não só a verificação de condições mínimas teria motivado a aprovação do projeto, como também o fato de que seu avanço permitiria acelerar a obtenção de resultados, em linha com o previsto pela Sistemática de Aprovação de Investimentos e com a necessidade de aumento da capacidade de refino no país. Assim, sendo a Petrobras uma sociedade de economia mista, a aprovação do PAR estaria diretamente



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

relacionada à consecução de sua função social, disposta no artigo 27, §1º, I do Estatuto das Estatais.

119. Concluindo a esse respeito, o defendente aduziu que os diretores não poderiam ser responsabilizados por falhas em funções que não seriam de sua atribuição, como a observância do cumprimento das etapas do projeto.

120. O defendente alegou ter agido, inclusive, de acordo com o *business judgement rule*, pautado sempre na boa-fé e nos interesses da Companhia. A aprovação unânime do projeto pela diretoria executiva indicaria que não teria havido indícios capazes de levantar suspeitas quanto à viabilidade de aprovação do projeto, até mesmo pelo fato de o VPL apresentado no estudo ser positivo.

121. Por fim, afirmou que sua atuação não causou qualquer dano à Petrobras. Os valores aportados no investimento, ainda que depois tenham se revelado maiores do que o originalmente previsto, teriam passado a integrar o ativo imobilizado da Companhia, de modo que não haveria de se falar em dilapidação e perda de patrimônio, mas sim em um aumento de seu valor e do valor de suas ações.

122. Com efeito, a diretoria executiva não precisaria de uma autorização específica para cada negociação, o que poderia tornar mais burocrático o andamento da Companhia. Dessa forma, tendo em vista à ausência de óbice no projeto, teriam aprovado a passagem de fase.

VI.1.2. GRAÇA FOSTER

VI.1.2.1 PRELIMINARES

Prescrição da pretensão punitiva

123. Foi arguida pela defendente a prescrição da pretensão punitiva pela CVM, em razão de o fato supostamente irregular, qual seja a aprovação da passagem à Fase IV, ter ocorrido em 25.11.2009, ao passo que o processo administrativo sancionador somente teria sido instaurado em março de 2016. Nesse sentido, o prazo prescricional de cinco anos para o exercício da pretensão punitiva da administração pública, previsto na Lei nº 9.873/99, ter-se-ia consumado.

124. A defendente afastou a tese levantada pela Acusação para justificar o exercício da pretensão punitiva pela Autarquia. Para a SPS, a aplicação do prazo prescricional penal de 16 (dezesesseis) anos, sob o fundamento de que o ilícito administrativo configuraria também o ilícito penal de corrupção passiva previsto no



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

artigo 317 do Código Penal, deveria ser aplicada a todos os acusados do presente processo, visto que a prescrição se conecta a fatos e não a pessoas.

125. A esse respeito, a defendente alegou, primeiramente, que o fato a ela imputado não configuraria crime, visto que o tipo penal de corrupção passiva não se enquadra no tipo administrativo referente à falta de dever de diligência e do dever de lealdade. Na verdade, a própria SPS teria indicado que somente a conduta de Paulo Roberto Costa e Renato de Souza Duque eram enquadradas como corrupção passiva. Com isso, o prazo prescricional penal, dado a falta de paralelismo entre as infrações, não poderia incidir no presente processo.

126. Adicionalmente, aduziu a defendente que os próprios precedentes indicados pela Acusação de modo a fundamentar sua tese afastariam a aplicação do prazo prescricional penal, uma vez que (i) o MS nº 24.013 imputou o recebimento de vantagem pessoal ao servidor acusado, o que configura crime, (ii) o RMS nº 16.387 decidiu pela aplicação do prazo prescricional apenas se procedimento penal tiver sido instaurado, o que, no caso ora em análise, não ocorreu e (iii) o Processo BCB nº 0101148656 firmou o entendimento de que o prazo prescricional se refere ao fato e não a pessoa quando se tratar de pessoas jurídicas relacionadas diretamente com os atos criminosos e delas beneficiadas ilicitamente.

127. Por fim, afirmou que o STJ possui sólida jurisprudência no sentido de que a observância dos prazos prescricionais penais nos processos administrativos somente é possível quando for constatado que o ilícito disciplinar também configura crime. A título de exemplificação: AgIns no RMS 38680/BA, RMS 46780/RS e RMS 35325/PE.

VI.1.2.2 *MÉRITO*

128. Inicialmente, a defendente teceu alguns comentários sobre a Operação Lava-Jato, a qual motivou a instauração do presente processo administrativo. Embora tenha ressaltado a importância da operação para o cenário nacional devido às denúncias do maior esquema de corrupção e lavagem de dinheiro do Brasil, salientou que, até sua deflagração em março de 2014, havia uma grande confiança interna e externa quanto aos funcionários da Companhia, inclusive àqueles que foram condenados no âmbito penal.

129. Ademais, à época dos fatos, não haveria qualquer indicação da ocorrência de irregularidades na Petrobras, de modo que não se levantavam suspeitas acerca dos projetos e informações que eram apresentadas. Nesse cenário, a defendente salientou que nem mesmo os órgãos fiscalizadores, como empresas de auditoria independente e a própria CVM, teriam questionado as condutas de diretores e administradores da Companhia.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

130. A defendente aduziu que teria atuado em conformidade com os cargos que ocupou e com o nível de autonomia que lhe era concedido em cada um deles. A esse respeito, destacou algumas medidas e providências tomadas em sua gestão como diretora executiva de gás e energia e como diretora presidente.

131. A título de exemplificação, destacou que, durante sua atuação como diretora de gás e energia, teria determinado que toda alteração em projetos que fosse de seu setor passasse à sua análise, de modo a evitar aditivos desnecessários. Com efeito, alegou que o mesmo não poderia ser esperado a respeito de projetos que não fossem de sua área de conhecimento, tendo em vista que não teria liberdade para tal, bem como pelo fato de haver uma confiança interna muito grande entre os diretores da Companhia, sendo aplicável a estes a inexigibilidade de conduta diversa.

132. Quanto à sua atuação como diretora presidente, algumas medidas teriam sido tomadas pela defendente que comprovariam a sua atuação proba, tais como: (i) a elaboração de uma nova referência de medição da performance do planejamento, controle e acompanhamento dos empreendimentos da Companhia apenas um mês depois de sua posse na nova função, (ii) expressiva reforma de governança a partir da adoção de medidas destinadas ao reforço dos mecanismos de controle de governança, (iii) criação de novos critérios e procedimentos para a migração de projetos da carteira em avaliação para carteira em implementação. A defendente ressaltou, ainda, a importância do item (iii), visto se relacionar diretamente com o objeto do presente processo.

133. Arguiu a defendente que teria paralisado projetos que possuíam preços excessivos ou inviabilidade econômica, como a unidade de fertilizantes III, o segundo trem de refino da RNEST e o empreendimento COMPERJ, além de ter afastado os diretores responsáveis pela execução desses projetos dois meses após sua posse como diretora presidente. Nessa toada, estaria demonstrada sua atuação zelosa e em interesse da Companhia, antes mesmo do vazamento de informações referentes à corrupção no âmbito da operação Lava-Jato.

134. Para a defendente, sua conduta teria sido pautada nos preceitos da *business judgement rule*. A Acusação não teria analisado os principais aspectos necessários à responsabilização dos administradores, quais sejam a individualização das condutas e a análise da boa-fé. Com isso, a conduta de cada um dos acusados teria sido superficialmente examinada, somada ao fato de não terem sido consideradas as circunstâncias à época dos fatos.

135. Além disso, destacou que, mesmo com atuação diligente e proba, os administradores podem ser induzidos a erro devido aos assuntos de grande relevância e complexidade com os quais devem lidar em um reduzido lapso de tempo. Assim, ainda que o administrador tenha sido induzido a erro e a companhia tenha incorrido em



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

perdas, não poderia ser responsabilizado caso tenha agido de boa-fé e decidido de forma informada, refletida e desinteressada.

136. Destarte, afirmou que a análise a ser feita deveria se restringir ao processo decisório e ao cumprimento dos deveres fiduciários por parte dos administradores e não ao mérito da decisão judicial, tampouco a eventuais prejuízos decorrentes de tal decisão. Isto é: a possibilidade de revisão *ex post* deveria ser limitada, visto que esta aumentaria consideravelmente a exposição dos administradores.

137. Outro aspecto ressaltado pela defendente se refere à obrigação de vigilância e monitoramento do administrador, pelo qual se tem o dever de investigar apenas quando existirem fundamentadas razões para tal. Caso contrário, poucos administradores aceitariam essa função, em razão do risco que incorreriam devido à conduta desleal de outros membros da companhia.

138. Segundo a defendente, seria esta a situação no presente caso: determinados administradores teriam manipulado dados e documentos técnicos e, devido à falta de conhecimento técnico específico dos demais sobre o tema para suspeitar das informações, teriam conseguido aprovar algumas pautas.

139. Nesse sentido, alegou a defendente a antijuridicidade de uma eventual condenação que fosse fundamentada em atos criminosos de outros administradores sem uma análise individualizada de sua conduta.

140. A defendente aduziu que a necessidade de confiança legítima entre os diretores de uma companhia seria reconhecida pela doutrina, sobretudo quando se trata de uma área em que não se possui conhecimento técnico. A esse respeito, afirmou, inclusive, ser esse o entendimento adotado por esta Autarquia.

141. Desse modo, não havendo, à época dos fatos, quaisquer razões que motivassem a defendente a duvidar sobre a veracidade das informações apresentadas pelos diretores já condenados criminalmente e responsáveis pelo projeto ora em questão, seria de se esperar que se confiasse em seus trabalhos.

142. Para ratificar esse argumento, a defendente afirmou (i) que teria havido diversos estudos de viabilidade, pareceres e documentos técnicos acerca do empreendimento RNEST, os quais teriam sido, inclusive, reconhecidos pela CVM e (ii) que os profissionais envolvidos nesses projetos eram extremamente qualificados, com currículos exemplares e que não suscitavam qualquer dúvida a respeito de seu conhecimento técnico.

143. A defendente esclareceu que não teria participado da aprovação do PAR, uma vez que ainda não era membro da diretoria executiva, tendo participado apenas de decisões posteriores. Ainda assim, a aprovação de projetos de tamanha complexidade,



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

sem qualquer contestação pelos demais diretores – seja do projeto ou seja dos estudos elaborados -, teriam confirmado a presunção de confiança legítima existente entre os membros da diretoria executiva.

144. Arguiu que o dever de informar seria uma análise de possibilidade e viabilidade, configurando-se, assim, uma obrigação de meio e não de resultado. Nessa linha, tendo em vista as circunstâncias envolvidas na referida deliberação, não teria havido outra decisão possível se não a tomada pela defendente.

145. Segundo a defendente, o dever de lealdade seria um dos deveres básicos da *business judgment rule*, segundo o qual a atuação do administrador deveria ser pautada na boa-fé e na busca dos melhores interesses da companhia, controlando, assim, possíveis conflitos de interesse entre o administrador e a companhia e impedindo a utilização de sua posição para obter alguma vantagem em proveito próprio. A falta do dever de lealdade de um colegiado não poderia ser considerada a partir da atitude de um único diretor.

146. No caso vertente, dois aspectos indicariam o cumprimento desse dever: (i) a inexistência de elemento, nos autos do processo, capaz de indicar que a defendente teria agido de má-fé e em benefício próprio e (ii) a atuação de má-fé de diretores comprovadamente culpados no âmbito da Operação Lava-Jato, o que feriu o dever de lealdade de seus pares e da Companhia. Assim, não se poderia afastar a proteção concedida à defendente pela *business judgement rule*.

147. O dever de diligência seria o segundo dever básico constituinte do *business judgement rule*, em que o administrador deveria ter o padrão de diligência exigível de um profissional de gestão, observando o grau de dever e responsabilidade dele esperado. Em suma, os deveres anexos do dever de diligência seriam: (i) dever de informação, (ii) dever de vigilância, (iii) dever de investigação, (iv) dever de intervenção e (v) dever de assiduidade.

148. A defendente afirmou ter agido de acordo com o que era esperado, na medida em que, respectivamente, (i) teria se informado sobre as matérias que não eram de sua expertise antes de deliberar sobre elas; (ii) teria acompanhado minuciosamente cada etapa referente ao projeto; (iii) teria fiscalizado atos referentes ao projeto em diversos momentos, tal como durante a Comissão Interna de Apuração, sem que houvesse interferência; (iv) não teria intervindo, durante a passagem de fase da RNEST, pois não teriam sido constatadas irregularidades, à época dos fatos, sobre os dados e fatos apresentados; e (v) teria atuado de modo assíduo durante toda sua trajetória profissional, o que seria reforçado pelo fato de não ter sido alvo de questionamentos por qualquer empregado da Companhia ou por tribunal administrativo ou judicial.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

149. A defesa rebateu, ainda, a tese acusatória segundo a qual a defendente teria ignorado os sinais de alerta presentes em alguns documentos apresentados. No caso, arguiu que a Acusação não teria logrado comprovar tal alegação, bem como não teria analisado com afinco todas as informações produzidas pela área responsável do estudo realizado.

150. Além disso, aduziu que se estaria exigindo da defendente uma análise específica e técnica que ia além de suas atribuições. No caso em tela, teria confiado nos dados que lhe foram apresentados, acreditando, sob a premissa de que estes eram dotados de verdade, estar informada para a tomada de decisão. Destacou que, à época dos fatos, não haveria motivos para desconfiança do trabalho realizado pelos diretores encarregados do projeto RNEST, os quais possuiriam reputação ilibada e competência técnica.

151. Outro argumento apresentado pela defendente se referiu ao atendimento à Sistemática Corporativa. Em suma, afirmou que a Sistemática consistiria em orientações de possíveis caminhos a serem adotados pelos dirigentes da Companhia; contudo, não seria de observância obrigatória, de forma que o não seguimento de seus preceitos não implicaria na falta de diligência, mas sim na adoção de medida mais favorável em um dado contexto fático.

152. Especificamente quanto à aprovação da passagem de fase da RNEST, a defendente sustentou que, no DIP de 25.11.2009, (i) o VPL apresentado teria um grau de atratividade satisfatório para o empreendimento; e (ii) diversos setores técnicos da Companhia teriam concordado com a proposta de mudança de fase.

153. Fundamentada em doutrinas diversas, a defendente discorreu sobre a questão do VPL. Em termos gerais, argumentou no sentido de que tal métrica não configuraria método absoluto frente aos demais mecanismos de avaliação e que tampouco poderia se desconsiderar outras variáveis quando da análise de um projeto.

154. Dito isto, aduziu que todos os indicadores constantes nos documentos técnicos fornecidos para os diretores teriam sido considerados, de modo que não poderia a Acusação avaliar o mérito da decisão informada e refletida tomada pela defendente na referida ocasião.

155. Além disso, discordou do posicionamento da Acusação a respeito da suposta inadequação das seguintes premissas: perpetuidade, concessão de benefícios tributários e perda de mercado por novos entrantes. De modo a comprovar a pertinência de cada um, a defendente justificou tais premissas, conforme se verifica a seguir:

- a) a utilização da perpetuidade como premissa, segundo especialistas em avaliação de empresa, seria salutar, de modo que não caberia falar em falta do



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

dever de diligência por esse uso, já que este parâmetro seria, inclusive, bastante regular;

- b) a inserção da concessão de benefícios tributários como premissa seria completamente factível tendo em vista o histórico de política fiscal brasileira; ainda assim, mesmo diante de tamanha expectativa, teria sido utilizadas no cenário de sensibilidade, o que comprovaria o cuidado dos técnicos responsáveis pela realização da projeção. Com efeito, tais incentivos teriam sido efetivamente concedidos em 2010.
- c) embora a premissa de perda de mercado por novos entrantes não tenha sido amplamente defendida pela dependente, afirmou ter concordado com sua utilização em razão do convencimento técnico do órgão colegiado. No caso, seria razoável presumir que a proximidade com a Venezuela e uma política de preços de combustíveis atrelada aos preços internacionais poderiam causar efeitos no que tange à competição e, portanto, atrapalhar os indicadores de viabilidade de um empreendimento.

156. Sobre as Refinarias *Premium*, a defendente atribuiu a desconsideração de sua concorrência para cálculo do VPL ao estágio que este projeto se encontrava, qual seja, a fase I. No caso, o cálculo de EVTE de projetos de refino consideraria apenas unidades de refino em operação ou projetos a partir da fase II.

157. Em seguida, salientou que, sendo a Petrobras uma companhia que visa à obtenção e maximização de lucro, a desistência do projeto em vez de sua continuidade para a fase IV importaria na perda de um grande investimento que já teria sido feito, haja vista que o custo afundado do empreendimento giraria em torno de US\$1,5 bilhão. Além disso, o projeto seria de fundamental importância para o país, conforme destacado em alguns DIPs sobre o assunto.

158. Arguiu, ainda, que, embora alguns pareceres de órgãos técnicos tivessem indicado determinados riscos e incertezas quanto ao projeto, não teria sido recomendada, em momento algum, sua desistência. Com isso, não se poderia falar em temeridade da decisão, pois não só o parecer não possuiria força cogente para com a diretoria executiva, como também teria apontado tão somente sinais de alerta inerentes à própria atividade.

159. Quanto à suposta omissão em não ter determinado a revisão do projeto em consonância com o estabelecido pela Sistemática Corporativa, reiterou a defendente que esta não seria de observância obrigatória. Ademais, afirmou que (i) não teria responsabilidade com relação a instauração do processo de reavaliação e (ii) teria adotado medidas no que concerne ao andamento do projeto.

160. Sobre o primeiro ponto, aduziu que a Sistemática Corporativa teria disposto que os procedimentos de revisão seriam de natureza facultativa. Ainda assim, a



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

competência para sua implementação seria da área de negócio, ou seja, da diretoria de abastecimento e não da defendente. Por sua vez, com relação ao segundo ponto, alegou ter iniciado, durante sua atuação como presidente da Petrobras, estudos de revisão das curvas físicas e financeiras do projeto RNEST para melhor avaliação de seu panorama, bem como teria alertado ao mercado, em junho de 2012, no que tange ao aumento de custos e prazos para a implantação da refinaria.

161. A defesa rebateu, também, a suposta omissão no acompanhamento da efetivação da parceria comercial com a PDVSA. Esclareceu, nesse contexto, que (i) conforme apontado pela SPS, não haveria provas de que a inclusão do segundo trem de refino se destinaria ao atendimento de necessidades encontradas no processamento do petróleo venezuelano, pois, ainda que a parceria não se concretizasse, o projeto seria viável para a Petrobras; (ii) considerando a natureza estatal da PDVSA e o sistema político venezuelano centralizado e instável, a exigência de formalização das tratativas poderia engessar a fluidez das negociações; e (iii) a parceria entre as companhias teria sido tratada não como uma relação comercial, mas sim como relação diplomática entre Brasil e Venezuela.

162. Em que pese as circunstâncias acima, arguiu a defendente que, ainda assim, a diretoria executiva teria emitido diversos documentos e cartas exigindo posicionamento por parte da empresa venezuelana, tendo destacado trechos de DIPs e e-mails que comprovariam essa diligência.

163. Com efeito, não poderia se exigir da defendente conduta diversa da deliberada quando da aprovação da passagem de fase, visto que os atos referentes à parceria entre a Companhia e a PDVSA não seriam de sua competência. Situação diversa teria sido verificada a partir de sua posse como diretora presidente em 2012, momento a partir do qual teria acompanhado ativamente as tratativas e incentivado uma conclusão definitiva para o assunto. Entre diversos feitos apontados pela defendente, pode-se mencionar que, em apenas 6 (seis) meses de mandato, teria feito a PDVSA (i) assinar 2 (dois) termos aditivos; (ii) ser constituída em mora; (iii) aceitar a inserção de cláusulas de encerramento antecipado com a estipulação jurídica de inexistência de indenização por parte da Petrobras em caso de término da relação.

164. Por último, a defesa rebateu a tese acusatória de que teria atuado em desvio de poder por suposta interferência no relatório da CIA RNEST, sustentando que não poderia a Acusação presumir, com base em uma simples conjectura, que a defendente quisesse alterar o resultado de investigações que ela própria teria solicitado a instauração.

165. Como argumento adicional, salientou que os membros integrantes da comissão de apuração seriam profissionais qualificados, autônomos e de grande responsabilidade, os quais deveriam ter reportado, portanto, o desconforto e as



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

interferências que a investigação estivesse tendo. Não obstante, a defendente arguiu inexistir, nos autos, qualquer demonstração de ingerência que não passasse de mera especulação, notadamente porque não se teria logrado êxito em comprovar que determinadas conclusões da investigação tivessem sido retiradas da minuta.

166. Destacou que a minuta comentada por ela não teria sido elemento modificativo dos trabalhos da CIA RNEST, mas somente um apontamento de que o trabalho não deveria fugir de seu escopo inicial. Os depoimentos prestados a esta CVM reforçariam, inclusive, que não houve qualquer intervenção por parte da defendente, em razão de terem se limitado a indicar um “desconforto” com os comentários, sem qualquer indício de que estes efetivamente modificaram a verdade dos fatos.

167. Com relação às alegações de que sua assessora teria assumido uma posição hierárquica na comissão, a defendente afirmou que aquela teria tal conduta em nome próprio e sem sua ciência, inclusive porque em momento algum teria outorgado mandato especial à sua auxiliar. Ademais, a comissão seria dotada de independência e, embora não tenha feito, poderia ter afastado sua assessora sob a alegação de impedimento.

V.1.3 JOSÉ SÉRGIO GABRIELLI

V.1.3.1 *PRELIMINAR*

Prescrição da pretensão punitiva

168. Primeiramente, o defendente atentou para a diferença de duas competências atribuídas à CVM: a competência de velar pelas informações relativas ao mercado e a competência de apurar práticas ilícitas. Valendo-se desta última, membros independentes do conselho de administração da Petrobras teriam solicitado a apuração de irregularidades referentes à correção de um comunicado ao mercado de 27.09.2014. Em dezembro do mesmo ano, teria sido instaurado o Inquérito Administrativo nº 14/2014, com vistas a apurar se as irregularidades constatadas pelas investigações internas enviadas pela Petrobras caracterizariam infrações à Lei nº 6.404/76.

169. A esse respeito, afirmou o defendente que, no que se refere ao projeto RNEST, referido Inquérito Administrativo teria como objeto apenas a conduta dos ex-diretores Paulo Roberto Costa e Renato Duque, os quais teriam sido os únicos membros considerados responsáveis no Relatório Final da Comissão Interna de Apuração sobre a RNEST. Nessa perspectiva, não teria como escopo a análise de qualquer questão



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

referente às decisões da diretoria sobre a construção da RNEST, inclusive o Programa de Antecipação da Refinaria.

170. Com isso, aduziu o defendente que a instauração do Inquérito Administrativo nº 14/2014 não configuraria ato inequívoco capaz de interromper a prescrição de eventuais irregularidades praticadas pela diretoria executiva no âmbito da construção da RNEST. O primeiro ato inequívoco acerca de tais fatos teria se dado com a intimação do defendente para apresentar defesa, a partir da instauração do Inquérito Administrativo nº 5/2016.

171. Sobre o tema, indicou jurisprudência do STJ que estabeleceria que (i) a interrupção somente ocorre com a instauração de inquérito administrativo voltado especificamente a apurar os fatos que são imputados ao acusado e (ii) a interrupção da prescrição não corre por meio de simples pedidos de informações e esclarecimentos em processos administrativos que não são especificamente voltados à apuração dos fatos imputados a um acusado.

172. Adicionalmente, o defendente arguiu que, quando da instauração do inquérito, o prazo prescricional para a pretensão punitiva já havia sido consumado. Embora o argumento para sua instauração fosse de que as investigações poderiam identificar atos qualificados como crimes e que, portanto, seriam regidos pelo prazo prescricional definido na legislação penal, o defendente afirmou que tais atos não foram identificados pelos técnicos que solicitaram a abertura do inquérito.

173. Contrapondo-se ao fundamento utilizado pela Acusação - a existência de alguns fatos criminosos alteraria o prazo prescricional de todos os atos que foram apurados nas investigações -, o defendente alegou que o prazo prescricional da legislação penal deveria ser aplicado apenas em casos em que se acusa o indivíduo da prática de um crime. Contudo, não teria sido imputado ao defendente, no caso vertente, qualquer tipo penal que se amolde à acusação que lhe é feita, isto é, falta de dever de diligência. A argumentação construída para contornar a prescrição seria insubsistente.

174. O defendente afirmou, ainda, que os julgados apresentados pela Acusação de modo a embasar sua tese possuiriam molduras fáticas completamente distintas do caso dos autos, de forma que se justificaria, mais uma vez, a aplicação do prazo prescricional quinquenal. Isso porque (i) no julgado do Supremo Tribunal Federal, o impetrante teria sido acusado pelo crime tipificado no art. 317 do Código Penal, de modo que importaria a aplicação do prazo prescricional penal no processo disciplinar, (ii) no julgado do Superior Tribunal de Justiça, entendeu-se que o ilícito administrativo que também configurar como crime será regido pela prescrição penal apenas se for instaurado procedimento penal visando à apuração de tais fatos e, por fim, (iii) no recurso nº 11.969, o Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional concluiu que a prescrição penal é aplicada quando tiver havido comunicação de crime ao



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Ministério Público Federal e não houver notícia de arquivamento ou absolvição decorrente de fato que possa impactar nessa esfera administrativa.

V.1.3.2 *MÉRITO*

175. O defendente aduziu, primeiramente, que teria sido sempre diligente em sua atuação. A saber: teria atuado de modo refletido, pois todas as questões aprovadas teriam sido amplamente debatidas pelos órgãos colegiados; de modo informado, pois os projetos deliberados teriam contado com documentação extensa apresentada pelas respectivas diretorias especializadas; e de modo desinteressado, pois teria pautado sua conduta em favor da companhia.

176. Salientou o defendente que a análise a ser feita pela Acusação deveria se pautar na licitude de sua conduta e não em seu mérito. Isso porque, em uma empresa como a Petrobras, seria impossível exigir de um administrador a leitura de cada documento produzido pela área técnica e a compreensão em profundidade dos diversos assuntos envolvidos, tendo em vista, inclusive, que haveria reuniões com mais de trinta assuntos em uma pauta.

177. A estrutura administrativa da Companhia, por conseguinte, teria sido pensada de modo a permitir uma administração célere e informada, tendo por base a impessoalidade e confiança nas propostas apresentadas pela diretoria especializada. Com isso, não seria necessário refazer o trabalho das áreas técnicas, mas tão somente avaliar a viabilidade de execução de um projeto.

178. Nessa perspectiva, a sistemática decisória da Companhia não teria sido negligente. Com efeito, a diretoria executiva decidiria a partir de estudos e análises técnicas elaboradas por órgãos especializados e a partir de manifestações de outras diretorias com conhecimento sobre o tema. O diretor de cada área deveria ter expertise para avaliar as propostas elaboradas pela sua gerência e capacidade de apresentar aos membros da diretoria executiva o projeto de modo preciso e compreensível.

179. Dessa maneira, concluiu que a confiança depositada nas informações sobre um determinado tema fornecidas pelo diretor da área não configuraria negligência e, sim, uma estratégia desenvolvida de modo a compatibilizar a tecnicidade das decisões com a eficiência.

180. Especificamente quanto à aprovação do PAR, o defendente afirmou que a peça acusatória não seria fundamentada nas informações disponíveis à diretoria executiva no momento da deliberação, mas sim em alertas genéricos constantes no cronograma original da obra, que, por sua vez, não seria objeto de análise no presente processo.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

181. No caso, alegou o defendente que alterações excepcionais no curso do projeto eram permitidas devido às peculiaridades do empreendimento, desde que previamente aprovadas pela diretoria executiva. Tal excepcionalidade não se configuraria uma irregularidade e, sim, o exercício da competência da diretoria em fixar padrões de contratação e, em casos de necessidade, autorizar exceções à sistemática estabelecida.

182. Com efeito, a aprovação do PAR teria ocorrido de modo refletido, em razão de a diretoria executiva ter exigido um planejamento que viabilizasse a execução regular e tempestiva das contratações. Assim, não teria sido aprovada a realização de qualquer contratação irregular e sim uma antecipação do projeto condicionada à realização de estudos e de planejamentos.

183. Quanto às regras de avaliação dos negócios, arguiu o defendente que a diretoria executiva teria autonomia para definir essas regras, bem como para modificá-las discricionariamente. Nesse sentido, seriam diretrizes para as diretorias especializadas, as quais deveriam seguir tais comandos para que os trabalhos técnicos fossem padronizados e coordenados e, também, para que alcançassem um grau de maturidade para quando da análise pelos órgãos colegiados.

184. Da mesma forma que um decreto do Presidente da República não pode ser anulado sob o argumento de que esse decreto viola um anterior, aduziu o defendente que as decisões da diretoria executiva não poderiam ser anuladas caso destoante de critérios anteriormente definidos. Na verdade, isso sequer teria ocorrido, tendo em vista que as decisões questionadas no presente processo teriam sido tomadas de acordo com interpretações razoáveis e compatíveis com as regras definidas pela própria diretoria executiva.

185. Ainda assim, mesmo que a diretoria executiva tivesse extrapolado os limites de sua atuação, a responsabilização pessoal do defendente encontraria óbice na própria legislação, em razão desta reconhecer a necessidade de ter havido violação da lei ou do estatuto. A mera violação de termos estabelecidos pela sua própria autoridade não seria passível de condenação.

186. Outro argumento apresentado pelo defendente foi de que a Acusação teria fundamentado seus questionamentos em uma investigação interna da Companhia, a qual, por seu turno, teria concluído apenas pela irregularidade da conduta de dois diretores durante a execução do PAR e não pela irregularidade da decisão concernente à antecipação. As questões levantadas na peça acusatória não seriam conclusões da auditoria realizada, mas afirmações isoladas de depoentes que não constituíram qualquer tipo de prova.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

187. Ademais, refutou o argumento de que o grau de maturidade do projeto à época contraindicava a tomada de postura mais ousada. Segundo o defendente, os riscos são parte da atividade empresarial, notadamente no setor de petróleo, de modo que não caberia ao campo de atuação desta Autarquia tecer comentários sobre o mérito da decisão.

188. Arguiu o defendente quanto à conveniência de uma análise da decisão mais adequada depois de transcorrido dez anos da deliberação. No caso, caberia à Acusação apenas a verificação referente à prática de ato ilícito e de gestão negligente, fato que não teria logrado alcançar.

189. No que concerne à aprovação do projeto RNEST à fase IV, o defendente iniciou alegando a fragilidade da peça acusatória, em razão desta se fundamentar majoritariamente no testemunho de V.V. Segundo o defendente, a depoente, também acusada por essa irregularidade na auditoria interna da Petrobras, teria buscado atribuir responsabilidade a seus superiores, ainda que as provas dos autos, conforme reconhecido pela própria Acusação, indicassem fatos contrários aos declarados.

190. Quanto ao elemento VPL, afirmou consistir em uma projeção de valor, feita em determinado momento, sob a suposição de que, no futuro, as mesmas condições seriam mantidas. Nesse sentido, embora esse valor fosse importante, não deveria ser analisado em absoluto. A partir disso, decorreriam alguns aspectos, como: (i) a decisão sobre um empreendimento deveria considerar outros fatores para além do próprio VPL; (ii) o resultado do VPL seria consequência de uma metodologia pré-definida, e (iii) o VPL teria uma margem de erro razoável quando se tratasse de prever a lucratividade de um empreendimento.

191. Além disso, aduziu que a Petrobras, sendo uma sociedade de economia mista, teria outros objetivos além da maximização de lucros, sendo o VPL a medida comparativa entre o rendimento esperado de um empreendimento e o rendimento que seria plausível obter com a aplicação do capital em investimentos de baixo risco no mercado financeiro. Nessa perspectiva, o VPL negativo indicaria maiores ganhos com o investimento no mercado financeiro do que na construção de uma refinaria, de modo que não seria, necessariamente, previsão de prejuízo.

192. Afirmou, também, que um dos elementos utilizados para a definição do VPL consistiria na projeção dos gastos futuros para manter o empreendimento, os quais, decerto, poderiam ser alterados devido às taxas de câmbio e de juros, bem como devido às projeções dos preços futuros do petróleo e dos lucros ligados às margens de refino. Por conseguinte, não seria estranho o VPL calculado ser diferente em anos diversos.

193. Especificamente quanto à questão da perpetuidade, sustentou que o prazo de 25 anos, frequentemente utilizado para o retorno de lucratividade dos investimentos,



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

seria inviável para refinarias, posto que estas possuiriam vida útil muito maior. Soma-se a isso, ainda, o fato de que uma refinaria somente seria lucrativa a partir da incorporação de inovações desenvolvidas ao longo do tempo, tornando o investimento necessário para a manutenção da refinaria muito alto.

194. No caso, salientou que, para calcular o VPL de uma refinaria, seria preciso escolher entre um bem cujo valor se extinguiria em 25 anos com menores custos de manutenção ou um bem perpétuo, com expectativa de vida acima de 25 anos. A escolha pela perpetuidade, para o defendente, teria sido a mais adequada por conta da peculiaridade desses empreendimentos.

195. Concluiu, a esse respeito, que o que se estaria em análise seria a assunção dos riscos do negócio em razão da lucratividade esperada, sendo imprescindível, portanto, o exame conjunto de outros fatores, como a importância estratégica de longo prazo do ativo.

196. Outro argumento apresentado pelo defendente foi de que a peça acusatória não teria mencionado a existência de cerca de US\$ 1,5 bilhão de custos afundados no projeto. O VPL apresentado, na primeira apreciação de solicitação de passagem para a fase IV, era positivo, o que teria justificado a continuidade do empreendimento.

197. Embora o VPL não estivesse tão atrativo na reunião que aprovou a passagem de fase, o defendente afirmou que o abandono do projeto causaria grandes prejuízos, de forma que seria mais proveitoso dar continuidade ao projeto que poderia acarretar a obtenção de lucros.

198. Para o defendente, a posição da diretoria executiva de solicitar, na reunião de 03.09.2009, a reapresentação da matéria concernente à passagem para a fase IV revelaria a sua diligência, posto que teria concluído pela necessidade de desenvolvimento da proposta. Além das análises constantes no DIP não terem sido convincentes, teria havido um conflito entre o parecer do PLAFIN e a proposta da diretoria de abastecimento, o que teria inviabilizado a passagem de fase.

199. Na reunião realizada em 25.11.2009, tendo sido superada as problemáticas apontadas na reunião anterior, a diretoria executiva teria aprovado a passagem para a fase IV. No caso, o PLAFIN, em conjunto com a diretoria de abastecimento, teria incorporado alguns cenários que englobavam elementos que afetavam o VPL da RNEST, o que teria tornado o projeto menos arriscado.

200. Nessa perspectiva, o defendente afirmou que seu voto teria sido informado, refletido e desinteressado, pois teria, respectivamente, promovido um debate entre as áreas técnicas da Companhia na busca de construir critérios mais adequados, analisado os posicionamentos técnicos, os riscos e as metodologias adequadas para o cálculo do VPL e agido em prol dos interesses da Companhia.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

201. Em relação à suposta falta de diligência por ter ratificado, como membro do conselho de administração da Petrobras, a passagem do projeto RNEST à fase IV, reafirmou os argumentos supracitados, pleiteando pela improcedência da acusação de descumprimento do dever de diligência nesse tópico.

202. No que tange à suposta falta de diligência por não ter se certificado, na qualidade de membro do conselho de administração, de que as correções necessárias às deficiências nos controles internos estavam sendo implementadas, salientou, em um primeiro momento, o distanciamento dessa acusação ao objeto tratado no presente processo. Consequentemente, a peça acusatória não poderia considerar a interrupção do prazo prescricional como sendo a solicitação de esclarecimentos à Companhia quando da deflagração da operação Lava Jato, tampouco a instauração dos inquéritos administrativos 12/2014 e 5/2016. O comportamento do conselho de administração referente às auditorias internas estaria, portanto, prescrito.

203. Superada essa questão, defendeu a inconsistência do mérito acusatório. Para o defendente, não seria racional a peça acusatória alegar a fragilidade de controle interno da Companhia ao mesmo tempo em que baseia sua acusação em auditorias internas da Petrobras.

204. Sustentou o defendente de que o sistema de controle interno existente teria sido eficaz a ponto de identificar a existência de não-conformidades e da necessidade de um *compliance* melhor. Com isso, a acusação não se trataria de falta de diligência, mas sim de uma falta de eficiência, pois o conselho de administração não teria conseguido coibir as irregularidades identificadas.

205. Além disso, a peça acusatória teria mencionado que o comitê de auditoria, em “reiteradas manifestações”, apontou a necessidade de aprimoramento dos controles internos, quando, na verdade, isso só teria ocorrido em três relatórios trimestrais enviados ao conselho de administração: (i) em fevereiro de 2006; (ii) em agosto de 2008 e (iii) outubro de 2009. Nessas ocasiões, o comitê de auditoria teria indicado irregularidades na execução de contratos e sugerido o aprimoramento de gestão. Não teria sido indicado qualquer conduta corrupta.

206. Ao contrário do que sustenta a Acusação, o conselho de administração teria envidado esforços para atender aos pedidos do conselho de administração, tendo, inclusive, aprovado a Política e Diretrizes de Controles Internos da Petrobras em 13.04.2009.

207. Em seguida, argumentou no sentido de que a Acusação teria esperado um relato das atividades desenvolvidas por cada diretoria no que toca às atividades de auditoria e controle interno, fato este que não seria possível visto que o conselho de administração possuiria pauta estrita e não extensiva.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

208. Por fim, concluiu afirmando que o compliance não foi centralizado de imediato, tendo em vista que órgãos adequados estariam avaliando a proposta e tratando-a no âmbito mais geral dos sistemas de gestão da Companhia.

V.1.4. JORGE ZELADA

V.1.4.1. *PRELIMINAR*

209. O defendente suscitou a ocorrência da prescrição quinquenal da pretensão punitiva da CVM, visto que transcorridos mais de cinco anos entre os fatos objetos do processo e a instauração do inquérito administrativo. No caso, os fatos teriam ocorrido entre 03.09.2009, ocasião em que a diretoria executiva teria determinado a reapresentação da matéria, e 25.11.2009, ao passo que o Inquérito Administrativo nº 05/2016 só teria sido instaurado em 24.03.2016, transpassado, portanto, seis anos.

210. Sustentou, também, que a prescrição estaria de igual modo consumada caso se considerasse como causa interruptiva do prazo prescricional o Inquérito Administrativo nº 14/2014, posto que este teria sido instaurado em 26.12.2014, ou seja, cinco anos após a prática do ato.

211. Quanto ao prazo prescricional penal, o defendente, em sentido contrário ao da Acusação, argumentou pela sua inaplicabilidade, tendo em vista que não configuraria como réu nas ações penais nº 5083376-05.2014.4.04.7000/PR e nº 5012331-04.2015.4.04.7000/PR, ações estas utilizadas para fundamentar a atração da prescrição penal para o presente processo. Com efeito, não haveria nenhuma imputação, tampouco investigação de corrupção passiva envolvendo o defendente, sendo sua imputação referente somente à violação ao dever de diligência.

212. O defendente afastou, ainda, o argumento utilizado na peça acusatória de que “a prescrição é fenômeno que se conecta com fatos e não com pessoas”. Salientou que (i) esse entendimento seria aplicável apenas aos acusados cujas imputações configurem como corrupção passiva; e (ii) o julgado colacionado pela Acusação teria como objeto situação fática completamente distinta, posto que os fatos imputados à pessoa jurídica constituiriam crimes.

213. Além disso, o defendente sustentou, com base em jurisprudência do STJ, que a aplicação do prazo prescricional penal dependeria, também, da instauração de ação penal em face do defendente, fato que não teria sido verificado.

V.1.4.2 *MÉRITO*



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

214. Inicialmente, o defendente teceu comentários sobre a *business judgement rule*, ressaltando que, por essa regra, os administradores não poderiam ser responsabilizados por prejuízos, caso tenham agido de boa-fé dentro de suas atribuições e em conformidade com a lei e com o estatuto social.

215. Também ressaltou que riscos seriam inerentes à atividade empresarial e, tratando-se da Petrobras, o contexto fático impediria uma análise acurada de cada uma das pautas a serem analisadas pela diretoria executiva.

216. Ademais, aduziu que as obrigações que vinculam os gestores de sociedades anônimas seriam obrigações de meio e de resultado, citando, para embasar sua afirmação, julgado do Superior Tribunal de Justiça. Dessa maneira, não haveria obrigatoriedade de atingir determinados resultados, afastando-se, por consectário lógico, a responsabilidade pessoal daqueles que tenham agido dentro de suas atribuições.

217. Dito isto, o defendente arguiu não ter sido demonstrada qualquer conduta em que tenha agido fora de suas atribuições ou em violação à lei ou ao estatuto social da Petrobras. No caso, teria sido acusado tão somente por integrar a diretoria executiva da Companhia, já que não teria havido sequer demonstração de desvio nas decisões ou de erro inescusável.

218. Com efeito, teria decidido sempre com base no material e pareceres fornecidos pelos diretores responsáveis pelas áreas às quais estava vinculado o projeto RNEST. Salientou, ainda, a especificidade das questões deliberadas pela diretoria executiva, as quais teriam um nível de tecnicidade muito alto e, por isso, uma análise pormenorizada inviabilizaria o dia a dia e eficiência da Companhia.

219. Além disso, à época dos fatos, não haveria desconfiança interna quanto aos trabalhos realizados pelos demais diretores, de modo que a licitude e a capacidade técnica dos diretores eram presumidas por todos. Nesse aspecto, a interpretação feita pelo defendente no momento da deliberação teria sido razoável, em razão de pareceres dos diretores encarregados do projeto apontarem para a continuidade do projeto, bem como pela reputação ilibada de seus responsáveis.

220. O defendente destacou o reconhecido direito de confiar garantido aos administradores, citando doutrina que estabelece que “os administradores têm o direito de confiar nas informações e nos relatórios e estudos elaborados pelo corpo executivo, por empregados, auditores (...)”.

221. Soma-se a isso o fato de que os estudos técnicos apresentados indicariam que o desenvolvimento do projeto estava em conformidade com os objetivos da empresa, tendo mencionado como exemplo o DIP AB-CR nº 327/2009.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

222. Ademais, o defendente pontuou a ausência de previsão, na Lei nº 6.404/76, de responsabilidade objetiva, visto que o artigo 158 da referida lei seria translúcido ao impor a obrigatoriedade do elemento volitivo para fins de responsabilidade pessoal dos administradores. No caso vertente, não haveria qualquer indicativo de atuação dolosa por parte do defendente, tendo a própria peça acusatória reconhecido que “*não [poderia] atribuir atos ilícitos intencionais referentes à Refinaria do Nordeste.*”

223. De modo a reforçar a necessidade de comprovação do elemento subjetivo para responsabilização dos administradores de recursos públicos, citou doutrina administrativista, bem como jurisprudência do Tribunal de Contas da União.

224. A tentativa de imputar responsabilidade ao defendente por descumprimento do dever de diligência pautando-se no fato de que o projeto teve um custo maior do que o planejado inicialmente seria realizar uma interpretação anacrônica dos fatos. Naquele momento, o ambiente político-econômico, a valorização da demanda e o valor de mercado do petróleo teriam superado os riscos do projeto existentes.

225. Nesse sentido, argumentou, ainda, ser o presente caso hipótese de inexigibilidade de conduta diversa, pois, tendo em vista as circunstâncias da época, não seria possível esperar entendimento contrário por parte do defendente.

226. Outro argumento suscitado pelo defendente se refere à impossibilidade de sua responsabilização por ato praticado por terceiro. Sobre o tema, o artigo 158, §1º, da Lei nº 6.404/76, estabelece que o administrador não é responsável por atos ilícitos de outros administradores, salvo quando comprovada sua ciência sobre tais condutas.

227. No caso em tela, o defendente alegou não ter tido conhecimento sobre os desvios, reforçando que a própria Acusação teria reconhecido que o projeto RNEST estava vinculado unicamente às diretorias de serviços e de abastecimento.

228. Especificamente quanto à aprovação do projeto à fase IV, o defendente considerou equivocada a desconsideração, por parte da Acusação, dos pareceres e relatórios dos órgãos técnicos. Afirmou que teriam sido, ou deveriam ter sido, observados e analisados pelos responsáveis pela formulação do DIP AB-CR nº 327/2009, os quais, por sua vez, teriam entendido que os benefícios do projeto seriam suficientes para justificar a exposição aos riscos.

229. Além disso, o referido DIP teria apresentado ponderações que indicavam que o corpo técnico teria tomado medidas necessárias para a readequação do projeto. Com efeito, o documento teria sido, inclusive, referendado pela gerência executiva de abastecimento corporativo e pelas áreas de planejamento financeiro, de estratégia e tributário.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

230. Ressaltou o defendente que nenhum dos pareceres emitidos teriam sugerido a suspensão do empreendimento ou a desaprovação da execução da fase IV do projeto.

231. Quanto ao parecer emitido pela PLAFIN em que se dispunha que “o VPL [Valor Presente Líquido] negativo apresentado frente ao expressivo investimento requerido representa um ponto de atenção para a companhia”, o defendente afirmou que a área técnica teria sanado essa questão, pois o DIP AB-CR nº 327/2009 teria apresentado VPL de US\$ 76.000.000,00 (setenta e seis milhões de dólares) positivos no cenário de referência.

232. Ainda assim, argumentou que o Tribunal de Contas da União entende que o VPL negativo não configura obrigatoriamente dano à companhia, o que teria sido, inclusive, reconhecido na peça acusatória e suficiente para afastar a responsabilização do defendente. Dessa maneira, mesmo que se considerasse o VPL como negativo, isso não implicaria necessariamente a ocorrência de prejuízo.

233. Assim, requereu pela improcedência do presente processo quanto à sua atuação, em razão de não ter sido demonstrada sua participação em quaisquer irregularidades, tendo atuado nos estritos ditames legais.

V.1.5. ALMIR BARBASSA E GUILHERME ESTRELLA

V.1.5.1. *PRELIMINAR*

234. Em defesa conjunta, os defendentes alegaram a ocorrência da prescrição quinquenal aplicável à pretensão punitiva da CVM, visto que o processo de construção da RNEST teria se iniciado em 14.02.2005, ao passo que o Processo CVM nº RJ2014/12184, do qual se originou o Inquérito Administrativo nº 14/2014, que, por sua vez, originou o presente processo, somente teria sido instaurado em 20.10.2014.

235. Além disso, discordaram quanto ao fato ensejador do cômputo do referido prazo, visto que as infrações imputadas aos defendentes, quais sejam, a falta do dever de diligência quando das deliberações referentes à aprovação do PAR e à aprovação da passagem do projeto à fase IV, teriam ocorrido, respectivamente, em 08.03.2007 e 25.11.2009.

236. Quanto à primeira infração, afirmaram os defendentes ser inequívoca a consumação da prescrição quinquenal, visto que o primeiro processo administrativo concernente as supostas irregularidades somente teria sido instaurado cerca de 7 (sete) anos depois. Quanto à segunda infração, informaram que o simples início da investigação não seria suficiente para interromper o prazo prescricional, visto ser



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

exigida a ciência do acusado sobre sua investigação, a qual somente teria ocorrido em fevereiro de 2017.

237. Afastaram a atração do prazo prescricional penal de 16 (dezesseis) anos defendido pela Acusação sob o argumento de que, para tal, é preciso que o agente responda pelo mesmo ato na esfera penal e administrativa, bem como que a suposta infração administrativa configure “crime em tese”. A esse respeito, apresentaram excertos jurisprudenciais do STJ, CRSFN e da CVM que confirmariam o alegado.

238. Considerando que os defendentes não teriam sido denunciados nem investigados criminalmente e que suas condutas analisadas no presente processo não poderiam ser enquadradas em qualquer tipo penal, a aplicação da prescrição penal implicaria em grave sanção por um crime em que sequer teriam tido relação.

239. Com efeito, as infrações imputadas aos defendentes - referentes à falta do dever de diligência – consistiriam em mera análise de como ocorreu o processo decisório na diretoria executiva, enquanto as ações penais utilizadas pela Acusação como fundamento de coincidência fática teriam como objeto a prática de corrupção na contratação das obras relativas ao empreendimento.

240. Como argumento adicional, aduziram que a prescrição seria aplicável individualmente a cada um dos acusados. A doutrina entenderia que, sendo um direito de punir, a pretensão punitiva deveria se conectar aos atos praticados por pessoas e não aos fatos, devendo, portanto, fazer uma análise subjetiva para a determinação e contagem dos prazos prescricionais.

241. Os defendentes arguíram, ainda, pela incompatibilidade do precedente apresentado pela Acusação para justificar a prescrição penal, visto que, naquele processo, o ato de relevância administrativa e criminal teria sido praticado pela mesma pessoa a quem foi estendido o prazo prescricional penal, circunstância não verificável neste.

242. Por fim, salientaram a impossibilidade de interpretação extensiva dos Direitos Penal e Processual Penal, de modo que não se admitiria a aplicação de prescrição penal a quem não tenha cometido o crime.

V.1.5.2. *MÉRITO*

243. De início, os defendentes apontaram para a flexibilidade do conceito de diligência, indicando que a análise de conduta dos administradores deveria ser pautada pela teoria do *business judgement rule*, ou seja, deveria se verificar se a decisão tomada foi informada, refletida e desinteressada. Em outros termos: mesmo que a decisão deliberada tenha trazido prejuízos para a Companhia, não há de se falar em



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

responsabilização caso os administradores tenham atuado de boa-fé e no interesse da Companhia.

244. Antes de adentrar especificamente nas deliberações dos defendentes, a defesa ressaltou a necessidade de se atentar para o contexto fático da época, visto que não caberia os julgadores emitir juízo com base em resultados que só foram conhecidos *a posteriori*. Nesse sentido, ressaltaram os defendentes que não teriam tido ciência da corrupção institucionalizada dentro da Companhia, já que os diretores envolvidos no esquema de desvio de recursos encobriam bem suas ações para não serem descobertos, de modo que nem mesmo as instâncias de controle teriam sido capazes de identificar tais irregularidades.

245. A fim de ilustrar o caráter informado, refletido e desinteressado das decisões tomadas pelos defendentes nas reuniões de 08.03.2007 e 25.11.2009, a defesa desmembrou os acontecimentos de cada momento do projeto. Dessa maneira, destacaram os defendentes que a escolha pela construção de uma nova refinaria no Brasil teria sido motivada por motivos de relevância nacional e de necessidade de independência frente ao mercado exterior.

246. Com relação à aprovação do Plano de Antecipação da Refinaria em 08.03.2007, o DIP apresentado pelo diretor de abastecimento teria apontado dificuldades na implantação da refinaria, de modo que a antecipação de determinados aspectos – como a compra de equipamentos críticos e a licitação de determinados serviços –, tal qual a contratação antecipada de projeto executivo de engenharia agilizariam o projeto.

247. Além disso, análises teriam concluído pela possibilidade de inauguração da refinaria em agosto de 2010, ainda que o novo cronograma carecesse de uma margem de segurança, desde que as áreas envolvidas priorizassem o projeto. No caso, o diretor executivo da área de abastecimento, responsável pelo empreendimento, teria ratificado categoricamente a possibilidade de antecipação da partida da refinaria.

248. Considerando que não havia qualquer fator que desaconselhasse o plano de antecipação, tendo, inclusive, a gerência de abastecimento corporativo concordado com tais providências, a diretoria executiva teria aprovado a proposta. Afirmaram os defendentes que as alterações realizadas no projeto e o aumento na estimativa de investimento seriam condições normais em empreendimentos de tamanha magnitude, inclusive porque, conforme preconiza a Sistemática Corporativa, o projeto vai sendo gradualmente detalhado.

249. Pontuaram os defendentes que os argumentos utilizados constantes na peça acusatória para questionar a tomada de decisão foram retirados da CIA RNEST, instalada cerca de 7 (sete) anos após a deliberação. Dessa maneira, a Acusação estaria se



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

utilizando de fatos e de condições desconhecidos naquela época para fundamentar a imputação de falta do dever de diligência.

250. Outro ponto rebatido refere-se à suposta falta de “justificativa adequada” para a antecipação, visto que a elaboração do projeto básico somente se iniciou em março de 2007, após a aprovação do PAR. Sustentaram os defendentes que, em razão do início recente da fase III, a ausência de um projeto básico seria evidente, pois, caso contrário, não teria sido necessário um plano de antecipação.

251. Aduziram, também, que a antecipação seria, naquele momento, considerada positiva, em razão de o projeto ser relevante tanto para a Companhia, quanto para o país. Além disso, a antecipação do projeto implicaria também na antecipação de receita, o que refletiria nos resultados da Petrobras.

252. Quanto ao estudo sobre o plano solicitado pela diretoria executiva para retorno em 45 dias, os defendentes destacaram depoimento de V.V., em que se confirma que a proposta foi reapresentada, tendo, inclusive, sido feitas apresentações sobre as medidas adotadas por cada área envolvida no projeto. A ausência de evidência dessa hipótese não poderia significar que ela não ocorreu, pois, como destacado pela própria peça acusatória, as atas das reuniões não eram descritivas e, sim, conclusivas.

253. Concluíram, portanto, que foram diligentes quando da aprovação do PAR, tendo em vista que pautaram sua decisão com base (i) nas informações técnicas apresentadas, bem como (ii) na confiança existente nos diretores responsáveis pelo projeto. Nesse contexto, destacaram o direito de confiar (*right to rely on others*) nas informações e nos estudos técnicos apresentados, já que se tratava de um assunto específico no qual não teriam conhecimento aprofundado, bem como não haveria motivo de desconfiança dos dados fornecidos.

254. Sobre o suposto não questionamento por partes dos defendentes quanto à escalada de preços e aos indícios de que o empreendimento daria prejuízo à Companhia, os defendentes aduziram que grande parte dos valores indicados pela Acusação consistiria, na verdade, em valores referentes a ações que ainda estavam sendo avaliadas, além de terem reiterado que a ausência de registro de questionamentos não significaria que estes não foram feitos.

255. Destacaram, ainda, que o aumento de custos da RNEST não teria sido ocasionado somente pelo PAR e dos aditivos contratuais dele resultantes, mas também por diversos outros fatores não mencionados na peça acusatória, como (i) o incremento na capacidade da refinaria; (ii) introdução de novos sistemas que melhorariam a qualidade dos derivados; (iii) o aquecimento do setor, que teria ocasionado significativo aumento de preços; e (iv) valorização do real frente ao dólar norte-americano,



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

impactando o custo da refinaria em dólares. Alguns desses fatores teriam sido, inclusive, elencados no fato relevante divulgado pela Companhia em 26.08.2009.

256. No que se refere à reunião de 03.09.2009 sobre a passagem à fase IV, os defendentes buscaram desconstruir os supostos indícios quanto à inviabilidade do projeto. Em primeiro lugar, afirmaram que um novo pacto teria sido firmado entre a Petrobras e a PDVSA, conforme fato relevante divulgado em 26.03.2008 e informações constantes no DIP nº 212/2009. Sendo assim, a formalização da parceria entre as companhias estaria avançando, diferentemente do que faria crer a Acusação.

257. Ainda assim, mesmo que a parceria não se concretizasse, o referido DIP teria contemplado um modelo de negócio alternativo, no qual a refinaria seria uma unidade de negócios “interna” ao Sistema Petrobras. Nesse cenário, o VPL seria, inclusive, mais atrativo tanto no cenário de referência, quanto no cenário de robustez. Dessa maneira, tratar-se-ia de um indicativo para a continuidade do projeto e não o contrário.

258. Em segundo lugar, a não consideração das refinarias *Premium* na avaliação do EVTE da RNEST teria sido motivada pela sua condição ainda embrionária, de modo que um projeto ainda imaturo não poderia obstar o prosseguimento de um que já estava em andamento. Com efeito, o parecer da Estratégia, bem como depoimentos de técnicos da Companhia corroborariam tal circunstância.

259. Os defendentes apontaram, ainda, que, mesmo diante dessas explicações, optaram pela reapresentação da matéria com os ajustes necessários. Tal fato seria mais um indicativo de sua conduta diligente, posto que, ao não aprovarem a passagem do projeto à fase IV naquela ocasião, teriam demonstrado comprometimento com seus deveres fiduciários para com a Companhia.

260. Em relação aos contratos autorizados a serem celebrados antes da efetiva passagem de fase, os defendentes destacaram só ter participado da reunião do dia 24.09.2009, tendo sido substituídos por suplentes na reunião de 22.10.2009.

261. Nada obstante, contrapuseram-se ao argumento da Acusação de que “essa precipitação, ainda que dependente de deliberação posterior, [indicaria] que, no colegiado de diretores, não se pensava em rever estruturalmente o projeto, mas dar-lhe seguimento a qualquer custo.” Afirmaram ser equivocada a conclusão da SPS, posto que os contratos teriam sido aprovados justamente pelo fato de se ter estabelecido a pendência destes frente à deliberação a ser feita.

262. Antes de discorrer sobre os motivos que levaram à efetiva aprovação da passagem do projeto RNEST à fase IV, a defesa teceu alguns comentários sobre o estudo de viabilidade técnica e econômica (“EVTE”). O EVTE teria como finalidade



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

aferir o sucesso ou fracasso de determinado empreendimento a partir de determinados fatores, os quais resultariam em um VPL, que poderia ser negativo ou positivo.

263. Nessa perspectiva, o VPL projetado poderia não se concretizar, já que consistiria em uma estimativa fundada em premissas - a razoabilidade quanto à escolha das premissas seria a única exigência que se fazia. Com o intuito de comprovar a adequação das premissas utilizadas no novo estudo realizado e apresentado na reunião do dia 25.11.2009, em que o VPL passou a ser de US\$76 milhões, os defendentes abordaram cada uma individualmente, conforme se observa a seguir:

- a) A perpetuidade seria uma metodologia utilizada na análise de empreendimentos em que há ativos cujos rendimentos se entendem indefinidamente ao longo do tempo. Em que pese sua utilização não ser usual em grande parte dos projetos da Companhia, sua inclusão no presente caso teria sido apropriada, tendo em vista que (a) uma refinaria, desde que periodicamente modernizada, teria prazo de duração indeterminado e (b) o setor petroquímico seria oligopolista. Essa premissa teria sido, inclusive, validada pela Estratégia e por técnicos da área. Os riscos existentes sobre os fluxos de caixas futuros, possível alerta destacado pela Acusação, seriam inerentes a qualquer atividade da Companhia, notadamente as do setor petrolífero.
- b) O fator de utilização seria uma metodologia indicativa da capacidade de processamento de determinada planta. No caso, teria sido aumentado com o intuito de refletir a média das melhores unidades do referido parque, visto se tratar de uma refinaria nova com tecnologia de ponta.
- c) A taxa mínima de atratividade seria uma taxa de desconto que representaria o retorno mínimo exigido pelo investidor para determinado empreendimento. Sua redução estaria relacionada à redução da participação da PDVSA na RNEST, uma vez que a presença da parceira venezuelana importaria maiores riscos para o projeto.
- d) As desonerações tributárias consistiriam em premissa completamente razoável se considerado que (i) a construção de uma nova refinaria no Nordeste atendia a relevantes interesses estratégicos do país, (ii) diferentemente do que alegou a área técnica, a Companhia mantinha negociações frequentes com o Ministério da Fazenda, e (iii) o Ministério da Fazenda era comandado por Guido Mantega, então presidente do conselho de administração da Companhia. Com efeito, esse último requisito não significaria, necessariamente, que os benefícios seriam concedidos, mas sim que os diretores, por terem participado de reuniões com o então Ministro, teriam mais conhecimento sobre as reais possibilidades de isenção do que o Tributário ou a Estratégia. Inclusive, diversos benefícios fiscais foram, de fato, concedidos posteriormente.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

e) A perda de mercado se relacionaria à possibilidade de um terceiro se apropriar da oportunidade de investimento que está sendo estudada e/ou desenvolvida, ou seja, seria a hipótese de a Petrobras não construir a RNEST e um terceiro construir uma outra refinaria em seu lugar. Não obstante a área técnica não ter considerado essa premissa factível, a quebra do monopólio estatal sobre o refino, a crescente demanda mundial por produtos derivados e a localização estratégica da região teriam sido fatores capazes de justificar essa consideração.

264. Com relação à deliberação tomada na reunião de 25.11.2009, os defendentes reiteraram os argumentos mencionados anteriormente quanto ao fato de não ter sido considerado o impacto concorrencial das Refinarias *Premium* e a indefinição relativamente à parceria com a PDVSA, quais sejam, o elevado grau de incerteza com relação ao prosseguimento daquele projeto e a negociação já em fase final dessa parceria.

265. Sobre as Refinarias *Premium*, a Acusação teria ignorado o conhecimento de determinadas informações por parte dos diretores da Companhia, conhecimento esse que lhes permitiria a avaliação de pertinência de determinadas premissas. Por sua vez, a assinatura de diversos instrumentos teriam indicado a proximidade de concretização da parceria entre Petrobras e PDVSA, tais como o acordo de acionistas, o estatuto social da RNEST S.A., o plano de negócios e o contrato de fornecimento de petróleo.

266. Como argumento adicional, destacaram que as negociações, no âmbito do presente projeto, eram feitas pelos governos dos dois países, pelos presidentes das companhias e pelo diretor de abastecimento, de modo que só teriam tido acesso a informações que lhes eram fornecidas. Contudo, como já exposto, a não concretização do acordo seria ainda melhor para a Petrobras do ponto de visto econômico.

267. Segundo os defendentes, a não realização de análise de risco quantitativa em casos em que o VPL era negativo no cenário de robustez, análise prevista pela Sistemática Corporativa, teria sido prescindível, em razão de terem sido apresentadas análises de sensibilidade considerando diversas variáveis, logo já teriam identificado os principais riscos do empreendimento e seus possíveis impactos numéricos sobre o VPL.

268. A defesa esclareceu, ainda, a afirmação de que seria parte do processo decisório da diretoria executiva “interferir no sentido de melhorar a análise [do EVTE ou do VPL]”. Diferentemente do alegado pela Acusação de que se trataria de uma distorção de um quadro desfavorável, arguiu-se tratar de um incentivo às áreas técnicas para redução de custos, a fim de aprimorar os indicadores do projeto e, portanto, torná-lo mais viável. A esse respeito, foram transcritos trechos de depoimentos de ex-diretores para confirmar essa alegação.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

269. Por conseguinte, concluíram os defendentes terem, mais uma vez, atuado de maneira diligente, posto que, ainda que existissem alertas e recomendações em determinados trechos do DIP concernente à passagem à fase IV e dos pareceres técnicos, a leitura integral dos documentos teriam apontado para a continuidade da viabilidade econômica e importância estratégica da RNEST.

270. Ainda de modo a comprovar o cumprimento de seu dever de diligência, os defendentes destacaram que, em depoimento, Graça Foster e V. V. F, teriam reconhecido suas contribuições para as discussões da diretoria executiva, tendo participado ativamente de cada aspecto relevante do projeto, não obstante a quantidade de matérias em que teriam que analisar em uma única reunião.

271. Por fim, solicitaram a admissão de provas produzidas nos autos do Inquérito Administrativo CVM nº 06/2016, bem como reservaram-se, ainda, o direito de apresentar proposta de termo de compromisso.

V.1.6. ILDO LUÍS SAUER

V.1.6.1. *PRELIMINAR*

272. Preliminarmente, o defendente suscitou a ocorrência da prescrição quinquenal da pretensão punitiva da CVM, visto que transcorridos mais de 5 (cinco) anos entre os fatos objeto do presente processo – datado de 08.03.2007 – e a instauração do inquérito administrativo – datado de 24.03.2016.

273. O defendente afastou, ainda, a aplicabilidade do prazo prescricional penal, posto que os fatos a ele imputados corresponderiam à suposta falta do dever de diligência enquanto administrador de companhia aberta, não se relacionando com o crime de corrupção passiva analisadas no âmbito das ações penais mencionadas pela Acusação.

274. A esse respeito, destacou que os fatos supostamente irregulares que teria praticado consistiriam na aprovação pela diretoria executiva, em 08.03.2007, do PAR e na não cobrança da estratégia de contratação que deveriam ter voltado à diretoria executiva em até 45 dias depois, de modo que tais condutas não teriam correspondência penal. Com efeito, o defendente não teria sido sequer citado nas ações penais mencionadas pela Acusação.

275. Além disso, os precedentes utilizados como fundamentação não teriam correlação com o caso em tela. O Recurso nº 11.969 do CRSFN teria como objeto um mesmo conjunto de fatos que representariam ilícito penal e administrativo, ou seja, os fatos analisados seriam os mesmos, ao passo que o que se estaria em questão neste



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

processo seria a possibilidade de estender o prazo prescricional a pessoas que não teriam participado de qualquer fato que ensejasse responsabilidade penal.

276. Como argumento adicional, destacou que o STJ possuiria jurisprudência pacífica no sentido de que a pretensão punitiva administrativa apenas se sujeitaria ao prazo prescricional criminal quando instaurada a respectiva ação penal.

V.1.6.2. *MÉRITO*

277. De início, o defendente salientou a importância de se atentar aos fatos que eram conhecidos e presentes à época dos acontecimentos, ou seja, sem o olhar enviesado e retrospectivo trazido pelas descobertas da Lava-Jato.

278. Além disso, esclareceu sobre a organização esquematizada pela Petrobras: os diretores seriam escolhidos com base em formação, conhecimento e experiência que se coadunassem com as áreas da companhia. No caso, o defendente seria um especialista da área de energia, de modo que sua expertise não compreenderia as demais áreas de atuação da Companhia e suas diretorias.

279. Ainda assim, ao receber as pautas das reuniões da diretoria executiva, a primeira providência seria a de examinar os DIPs anexos e se estes possuíam os elementos necessários para a tomada de uma decisão informada e refletida. Em seguida, verificaria se a proposta e justificativa seriam aderentes ao plano estratégico e de negócios da Petrobras, ao disposto no estatuto social e às normas vigentes aplicáveis.

280. Afirmou, também, que o dever de diligência seria um standard aplicável aos administradores, no qual estes deveriam observar os negócios da companhia da forma que todo homem ativo e probo emprega na administração de seu próprio negócio. A atividade de administração, contudo, constituiria em obrigação de meio e não de fim, de modo que o administrador não asseguraria resultado.

281. A defesa analisou três dos subdeveres relacionados ao dever de diligência por motivos de pertinência, quais sejam o dever de se informar, o dever de investigar e o dever de vigiar. O primeiro consistiria na obtenção de informações disponíveis no momento da prática de determinado ato negocial, de acordo com as circunstâncias de cada caso: o tempo disponível para a efetiva tomada de decisão e os custos demandados por uma eventual investigação mais profunda e detalhada; o segundo configuraria a imposição ao administrador do dever de pesquisar mais profundamente as informações disponibilizadas mediante a existência de “sinais de alerta”; por fim, o terceiro não diria respeito a atos específicos, mas a uma vigilância geral acerca do andamento dos negócios e a execução das deliberações e decisões tomadas, sob pena de criar-se um nível de responsabilidade incompatível com a atividade de administrador.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

282. De modo a comprovar sua diligência e empenho no exercício de suas funções, o defendente destacou trechos de livros e cartas que indicariam que ele não só não se beneficiava de qualquer esquema de propina, como também não aceitaria fazer parte de um por ter uma postura extremamente profissional e comprometida.

283. Em seguida, o defendente aduziu que a aprovação do PAR não teria sido uma autorização para adquirir bens e serviços, mas sim uma autorização para que se realizassem estudos que viabilizassem sua implementação e para que se revisasse o plano de negócios da refinaria. A esse respeito, transcreveu trechos de seu depoimento escrito sobre a matéria, cujos argumentos principais serão resumidos a seguir:

- a) A fase III, fase na qual se autoriza a contratação e compra de equipamentos e serviços definindo as tecnologias que efetivamente serão aplicadas, não teria sido apreciada pelo defendente.
- b) Na pauta de aprovação da fase II, o DIP apresentado teria considerado as análises de sensibilidade em um projeto como 100% da Petrobras, de modo que a não participação da PDVSA não alteraria o resultado positivo do projeto. Outros fatores relevantes quanto à definição da participação da PDVSA na refinaria seriam (a) a negociação do projeto da refinaria e a preservação dos interesses da Petrobras fariam parte de acordo entre as companhias e não seriam de sua atribuição e sim das áreas internacional, de abastecimento e da presidência; (b) o não prosseguimento do projeto retardaria ainda mais o início da produção, o que poderia ter gerado perdas para a Petrobras; (c) a concretização do acordo com a PDVSA permitiria que o óleo “mejorado” a ser processado na RNEST fosse produzido pela Petrobras nos campos da Venezuela.
- c) Além disso, em abril de 2005, teriam sido apresentados diversos documentos que demonstrariam o desenvolvimento de negócios e atividades de cooperação no setor de refino entre a Petrobras e a PDVSA, bem como teria sido firmado um memorando de entendimento e carta de intenção para desenvolvimento de projetos comuns entre as companhias, o que indicaria o compromisso para com a concretização da parceria.
- d) A área de gás e energia não teria participado, com base nas responsabilidades definidas no plano organizacional da empresa, das atividades relacionadas à comercialização de petróleo e seus derivados. Inclusive, o defendente não teria sequer elementos técnicos e administrativos para rejeitar a passagem do projeto para a próxima fase, uma vez que os procedimentos internos estariam todos de acordo com as normas e os indicadores econômicos eram positivos e alinhados com a disciplina de capital da Companhia. A esse respeito, apresentou, ainda,



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

estudos que indicavam que os números estimados estariam compatíveis com a métrica internacional.

- e) Três principais pontos indicariam que as previsões feitas na fase II se concretizariam: (a) a Petrobras teria larga capacidade tecnológica no desenvolvimento e implementação de projetos de refino; (b) larga experiência da Companhia e sua capacitação na expansão e implantação de novas tecnologias em unidades de processo nas suas refinarias; e (c) os instrumentos de gestão permitiriam o acompanhamento da implementação de projeto. Dessa maneira, afirmou que o problema da RNEST teria sido a má-fé e dolo dos diretores responsáveis ao violarem as premissas e objetivos empresariais aprovados.
- f) A CIA RNEST, ao indicar os responsáveis pelos problemas no projeto e na sua implementação, não teria lhe mencionado.
- g) Ao analisar retrospectivamente os fatos relevantes, concluir-se-ia de que, após a saída do defendente da diretoria executiva, o orçamento dos custos de construção e instalação da refinaria RNEST teria permanecido como previsto inicialmente por um longo período, isto é, de US\$4,05 bilhões.
- h) A aprovação do PAR teria sido condicionada a um esforço concentrado de diversas áreas da Companhia, notadamente o jurídico, o centro de pesquisas, a área de compra de materiais e de engenharia, as quais deveriam ter apresentado um estudo até 45 dias aos diretores. Até a sua destituição, nenhum dos estudos de projeto básico e de detalhamento, imprescindíveis para a implementação do PAR, teriam sido submetidos à diretoria executiva, de modo que somente em 27.03.2008, seis meses após a sua destituição, uma avaliação do PAR teria sido apresentada. Por conseguinte, aduziu que as decisões subsequentes, relacionados com o PAR, não teriam tido sua participação.

284. Nesse contexto, a defesa afirmou que as ponderações e recomendações feitas nos DIPs referentes ao PAR teriam sido absolutamente naturais, não evidenciando qualquer situação anômala que pudesse indicar os atos ilícitos posteriormente descobertos. Pelo contrário: os documentos teriam apontado para a importância que o projeto RNEST teria.

V.1.7 PAULO ROBERTO COSTA

V.1.7.1. *PRELIMINAR*

285. Preliminarmente, o defendente alegou que o termo de acusação seria inepto na medida em que a peça acusatória não teria descrito o nexo de causalidade entre o



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

prejuízo causado à companhia e o ato de gestão do administrador, limitando-se a imputar genericamente à administração os fatos em questão, o que violaria os princípios da ampla defesa e do contraditório.

286. O defendente suscitou, ainda, sua ilegitimidade passiva no que tange a uma suposta irregularidade com as demonstrações financeiras da Companhia, uma vez que, como diretor de abastecimento, nunca havia participado do acompanhamento de retorno de investimento, testes de *impairment* e demonstrações financeiras, que eram feitas e coordenadas pela diretoria financeira.

V.1.7.2. *MÉRITO*

287. O defendente afirmou que as irregularidades destacadas no presente processo não poderiam lhe ser imputadas, tendo em vista que teria trabalhado na empresa apenas no início da execução das obras da refinaria, tendo saído no ano de 2012. Com efeito, teria declarado, no acordo de colaboração premiada, não ter tido ingerência sobre as contratações, que dependeriam de inúmeras etapas e concessões da diretoria executiva, da qual não seria parte.

288. Além disso, traçou um breve histórico profissional, destacando que, ao se aposentar em abril de 2012, o conselho de administração teria elogiado e agradecido por seus serviços prestados, dentre os quais citou: a ampliação do refino nacional com aumento de carga das refinarias existentes e principalmente a colocação de unidades de conservação para maior uso do petróleo pesado, unidades para redução de enxofre na gasolina e no óleo diesel.

289. Em seguida, o defendente descreveu sua função no cargo de diretor de abastecimento. Nesse sentido, afirmou que era de sua competência dirigir as áreas de abastecimento da Companhia, que compreendiam as áreas de marketing e comercialização, refino, logística corporativa, petroquímica e novos empreendimentos. A responsabilidade pelo segundo maior orçamento da Companhia seria a do diretor de abastecimento.

290. Explicou, ainda, que a Petrobras funcionaria com uma diretoria colegiada, de modo que “quando os assuntos são levados a esta Diretoria, qualquer que seja o assunto, a sua aprovação ou não é decisão de todos; todos são responsáveis por todas as áreas”.

291. Ademais, o defendente ressaltou seu pioneirismo em ter firmado acordo de colaboração premiada quanto aos fatos investigados no caso da Operação Lava-Jato. O instrumento teria sido extremamente decisivo para a identificação de inúmeros outros coautores e partícipes da organização criminosa, bem como para a prevenção de



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

infrações penais decorrentes de atividades criminosas. Outros impactos positivos decorrentes desse acordo também foram mencionados pela defesa.

292. Afirmou, ainda, que os procuradores incumbidos de atuar na operação Lava Jato enviaram o acordo de colaboração premiada firmado entre o defendente e o Ministério Público para a 5ª Câmara de Coordenação e Revisão – Combate à Corrupção por entenderem que este abarcaria eventuais repercussões no campo da improbidade administrativa, tendo sido homologado em 05.02.2015, de modo que não mais caberia qualquer pleito contra o defendente pautado em descumprimento do dever de probidade.

V.2. MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

V.2.1. DILMA ROUSSEFF

V.2.1.1. *PRELIMINAR*

293. A defendente suscitou a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva da CVM. No caso, sua conduta supostamente irregular teria cessado em 22.04.2010, quando teria deixado de ocupar cargo no conselho de administração da Petrobras, enquanto a investigação acerca de eventual violação a dever de diligência por inconsistências nos controles internos da Companhia só teria iniciado em 03.06.2016, nos autos do Inquérito Administrativo nº 05/2016. Isto é: o prazo de 5 (cinco) anos para o exercício da pretensão punitiva desta Autarquia teria transcorrido.

294. Nessa linha, argumentou que os processos instaurados para apurar denúncias de atos ilícitos no contexto da “Operação Lava-Jato” não poderiam ser considerados como causas interruptivas do prazo prescricional, visto que a própria CVM teria reconhecido que “a deficiência de controles internos não se direciona diretamente com as contratações e condução do projeto da RNEST, ou seja, os fatos objeto da pretensão punitiva não configuram também crime” (fls. 5.691).

295. A defendente arguiu que o escopo inicial do Inquérito Administrativo nº 14/2014, o qual tinha como objeto a possível inobservância de deveres fiduciários dos administradores da Petrobras, não poderia ser expandido de modo a abranger toda e qualquer infração a dever fiduciário dos administradores da Companhia, mas apenas aquelas relacionadas à Operação Lava-Jato, visto que isso significaria interrupção até mesmo das infrações não apuradas. O princípio da segurança jurídica restaria prejudicado.

V.2.1.2. *MÉRITO*



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

296. De início, a defesa de Dilma Rousseff destacou que, independente de análise política e parcial, sua conduta sempre foi de combate à corrupção e aos atos danosos a administração pública, tendo sido responsável pela sanção da Lei nº 12.850/13 (Lei de Organização Criminosa) e Lei nº 12.846/13 (Lei Anticorrupção). Tais leis teriam sido de fundamental importância para o país, visto ter diminuído a impunidade e articulado programas de integridade às normas de ordem pública, como o *compliance*.

297. A integridade de sua atuação como chefe do Poder Executivo teria sido pautada, ainda, na moralidade e na independência da Polícia Federal, tendo os fatos do presente processo sido descobertos apenas por conta de seu trabalho e empenho na defesa da administração pública contra atos lesivos.

298. Ao tratar do suposto descumprimento do dever de diligência, afirmou que esse dever consiste em um mandamento que baliza a conduta dos administradores, ressaltando, contudo, que não há, na lei, exigência de uso de meios excepcionais ou extraordinários na condução dos negócios da companhia. Sendo assim, a análise por parte do órgão julgador deveria ser restrita à verificação da forma como o administrador desempenhou sua função, independente do resultado de sua atuação.

299. A esse respeito, colacionou doutrinas e precedentes da CVM que estabelecem que o cumprimento do dever de diligência deve ser observado no caso concreto, atentando-se para a realidade fática em questão, bem como para os perigos de uma análise realizada *a posteriori*. Com isso, sustentou que o dever de diligência é uma obrigação de meio e não de resultado, na qual se considera que o administrador foi diligente caso sua decisão tenha se dado de forma informada, refletida e desinteressada.

300. Destacou, também, o dever de vigilância ou monitoramento que decorre do dever de diligência. Para explicá-lo, recorreu às lições de Nelson Eizirik, o qual afirma que o dever de vigilância não consiste em um dever de análise exaustiva de cada ato da Companhia, mas sim em um acompanhamento geral dos negócios sociais, visto que o exame minucioso de toda atividade desenvolvida poderia gerar mais custos do que benefícios.

301. Ademais, a defendente apresentou algumas considerações quanto ao conselho de administração, ressaltando a sua função de órgão deliberativo da companhia. Afirmou que “o conselho é colegiado e, portanto, produz decisões, atos deliberativos que são atos da sociedade e que informam e orientam a Diretoria, que, por sua vez, desempenha função executiva.”

302. Destarte, o conselho de administração só poderia intervir na conduta da diretoria diante de uma evidente *red flag*. De modo a reforçar essa condição, abordou o princípio da confiança na dogmática penal, em que também se reconhece a impossibilidade de os órgãos deliberativos revisarem todos os atos dos órgãos que



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

cooperam entre si com divisão de funções, salvo se houver justificada desconfiança, bem como citou julgado desta CVM que decidiria nessa mesma toada.

303. A defendente afirmou existir, com base no que foi exposto, um direito do conselho administração em confiar nas informações elaboradas pelos profissionais da Companhia, de modo que a deliberação teria sido legítima, visto que pautada em relatórios gerenciais providos pela diretoria executiva e pelas demais instâncias de gestão.

304. Quanto às políticas de controle interno, a defendente, enquanto membro do conselho de administração, teria demonstrado seu comprometimento em diversas ocasiões:

- a) na reunião de 11.08.2008, diante do relatório de não-conformidades nos sistemas de controle interno elaborado pelo comitê de auditoria, o conselho de administração teria feito questionamentos ao presidente da Companhia e determinado que a diretoria executiva apresentasse proposta de Plano de Ação com relação ao aumento de não-conformidades na contratação na Companhia;
- b) na reunião de 13.04.2009, o conselho de administração, ao ouvir as recomendações do comitê de auditoria em relação às necessárias melhorias na estrutura de *compliance* da Companhia, teria discutido a questão, tendo o presidente da Petrobras, em seguida, esclarecido que o assunto já era tratado na revisão do sistema de gestão da Companhia e seria submetido ao conselho assim que concluído;
- c) ainda na reunião de 13.04.2009, o gerente geral de controles internos da unidade financeiro-corporativo teria apresentado a política e diretrizes de controles internos, elaborada em conformidade ao deliberado na reunião de 11.08.2008. Na ocasião, os conselheiros teriam sido informados da implantação de ações para remediar as falhas internas e do cumprimento das exigências de controladoria previstas na legislação norte-americana.
- d) na reunião de 20.10.2009, tendo em vista que as medidas adotadas não tinham sido suficientes para solucionar os problemas de controle interno, o conselho de administração teria indagado o Presidente da Companhia sobre a questão, o qual se comprometeu a apresentar as medidas tomadas nas diferentes áreas por diretoria para sanar as não-conformidades.

305. Nesse sentido, a defendente afirmou que, contrariamente ao que supõe a Acusação, suas decisões foram informadas, refletidas e desinteressadas, tendo agido na forma da lei e dentro de suas competências. Com efeito, o presidente da Companhia teria sido instado a prestar esclarecimentos sobre a implementação das correções, posto



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

que tal correção era de sua atribuição e não do conselho de administração. O conselho de administração deveria apenas deliberar para que as correções fossem implementadas.

306. Adicionalmente, arguiu que o prazo para a conclusão dos trabalhos pelas diretorias também era razoável, visto se tratar de uma Companhia de grande porte, além das dificuldades inerentes à própria implementação de regras de *compliance*. A defendente teria deixado de compor o conselho de administração cerca de um semestre depois da deliberação datada de 20.10.2009, prazo esse que impossibilitaria a caracterização de uma possível omissão.

307. Discordou da tese constante na peça acusatória quanto às supostas falhas existentes na política de diretrizes de controles internos, pois, a seu ver, a notícia de irregularidades na Petrobras após a sua implementação não implicaria, necessariamente, na sua inépcia. Na verdade, não houve sequer alguma comprovação, por parte da Acusação, de que a política aprovada não teria surtido efeito.

308. Destacou que, à época dos fatos, *compliance* ainda seria muito embrionário e possuiria grandes dificuldades em sua implementação. No caso, o desenvolvimento da prática somente teria ocorrido após duas circunstâncias específicas: a Lei nº 12.846/13 (Lei Anti-Corrupção) e a Operação Lava-Jato.

V.2.2. FRANCISCO ROBERTO DE ALBUQUERQUE, GUIDO MANTEGA, JORGE GERDAU JOHANNPETER, LUCIANO GALVÃO COUTINHO, SERGIO FRANKLIN QUINTELLA, SILAS RONDEAU CAVALCANTE SILVA

309. Francisco Roberto de Albuquerque, Guido Mantega, Luciano Galvão Coutinho, Sérgio Franklin Quintella e Silas Rondeau Cavalcante Silva apresentaram defesa conjunta que, em razão da similaridade entre os argumentos apresentados, será tratada conjuntamente com a defesa de Jorge Gerdau Johannpeter.

V.2.2.1. *PRELIMINAR*

310. Inicialmente, os defendentes suscitaram a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva desta Autarquia, tendo em vista que o Processo CVM nº RJ2014/12184, instaurado em 20.10.2014, não teria consistido em ato inequívoco quanto à apuração das supostas irregularidades a eles imputadas. A esse respeito, destacaram o PAS CVM nº 23/05, o qual se assemelharia ao presente processo, já que, embora a investigação tenha se iniciado antes da consumação do prazo prescricional, esta teria se dado de modo genérico, de modo que o fato específico teria sido investigado apenas após o término desse prazo, motivo pelo qual o Colegiado teria concluído pela prescrição.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

311. No caso em tela, o Processo CVM nº RJ2014/12184 teria sido instaurado para apurar fatos envolvendo a Operação Lava-Jato, o que não poderia interromper o prazo regular dos fatos específicos envolvendo a conduta dos defendentes: a suposta ratificação da passagem à fase IV do projeto RNEST e a atuação quanto aos controles internos da Petrobras.

312. Outrossim, tampouco a instauração do Inquérito Administrativo nº 14/2014 poderia figurar como causa interruptiva do prazo prescricional, porque tal inquérito teria como objeto eventuais irregularidades relacionadas à possível inobservância de deveres fiduciários da Companhia, não especificando, por conseguinte, os fatos ora em análise.

313. Com efeito, a causa interruptiva da suposta infração relacionada à passagem de fase teria sido a instauração do presente Inquérito Administrativo nº 05/2016 em 24.03.2016, o qual se destinou à apuração de possíveis irregularidades envolvendo o projeto RNEST. Nada obstante, nem mesmo referido inquérito poderia ensejar a interrupção da contagem do prazo prescricional quanto à temática dos controles internos, visto que não teria sido objeto de análise e investigação no curso de seu andamento.

V.2.2.2. *MÉRITO*

314. Os defendentes afirmaram ter cumprido com o dever de diligência, posto terem seguido os preceitos previstos pelo instituto: atuação pautada na boa-fé e no interesse social e conforme suas competências definidas na lei, no estatuto social e nos regulamentos internos da Companhia. No caso, não haveria de se falar em falta do dever de diligência pela ratificação da passagem do projeto RNEST à fase IV, pois, como bem reconhecido pela própria Acusação, o conselho de administração não deliberaria a respeito de avaliações ou passagens de fase de projeto de investimento.

315. Com efeito, o estatuto social da Companhia teria previsto funções distintas para o conselho de administração e para a diretoria: aquele seria responsável por definir os parâmetros de investimentos sob uma perspectiva macro, enquanto esta estabeleceria as oportunidades comerciais a serem aproveitadas dentro de tais linhas estratégias e comerciais pré-definidas. Nesse contexto, os projetos da Sistemática Corporativa seriam de atribuição da diretoria, a qual ficaria responsável, também, por seu planejamento, aprovação, execução e acompanhamento.

316. Desse modo, considerando que o conselho de administração não teria competência para aprovar, nem ratificar aprovações realizadas por outras esferas da Companhia de passagens de fase dos projetos de investimento, aduziram os defendentes que a apresentação feita do projeto RNEST ao conselho de administração em



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

17.12.2009 teria sido apenas uma explanação do investimento, na qual não teria sido tomada nenhuma decisão, mas apenas emitida orientações gerais ao corpo de diretores para a condução do negócio.

317. Os defendentes apresentaram, ainda, indícios que comprovariam que, naquela ocasião, os administradores não teriam ratificado referida passagem de fase, quais sejam: (i) a ata da reunião não teria feito qualquer alusão a uma possível revisitação da decisão tomada pela diretoria; e (ii) as matérias que eram deliberadas pelo conselho de administração seriam expressamente mencionadas nas atas das reuniões, sendo o principal indicativo disso a utilização da expressão “o conselho de administração aprovou (...)”. Além disso, o fato de as passagens às fases II e III, aprovadas pela diretoria, não terem sido submetidas ao conselho de administração comprovariam a desnecessidade de o conselho ratificá-las.

318. A SPS teria, inclusive, reconhecido ter sido a diretoria executiva a responsável pela aprovação da passagem do projeto à fase IV ao indagar a Renato Duque, então diretor, o porquê de seu voto ter sido favorável à proposta na reunião de 25.11.2009. A própria ata desta reunião teria expressamente anotado a decisão de autorizar a execução do empreendimento, isto é, a aprovação da fase IV.

319. Outrossim, o também ex-diretor Paulo Roberto Costa teria confirmado, em delação premiada, que o conselho de administração não teria ingerência sobre as questões operacionais dos projetos de investimento da Petrobras.

320. Superada a questão referente à suposta ratificação da passagem de fase pelo conselho de administração, os defendentes teceram comentários sobre os possíveis sinais de alertas existentes na citada apresentação. Destacaram, de início, o cuidado que se deve ter ao analisar fatos depois de já conhecidos os resultados, visto que um olhar contaminado por fatos posteriores poderia influenciar um julgamento imparcial sobre as circunstâncias fáticas da época.

321. Aduziram os defendentes que os pontuais problemas indicados na peça acusatória consistiriam, naquele momento, em problemas individualizados e circunstanciais, os quais possuiriam inclusive, planos de saneamento. Assim, não haveria de se falar em uma sistemática de erros recorrentes.

322. O plano estratégico 2020 e a aprovação de negócios 2009-2015 teriam estabelecido medidas que otimizariam o projeto, reduzindo os custos do programa de investimentos da Companhia. Ainda assim, mesmo diante de diversas ações promovidas a fim de diminuir os gastos, uma estimativa de orçamento exata seria impossível dada a complexidade e as dificuldades do empreendimento.

323. Sobre as premissas supostamente irregulares utilizadas para o novo cálculo do VPL, os defendentes afirmaram serem adequadas. Com efeito, a perpetuidade seria



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

regular quando da análise de vida de um projeto de investimento; a potencial perda de mercado teria sido objeto de estudo da Estratégia Corporativa considerando seus riscos para a Petrobras; e a perspectiva de obtenção de novos benefícios tributários teria sido considerada a partir de reuniões realizadas com os órgãos governamentais para negociar sua obtenção. Ressaltaram, ainda, que essas premissas teriam sido adotadas como fatores de sensibilidade, conforme recomendado.

324. Em que pese a ausência de sinais de alertas e de indícios de irregularidades dentro da Companhia, destacaram os defendentes que, depois de discutido o projeto, solicitaram que a matéria retornasse para análise posterior. Não obstante, não teria havido, naquela ocasião, motivo suficiente para ensejar a interrupção do empreendimento, o qual, conforme já mencionado, seria de fundamental relevância para o parque de refino nacional.

325. Como argumento adicional, salientaram que o documento que possuiria as informações relativas aos riscos do projeto teria sido elaborado pela diretoria encarregada do empreendimento. Citando precedentes deste Colegiado e da doutrina estrangeira, os defendentes aduziram ter direito de confiar nesses dados, pois estes não possuiriam qualquer sinal suspeito.

326. Considerando a tecnicidade dos estudos e a reputação profissional dos diretores, não haveria razão para desconfiança quanto aos materiais apresentados. Na verdade, seria de entendimento consolidado que o conselho de administração não teria competência para fiscalizar minuciosamente cada ato de competência da diretoria.

327. Sobre a aprovação dos aportes de capital na refinaria, afirmaram ter sido situação completamente típica, tendo em vista que a refinaria não estaria finalizada e operando, ou seja, não produziria receitas advindas da execução de suas atividades de refino. Por conseguinte, o aporte de capital para o término da construção da RNEST teria sido medida mais que razoável.

328. Por fim, alegaram que o aporte não teria destoado da orientação do conselho para redução dos custos dos projetos de investimento da Companhia, uma vez que a orientação estabeleceria a redução de gastos com projetos de acordo com a fase em que estes se encontravam, mas não o impedimento de realização de aportes.

329. No que se refere à suposta omissão quanto aos controles internos da Petrobras, sustentaram, em primeiro lugar, se tratar de uma acusação residual e genérica, em razão não se ter a exata definição e identificação da conduta ilícita cometida. No caso, a Acusação não teria especificado quando os defendentes teriam sido passivos e omissos, limitando-se a definir um determinado período de tempo, de modo que o exercício do direito de ampla defesa e contraditório restaria prejudicado.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

330. Arguiram, ainda, que a sanção de uma conduta não definida claramente nos autos implicaria na aplicação de responsabilidade objetiva, responsabilidade essa que não encontra azo na esfera sancionadora. Sobre o tema, apresentaram dois julgados do Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, no qual os acusados teriam sido absolvidos pela ausência de comprovação de sua participação nos ilícitos em questão, bem como destacaram doutrina penal que também estabelece a impossibilidade de aplicação da pena com base na responsabilidade objetiva nos processos administrativos punitivos.

331. Além disso, os defendentes sustentaram que a adequação dos controles internos de uma Companhia envolveria uma evolução contínua e gradual, de modo que o espaço delimitado pela Acusação – qual seja, de outubro de 2009 a março de 2010 – seria insuficiente para averiguar se as irregularidades estariam sendo aprimoradas ou não.

332. O tempo delimitado pela Acusação, então, não seria suficiente para verificar o êxito da política de controles internos, haja vista que sua aprovação teria ocorrido apenas em 13.04.2009. No caso, alegaram que a evolução e melhoria dos controles internos, em uma companhia do porte da Petrobras, envolvem grandes esforços, como a disseminação de princípios e regras aos funcionários e a inserção e/ou alteração de novos sistemas de autorizações e aprovações.

333. Em seguida, afirmaram ter tomado outras medidas efetivas para a correção do problema, qual seja: (i) na reunião de 20.10.2009, teriam solicitado à diretoria o detalhamento, por área, das medidas destinadas ao tratamento das não-conformidades reportadas pelo comitê de auditoria na nota de 20.10.2009; e (ii) na reunião de 30.10.2010, teriam analisado e aprovado o plano anual de auditoria interna, depois de verificados aspectos de eficiência, eficácia e economia, bem como de conformidade às normas e legislações aplicáveis em diversas áreas da Petrobras.

334. Dessa maneira, os controles internos da Petrobras teriam sido acompanhados pelos conselheiros a partir do trabalho conjunto com a auditoria interna e com o comitê de auditoria, o qual elaborava relatórios trimestrais reportando as deficiências e a evolução dos trabalhos de aprimoramento para o conselho.

335. No caso em tela, não se poderia afirmar que o reporte sobre não-conformidades pontuais pelo comitê de auditoria caracterizaria a total ineficiência e inaplicabilidade dos controles da Companhia, posto que os casos reportados não seriam fulcrais e substanciais à época dos fatos.

336. Salientaram que, entre 2007 e 2009, os trabalhos de auditoria interna teriam sido de grande volume, inclusive reforçado pelo incremento de auditores internos, o que



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

teria permitido a recuperação de valores relevantes em decorrência do tratamento de não-conformidades.

337. Por fim, concluíram que a prática sistemática de corrupção dentro da Companhia não teria sido decorrência de um sistema de controle falho, mas sim de sua manipulação por aqueles que o conheciam, de modo que nem mesmo o TCU e AGU teriam descoberto os atos ilícitos e tampouco os auditores internos teriam apontado a inconsistência do sistema operacional utilizado.

338. Indicaram, ainda, interesse em apresentar proposta de termo de compromisso, em até 30 dias da data da apresentação de sua defesa.

V.2.3. FÁBIO COLLETTI BARBOSA

339. Inicialmente, o defendente traçou breve histórico acadêmico e profissional, ressaltando os prêmios e reconhecimentos que obteve por seu desempenho em suas funções. Destacou, nesse sentido, não ter sido alvo de nenhum processo da Operação Lava-Jato e nem mesmo envolvido nas irregularidades investigadas internamente na Petrobras quanto ao projeto RNEST.

340. Além disso, o defendente sustentou que, à época dos fatos, as circunstâncias seriam distintas das atuais, de modo que, internamente, os profissionais da Companhia não teriam ciência do *modus operandi* de corrupção que havia se desenvolvido. Especificamente quanto ao projeto RNEST, este teria se demonstrado, inicialmente, como um negócio adequado e alinhado aos interesses sociais e nacionais, tendo suas principais inconsistências sido encobertas por aqueles que visavam a obtenção de vantagens indevidas para não serem descobertos.

341. Dessa maneira, citando trechos jurisprudenciais e doutrinários, atentou para o risco de análise *ex-post*, de modo que o julgador, em sua análise, deveria considerar as informações que o administrador tinha em mãos quando da tomada de decisão. Isso porque exigir outra deliberação devido às consequências advindas, sem, contudo, ter tido sinais de alertas contundentes para tal, seria aplicar um *standard* inatingível de diligência ao administrador, podendo, ainda, prejudicar a atividade econômica de um país ao desincentivar profissionais qualificados a esse cargo.

342. O defendente teceu, ainda, alguns comentários a respeito do dever de diligência a partir de diversas doutrinas, defendendo a tese de que esse dever deveria ser observado de acordo com o tempo e com o caso concreto. Em se tratando de um conselheiro, visto consistir em uma função de dedicação em tempo parcial, o dever de diligência englobaria também o direito de confiar nas informações e estudos do corpo



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

executivo, salvo quando existissem motivos que apontassem para uma irregularidade (“sinais de alerta”).

343. No caso em tela, em razão do grande porte da Petrobras, não poderia se exigir dos administradores a revisão minuciosa de cada dado apresentado pelos diretores a não ser que houvesse um sinal de alerta, sob pena de engessamento da atividade econômica. Para o defendente, os supostos indícios de irregularidades indicados pela Acusação não consistiriam em sinais de alerta consistentes, de modo que, naquelas circunstâncias, não se poderia exigir dele conduta diversa.

344. Ainda a esse respeito, preceituou que os julgadores deveriam observar a *business judgement rule*, de modo a verificar se os administradores agiram de maneira informada, de boa-fé e nos interesses da Companhia.

345. Quanto ao mérito da acusação, o defendente afirmou, primeiramente, existir um erro de premissa na peça acusatória: o conselho de administração não teria ratificado a passagem do projeto RNEST à fase IV, tendo em vista que as avaliações ou passagens de fase de projetos de investimento não seriam objeto de deliberação pelo conselho de administração.

346. Com efeito, diferentemente do alegado de que “por mais que o tema já tivesse sido deliberado pela Diretoria Executiva, buscava-se a ratificação pelo conselho, que foi concedida”, a apresentação do projeto RNEST teria sido realizada pela diretoria executiva como parte de pauta informal, não tendo sido, inclusive, registrada na ata da reunião como pauta formal, tampouco se submetido ao rito exigido às matérias a serem deliberadas. A própria Acusação teria expressado, na peça acusatória, que o “status do projeto RNEST” teria sido apresentado aos conselheiros.

347. No caso, afirmou que a lâmina 15 do PowerPoint teria induzido a erro, fazendo crer que o propósito da apresentação seria uma proposta de aprovação de passagem de fase. Não obstante, o conselho de administração não teria ratificado a aprovação – a ata da reunião, inclusive, nem faria menção a essa suposta ratificação -, mas apenas emitido orientações e determinado a reapresentação do projeto ao colegiado.

348. Arguiu o defendente que a medida tomada pelo conselho de administração de aconselhar a diretoria quanto à continuidade do projeto teria sido a mais diligente possível, haja vista que (i) em agosto de 2009, a Companhia teria emitido fato relevante de que o orçamento do projeto estaria estimado em US\$12 bilhões; (ii) a fase IV já teria sido previamente deliberada pela diretoria executiva em 25.11.2009; e (iii) a diretoria executiva já teria autorizado a celebração de contratos que montavam a quase R\$10 bilhões.

349. Sobre os supostos sinais de alerta, arguiu que estes consistiriam em sinalização evidente, qualificada e capaz de alterar o que se espera da conduta de um



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

administrador probo, que conduza sua função como se sua empresa fosse. Diferenciou, assim, esses indícios das chamadas “sensibilidades”, as quais seriam os riscos inerentes à prática da administração de empresas. Estas últimas configurariam, na verdade, fatores alternativos a cenários desfavoráveis, de modo que não se poderia falar em motivos para o cancelamento do projeto RNEST.

350. O defendente afirmou, ainda, que a apresentação feita teria tido como objetivo convencer o conselho de que as novas sensibilidades consideradas no estudo potencialmente aumentariam o VPL, tendo enumerado aspectos importantes e positivos que deveriam ser considerados para a continuidade do projeto. Reiterou, contudo, que não teria se tratado de uma deliberação formal, mas apenas uma apresentação.

351. Por último, a defesa rebateu um a um os fatos apontados como sinais de alerta pela Acusação, concluindo que tais fatos não poderiam ensejar os questionamentos considerados devidos pela SPS. Tais contrapontos podem ser assim resumidos:

- a) A parceria da Petrobras com a PDVSA teria sido tratada como uma parceria com alta probabilidade de concretização. No caso, não sendo da alçada do conselho de administração os detalhes sobre contratações e parcerias específicas em projetos de investimento, os conselheiros teriam confiado nos documentos apresentados que indicavam que as negociações entre as companhias estariam em andamento, inclusive tendo em vista que havia um memorando de entendimento firmado entre elas. Além disso, caso a sociedade não se concretizasse, a rentabilidade da RNEST seria ainda maior, de modo que não se poderia considerar a dúvida quanto à parceria um contundente sinal de alerta.
- b) A escalada de custo teria sido explicada na apresentação feita no dia 17.12.2009, cujas principais justificativas consistiriam na (a) restrição ao mercado fornecedor, que incluiria o aumento significativo dos custos de projeto de refino; (b) dificuldade na execução da terraplanagem, que implicou no aditamento de novos contratos e maiores investimentos; e (c) na complexidade na gestão de interfaces.
- c) A informação falsa divulgada nas notas explicativas de 2008, publicadas em março de 2009, não seriam de competência do conselho de administração. Ao alegar que “os conselheiros nada fizeram”, a Acusação estaria exigindo uma conduta dos conselheiros nada razoável, ainda mais porque a informação teria sido apresentada sem nenhum destaque, no corpo de uma apresentação em formato de *PowerPoint*, cujo foco estaria em justificar os problemas enfrentados pelo projeto.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

- d) O VPL desfavorável à Companhia em mais de US\$3 bilhões teria sido justificado pela diretoria executiva, que teria apresentado explicações e justificativas que pareceram convincentes para a continuidade do projeto, além de terem sido avaliados novos fatores.
- e) A não consideração do impacto das Refinarias *Premium* no projeto também não seria sinal de alerta, pois (a) o objetivo e foco da apresentação não teria sido a análise aprofundada dos VPLs, mas sim uma prestação de contas do status do projeto; e (b) a decisão de não incluir no VPL os efeitos das Refinarias *Premium* teria sido iniciativa dos elaboradores da apresentação.
- f) As novas premissas teriam sido tratadas em uma análise de sensibilidade, de forma que, caso houvesse a certeza de que elevariam de fato os VPLs, teriam sido implementadas desde o início do projeto. No caso, o uso de sensibilidades seria prática usual de mercado para avaliação da viabilidade de projetos de investimento.

352. Acerca da suposta omissão em se certificar das correções necessárias às deficiências nos controles internos, o defendente arguiu que não poderia ser responsabilizado por eventuais falhas visto que, conforme reconhecido na peça acusatória, o comitê de auditoria não seria órgão estatutário da Petrobras no período em análise.

353. Destacou que a própria Acusação teria reconhecido seu trabalho diligente enquanto presidente do comitê de auditoria. Com efeito, a partir das atas de reunião do comitê de auditoria, poderia se depreender que o defendente envidou melhores esforços para aprimorar as práticas de auditoria, tendo se reunido com os mais diversos profissionais da área, como assessores, gerentes de auditoria interna, gerentes de contabilidade, entre outros.

354. Em seguida, aduziu que não seria de competência do conselho de administração a implementação de controles internos. Não obstante, o órgão teria sido diligente, tendo em vista que (i) teria determinado que a diretoria executiva apresentasse proposta de plano de ação sobre o assunto; e (ii) que o presidente da Companhia apresentasse as medidas tomadas nas diferentes áreas.

355. O defendente argumentou, ainda, não proceder o argumento da Acusação de que, após a reunião de 20.10.2009, na qual teria sido aprovado o plano anual de atividades de auditoria, o conselho de administração não teria discutido novamente o tema. A esse respeito, afirmou que (i) não existiriam elementos fáticos que permitissem tal presunção, (ii) não teria sido indicado nexos causal entre a suposta falha de diligência no acompanhamento das medidas tomadas para resolver as não-conformidades e os



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

danos causados à Petrobras, tendo a Acusação feito uma imputação de responsabilidade absolutamente genérica e desprovida de fundamentação.

VI. DA DISTRIBUIÇÃO DO PROCESSO

356. Em reunião do Colegiado, ocorrida no dia 13.8.2019, o presente processo foi designado a mim, nos termos do art. 5º-A, § 7º, II, da Deliberação CVM nº 558/08, por conexão, considerando ter sido anteriormente sorteado para atuar na qualidade de relator dos PAS 19957.005789/2017-71 e 19957.009227/2017-04.

VII. DOS PEDIDOS DE PRODUÇÃO DE PROVAS (DOC. SEI 1078841)

357. Em reunião do Colegiado, ocorrida no dia 18.8.2020, o Colegiado da CVM apreciou os pedidos de produção de provas formulados no processo, tendo-os indeferido por terem sido formulados de forma genérica, não fundamentada, ou por não terem o condão de trazer aos autos elementos probatórios que contribuíssem para a instrução processual face ao amplo conjunto fático-probatório que já o instrui.

É o relatório.

Rio de Janeiro, 24 de agosto de 2020.

HENRIQUE BALDUINO MACHADO MOREIRA
DIRETOR RELATOR



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM Nº 05/2016

Reg. Col. nº 1404/2019

Acusados:

Almir Guilherme Barbassa
Dilma Vana Rousseff
Fábio Colletti Barbosa
Francisco Roberto de Albuquerque
Guido Mantega
Guilherme de Oliveira Estrella
Ildo Luís Sauer
Jorge Gerdau Johannpeter
Jorge Luiz Zelada
José Sérgio Gabrielli de Azevedo
Luciano Galvão Coutinho
Maria das Graças Silva Foster
Nestor Cuñat Cerveró
Paulo Roberto Costa
Renato de Souza Duque
Sergio Franklin Quintella
Silas Rondeau Cavalcante Silva

Assunto: Apurar possível inobservância de deveres fiduciários de administradores da Petrobras na construção da Refinaria Abreu e Lima. Infração aos artigos 153, 154, §2º, “c”, 155, e 163, I, da Lei nº 6.404/76.

Diretor Relator: Henrique Machado

VOTO

I. BREVE RESUMO DAS ACUSAÇÕES

1. Conforme relatado, este processo foi instaurado pela SPS¹ para apurar a responsabilidade dos administradores da Petrobras por supostamente descumprirem seus deveres fiduciários nos procedimentos relativos à construção da Refinaria Abreu e Lima - RNEST.

¹ Os termos iniciados em letra maiúscula utilizados neste voto e que não estiverem aqui definidos têm o significado que lhes foi atribuído no Relatório.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

2. Os diretores Paulo Roberto Costa e Renato Duque foram acusados de terem se beneficiado pessoalmente do cargo para obter vantagens pecuniárias indevidas de sociedades contratadas para realizar serviços de engenharia na Refinaria, em infração ao art. 154, §2º, “c”, da Lei nº 6.404/76 c/c art. 155, *caput*, da Lei nº 6.404/76.²
3. Foram acusados também os diretores Almir Barbassa, Guilherme Estrella, Ildo Sauer, Jorge Zelada, Sérgio Gabrielli, Graça Foster e Nestor Cerveró, por terem faltado com o cuidado e a diligência esperados na aprovação de etapas do projeto de construção da RNEST, em infração ao art. 153³ da Lei nº 6.404/76.
4. Guido Mantega, Fábio Barbosa, Francisco de Albuquerque, Jorge Gerdau, Luciano Coutinho, Sérgio Quintella, Sergio Gabrielli e Silas Rondeau, membros do conselho de administração da Petrobras, foram acusados de terem faltado com diligência ao consentirem com a aprovação pela diretoria da etapa de execução do projeto de construção da Refinaria, em infração ao art. 153 da Lei nº 6.404/76.
5. Os conselheiros Dilma Roussef, Guido Mantega, Fábio Barbosa, Francisco de Albuquerque, Jorge Gerdau, Luciano Coutinho, Sergio Gabrielli e Silas Rondeau foram acusados de não terem verificado correções necessárias para o bom funcionamento dos controles internos da Companhia, em violação ao dever de diligência estabelecido no art. 153 da Lei nº 6.404/76.
6. Graça Foster foi ainda acusada de desvio de poder por ter supostamente interferido indevidamente no relatório final da comissão interna de apuração da Petrobras, em infração ao art. 154, *caput*, da Lei nº 6.404/76.

II. PRELIMINARES

II.1. PRESCRIÇÃO

² Art. 154. O administrador deve exercer as atribuições que a lei e o estatuto lhe conferem para lograr os fins e no interesse da companhia, satisfeitas as exigências do bem público e da função social da empresa.

(...)

§ 2º É vedado ao administrador:

(...)

c) receber de terceiros, sem autorização estatutária ou da assembléia-geral, qualquer modalidade de vantagem pessoal, direta ou indireta, em razão do exercício de seu cargo.

Art. 155. O administrador deve servir com lealdade à companhia e manter reserva sobre os seus negócios, sendo-lhe vedado: (...)

³ Art. 153. O administrador da companhia deve empregar, no exercício de suas funções, o cuidado e diligência que todo homem ativo e probo costuma empregar na administração dos seus próprios negócios.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

7. Os acusados aduzem a prescrição da pretensão punitiva desta Comissão por entenderem que a Acusação considerou erroneamente o primeiro ato interruptivo do prazo prescricional. Afirmam que os acusados não teriam tido prévia ciência da investigação em curso, não podendo atos internos serem considerados suficientes para interromper a fluência do prazo da prescrição quinquenal. Argumentam, assim, que entre a prática dos atos reputados ilícitos pela Acusação e o primeiro ato inequívoco de apuração apto a interromper a prescrição teria transcorrido o prazo de cinco anos.

8. Também aduzem a impossibilidade de se utilizar a substituição do prazo quinquenal pelo prazo penal àquelas pessoas que não teriam sido acusadas em sede criminal, pois as condutas analisadas individualmente não constituiriam simultaneamente infração penal e administrativa. As defesas entendem que o agente deve responder pelo mesmo ato na esfera penal e administrativa, devendo a suposta infração administrativa configurar “crime em tese”.

9. As defesas alegam ainda que o prazo quinquenal relativo à suposta omissão do conselho de administração em fiscalizar os controles internos da Petrobras teria escoado, uma vez que a emissão do Ofício nº 560/2014, de **20.10.2014**, marco temporal considerado pela Acusação, não se prestaria para tal finalidade. Aduzem que o ato bastante para interromper o prazo prescricional seria aquele praticado com objetivo de investigar especificamente o fato objeto da ação punitiva, o que teria ocorrido somente em **03.06.2016**.

10. Sobre o prazo de prescrição, assim dispõem os artigos 1º e 2º da Lei nº 9.873, de 23 de novembro de 1999, que regula o prazo de prescrição para o exercício da ação sancionadora no âmbito da Administração Pública Federal:

Art. 1º Prescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração Pública Federal, direta e indireta, no exercício do poder de polícia, objetivando apurar infração à legislação em vigor, contados da data da prática do ato ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado.

§1º Incide a prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o caso.

§2º Quando o fato objeto da ação punitiva da Administração também constituir crime, a prescrição rege-se pelo prazo previsto na lei penal.
(...)

Art. 2º Interrompe-se a prescrição da ação punitiva I – pela notificação ou citação do indiciado ou acusado, inclusive por meio de edital; II - por qualquer ato inequívoco, que importe apuração do fato; III - pela decisão condenatória recorrível; IV – por qualquer ato inequívoco que



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

importe em manifestação expressa de tentativa de solução conciliatória no âmbito interno da administração pública federal.

II.1.1. ATO INEQUÍVOCO DE APURAÇÃO

11. Com relação ao termo “ato inequívoco que importe apuração do fato” contido na mencionada legislação, cabe registrar que está pacificado neste Colegiado⁴ que ele não se refere somente ao ato que instaura o processo administrativo sancionador, nem depende da prévia ciência dos acusados⁵.

12. Relata a Acusação que o início do processo de construção da RNEST se deu em fevereiro de 2005 (fls. 477 a 479), e que as aprovações do PAR e da etapa de execução do projeto ocorreram em **08.03.2007 e 25.11.2009**, respectivamente, tendo esta última decisão sido confirmada pelo conselho em **17.12.2009**.

13. As apurações no âmbito desta Autarquia começaram em **10.10.2014** por meio do Ofício nº 529/2014, por meio do qual o Superintendente de Relações com Empresas, Fernando Soares Vieira, reporta-se às matérias veiculadas naquela mesma data nos jornais O Globo, O Estado de São Paulo, Valor Econômico, entre outros,

⁴ V. PAS CVM RJ2001/0554, julgado em 23.10.2002; PAS CVM 10/2000, julgado em 8.7.2004; PAS CVM nº 22/94, julgado em 15.04.2004; PAS CVM 02/2004, julgado em 7.12.2005; PAS CVM nº RJ2005/6924, julgado em 31.10.2006; PAS CVM 14/2003, julgado em 15.5.2007; PAS CVM RJ2008/2570, julgado em 12.5.2009; PAS CVM 03/2006, julgado em 1.12.2010; PAS CVM 04/2009, julgado em 11.6.2013; PAS CVM 14/2009, julgado em 11.8.2015; PAS CVM RJ2011/11073 e RJ2010/2695, julgado em 15.12.2015; PAS CVM nº RJ2015/5002 e PAS CVM RJ2014/5807, julgado em 15.3.2016; PAS CVM 12/2013, julgado em 24.5.2016; PAS CVM nº 01/2011, julgado em 27.02.2018

⁵ Sobre o tema, o Diretor Luiz Antonio Sampaio Campos consignou, no julgamento do PAS CVM nº 22/94, de 15.04.2004, que: Merece especial atenção, no meu sentir, a hipótese constante do inciso II, do art. 2º, acima mencionado, que faz referência a ‘qualquer ato inequívoco que importe na apuração do fato’ como causa apta a ensejar a interrupção do prazo prescricional. Nesse sentido, parece-me que qualquer ato praticado pela administração pública, quando tenha por finalidade a apuração ou o esclarecimento do fato, objeto da ação punitiva, insere-se na hipótese prevista no inciso II, do art. 2º, da Lei n.º 9.873/99, desde que seja inequívoco. Dentre esses fatos, por certo se enquadram as diligências, a oitiva de pessoas, inclusive como testemunhas, indiciados ou informantes, a troca, ou a solicitação de informações a outros órgãos ou à Bolsa de Valores, e tudo o mais que leve a apurar um fato, um ato ilícito e buscar os seus responsáveis. Na mesma direção é excerto da decisão proferida pela MM. Juíza da 14ª Vara Federal do Rio de Janeiro ao indeferir pedido de antecipação de tutela que buscava justamente suspender, em razão de alegada prescrição, processo sancionador instaurado por esta Comissão: O citado art. 2º, II, da Lei nº 9.873/99 estabelece que se interrompe a prescrição ‘por qualquer ato inequívoco, que importe apuração do fato’, não se exigindo o conhecimento pessoal da parte investigada. A menção ao pronome indefinido ‘qualquer’ denota a intenção do legislador em incluir como causa interruptiva da prescrição os atos, indiscriminadamente, destinados à apuração dos fatos supostamente irregulares, independente da ciência do interessado. Se o legislador quisesse condicionar a interrupção do prazo prescricional à prévia comunicação ao interessado da prática de um ato de investigação, teria estabelecido redação semelhante a do inciso ‘I’.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

acerca das denúncias de corrupção na Petrobras e solicita à Companhia manifestação quanto (i) ao teor das informações divulgada, (ii) as medidas já adotadas e (iii) as medidas que pretende adotar sobre o assunto. Trata-se de ato inequívoco de apuração protagonizado pela SEP que, frise-se, o realizou no mesmo dia em que as primeiras informações sobre as irregularidades foram divulgadas ao público.

14. Aliás, importa destacar também que a tempestiva investigação iniciada pela SEP ocorreu em estreita conformidade com os procedimentos ordinários de apuração adotados por aquela superintendência no âmbito da Supervisão Baseada em Risco, que incluem o acompanhamento das notícias divulgadas ao público. De fato, no Plano Biental 2013/2014⁶ constava expressamente as ações previstas e os resultados delas esperados:

Ações Gerais e Resultados Esperados

Para cumprir os mandatos legais de proteger os investidores contra atos irregulares, garantir o acesso à informação adequada e fiscalizar e punir atos irregulares, a CVM, em sua atividade de acompanhamento e fiscalização de empresas, realiza duas grandes ações gerais, descritas abaixo juntamente com os resultados esperados:

a) Acompanhamento das informações periódicas e eventuais divulgadas ao mercado pelas companhias, verificando sua disponibilização oportuna e sua qualidade, de modo a possibilitar a tomada de decisão pelo investidor de forma refletida.

b) Acompanhamento da atuação dos administradores e acionistas controladores das companhias, verificando a observância do respeito às leis e normas societárias e aos direitos dos acionistas, de modo a fortalecer a confiança dos investidores no mercado.

(...)

O resultado esperado para a segunda ação geral está sujeito ao evento de risco:

4. Existência de irregularidades nas propostas e decisões da administração, nas deliberações em assembleias gerais e na condução dos negócios por parte dos controladores e órgãos de administração.

15. As diligências da área técnica evoluíram para, em **20.10.2014**, a instauração do Processo RJ-2014/12184, origem do inquérito administrativo nº 14/2014, posteriormente desmembrado em outros inquéritos, a bem da eficiência administrativa e da duração razoável do processo, e a emissão também em **20.10.2014** do Ofício nº 560/2014, pelo qual a SEP requereu da Petrobras esclarecimentos sobre atos de corrupção envolvendo o diretor de abastecimento da Petrobras Paulo Roberto Costa e

⁶ Acessível em: http://www.cvm.gov.br/menu/acesso_informacao/planos/sbr/bienio_2013_2014.html.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

um doleiro (fls. 32-45). Mais do que isso, considerando as apurações internas realizadas pela Petrobras para investigar os fatos revelados pela imprensa, a área técnica requereu, por meio do referido ofício, cópia do relatório final daquelas apurações.

16. Em **13.11.2014**, a Petrobras encaminhou relatório sobre os procedimentos de contratação de serviços da RNEST elaborado pela comissão interna de apuração (fls. 46 e seguintes), trazendo à luz diversas não-conformidades. Assim manifestou-se a companhia em seu ofício capeador:

Em atendimento ao ofício em epígrafe, a PETROBRAS, companhia de capital aberto com sede na Avenida República do Chile nº 65, Rio de Janeiro/RJ, vem, por intermédio de seu Diretor Financeiro e de Relações com Investidores, encaminhar os seguintes relatórios:

1 - Processo de aquisição da Refinaria de Pasadena; 2 – contratos celebrados com a Astromarítima Navegação S.A.; 3 – contratos celebrados com a Ecoglobal Ambiental Comércio e Serviços Ltda.; 4 – Irregularidade no cadastro junto à Petrobras da empresa Sanko-Sider Comércio, Importação e Exportação de Produtos Siderúrgicos Ltda.; **5 – procedimentos de contratação para a implantação da RNEST**; e 6 – procedimentos de contratação para a implantação do COMPERJ.

Tão logo as demais Comissões forem concluindo seus trabalhos, enviaremos cópias dos relatórios finais.

17. A documentação enviada pela Companhia, a partir dos ofícios enviados pela CVM, é subsídio direto das diligências complementares e das acusações tratadas neste processo administrativo sancionador, conforme facilmente se percebe dos autos deste processo e do relatório de inquérito.

18. Assim, como se observa, desde a sua atuação pró-ativa no âmbito da Supervisão Baseada em Risco, atos inequívocos de apuração foram realizado com a emissão de ofícios pela área técnica, **em 10.10.2014 e 20.10.2014**, que deflagraram as investigações e iniciaram a obtenção de informações relevantes, que, ao final, deram causa à instauração do presente processo sancionador. Ambos os ofícios, portanto, representam atos praticados com o evidente intuito de investigar as irregularidades reveladas pela Operação Lava Jato, aptos, assim, a interromper o prazo prescricional, na forma da legislação de regência.

II.1.2. PRAZO DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL

19. Noutro ponto, tem-se que a aprovação do PAR pela diretoria (**08.03.2007**) deu-se em prazo superior ao prazo quinquenal ordinariamente estabelecido na Lei nº 9.873/99, que regula o prazo de prescrição para o exercício da ação sancionadora no



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

âmbito da Administração Pública Federal. Como visto, a Lei nº 9.873/99 estabelece, como regra geral, que prescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração Pública Federal no exercício do poder de polícia, objetivando apurar infração à legislação em vigor, contados da data da prática do ato ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado (art. 1º).

20. O comando legal, entretanto, não foi olvidado pela Acusação. A peça acusatória cita que, se o fato objeto da pretensão punitiva da Administração também configurar crime, o prazo prescricional será regulado pela lei penal, consoante expressamente disposto no §2º do art. 1º da Lei referida. Entende a Acusação que essa seria a hipótese dos autos, pois os fatos ora apurados constituiriam, a um só tempo, infração à legislação que regula as sociedades anônimas abertas, sujeitas à fiscalização da CVM, e às normas penais, atraindo, em consequência, o prazo prescricional previsto na lei penal.

21. Argumenta que o processo de contratação de serviços para a construção da RNEST mediante notório favorecimento de sociedades de engenharia e prestadoras de serviços diversos, além de caracterizar a conduta penalmente tipificada pelo art. 317⁷ do Código Penal, em exame nos autos da Ação Penal nº 5036528-23.2015.4.04.7000/PR, também configura violação aos deveres impostos pela lei societária aos administradores de companhias abertas.

22. Neste passo, e considerando que o prazo prescricional penal é de 16 (dezesseis) anos, a teor do que dispõe o inciso II do art. 109⁸ do Código Penal, seria perfeitamente possível o exercício da pretensão sancionadora também na via administrativa. Destaca ainda que a atração do prazo prescricional penal para a seara administrativa se daria, inclusive, em relação àqueles que não foram acusados na esfera penal, porquanto a prescrição de que trata a Lei nº 9.873/99 seria fenômeno que se conecta com fatos, e não com pessoas, motivo pelo qual se autoriza sua interrupção no momento em que é iniciada a apuração do fato, independentemente do conhecimento, ou não, de sua autoria.

23. A controvérsia jurídica que permeia esta questão foi tratada com profundidade e ineditismo no julgamento dos PAS CVM nº 19957.009805/2019-66 e nº 19957.009824/2019-92, em 16.12.2019, nos quais se apurou irregularidades relativas às

⁷ Art. 317 - Solicitar ou receber, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida, ou aceitar promessa de tal vantagem: Pena – reclusão, de 2 (dois) a 12 (doze) anos, e multa.

⁸ Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1o do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se: (...) II - em dezesseis anos, se o máximo da pena é superior a oito anos e não excede a doze;



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

contratações de navios-sonda pela Petrobras. Nesta oportunidade, trago aos autos as razões do voto que proferi naquela assentada.

II.1.2.1. A REGRA GERAL DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA (ART. 1º, CAPUT, DA LEI Nº 9.873/99)

24. Sobre o assunto, destaco inicialmente que a Lei nº 9.873/99, fruto da conversão de uma série de medidas provisórias editadas em sequência à Medida Provisória nº 1.708, de 30 de junho de 1998, é um importante marco na regulamentação da prescrição da ação punitiva e do exercício do poder de polícia no âmbito da Administração Pública Federal. A par da imprescritibilidade não ser a regra no ordenamento jurídico brasileiro, a ausência de expressa regulamentação ensejava ampla discussão em sede doutrinária e jurisprudencial, em detrimento do princípio da segurança jurídica que deve reger as relações jurídicas, dentre as quais aquelas entre a Administração Pública e o cidadão.

25. Após a promulgação da Lei nº 9.873/99, a regra geral do prazo de prescrição para o exercício da ação punitiva pela Administração Pública Federal restou expressamente prevista em seu art. 1º, *caput*, que estabeleceu prazo como sendo de cinco anos contados da data da prática do ato ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado a infração. Assim, a lacuna normativa foi superada por regra geral que apresenta dois elementos objetivos que guiam o decurso temporal para o exercício da pretensão punitiva, a saber, o prazo prescricional (cinco anos) e o termo inicial de sua contagem (data da prática do ilícito).

26. Percebe-se, ainda, que a regra de prescrição não autoriza outros elementos informadores para a sua caracterização. Não autoriza, por exemplo, que o reconhecimento da prescrição dependa da existência de processo judicial ou das pessoas envolvidas na apuração e tampouco estabelece qualquer gradação em razão da gravidade em tese dos ilícitos apurados. Aliás, no âmbito de atuação desta Comissão de Valores Mobiliários, tanto as infrações de natureza grave quanto as de menor gravidade, tanto as infrações de natureza dolosa quanto as culposas, submetem-se ao mesmo prazo quinquenal. A pretensão punitiva sobre infrações decorrentes de abuso de poder de controle, por exemplo, submete-se ao mesmo prazo de infrações decorrentes da não divulgação de informações periódicas⁹.

⁹ O juízo da CVM quanto à diferença entre a gravidade em abstrato dessas condutas orientou o Anexo 63 da Instrução CVM nº 607, de 17 de junho de 2019, de forma que o valor máximo da pena-base pecuniária para a infração por não divulgação de informações periódicas (Grupo I) é R\$ 300.000,00 e a para a infração de abuso de poder de controle (Grupo V) é R\$ 20.000.000,00.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

II.1.2.2. DA SUBSTITUIÇÃO DO PRAZO QUINQUENAL

27. A Lei nº 9.873/99 trouxe relevante exceção ao prazo quinquenal. Nos termos de seu art. 1º, §2º, o prazo de cinco anos deve ser substituído pelo prazo previsto na lei penal. Transcreve-se:

Art. 1º Prescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração Pública Federal, direta e indireta, no exercício do poder de polícia, objetivando apurar infração à legislação em vigor, contados da data da prática do ato ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado.

(...)

§ 2º Quando o fato objeto da ação punitiva da Administração também constituir crime, a prescrição reger-se-á pelo prazo previsto na lei penal.

28. Por um lado, a racionalidade dessa previsão justifica-se em função de que, se o fato investigado no âmbito da Administração Pública também tem repercussão em sede penal, demonstrando, por isso, que sua ocorrência é considerada de tamanha gravidade que mereça a reprimenda criminal, há interesse da sociedade em prolongar o prazo durante o qual a administração deve buscar a punição dos infratores. Aplica-se, em certa medida, a própria teoria da prescrição em matéria penal.

29. Por outro lado, a substituição do prazo quinquenal é justificada pelo fato de que a persecução penal é comumente subsidiada pelos esforços investigativos realizados pelos diversos órgãos administrativos. No âmbito do mercado de valores mobiliários, considerando a especificidade e a complexidade dos atos e negócios realizados, a atuação do Ministério Público Federal e da Polícia Federal é amplamente fomentada pelas áreas técnicas da CVM, seja por meio da comunicação de crime, seja pela atuação coordenada em operações específicas. Nesse contexto, a padronização dos prazos prescricionais em sede administrativa e criminal permite que os esforços investigativos conjuntos perdurem enquanto persistir a pretensão punitiva estatal.

30. No mesmo sentido, ao analisar o dever legal do Banco Central do Brasil (“BCB”) de comunicar a existência de crimes ao Ministério Público, assim me manifestei¹⁰ na primeira edição da revista jurídica da Procuradoria-geral do Banco Central (“PGBCB”):

Uma vez que os dados obtidos pela área de fiscalização do BC muito frequentemente comprovam ou auxiliam a comprovação de crimes no âmbito do SFN e diante do crescente prejuízo que esses ilícitos

¹⁰ Revista da Procuradoria-Geral do Banco Central. – Vol. 1, n. 1 (dez. 2007), pg.185/212. *O Dever Legal do Banco Central de Informar a Ocorrência de Crimes e o Poder Requisitório do Ministério Público*. Brasília: BCB, 2007.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

infligem à sociedade brasileira, dentre as hipóteses de transferência do sigilo bancário previstas pela LC 105/2001 está a comunicação entre o Banco Central e o Ministério Público, na forma descrita pelo artigo 9º dessa norma complementar.

O Banco Central deve, portanto, transferir ao Ministério Público as informações sigilosas que já detém em razão de suas atribuições, quando verificar a ocorrência de crime, ou indício de crime, sujeito à ação penal pública. Isso para cooperar com o ente público responsável pela persecução penal e titular da ação penal pública no combate a crimes como lavagem de dinheiro, gestão temerária, evasão de divisas etc.

Dados do Banco Central demonstram sua significativa colaboração com o Ministério Público, principalmente nos últimos dez anos, período em que foram realizadas aproximadamente novecentas comunicações por ano. A principal incidência é de crimes conhecidos por “crimes do colarinho branco”, como desvio de recursos e evasão de divisas.

31. O Relatório de Atividade Sancionadora desta Comissão de Valores Mobiliários também destaca que o art. 9º da Lei Complementar nº 105/01 e o art. 13, I, da ICVM nº 607/19 estabelecem que a CVM deve comunicar o Ministério Público quando, no exercício de suas atribuições, verificar a ocorrência de crime definido em lei como de ação pública, ou indícios da prática de tais crimes. A CVM também mantém, desde 2008, Termo de Cooperação com o Ministério Público Federal para prevenção e combate a ilícitos no mercado de capitais e intercâmbio de informações.

32. Dentre os crimes ordinariamente comunicados estão aqueles tipificados na Lei nº 6.385/76, quais sejam a manipulação de mercado (art. 27-C), o *insider trading* (art. 27-D) e o exercício irregular de cargo, profissão, atividade ou função (art. 27-E), bem como a oferta pública de valores mobiliários sem registro na CVM (art. 7º, II, da Lei nº 7.492/86), crimes contra a economia popular (esquemas de pirâmide) e o estelionato (art. 171 do Código Penal).

33. Quanto à constitucionalidade da substituição do prazo quinquenal, a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal reconhece a aplicação do prazo prescricional penal, em processo administrativo, quando o fato for tido como crime. Cite-se, como exemplo, o julgamento de Recurso Ordinário em Mandado de Segurança nº 33.858, de relatoria da Ministra Carmen Lúcia, DJe nº 255/2015:

Ementa. Recurso Ordinário em Mandado de Segurança. Processo Administrativo Disciplinar. Pena de demissão. Fato capitulado como crime. Prescrição punitiva estatal. Prazo fixado a partir da lei penal (art. 142, § 2º, da Lei nº 8.112/1990). Precedentes. Recurso ordinário em mandado de segurança ao qual se nega provimento.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

34. Em outra decisão sobre a matéria, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, no Mandado de Segurança nº 35631, DJe nº 248/2018, o Pretório Excelso assim assentou o seu entendimento:

Embargos de declaração recebido como agravo interno. Impugnação específica evidenciada. Desnecessidade de intimação para complementar as razões. Inteligência do art. 1.024, § 3º, do CPC. Mandado de Segurança impetrado contra ato do CNMP. Conduta que caracteriza infração administrativa e penal. Legitimidade da aplicação do prazo prescricional da lei penal, independentemente de instauração de procedimento na esfera criminal. Observância ao art. 244, parágrafo único, da LC 75/93. Precedentes. Alegada atipicidade da conduta. Necessidade de reexame fático-probatório. Impossibilidade na via mandamental. Ilegalidade ou abuso de poder não caracterizados. Embargos de declaração recebidos como agravo interno, ao qual se nega provimento.

II.1.2.3. DA INDEPENDÊNCIA FACE AO PROCEDIMENTO NA ESFERA CRIMINAL

35. Como já destacado anteriormente, a Lei nº 9.873/99 não traz qualquer requisito de prévio ajuizamento de ação judicial para a caracterização do prazo prescricional, nem na regra geral nem no dispositivo que trata da substituição do prazo quinquenal. Estabeleceu-se, entretanto, pertinente discussão quanto a quem competiria definir que os fatos objetos de apuração administrativa constituiriam crime: à autoridade administrativa, ao Ministério Público ou ao Judiciário.

36. O Ministério Público por meio da investigação e da coleta de dados, quando vislumbrar a prática de conduta penalmente tipificada por norma, deverá apresentar ao Poder Judiciário a competente ação penal pública, buscando a repressão da criminalidade pela condenação judicial. O MP exerce, pois, por expressa determinação constitucional, a convicção sobre a existência de justa causa para a propositura da ação penal pública (*opinio delicti*). É ele quem averigua a pertinência e a relevância das provas obtidas para o ajuizamento ou não da ação. Ao Judiciário, por seu turno, caberá a decisão final quanto à ocorrência de crime após o devido processo legal.

37. Nada obstante, prevalece salutarmente o entendimento de que cabe à própria Administração Pública avaliar a ocorrência de crime e aplicar autonomamente a substituição do prazo quinquenal. Com efeito, da análise lógico-sistemática dos diversos dispositivos que consagram a autonomia das instâncias administrativa e penal, impende concluir que cabe à própria administração qualificar os atos sob sua investigação e concluir quanto à existência de indícios de crime e, conseqüentemente, pela aplicação da regra de substituição do prazo quinquenal.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

38. A rigor, cabendo às autoridades administrativas o poder-dever de verificar a existência de indícios de crime e de comunicar ao Ministério Público fatos que lhe pareçam configuradores de ilícitos criminais, não se compreenderia a interpretação jurídica que conduísse pela necessidade de ajuizamento de ação judicial pelo MP ou manifestação final do Poder Judiciário. No primeiro caso, a própria ação judicial poderia deixar de ser ajuizada pela ausência de investigação prévia pelo órgão administrativo. No segundo, mais grave, todo o processo penal não se beneficiaria da atuação especializada de diversos órgãos, além do evidente risco de que eventual demora na prestação jurisdicional impedisse materialmente a eficácia de um novo processo administrativo sobre os mesmos fatos.

39. Ademais, exigir correlação prévia e direta entre a investigação administrativa e o ajuizamento de processo penal violaria princípio geral de direito que garante a segurança jurídica das relações entre a Administração Pública e os cidadãos, pois ambos têm interesse na previsibilidade e estabilidade da atuação administrativa. Nesse contexto, a prescrição administrativa não pode depender de evento futuro e incerto, qual seja, o ajuizamento de ação penal (ou o recebimento da denúncia e até mesmo a condenação criminal).

40. Nesse sentido, é ampla a jurisprudência¹¹ do Supremo Tribunal Federal, valendo destaca o seguinte julgado:

EMENTA: I. – Processo administrativo disciplinar: renovação. Anulado integralmente o processo anterior dada a composição ilegal da comissão que o conduziu – não, apenas, a sanção disciplinar nele aplicada -, não está a instauração do novo processo administrativo vinculado aos termos da portaria inaugural do primitivo. II. – Infração disciplinar: irrelevância, para o cálculo da prescrição, da capitulação da infração disciplinar imputada no art. 132, XIII – conforme a portaria de instauração do processo administrativo anulado -, ou no art. 132, I – conforme a do que, em consequência se veio a renovar -, se, em ambos, o fato imputado ao servidor público – recebimento, em razão da função de vultosa importância em moeda estrangeira - caracteriza o crime de corrupção passiva, em razão de cuja cominação penal se há de calcular a prescrição da sanção disciplinar administrativa, independentemente da instauração, ou não, de processo penal a respeito. (Mandado de Segurança n. 24.013/DF, Redator para o acórdão o Ministro Sepúlveda Pertence, Plenário, DJ 1.7.2005)

¹¹ Mandado de Segurança n° 23.242/SP, Rel. Ministro Carlos Velloso, j. em 10/4/2002; Recurso Ordinário em Mandado de Segurança n° 30.965/DF, Rel. Ministra Carmem Lúcia, Segunda Turma, DJe 26.10.2012; Agravo Regimental no Recurso Ordinário em Mandado de Segurança n° 31.506/DF, Rel. Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 26.3.2015.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

41. No mesmo diapasão, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o seu entendimento em recente decisão exarada pela Primeira Seção daquele egrégio tribunal:

ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE. CONDOTA TAMBÉM TIPIFICADA COMO CRIME. PRESCRIÇÃO. CÓDIGO PENAL. PENA EM ABSTRATO. OBSERVÂNCIA.

1. A contagem prescricional da ação de improbidade administrativa, quando o fato traduzir crime submetido a persecução penal, deve ser pautada pela regra do Código Penal, em face do disposto no inciso II do art. 23 da Lei n. 8.429/1992 e no § 2º do art. 142 da Lei n. 8.112/1990.

2. Se a Lei de Improbidade Administrativa (art. 23, II), para fins de avaliação do prazo prescricional, faz remissão ao Estatuto dos Servidores Públicos Federais (art. 142, § 2º) que, por sua vez, no caso de infrações disciplinares também capituladas como crime, submete-se à disciplina da lei penal, não há dúvida de que "a prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, [...] regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime", conforme expressa disposição do art. 109, *caput*, do Estatuto Repressor.

3. Deve ser considerada a pena in abstrato para o cálculo do prazo prescricional, "a um porque o ajuizamento da ação civil pública por improbidade administrativa não está legalmente condicionado à apresentação de demanda penal. Não é possível, desta forma, construir uma teoria processual da improbidade administrativa ou interpretar dispositivos processuais da Lei n. 8.429/92 de maneira a atrelá-las a institutos processuais penais, pois existe rigorosa independência das esferas no ponto... A dois (e levando em consideração a assertiva acima) porque o lapso prescricional não pode variar ao talante da existência ou não de ação penal, justamente pelo fato de a prescrição estar relacionada ao vetor da segurança jurídica." (REsp 1.106.657/SC, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 20/09/2010).

4. Embargos de divergência desprovidos.

(EDv nos EREsp 1656383/SC, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 27/06/2018, DJe 05/09/2018)

42. O Tribunal Regional Federal da 2ª Região também se manifesta sobre a matéria no mesmo sentido do STF e do STJ, valendo citar o seguinte julgado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMPROBIDADE. RECEITA FEDERAL. FAVORECIMENTO ILÍCITO. RECEBIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. FUNDAMENTAÇÃO. PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA.

(...)

5. No tocante à alegada prescrição, considerando que as condutas narradas pelo MPF, imputadas à agravante, também são tipificadas como ilícito criminal, é aplicável à espécie o comando contido no art.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

142, I, §2º da Lei nº 8.112/90 e art. 109, II do Código Penal, haja vista que, conforme apontou o Juízo a quo, "os fatos narrados pelo MPF também se encontram tipificados no Código Penal, artigos 288, 317 e 333", que apresentam pena máxima, em abstrato, de 12 (doze) anos de reclusão.

6. Dessa forma, segundo as regras do art. 109, *caput*, do Código Penal, embora tenha sido prolatada sentença absolutória nos autos da ação penal, por ausência de provas, aplica-se, ao caso, a pena máxima prevista para o crime enquanto não houver sentença final transitada em julgado.

(...)

8. Agravo de instrumento desprovido.

(Agravo de Instrumento 0003078-77-2018.4.02.0000, Rel. ALCIDES MARTINS, 5ª TURMA ESPECIALIZADA, julgado em 12/07/2018, DJe 16/07/2018)

43. Por fim, considerando a similaridade das atribuições em sede sancionadora, trago a colação o entendimento do Conselho Administrativo de Defesa Econômica ("CADE") no julgamento do processo administrativo nº 08012.004674/2006-50, na forma do voto vogal do Presidente Alexandre Barreto de Souza:

Entendo que, em uma interpretação literal da lei de prescrição administrativa, realmente não há essa exigência posta pelo legislador. Não quer dizer que a Autoridade Administrativa é quem vá definir o que é crime ou não, extrapolando sua competência, mas a interpretação do texto da lei é clara: cartel é crime. Até que o Judiciário apresente entendimento contrário, por exemplo, julgando inconstitucional referida norma, não vejo porque complicar toda a análise da prescrição, incluindo uma série de variáveis, para, ao final, chegar a uma conclusão que, para mim, vai diretamente contra a vontade do legislador.

Por fim, entendo que a jurisprudência não é algo irretocável, mas certamente que deve ser considerada, a fim de não gerar insegurança jurídica, o que normalmente causa efeitos muito negativos para a sociedade. Assim, um entendimento do Conselho que vise a alterações na sua jurisprudência deve ser sopesado pelos seus efeitos negativos, e, se realmente entender necessário, que se faça essa alteração. Sobre esse tema, não vislumbro justificativa, em termos de benefícios para a sociedade, que justifique o custo de uma mudança de entendimento jurisprudencial dessa magnitude. Muito pelo contrário.

Concluindo, entendo que tanto por uma interpretação literal quanto por uma interpretação sistemática do art. 1º, §2º, da Lei nº 9.873/99, bem como pela importância de se observar a jurisprudência desse Conselho, voto pela rejeição da prejudicial de mérito referente ao prazo prescricional.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

44. Assim, entendo que o artigo 1º, §2º, da Lei nº 9.873/99, somente exige que o fato apurado constitua crime e não impõe que haja persecução criminal quanto ao mesmo fato que enseja a responsabilização administrativa. É, portanto, prescindível, para fins de substituição do prazo quinquenal a propositura de ação penal ou decisão do Poder Judiciário.

II.1.2.4. DA PRESCRIÇÃO EM RELAÇÃO AOS FATOS E, NÃO, AOS SUJEITOS.

45. Perquire-se neste ponto se o prazo prescricional de que trata o artigo 1º, §2º, da Lei nº 9.873/99, se refere aos fatos apurados em sede administrativa ou aos sujeitos que praticam o tipo criminal. Em outras palavras, perquire-se se a substituição do prazo quinquenal seria aplicável tão somente aos sujeitos que praticam o crime ou se seria aplicável aos fatos objetos de apuração e, portanto, a todos que incorrerem em infração administrativa relativa àqueles fatos.

46. Para o deslinde desse ponto, recorrerei a algumas regras de interpretação jurídica¹². A primeira é que o intérprete, na busca da extração do sentido do conteúdo da norma jurídica, deve afastar a exegese que conduz ao vago e ao inexplicável. Outra regra hermenêutica de amplo conhecimento diz que onde a lei não distingue não deve o intérprete distinguir. Por fim, não menos conhecida é a máxima de que a lei não contém palavras inúteis (*verba cum effectu sunt accipienda*). Conforme pontua Carlos Maximiliano¹³:

Não se presumem, na lei, palavras inúteis. (...) Devem-se compreender as palavras como tendo alguma eficácia. As expressões do Direito interpretam-se de modo que não resultem frases sem significação real, vocábulos supérfluos, ociosos, inúteis (...) porém a verdade é que sempre se deve atribuir a cada uma a sua razão de ser, o seu papel, o seu significado, a sua contribuição para precisar o alcance da regra positiva. (...) Dá-se valor a todos os vocábulos e, principalmente, a todas as frases, para achar o verdadeiro sentido de um texto; porque este deve ser entendido de modo que tenham efeito todas as suas provisões, nenhuma parte resulte inoperativa ou supérflua, nula ou sem significação alguma.

(...) Não se presume a existência de expressões supérfluas; em regra, supõe-se que leis e contratos foram redigidos com atenção e esmero; de sorte que traduzam o objetivo dos seus autores. Todavia é possível, e não muito raro, suceder o contrário; e na dúvida entre a letra e o espírito, prevalece o último. Quando, porém, o texto é preciso, claro o sentido e o inverso se não deduz, indiscutivelmente, de outros

¹² MONTEIRO, Washington B. “Curso de Direito Civil. Vol. I.” SP: ed. Saraiva, 2012, p. 43.

¹³ MAXIMILIANO, Carlos. “Hermenêutica e Aplicação do Direito. RJ: Forense, 20ª ed., 2011, p. 204/205.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

elementos de Hermenêutica, seria um erro postergar expressões, anular palavras ou frases, a fim de tornar um dispositivo aplicável a determinada espécie jurídica: *interpretatio in quacum que dispositione ne sic facienda ut verba non sint superflua, et sine virtute operandi*: Interpretem-se as disposições de modo que não pareça haver palavras supérfluas e sem força operativa.

47. É necessário reconhecer que a expressa redação do dispositivo legal em comento não apresenta qualquer termo que permita analisar a incidência da prescrição com base nos sujeitos infratores e, não, nos fatos apurados. Novamente, onde a lei não distingue não deve o intérprete distinguir.

48. Ao contrário, o artigo 1º, §2º, da Lei nº 9.873/99, é ainda mais claro em sua intenção de delimitar a prescrição aos fatos e, não, aos sujeitos infratores. Assim, é que a mencionada norma faz referência ao fato objeto de apuração administrativa e, não, à que as infrações administrativas tenham idêntica capitulação legal. Ao contrário, por exemplo, da Lei nº 8.112/90 que expressamente estabelece que as infrações disciplinares sejam também capituladas como crime.

Lei nº 9.873/99

Art. 1º Prescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração Pública Federal, direta e indireta, no exercício do poder de polícia, objetivando apurar infração à legislação em vigor, contados da data da prática do ato ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado.

(...)

§ 2º Quando o fato objeto da ação punitiva da Administração também constituir crime, a prescrição rege-se-á pelo prazo previsto na lei penal.

Lei nº 8112/90

Art. 142. A ação disciplinar prescreverá:

(...)

§ 2º Os prazos de prescrição previstos na lei penal aplicam-se às infrações disciplinares capituladas também como crime.

49. Mais do que isso, ainda me reportando às regras de hermenêutica, não pode o intérprete alegar imprecisão da norma de modo a concluir que ela quis dizer aquilo que efetivamente não disse. Tampouco pode o intérprete, sob os auspícios do princípio jurídico da proporcionalidade, “completar” a norma a fim de reparar-lhe o “erro”. O famoso brocardo (“a lei não contém palavras inúteis”) é corolário do princípio da legalidade.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

50. Assim, independentemente do juízo do intérprete quanto à proporcionalidade do prazo prescricional, não posso abonar a interpretação segundo a qual o legislador ao dizer “o fato objeto” quis dizer “o fato típico, antijurídico e culpável”. *Data maxima venia*, a interpretação correta do dispositivo deve guardar maior robustez do liame entre a interpretação e o texto legal.

51. Com efeito, a interpretação do disposto no §2º do 1º da Lei nº 9.873/99 no sentido de que a substituição do prazo quinquenal seria aplicável apenas ao autor da conduta descrita no tipo criminal não se coaduna com as regras de hermenêutica jurídica, tendo, por isso, consequências deletérias e indesejadas pelo legislador.

52. Perceba-se, por exemplo, que o prazo para o exercício da pretensão punitiva em relação às infrações administrativas de manipulação de mercado, *insider trading*, exercício irregular de atividade, oferta pública de valores mobiliários sem registro na CVM, crimes contra a economia popular (esquemas de pirâmide), estelionato, entre outros, seria drasticamente reduzido quando praticadas por pessoa jurídica. Afinal, pessoas jurídicas não praticam crime¹⁴.

53. Nesse mesmo exemplo, tal interpretação levaria ao resultado de que os prazos prescricionais aplicáveis às pessoas físicas e jurídicas, na investigação e punição administrativas no âmbito do mercado de valores mobiliários, seriam injustificadamente diferentes e contrários à lógica do *enforcement* conduzido por esta Autarquia, destacadamente nos casos em que as infrações são praticadas por pessoa jurídica interposta. Além disso, afigura-se ameaça à segurança jurídica na medida em que investigações e julgamentos poderiam ocorrer em momentos distintos apesar da inevitável conexão fática.

54. Noutro ponto, verifica-se ainda que a circunscrição da substituição do prazo quinquenal aos autores do tipo criminal acarretaria ineficiência administrativa e redução da disciplina no mercado de valores mobiliários. Isto porque, mesmo após a utilização de recursos humanos e orçamentários voltados à apuração dos fatos, com a consequente identificação de diversos ilícitos administrativos a eles relativos, a autoridade do mercado de capitais estaria impedida de punir os agentes que não executassem a conduta descrita no tipo criminal, ainda que as infrações restassem sobejamente demonstradas.

55. É exatamente o que ocorre no presente caso. Tendo a área técnica da CVM analisado o contexto fático em que se perpetrou o crime de corrupção passiva, deparou-se com robusto conjunto probatório da ocorrência de violação do dever de diligência dos administradores da Petrobras. Mais do que isso, é possível inclusive questionar se as aprovações e omissões em exame nestes autos teriam ocorrido em detrimento da

¹⁴ Exceto as condutas lesivas ao meio ambiente, nos termos do art. 225, §3º, da Constituição Federal.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

Companhia se os acusados tivessem sido diligentes, não apenas no ato das respectivas deliberações, mas também na adoção de regras de governança do colegiado proporcionais à maior companhia aberta brasileira.

56. Por oportuno, considerando a minha experiência como supervisor do sistema financeiro e do mercado de capitais, reporto a minha incredulidade quanto à premissa implícita na tese de que as áreas técnicas dos órgãos administrativos estejam, ou mesmo devam estar, aptas a realizar juízo quanto às excludentes de antijuridicidade penal a fim de avaliar a ocorrência ou não da prescrição administrativa. É evidente que aquelas áreas devem ter concluído pela existência de indícios de crime, e inclusive reportá-los ao Ministério Público, mas não se deveria impor sofisticação jurídica mais compatível com o juízo exauriente a cargo dos órgãos que compõem a justiça criminal. Entendo ser devida certa modulação na transposição de institutos de Direito Penal.

57. Sobre o assunto, verifico que a doutrina e a jurisprudência ainda não se manifestaram especificamente sobre o ponto em discussão. Entendo, nada obstante, que os julgados sobre a matéria percutam a questão em exame e efetivamente se prestam a demonstrar a adequada interpretação jurídica.

58. Em linha com o entendimento esposado neste voto, é a sentença do Juízo da 15ª Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal no julgamento do Mandado de Segurança nº 49189-15.2010.4.01.3400, cujo excerto pertinente ao tema em discussão segue reproduzido abaixo:

Em primeiro lugar, o texto legal apenas exige que o fato objeto da ação punitiva da Administração também constitua crime. Não menciona nem a necessidade de procedimento criminal já instaurado, nem a necessidade de que o sancionado administrativamente seja também passível de sanção penal.

Ao contrário, apenas exige que o fato que configura infração administrativa seja também tipificado penalmente. Como essa tipificação penal indica que se trata de bem jurídico de especial importância, há necessidade de maior proteção não só na esfera penal, mas também na administrativa.

A não aplicação à pessoa jurídica dessa regra, salvo quando se tratar de infração ao meio ambiente, pois somente nesse caso essa poderia cometer crime (ser sujeito ativo), tiraria toda a carga axiológica do disposto no parágrafo segundo do artigo 1º da Lei nº 9.873/99, passando a punição administrativa a representar nesses casos mero adereço da sanção penal.

De outro lado, a determinação contida no parágrafo 5º do artigo 173 da Constituição também afasta o argumento trazido pelo impetrante:



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

“A lei, sem prejuízo da responsabilidade individual dos dirigentes da pessoa jurídica, estabelecerá a responsabilidade desta, sujeitando-a às punições compatíveis com sua natureza, nos atos praticados contra a ordem econômica e financeira e contra a economia popular”.

Também a propositura de ação penal ou a existência de inquérito penal são prescindíveis para que a regra do parágrafo segundo do artigo 1º da Lei nº 9.873/99 seja aplicada. Como as esferas criminal e administrativa são independentes, para tanto basta uma análise (e a devida fundamentação) da autoridade sancionadora de que o fato objeto da ação punitiva da Administração também constitui crime.

59. O Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional no âmbito do Recurso nº 11.969, j. em 21.10.2014, já manifestou seu entendimento de que a prescrição da pretensão punitiva é fenômeno que se vincula aos fatos e, não, aos sujeitos autores do crime.

A questão aqui não gira em torno da possibilidade de ser a pessoa jurídica punida criminalmente, limitando-se a lei a prever a utilização do prazo prescricional do direito penal quando o fato também constituir crime. Não se faz, portanto, análise subjetiva, mas sim objetiva quanto ao fato. E não poderia ser diferente, já que, ao meu ver, a prescrição refere-se ao fato e não a pessoas. (...) Dessa forma, considerando que, pelo meu entendimento, a prescrição refere-se, ao fato, e não à pessoa, ainda que eventualmente adote-se o entendimento de que pessoa jurídica não possa responder criminalmente por seus atos, o prazo a lhe ser aplicado deverá ser o mesmo daquele previsto para o fato criminoso, de forma objetiva. Por esse motivo, entendo não estar prescrita a pretensão punitiva em relação à pessoa jurídica” (371ª Sessão, Processo BCB 0101148656, julgado em 21.10.2014).

60. Também o CADE, por oportunidade da análise da prescrição em relação às pessoas jurídicas participantes de cartel, realizou análise semelhante quanto ao assunto, como se percebe do voto vogal proferido pelo Conselheiro Paulo Burnier da Silveira, no julgamento do Processo Administrativo nº 08700.001859/2010-31, *in verbis*:

Objeto de apuração vs. autoria do ilícito

Percebe-se que o 2º requisito mencionado – apuração na esfera penal – se refere ao objeto da apuração, e não a sua autoria. E aqui reside talvez a principal divergência em relação à tese que sustenta a prescrição quinquenal.

No caso ora em exame, a Conselheira-Relatora entendeu que o prazo prescricional de 12 (doze) anos para ilícitos administrativos de cartéis só se aplicaria *in casu* às pessoas físicas, já que, para as pessoas jurídicas, não haveria crime passível de apuração.

No entanto, a jurisprudência do STJ se refere ao objeto, isto é, à materialidade dos ilícitos que podem ser perquiridos



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

concomitantemente nas esferas administrativa e penal – e não propriamente à autoria. A própria redação do §2º do art. 1º da Lei nº 9.873/99 deixa claro que a aplicação do prazo prescricional da lei penal se dá quando há coincidência em relação ao “*fato objeto da ação punitiva da Administração*”.

O *telos* da norma é evitar que haja processos paralelos de apuração de ilicitude – nas esferas administrativa e penal – com prazos prescricionais distintos.

É por esse motivo que não se exige identidade exata nos polos passivos do processo administrativo e do processo criminal. De fato, não faria sentido considerar a prescrição de 5 anos para pessoas físicas que eventualmente constassem no polo passivo do processo do CADE, mas não constassem, por qualquer motivo que seja, no polo passivo do processo criminal. A Lei nº 9.873/99 e a jurisprudência do STJ não exigem exame de autoria para fins de aferição da prescrição, bastando a mera apuração da sua materialidade.

Prescrição de 12 (doze) anos para pessoas jurídicas

Além disso, sustentou-se que a inexistência de previsão criminal quanto às pessoas jurídicas obstaria a incidência do prazo de prescrição de 12 (doze) anos. Respeitosamente, permito-me também registrar minha divergência deste entendimento.

Mais uma vez, destaca-se que o elemento central é o “*fato objeto da ação punitiva da Administração*” (Lei nº 9.873/99, art. 1º, §2º). Nesse sentido, parece-me irrelevante o fato das pessoas jurídicas não serem passíveis de responsabilização penal, para fins de contagem da prescrição.

61. Aliás, este Colegiado já se manifestou mais de uma vez no sentido de que o conteúdo jurídico do termo “fato” na Lei nº 9.873/99 não é idêntico à “conduta” ou “infração”. Ou seja, na verificação da incidência ou não da prescrição da pretensão punitiva devem ser considerados os fatos objetos de apuração e, não, as condutas ou infrações praticadas pelos sujeitos. Esse é expressamente o entendimento¹⁵ que externei no voto proferido por oportunidade do julgamento do PAS nº 13/2014, de 5 de novembro de 2019, aprovado por unanimidade:

Cumprir destacar ainda que o ato inequívoco, descrito no inciso II do art. 2º da Lei nº 9.873/99, refere-se à apuração de fatos e não de pessoas, na medida em que, somente após os esforços de apuração, é

¹⁵ Esse foi também meu entendimento ao acompanhar o voto condutor do julgamento do PAS nº RJ2015/9443, de 4 de junho de 2019, segundo o qual a apuração de determinados fatos é suficiente para interromper a prescrição de todas as infrações a eles relacionadas, pois “com base nos fatos investigados são então identificadas as infrações cometidas e a participação das pessoas nas infrações apuradas, para que, então, identificadas materialidade e autoria, se promova a acusação”. A interrupção da prescrição atingiria inclusive condutas autônomas, desde que praticadas no mesmo contexto fático.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

possível à área técnica firmar sua convicção a respeito da existência da irregularidade e de seus autores, bem como da precisa definição do ilícito à luz da legislação de regência.

62. Assim, em ambos os julgamentos acima mencionados, o entendimento é de que o termo “fato” contido no art. 2º, II, da Lei nº 9.873/99 não pode ser compreendido como “conduta”, “infração” ou “fato típico, antijurídico e culpável” e não se vincula aos sujeitos. Essa é exatamente a mesma conclusão a que se deve chegar a partir da interpretação lógico-sistemática do art. 1º, §2º, da Lei nº 9.873/99. Transcrevo os dispositivos:

Lei nº 9.873/99

Art. 1º Prescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração Pública Federal, direta e indireta, no exercício do poder de polícia, objetivando apurar infração à legislação em vigor, contados da data da prática do ato ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado.

(...)

§ 2º Quando o fato objeto da ação punitiva da Administração também constituir crime, a prescrição reger-se-á pelo prazo previsto na lei penal.

Art. 2º Interrompe-se a prescrição da ação punitiva:

I - pela citação do indiciado ou acusado, inclusive por meio de edital;

I – pela notificação ou citação do indiciado ou acusado, inclusive por meio de edital;

II - por qualquer ato inequívoco, que importe apuração do fato;

63. Entendo, assim, que a jurisprudência desta comissão compreende o termo fato contido na Lei nº 9.873/99 como o contexto fático no qual se realiza a apuração das infrações administrativas e, não, como o fato jurídico objeto do Direito Penal.

64. Noutro ponto, impende também ter presente que a proporcionalidade do prazo prescricional é juízo de competência do legislador, que o define nos termos da Lei. A própria premissa de que o prazo prescricional deve ser proporcional à gravidade do ilícito, conquanto válida, é dirigida ao legislador e, não, ao intérprete, cabendo àquele a sua positivação em norma.

65. No Direito Positivo, são inúmeros os exemplos de que a gravidade e o prazo prescricional não obedecem a uma correlação automática ou necessária. No âmbito de atuação desta Comissão de Valores Mobiliários, como já destacado, tanto as infrações de natureza grave quanto as de menor gravidade, tanto as infrações de natureza dolosa quanto as culposas, submetem-se ao mesmo prazo quinquenal. Infrações administrativas



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

relativamente singelas, como o atraso na entrega de informações periódicas, têm prazo prescricional superior a crimes, como o peculato culposo.

66. Assim, independentemente do meu juízo pessoal quanto à proporcionalidade ou não do prazo prescricional previsto na Lei nº 9.873/99, compete-me analisar a incidência ou não da hipótese legal, razão pela qual também não acolho os argumentos de que o prazo previsto na lei penal seria desproporcional às infrações em exame no presente processo.

67. Por tais razões, entendo que a substituição do prazo quinquenal pelo prazo da lei penal, de que trata o artigo 1º, §2º, da Lei nº 9.873/19, aplica-se a todas as infrações administrativas que simultaneamente decorram dos fatos apurados e dos quais verifica-se a ocorrência de crime, porquanto à prescrição da pretensão punitiva administrativa é fenômeno que se vincula aos fatos e não aos sujeitos da conduta criminosa.

II.1.2.5. ANÁLISE DA PRESCRIÇÃO NO CASO CONCRETO

68. Por tais razões, a substituição do prazo quinquenal pelo prazo da lei penal é aplicável às infrações administrativas decorrentes do fato singular consistente na aprovação do PAR, pela qual se materializaram as contratações espúrias objeto da mencionada ação penal, motivo por que tem repercussão penal e administrativa. E com base na sanção penal em abstrato, nos termos do artigo 109, II, c/c artigo 317, ambos do Código Penal, o prazo prescricional da pretensão punitiva administrativa no presente caso é de 16 anos.

69. Do mesmo modo, a substituição do prazo quinquenal pelo prazo de 16 anos também se aplica às aprovações da mudança de fase da RNEST realizadas pela diretoria, **em 25.11.2009**, e pelo conselho de administração, **em 17.12.2009**, a despeito de não ter transcorrido sequer o prazo superior ao prazo quinquenal ordinariamente estabelecido na Lei nº 9.873/99. Isso ocorre, pois, é a partir dessas deliberações que as contratações previamente acertadas puderam se concretizar, permitindo, por consequência, o pagamento adrede combinado de propinas a administradores da Petrobras e a outros agentes públicos. E, como visto, a presença de fato que pode constituir, em tese, infração penal e administrativa ao mesmo tempo, impõe-se a aplicação do prazo prescricional penal, por força do art. 1º, §2º, da Lei nº 9.873/99.

70. Não merece melhor sorte a tese das defesas de que a emissão do Ofício nº 560/2014, de **20.10.2014**, pela SEP não seria ato de investigação apto a interromper a prescrição da suposta omissão do conselho em fiscalizar os controles internos da Petrobras, cuja reunião destacada pela SPS para respaldar a sua tese acusatória ocorreu em **20.10.2009**, pelas razões já destacadas neste Voto. Entre as informações contidas na



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

resposta da Companhia àquela diligência estão as inúmeras não-conformidades nas contratações da RNEST que foram relatadas nos achados de auditoria reportados ao conselho de administração.

71. Deste modo, forçoso reconhecer que a conduta autônoma e distinta do conselho de administração no exame do assunto se deu no mesmo contexto fático das apurações relativas à contratação de serviços mediante fraude na RNEST, motivo pelo qual aquela primeira diligência é suficiente para interromper a prescrição das infrações dela derivadas.

72. Após a expedição desse ofício inaugural pela SEP, sobrevieram outros atos interruptivos da prescrição punitiva desta CVM, conforme prevê o art. 2º da Lei nº 9.873/19, a demonstrar que a investigação seguiu seu regular curso. Neste sentido, cabe consignar, em resumo, os seguintes atos de apuração: (i) a emissão do MEMO/CVM/SEP/GEA-3/Nº018/2014, de 18.12.2014, propondo a abertura de inquérito administrativo para aprofundar as investigações (fls. 12-30); (ii) o despacho de instauração do inquérito administrativo, de 26.12.2014 (fls. 10); (iii) a emissão do Ofício CVM/SPS/Nº 046/2015, em 23.01.2015, autorizando inspeção na sede da Petrobras (fls. 273); (iv) a intimação de diversas pessoas da Companhia para prestar informações em 22.11.2016 (fls. 2.921-2.930); (v) a oitiva de vários dos acusados em 27.01.2017 (fls. 2.991-3.000); e (vi) apresentação do relatório de inquérito administrativo em 07.12.2018 (fls. 5.595-5.716). Já na fase sancionadora¹⁶, os Acusados foram citados para apresentarem defesa em 21.12.2018 (fls. 5.736 a 5.752).

73. Todos esses atos inequívocos de investigação interromperam o prazo prescricional, sendo que, em nenhum momento entre eles, transcorreu intervalo superior a cinco anos. Rejeito, portanto, os argumentos das defesas e voto pelo não acolhimento da preliminar de prescrição da pretensão punitiva desta CVM.

II.1.3. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE

74. Também não verifico no presente processo a ocorrência da prescrição intercorrente, cujo prazo é de três anos, nos termos do §1º do art. 1º da Lei nº 9.873/1999. Conforme entendimento consolidado deste Colegiado¹⁷, a prescrição

¹⁶ Nos termos do art. 21 da Instrução CVM nº 607, de 17 de junho de 2019, “[c]onsidera-se instaurado o processo administrativo sancionador com a citação dos acusados para apresentação de defesa”.

¹⁷ V. PAS CVM nº 22/1994, Diretor-Relator Luiz Antonio de Sampaio Campos, j. 15.04.2004; PAS CVM nº 11/2002, Diretora-Relatora Luciana Dias, j. 26.02.2013; PAS CVM nº 08/2012, Diretora-Relatora Ana Novaes, j. 16.12.2014; PAS CVM nº 23/2010, Diretor-Relator Roberto Tadeu Antunes Fernandes, j. 04.11.2014; PAS CVM nº RJ2010/3695, Diretor-Relator Pablo Renteria, j. 15.12.2015; PAS CVM nº 11/2013, Diretor-Relator Gustavo Machado Gonzalez, j. 30.01.2018; PAS CVM nº



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

intercorrente somente é aplicável a partir do momento em que estiver instaurado o processo administrativo sancionador, isto é, depois da intimação dos acusados para apresentação de defesa. Nesses julgados, também se consolidou o entendimento de que atos que impulsionam o processo têm o condão de interromper o prazo prescricional de três anos, inclusive os de mero expediente, consoante entendimento igualmente ratificado pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região¹⁸.

75. O processo administrativo sancionador começou em 21.12.2018, quando os acusados foram intimados a apresentar defesa, iniciando-se a partir daí a fluência do prazo de três anos da prescrição intercorrente. Esse prazo, contudo, foi interrompido pela distribuição dos autos, por meio de despacho emitido em 13.08.2019 pela Secretaria Executiva da Presidência (fls. 6.155), para minha relatoria, a demonstrar a existência de ato expedido para impulsionar o processo administrativo em direção à sua conclusão, apto a interromper, por isso, a prescrição intercorrente.

76. Assim, não se observa a fluência de prazo superior a três anos desde o referido despacho e a realização do presente julgamento. Afasto, portanto, a incidência da prescrição intercorrente no presente processo.

II.2. AUSÊNCIA DE PARECER DA PROCURADORIA FEDERAL ESPECIALIZADA

77. O acusado Nestor Cerveró alega a nulidade do presente processo em razão de a Procuradora Federal Especializada junto à CVM – PFE não ter emitido, antes da intimação dos acusados para apresentação de defesa, opinião a respeito da regularidade

RJ2003/2759, Diretor-Relator Henrique Balduino Machado Moreira, j. 20.02.2018; PAS CVM nº 18/2013, Diretor-Relator Henrique Balduino Machado Moreira, j. 08.05.2018.

¹⁸ Vale transcrever o acórdão na íntegra: “Processo Administrativo. ANP. Prescrição Intercorrente. Art. 1º, §1º, Lei 9.873/99. inócurrenre. I - Inicialmente, cumpre trazer à colação o teor do art. 1º, § 1º, da Lei n.º 9.873/99, o qual dispõe que ‘incide a prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho1. II - Em sendo assim, instaurado o procedimento administrativo, caso a Administração deixe o mesmo pendente de julgamento ou despacho por mais de três anos, forçoso será reconhecer a prescrição da pretensão punitiva. III - In casu, pela análise dos documentos acostados aos autos, não se depreende que o procedimento administrativo ora em análise ficou paralisado desde a autuação, pendendo de julgamento ou despacho por mais de três anos. IV - Destarte, cumpre destacar que, quando a Administração pratica atos que impulsionam o processo, ainda que seja despacho de mero expediente, não estará caracterizada a inércia da mesma, não havendo, portanto, que se falar em prescrição intercorrente a que se refere o artigo 1º, § 1º, da Lei nº 9.873/99 V - Remessa Necessária e Apelação da ANP providas” (TRF da 2ª Região, Sétima Turma Especializada, Processo n. 2004.5101.0140181, Rel. Des. Reis Friede, j. 02.03.2011).



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

formal da peça acusatória, conforme determina o artigo 9º da Deliberação CVM nº 538/2008¹⁹.

78. Ocorre, entretanto, que presente processo sancionador foi precedido de inquérito administrativo, fase investigativa na qual participam da instrução do feito a SPS e a PFE, conforme regras previstas nos arts. 5º e 6º da mencionada Deliberação, vigente à época dos fatos. Diferentemente do procedimento estabelecido para os termos de acusação, quando a PFE emite parecer sobre a regularidade dos requisitos formais da peça acusatória elaborada pelas superintendências dessa CVM, o inquérito administrativo prescinde de tal opinião jurídica, porquanto a PFE participa diretamente da elaboração da própria peça acusatória.

79. Por tal razão, não acolho a preliminar.

II.3. INÉPCIA DA ACUSAÇÃO, NÃO INDIVIDUALIZAÇÃO DAS CONDUTAS E ILEGITIMIDADE PASSIVA

80. Vários acusados alegam que a Acusação não demonstrou a participação de cada qual nos atos considerados ilícitos ou não comprovou alguma falha em seus deveres de fiscalização. Segundo afirmam, não constaria da peça acusatória a necessária individualização de suas condutas nem a demonstração de qualquer omissão intencional por parte deles sobre as supostas irregularidades.

81. As alegações não merecem acolhida.

82. O relatório de inquérito é inequívoco ao identificar todos os fatos atribuídos aos acusados, especificando notadamente as deliberações da diretoria e do conselho de administração em que cada acusado teria praticado as supostas condutas comissivas ou omissivas sobre as quais foi formulada acusação. Robusteceu sua narrativa com o resumo das oitivas tomadas dos acusados e de outros funcionários da Petrobras, para, assim, analisar em seções específicas do relatório de inquérito as diversas condutas consideradas ilícitas, com esteio em extenso conjunto probatório colacionado ao processo.

83. Concluo, portanto, que a SPS se desincumbiu de caracterizar as possíveis infrações e identificar seus possíveis autores, tendo individualizado devidamente a conduta dos acusados. Estão presentes na peça acusatória todos os elementos necessários à compreensão dos ilícitos imputados aos acusados e, por conseguinte, ao

¹⁹ Art. 9º Antes da intimação dos acusados para apresentação de defesa, a PFE emitirá parecer sobre o termo de acusação, no prazo de 30 (trinta) dias contados da data do termo de acusação, analisando objetivamente a observância dos requisitos do art. 6º e o cumprimento do art. 11.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

exercício do seu direito de defesa, não havendo que se falar, também, em inépcia da acusação.

84. Em relação à preliminar de ilegitimidade passiva arguida por Paulo Roberto Costa, com a alegação de que nunca teria participado, como diretor de abastecimento, do acompanhamento de retorno de investimentos, cuja competência seria da diretoria financeira, entendendo tratar-se de questão de mérito cujo deslinde não pode se dar em sede preliminar.

85. Portanto, pelos motivos expostos, afasto as preliminares de inépcia da acusação, não individualização das condutas e ilegitimidade passiva.

II.4. EFEITOS DOS ACORDOS DE COLABORAÇÃO PREMIADA NA COMPETÊNCIA DA CVM

86. Paulo Roberto Costa afirma que os procuradores incumbidos de atuar na operação Lava Jato enviaram o acordo de colaboração premiada firmado entre o defendente e o Ministério Público para a 5ª Câmara de Coordenação e Revisão – Combate à Corrupção por entenderem que este abarcaria eventuais repercussões no campo da improbidade administrativa, tendo sido homologado em 05.02.2015, de modo que não mais caberia qualquer pleito contra o defendente pautado em descumprimento do dever de probidade.

87. Paulo Roberto Costa declara que a 5ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal (“5ª CCR-MPF”), em sua 852ª reunião, de 5.2.2015, teria homologado, no campo da improbidade administrativa, o Acordo de Colaboração Premiada que firmou com o Ministério Público Federal envolvendo os fatos investigados na Operação “Lava Jato”, de modo que não caberia qualquer pleito contra o defendente em razão do descumprimento do dever de probidade.

88. De fato, consta da ata da referida reunião o recebimento de ofício encaminhado por Procurador da República para análise e homologação de acordos firmados no âmbito da Operação “Lava Jato”, embora a ata não traga as partes envolvidas em tais acordos. A ata registra “*que as disposições da nova Lei 12.846, de 2013, compõem um microsistema sancionatório estabelecendo o acordo de leniência como ferramenta de solução extrajudicial no campo da responsabilização de índole civil, na linha do que já prevê a Lei 12.850, de agosto de 2013, na esfera penal*”, e que, em função disso, a Câmara resolveu homologar, no campo da improbidade administrativa, os acordos encaminhados por meio do mencionado ofício.

89. Em vista disso, Paulo Roberto Costa aduz que seria incabível qualquer pleito contra ele no presente PAS, pois as imputações a que responde – artigos 153, 176



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

e 177, §3º, da Lei nº 6.404/76, e artigos 14 e 26, I, da Instrução CVM nº 480/2009 – estariam inseridas no âmbito da improbidade administrativa.

90. Não procede, no entanto, a argumentação do acusado.

91. Sobre esse ponto, destaco inicialmente o voto da Procuradora Mônica Nicida Garcia, exarado em 1.9.2016, ao apreciar, na própria 5ª CCR-MPF, o Acordo de Leniência envolvendo ilícitos na contratação de navios-sonda para a Petrobras. A procuradora, citando a decisão tomada na supramencionada 852ª reunião da Câmara, reconheceu em seu voto que o MPF vinha admitindo a celebração de acordos que envolviam a atenuação ou mesmo a não aplicação das sanções previstas na Lei nº 8.429/1992, conhecida como Lei da Improbidade Administrativa.

92. Nos termos do mencionado voto, “[n]ão faria, mesmo, sentido que o Ministério Público, titular da ação penal e da ação de improbidade, pudesse celebrar acordos em uma seara e não em outra.”

93. Acrescento, nesse aspecto, que, em vista da necessidade de não comprometer a efetividade dos acordos de colaboração ali apreciados, a 5ª CCR-MPF, em sua decisão 5.2.2015, delimitou os termos pelos quais a homologação aprovada naquela data passaria a repercutir seus efeitos no âmbito da improbidade administrativa:

a) formulação de pedidos declaratórios de sujeição das condutas praticadas às hipóteses normativas da Lei nº 8429/92; b) abstenção de pleito judicial no tocante às sanções previstas no art. 12 do citado diploma legal, considerando as cominações e as consequências na esfera penal, decorrentes dos acordos de colaboração premiada e das ações penais propostas; c) em caso de quebra do acordo firmado, o MPF pleiteará a aplicação das sanções correspondentes aos atos de improbidade praticados.

94. A par da expressa previsão no acordo de que a colaboração premiada produziria efeitos inclusive sobre a propositura pelo MPF de ação de improbidade administrativa relativa aos fatos descritos na transação, não é possível extrair dessa constatação qualquer repercussão quanto ao trâmite do presente processo administrativo. Primeiro porque o acordo de delação premiada não foi celebrado com a Comissão de Valores Mobiliário, mas com o Ministério Público Federal, que estabeleceu restrições a sua própria competência legal para o ajuizamento de ações de natureza criminal ou civil, não havendo qualquer decisão que expressamente alcance ou restrinja o dever desta comissão de investigar e punir em sede administrativa as infrações que tiver conhecimento no âmbito do mercado de valores mobiliários.

95. Os efeitos da colaboração premiada devem respeitar as balizas do acordo homologado em juízo. No caso vertente, além desta autarquia não ter sido alcançada pelos efeitos da transação, verifica-se que uma eventual condenação pelas infrações de



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

que é acusado – ao art. 154, §2º, c) c/c art. 155, *caput*, da Lei nº 6.404/76 –, não prejudicam nem infirmam as cláusulas do acordo de delação premiada. Ao contrário, independentemente da convicção que seja alcançada por esta comissão, as repercussões criminais e em sede de ação de improbidade administrativa, continuarão sendo restringidas pela transação realizada com o *parquet* e homologada em juízo.

96. Além disso, no caso concreto, examina-se o reflexo dos fatos tratados no acordo de delação premiada no âmbito meramente administrativo e à luz dos deveres fiduciários impostos aos administradores de companhias, em especial o dever de lealdade, pela Lei nº 6.404/76, o que não representa caracterização da prática de improbidade administrativa, reservada ao Poder Judiciário.

97. De tudo o exposto, concluo que a decisão da 5ª CCR-MPF, em sua 852ª reunião, no que tange ao Acordo de Colaboração Premiada firmado pelo acusado com o Ministério Público Federal, não atinge as infrações administrativas aqui apuradas e não elide a competência legal da CVM para impor a ele, nos termos do art. 11²⁰ da Lei nº 6.385/76 sanções contra a eventual infração aos art. 154, §2º, c) c/c art. 155, *caput*, da Lei nº 6.404/76.

98. Rejeito, portanto, a preliminar arguida.

III. MÉRITO

99. A RNEST surgiu, em 14.02.2005, como projeto conjunto da Petrobras e da companhia de petróleo venezuelana PDVSA, a partir da assinatura de um memorando de entendimentos para o desenvolvimento de negócios e atividades de cooperação no setor de refino, que tinha por objetivo atender a estratégia de processamento de petróleo do Brasil e da Venezuela (fls. 477-479). De acordo com o memorando, cada empresa teria 50% de participação na futura refinaria (fls. 471), pois elas teriam interesse comum no processamento de óleo pesado e extrapesado disponíveis em seus territórios. Naquele primeiro momento, a Petrobras previu que o valor total do investimento seria de US\$2,3 bilhões, com VPL de US\$209,9 milhões.

100. Em 29.9.2005, a diretoria aprovou a passagem do projeto para a segunda fase, também denominada de conceitual (fls. 468). Com a conclusão da etapa conceitual (fase II) no final de 2006 (fls. 1.203 a 1.223), a administração estabeleceu que a refinaria teria uma unidade de destilação atmosférica de 200 MBPD e dois trens de

²⁰ Art. 11. A Comissão de Valores Mobiliários poderá impor aos infratores das normas desta Lei, da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 76 (Lei de Sociedades por Ações), de suas resoluções e de outras normas legais cujo cumprimento lhe caiba fiscalizar as seguintes penalidades, isoladas ou cumulativamente:



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

conversão e hidrotratamento: um para o processamento de petróleo brasileiro e outro para o petróleo venezuelano.

101. Em 21.12.2006, a diretoria da Petrobras aprovou o cronograma da obra da refinaria prevendo iniciar a pré-operação no segundo semestre de 2011 (fls. 1.219 a 1.220). Para cumprir essa meta, os gerentes executivos responsáveis pelo projeto apontaram a necessidade de antecipar medidas que, segundo a Sistemática Corporativa, só deveriam ser tomadas na fase de execução (fase IV). À época, o projeto se encontrava na fase de planejamento (fase III).

102. Pouco tempo depois, em 08.03.2007, a diretoria da Petrobras aprovou a implementação do Plano de Antecipação da Refinaria pela qual tomava medidas para antecipar o início das atividades da RNEST para o mês de agosto de 2010. Houve, a partir desse momento, a necessidade de acelerar as diversas contratações que somente deveriam ocorrer na fase de execução do projeto.

103. Após a fase de planejamento, em 25.11.2009, a diretoria autorizou o início da fase de execução do projeto, nos termos do documento interno DIP 327/2009, com a previsão de custo modificada de US\$4,1 bilhões para US\$13,3 bilhões. Anteriormente a essa aprovação, o DIP 212/2009, de 3.9.2009, trazia para o empreendimento, um VPL negativo em US\$3,067 bilhões, o que motivou a alteração de determinadas premissas, consignadas no DIP 327/2009, que elevaram o VPL para um valor positivo de US\$76 milhões, quando o projeto teve sua execução aprovada pela diretoria.

104. Feito este relato conciso dos principais eventos do projeto RNEST, analisarei, primeiro, as acusações de descumprimento dos deveres de lealdade formuladas pela SPS em desfavor de Paulo Roberto Costa e Renato Duque, por supostamente terem recebido vantagens indevidas em razão do cargo de diretor da Petrobras.

105. Na sequência, tratarei das acusações relativas à falta de diligência da diretoria e do conselho de administração nas aprovações do projeto RNEST. Ainda nesse item sobre a diligência dos administradores, abordarei a suposta omissão do conselho de administração na supervisão dos controles internos da Companhia.

106. Por fim, examinarei a acusação de desvio de poder imputada a Graça Foster por ter interferido nos trabalhos da comissão interna de apuração da Petrobras, instaurada para investigar as contratações da Refinaria.

III.1 VIOLAÇÃO AO DEVER DE LEALDADE

107. Paulo Roberto Costa, diretor de abastecimento de 14.05.2004 a 29.04.2012, e Renato Duque, diretor de serviços de 31.01.2003 a 29.04.2013, foram acusados de



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

terem se beneficiado pessoalmente de seus cargos para obter vantagens pecuniárias indevidas de sociedades contratadas para prestar serviços de engenharia na Refinaria, em infração ao art. 154, §2º, “c”, da Lei nº 6.404/76 c/c art. 155, *caput*, da Lei nº 6.404/76.

108. No âmbito da Operação Lava Jato, o Ministério Público Federal demonstrou que os dois administradores lograram frustrar o caráter competitivo de licitações de grandes obras realizadas pela Petrobras, obtendo, com isso, vantagens pecuniárias indevidas. Paulo Roberto Costa e Renato Duque praticaram atos de ofício para que contratos superfaturados fossem firmados pela Petrobras com as empresas pertencentes ao “cartel da propina” (fls. 3.648). Destaco, por oportuno, os contratos e seus correspondentes montantes no tocante à construção da RNEST:

Contrato n. 0800.008.76002.13.2 (fls. 3.699)

Objeto: UCR – Unidade de Coqueamento Retardado

Valor: R\$3.411.000.000,00

Consórcio CNEC – Construções e Comércio Camargo Correa S.A. e CNEC Engenharia S.A.

Contratos n. 0800.0087262.13.2 e n. 8500.0000080.10.2 (fls. 3.785)

Objeto: serviços de interligações elétricas

Valor: R\$498.047.383,64

Galvão Engenharia

Contrato n. 0800.0055148.09.2 (fls. 3.592)

Objeto: UHDTs e UGHs

Valor: R\$3.190.646.503,15

Consórcio CONEST – Odebrecht, OAS

Contrato n. 8500.0000057.09.2 (fls. 3.594)

Objeto: UDAs

Valor: R\$1.485.103.583,21

Consórcio CONEST – Odebrecht, OAS

109. Na ação penal nº 5036528-23.2015.4.04.7000/PR, Paulo Roberto Costa e Renato Duque foram condenados por lavagem de dinheiro e corrupção passiva pelo recebimento de vantagens indevidas em razão de seus cargos na diretoria da Petrobras, em contratos obtidos pela Construtora Norberto Odebrecht S.A. (“Odebrecht”) na RNEST, entre outros projetos de investimento (fls. 4.583 a 4.699, itens 1.053 e 1.055). Reproduz-se a seguir trecho da sentença proferida explicando o esquema criminoso e as diversas transações utilizadas para efetuar os pagamentos ilícitos aos administradores da Petrobras²¹:

²¹ Tanto a sentença quanto provas nela mencionadas foram obtidas no site do Tribunal Regional Federal da 4ª Região (<https://www.jfpr.jus.br/>), na seção do Paraná, mediante a inclusão do número e da chave do processo, constantes da página da Operação Lava Jato do MPF (<http://www.mpf.mp.br/para-o-cidadao/caso-lava-jato/atuacao-na-1a-instancia/parana/denuncias-do-mpf>).



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Então, pode-se concluir que, somente pela conta da *off-shore* Constructora International Del Sur, foram transferidos, entre 03/04/2009 a 27/11/2009, em dezesseis operações, USD 3.014.127,00 aos agentes da Petrobras **Paulo Roberto Costa** (cinco operações no total de USD 1.118.023,00), Pedro José Barusco Filho (nove operações no total de USD 1.020.672,00) e **Renato de Souza Duque** (duas operações no total de USD 875.432,00). Os recursos que foram repassados pela conta em nome da Constructora Internacional Del Sur vieram, por outro lado, das contas em nome das *off-shores* da Smith & Nash (USD 8.368.700,00) e da Golac Projects (USD 38.867.071,00), que, como visto, tem [sic] por beneficiário proprietária a Construtora Norberto Odebrecht, com sede no Brasil, [....].

Então, pode-se concluir que, somente pela conta da *off-shore* Klienfeld Services, foram transferidos, entre 11/06/2007 a 04/06/2010, em treze operações, USD 2.618.171,87 aos agentes da Petrobras **Paulo Roberto Costa** (quatro operações no total de USD 909.322,70), Pedro José Barusco Filho (sete operações no total de USD 874.386,17) e **Renato de Souza Duque** (duas operações no total de USD 834.463,00). Os recursos que foram repassados pela conta em nome da Klienfeld Services vieram, por outro lado, das contas em nome das *off-shores* da Smith & Nash (USD 3.403.000,00), da Golac Projects (USD 31.200.000,00) e da Sherkson International (USD 82.696.500,00), que, como visto, tem [sic] por beneficiário proprietária a Construtora Norberto Odebrecht, com sede no Brasil, [...].

Tem-se, em resumo, que através de três contas em nome de *off-shores* que têm como beneficiária controladora a Odebrecht, conforme informações constantes nos cadastros documentais das contas, a Smith & Nash, Arcadex Corporation e Havinsur S/A, foram realizadas transferências milionárias, entre 03/2010 a 08/2011, de USD 4.462.480,00 mais 1.925.100 francos suíços, para contas secretas no exterior em nome de *off-shores* que eram controladas por agentes da Petrobrás, especificamente para **Paulo Roberto Costa** (Sagar Holdings) e para **Renato de Souza Duque** (Milzart Overseas Holdings). [....]

Como os repasses foram efetuados a **Paulo Roberto Costa**, Pedro José Barusco Filho e **Renato de Souza Duque** durante o período em que eram dirigentes da Petrobrás e como a Odebrecht mantinha contratos com a Petrobrás a esse tempo, forçoso concluir que se trata de vantagem indevida, ou seja, propina, paga pelo referido grupo empresarial aos referidos agentes da Petrobrás, máxime porque não foi identificada qualquer causa lícita para essas transferências, tampouco as Defesas dos executivos da Odebrecht se preocuparam em esclarecê-las. [...]

110. Paulo Roberto não negou ter praticado tais atos espúrios, tendo confessado, após celebrar notório acordo de colaboração em juízo, os recebimentos indevidos. Também reconheceu em depoimento prestado a esta Autarquia que a prática desses atos teve início em seguida a sua posse no cargo de diretor de abastecimento da Petrobras (fl. 2.887 a 2.888, arquivo 00.03.48.421000). Declarou ainda que, a partir de 2006, houve



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

solicitação por partes das empresas pertencentes ao esquema de corrupção para aumentar o volume de obras da Petrobras (fl. 2.887 a 2.888, arquivo 01.00.08.008000, 1mm45ss).

111. Renato Duque foi intimado a comparecer a esta CVM para prestar esclarecimentos, no entanto, reservou-se o direito de nada declarar para discutir o assunto apenas em sede criminal. Já na fase sancionadora deste processo, o acusado, embora devidamente citado, não apresentou suas razões de defesa.

112. Os fatos narrados neste processo administrativo sancionador revelam situação extremamente grave sob a perspectiva dos deveres fiduciários dos administradores de companhias abertas: a utilização do cargo de administrador para negociar o recebimento de vantagens indevidas de sociedades contratadas.

113. A Lei nº 6.404/76 estabelece deveres fiduciários aos administradores de maneira abstrata, fixando padrões gerais de conduta a fim de acomodar diversas circunstâncias e peculiaridades da vida social, pois é praticamente impossível enumerar todos os possíveis comportamentos indesejados praticados pelo administrador em desfavor dos interesses da companhia.

114. O *caput* do art. 155 da Lei nº 6.404/76 dispõe genericamente que o administrador deve servir com lealdade à companhia e manter reserva sobre os seus negócios, sendo-lhe vedada a prática dos atos descritos em seus dispositivos, os quais compõem rol meramente exemplificativo de condutas sabidamente contrárias à lealdade que se espera de um administrador.

115. Como se sabe, os administradores recebem poderes dos acionistas para serem utilizados no interesse da sociedade, de modo que ela possa se desenvolver, florescer e dar frutos a serem partilhados entre os acionistas. Deste modo, não se pode cogitar, em hipótese alguma, que o administrador pode apropriar-se indevidamente do patrimônio social para satisfazer anseios pessoais. A atuação em benefício próprio configura grave violação ao dever de lealdade²².

116. Do mesmo modo, o art. 154 da Lei nº 6.404/76, ao estabelecer que os administradores devem exercer suas atribuições para lograr os fins e no interesse da companhia, explicita de forma aparentemente singela um dos princípios fundamentais da lei societária, a prevalência do interesse da companhia. Em relação à atuação dos administradores, o dispositivo consagra, nesses termos, o interesse da companhia como pressuposto e, concomitantemente, um orientador de suas atividades.

²² Conselho de Administração e Diretoria. In: Direito das Companhias. LAMY FILHO, Alfredo; PEDREIRA, José Luiz Bulhões (Coord.). Rio de Janeiro: Forense, 2009, p. 1.129.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

117. Os fatos devidamente comprovados neste processo demonstram que Paulo Roberto Costa atuou deliberadamente em 2007 para apressar a construção da RNEST, ciente de que receberia, também adiantadamente, vantagens indevidas decorrentes das contratações que se seguiriam à aprovação do PAR.

118. Ao empreender diversas etapas da construção da Refinaria antes da suficiente especificação das obras, contrariamente ao que preconizava a Sistemática Corporativa da Petrobras, o Acusado deu causa a constantes aditamentos e alterações contratuais que encareceram sobremaneira o projeto. E mais, sem lograr antecipar o início da produção dos derivados de petróleo, subterfúgio argumentativo utilizado para amparar a aprovação das precipitadas contratações.

119. Paulo Roberto Costa praticou tais atos sabedor de que as contratações seriam francamente mais custosas à Petrobras, conforme admitiu em depoimento ao declarar que se tivesse o projeto detalhado “*com certeza seria mais barato*”, a demonstrar o dolo de sua conduta desleal com a Companhia.

120. Do mesmo modo, restou comprovado que Paulo Roberto Costa continuou a valer-se do caráter fiduciário de suas atribuições para satisfazer seus interesses pessoais ao conduzir as obras de construção da RNEST fora dos padrões recomendados pela política de gestão de projetos da Petrobras, e, ao mesmo tempo, receber pagamentos indevidos das sociedades contratadas para prestar serviços de engenharia ao empreendimento.

121. Como bem apurado pela SPS, a passagem da fase de planejamento (fase III) para a fase de execução (fase IV) ocorreu no segundo semestre de 2009, quando a previsão de custo da RNEST já havia saltado, em pouco mais de dois anos, de US\$4,1 bilhões para US\$13,3 bilhões. Naquele momento, o projeto RNEST já se encontrava muito mais atrasado do que a previsão anterior à própria aprovação do PAR. Esse contexto de constante atraso na construção da Refinaria servia de pretexto para a realização de outras contratações açodadas e mal especificadas, submetidas, por isso, a aditamentos e sobrepreços.

122. Assim, Paulo Roberto Costa atuou decisivamente para implantar um ciclo vicioso de pagamentos indevidos fundado em contratos superfaturados, tendo, por consequência, o aumento desenfreado dos custos do projeto RNEST, que totalizaram mais de US\$ 18 bilhões em 2014.

123. No caso concreto, restou evidenciado que Paulo Roberto Costa buscou, em primeiro lugar, o seu interesse pessoal em detrimento do interesse da Petrobras, companhia da qual era diretor, tendo agido no sentido de violar, conscientemente, a obrigação de perseguir o interesse social, em infração ao art. 154, § 2º, “c”, c/c art. 155, *caput*, da Lei nº 6.404/76.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

124. Com relação à atuação de Renato Duque, ressaltou a SPS que o acusado levou a deliberação da diretoria, em 24.09 e 22.10.2009, nove contratos do projeto RNEST no total de R\$9,9 bilhões, dos quais R\$8,0 bilhões foram celebrados mediante objeto superfaturado a fim de permitir o pagamento de propinas, conforme consta da investigação criminal. Em outras palavras, mais de 80% do valor objeto daquelas deliberações serviram para manter ativa a máquina de corrupção que permeava a alta administração da Petrobras.

125. As provas dos autos revelam, ainda, que as datas dessas deliberações pela diretoria são próximas às datas da abertura da conta bancária no ING Bank (Monaco) da Milzart Overseas Holdings Inc., de titularidade de Renato Duque, ocorrida em 11.09.2009 (fls. 4.700 a 4.704), e da primeira transferência de recursos realizada, em 17.11.2009, pela Constructora Internacional Del Sur S.A., controlada indireta da Odebrecht (fls. 4.721, verso e 4.722).

126. Ainda sobre os pagamentos ilícitos ao referido diretor, importa mencionar que o gerente executivo da Petrobras subordinado a Renato Duque assumiu ter repassado dinheiro em espécie proveniente de vantagens indevidas a ele, de modo a dificultar o rastreamento dos valores arrecadados do crime de corrupção. Tal circunstância não passou despercebida pela sentença da ação penal antes mencionada:

Forçoso reconhecer que não foi possível rastrear a maior parte dos valores, o que é, porém, compreensível considerando as estratégias sofisticadas de dissimulação utilizadas, que envolviam não só as contas secretas no exterior, das quais não se tem aliás todos os documentos, mas também vultosas transações estruturadas em espécie no Brasil.

127. Deste modo, em relação à conduta apontada a Renato Duque, restou configurada a participação direta do Acusado na negociação e celebração de contratos superfaturados que serviram para abastecer o sistema de pagamentos ilícitos a administradores e outros agentes públicos.

128. Por tais razões, Renato Duque também agiu conscientemente divorciado dos interesses da Petrobras, em flagrante violação ao art. 154, § 2º, “c”, c/c art. 155, *caput*, da Lei nº 6.404/76.

III.2 VIOLAÇÃO AO DEVER DE DILIGÊNCIA

129. Neste momento, cabe examinar as acusações formuladas aos administradores da Petrobras por não terem sido diligentes no processo decisório por meio do qual foram deliberadas as passagens de etapa da construção da RNEST. Sob essa perspectiva, foram acusados de violar o art. 153 da Lei nº 6.404/76 os diretores Almir Barbassa, Guilherme Estrella, Ildo Sauer, Jorge Zelada, Sérgio Gabrielli, Graça



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Foster e Nestor Cerveró, assim como os membros do conselho de administração Guido Mantega, Fábio Barbosa, Francisco de Albuquerque, Jorge Gerdau, Luciano Coutinho, Sérgio Quintella, Sergio Gabrielli e Silas Rondeau.

130. Mais adiante, será examinada à luz do padrão de conduta previsto no art. 153 da Lei nº 6.404/76 a atuação dos membros do conselho de administração Dilma Rousseff, Guido Mantega, Fábio Barbosa, Francisco de Albuquerque, Jorge Gerdau, Luciano Coutinho, Sergio Gabrielli e Silas Rondeau, por não terem verificado correções consideradas necessárias para o bom funcionamento dos controles internos da Petrobras.

131. Antes de examinar o mérito dessas questões envolvendo o dever de diligência, entendo relevante destacar que a lei societária estabeleceu no seu art. 153 padrão de conduta com conceitos jurídicos indeterminados mediante modelo abstrato de conduta, a fim de ser possível aplicá-lo às mais diversas situações do cotidiano empresarial, independentemente do tamanho das companhias – pequenas, médias ou grandes – e dos negócios a elas relacionados – simples ou complexos²³.

132. Em seu conteúdo específico, o dever de diligência impõe aos administradores de companhia aberta o emprego do cuidado que todo homem ativo e probo costuma empregar na administração dos seus próprios negócios, exigindo-se, com isso, capacidade profissional com caráter técnico²⁴. Por esta razão, ao utilizar os recursos entregues pelos acionistas à companhia, o administrador deve deles dispor de maneira racional e justificada, tomando decisões técnicas respaldadas em informações relevantes disponíveis.

133. Para avaliar esse processo decisório e instrumentalizar os comportamentos esperados, a doutrina decompõe o dever de diligência em múltiplos aspectos²⁵. Desse modo, a aplicação da norma pressupõe estabelecer qual comportamento se poderia, razoavelmente, esperar do administrador em situações semelhantes²⁶, cuja concretude se reflete, entre outros aspectos, na busca por informações necessárias e relevantes para respaldar uma decisão instruída, refletida, justificada e tomada no melhor interesse da companhia.

²³ LAMY FILHO, Alfredo e BULHÕES PEDREIRA, José Luiz (coord.), *Direito das Companhias*, Rio de Janeiro: Forense, 2017, 2ª edição, p. 800.

²⁴ PARENTE, Flávia. *O Dever de Diligência dos Administradores de Sociedades Anônimas*. 1. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2005. p. 102-107.

²⁵ Neste sentido, Flávia Parente cita cinco deveres específicos que se desdobram do dever de diligência: o dever de se qualificar para o cargo, o dever de bem administrar, o dever de se informar, o dever de investigar e o dever de vigiar. PARENTE, Flávia. *O Dever de Diligência dos Administradores de Sociedades Anônimas*. 1. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2005. p. 102-107.

²⁶ Adamek, Marcelo Vieira von. “Responsabilidade Civil dos Administradores de S/A e as Ações Correlatas”. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 125-126.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

134. A fim de avaliar decisões negociais tomadas por administradores de companhias, adota-se, conforme jurisprudência desta Comissão²⁷, o padrão de revisão da *business judgment rule* segundo a qual, ante a inexistência de pressupostos que demonstrem má fé, fraude, interesse ou conflito do administrador, e ante a adequação procedimental do respectivo processo decisório, as decisões de um administrador devem, em princípio, ser consideradas regulares²⁸. Isto é, tais decisões gozam da presunção de que foram tomadas buscando o melhor interesse social.

135. Nessa análise, deverá o julgador examinar as circunstâncias e peculiaridades do caso concreto para asseverar a regularidade ou não da conduta adotada pelo administrador, considerando o porte da companhia e seu objeto social, as funções genéricas e específicas de cada administrador estabelecidas no estatuto social, a complexidade das operações e das transações realizadas, a relevância da decisão no contexto da companhia, bem como quaisquer outras informações capazes de influenciar concretamente a condução dos negócios sociais pelo administrador.

136. Dito isso, passo ao exame das acusações de violação ao dever de diligência na ordem descrita pelo relatório de inquérito, como se segue.

III.2.1 PROCESSO DECISÓRIO QUE DELIBEROU O PAR

137. Como bem detalhado no relatório, a Acusação questiona a diretoria por ter aprovado, em 08.03.2007, a antecipação das contratações para a construção da Refinaria. Segundo afirma, os diretores teriam ignorado a Sistemática Corporativa e os alertas das áreas técnicas quanto à falta de definição da parceria com a PDVSA e à reduzida margem de segurança do cronograma de construção da Refinaria, para decidir o início das atividades operacionais da RNEST.

138. Com essa visão, a SPS atribuiu responsabilidade aos diretores Almir Barbassa, Guilherme Estrella, Ildo Sauer, Jorge Zelada, Sérgio Gabrielli e Nestor Cerveró, por violação ao dever de diligência previsto no art. 153 da Lei nº 6.404/76.

²⁷ PAS CVM nº 03/02, Rel. Norma Jonssen Parente, j. em 12.02.2004; PAS CVM nº RJ2008/9574, Rel. Ana Novaes, j. em 27.11.2012; e PAS CVM nº RJ2005/1443, Rel. Pedro Oliva Marcilio, j. em 10.05.2006.

²⁸ Na mesma linha, é o voto do Diretor Gustavo Borba no PAS CVM nº RJ2013/11703, de 05 de setembro de 2017, segundo o qual: “Ao se aplicar a *business judgment rule*, restringe-se a esfera de atuação do julgador, a quem caberá analisar tão somente se o comportamento do administrador ao longo do processo decisório demonstra que ele atuou de maneira informada, refletida e desinteressada, ainda que, posteriormente, considerando os resultados obtidos, venha a se verificar que a decisão tomada não foi a mais benéfica para a companhia”.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

139. Em contraponto às conclusões da área técnica, os acusados alegam, em resumo, que os documentos que cuidavam da antecipação da RNEST teriam sido analisados com a devida diligência, não havendo neles qualquer indicativo de risco à Petrobras decorrente da aprovação do PAR. Além disso, afirmam que o avanço do projeto permitiria acelerar a obtenção de resultados e aumentar a capacidade de refino no país, a demonstrar atuação de boa-fé e no melhor interesse da Companhia.

140. Em que pesem os argumentos apresentados, eles não são capazes de afastar a caracterização da infração.

141. Com efeito, três meses antes, a diretoria da Petrobras aprovou, em 21.12.2006, o cronograma de construção da RNEST, cuja pré-operação da Refinaria estava prevista para começar em janeiro de 2012. A documentação suporte da reunião já apresentava diversos fatores que tinham impacto direto no cumprimento do cronograma então estabelecido e propunha recomendações à diretoria. Neste particular, cabe destacar os seguintes trechos da referida documentação (fls. 3.861, CD- arquivo):

Está previsto o desenvolvimento do projeto na forma de parceria com a PDVSA, mas não há definição sobre a mesma até o momento. Um Memorando de Entendimentos, firmado entre Petrobras e a PDVSA, prevê a elaboração, em conjunto, de estudos para implantação da refinaria, sem, no entanto, firmar compromisso de investimentos, definir participações societárias ou estabelecer critérios de comercialização. [...]

Recomendamos que a aprovação de recursos físicos, de pessoal e financeiros, propostos para a fase FEL 3, esteja condicionada à definição do parceiro no empreendimento, bem como da criação da empresa que constituirá a refinaria, ou da criação de um mecanismo que garanta o ressarcimento desses gastos, no caso de antecipação por parte da Petrobras. [...]

[Recomendamos] Não assumir compromissos que tragam alguma irreversibilidade em relação a [sic] implantação do projeto antes da aprovação do projeto básico. Em especial, apenas realizar a aquisição antecipada dos equipamentos críticos e os gastos de terraplanagem após a conclusão do projeto básico de Engenharia. [...] [grifou-se]

142. Esse contexto muito bem reconstruído pela SPS de que o cronograma completo da RNEST fora aprovado pouco tempo antes da deliberação do PAR é relevante para compreender a realidade da época e, com isso, afastar o argumento de que se estaria examinando, em sede de julgamento, fatos descontextualizados em função da passagem do tempo. A análise da matéria será feita aqui à luz dos fatos que permeavam a decisão à época, das informações disponíveis para os diretores e do conhecimento prévio que tinham sobre o assunto.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

143. A toda evidência, após a aprovação do projeto conceitual da RNEST, não houve nenhuma alteração naquele cenário que pudesse justificar minimamente a antecipação do começo das atividades operacionais da Refinaria. Tampouco as recomendações sugeridas pelos técnicos foram atendidas naquele módico intervalo de modo a reduzir as incertezas que cercavam o projeto naquele momento. Em outras palavras, não havia progresso no projeto ou melhora nas circunstâncias que pudesse justificar minimamente o início das atividades de refino antes do prazo aprovado no projeto conceitual. E mais, a leitura do DIP submetido à diretoria demonstra que constou textualmente que “o cronograma apresentado não possui[a] margem de segurança” (fls. 3.862 e seguintes).

144. Mais do que isso, existiam fundamentos e circunstâncias claramente sensíveis ao objeto da deliberação do PAR, os quais requeriam cautela por parte dos administradores na tomada de decisão. Nada obstante, Almir Barbassa, Guilherme Estrella, Ildo Sauer, Jorge Zelada, Sérgio Gabrielli e Nestor Cerveró aprovaram a antecipação do projeto sem qualquer questionamento.

145. Diante da existência de contradição material nos fundamentos e nas recomendações dos pareceres técnicos, seria esperado que os diretores tivessem demandado esclarecimentos adicionais sobre as razões daquela inopinada deliberação sobre a antecipação da RNEST. A inexistência de questionamentos com relação ao DIP e às circunstâncias que envolviam a deliberação, notadamente devido à recente discussão sobre o assunto, demonstra que os acusados não examinaram o assunto com a atenção exigida pelo padrão de diligência estabelecido pela Lei nº 6.404/76.

146. Não se quer com isso dizer que a diretoria não pudesse afastar aspectos da Sistemática Corporativa para tomar a decisão que lhe parecesse a mais adequada. Na realidade, o que se afirma com convicção é que a decisão precisa expressar uma reflexão sobre tais aspectos e apresentar justificativa razoável para afastar procedimentos da Sistemática Corporativa, de modo a demonstrar que eles não foram simplesmente desconsiderados no processo de tomada de decisão, assegurando, com isso, que a decisão, ao final, foi hígida à luz do padrão de diligência exigido pela Lei nº 6.404/76.

147. Evidentemente que não se está exigindo que os diretores verificassem pessoalmente a veracidade de todas as informações existentes no DIP, nem investigassem todos os atos praticados por seus pares, como parecem crer as defesas. No entanto, seria deles esperado o questionamento das informações que claramente estavam desalinhadas com o objeto da deliberação.

148. Também não se está atribuindo responsabilidade aos diretores por meramente fazerem parte da diretoria colegiada da Petrobras, mas em função do comportamento negligente demonstrado diante da evidente incompatibilidade existente



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

entre o objeto da decisão e as incertezas apontadas nos pareceres técnicos constantes do DIP.

149. Quanto ao argumento de que teria havido ampla discussão sobre o assunto e que teria faltado apenas o correspondente registro, cabe destacar que a análise do cumprimento do dever de diligência deve ser verificável em concreto. Como não existe nos autos documentação relativa às alegadas discussões, não é possível considerá-las na avaliação da conduta dos administradores. Do mesmo modo, não há evidências de que o estudo solicitado pela diretoria no momento da deliberação do PAR tenha retornado ao colegiado²⁹. A rigor, a ausência de formalização de discussões, pedidos adicionais de informações ou divergências permite inferir o seguinte no presente caso: ou os diretores não examinaram a documentação com o grau de atenção suficiente para perceber aquelas considerações técnicas ou sentiram-se capazes, a despeito delas, para tomar a decisão. E, em ambas as situações, resta evidenciado o descumprimento do dever legal de diligência.

150. Cabe afastar também o argumento trazido pelos acusados Almir Barbassa e Guilherme Estrella de que o aumento de custos da RNEST não teria sido ocasionado somente pelo PAR e dos aditivos contratuais dele resultantes, mas também por diversos outros fatores, tais como: (i) o incremento na capacidade da Refinaria; (ii) introdução de novos sistemas que melhorariam a qualidade dos derivados; (iii) o aquecimento do setor, que teria ocasionado significativo aumento de preços; e (iv) valorização do real frente ao dólar norte-americano, impactando o custo da Refinaria em dólares, pois o que está em exame não é a decisão em si nem os resultados dela decorrentes, mas o processo que amparou a tomada de decisão³⁰. E, neste particular, restou evidenciado que os diretores não agiram com diligência porquanto decidiram aprovar o PAR mesmo diante de informações que se mostravam objetivamente incoerentes com a antecipação proposta.

151. Sobre a ausência de justificativa para amparar a deliberação, cabe reproduzir trechos dos achados da comissão interna de apuração da Petrobras (fls. 1.243):

A Comissão não evidenciou justificativa adequada para a elaboração do PAR, uma vez que a contratação e/ou elaboração dos

²⁹ Em sua defesa, Ildo Sauer alega que até a sua destituição, nenhum dos estudos de projeto básico e de detalhamento, imprescindíveis para a implementação do PAR, teriam sido submetidos à diretoria executiva, de modo que somente em 27.03.2008, seis meses após a sua destituição, uma avaliação do PAR teria sido apresentada.

³⁰ Apesar disso, cabe mencionar que o gerente executivo responsável por executar as contratações decorrentes do PAR afirmou que “achou uma burrice” a aprovação da antecipação, chamando-a de “programa de aumento de custo” (fls. 2913, 01h15mm28ss). No mesmo sentido foi a declaração de Graça Foster ao afirmar que “o PAR mudou tudo de lugar” (fls. 3.036 a 3.048, arquivo 00.48.10.552000, 26mm40ss).



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

projetos básicos das unidades, condições necessárias para a definição consistente do cronograma de antecipação, somente foram iniciadas a partir de março/2007, quando da aprovação do PAR [...].

A Diretoria Executiva aprovou o PAR ciente de que “o cronograma apresentado não possuía margem de segurança, exigindo para sua implementação priorização pelas áreas envolvidas”. [...]

5.4.16 O Sr. M.G., então Diretor-Presidente da Refinaria Abreu e Lima S.A. [...], declarou à Comissão que “o PAR causou a quebra do conceito geral de EPC e a antecipação das contratações sem que o projeto tivesse um nível de maturidade suficiente, gerando aditivos e elevação dos custos.”. O Sr. W.G.R., então Gerente Geral de Implantação da RNEST [...], alegou “**que o projeto básico não estava em um nível de maturidade suficiente para iniciar a fase de implantação do empreendimento.**”

7.1 [...] **A Comissão não obteve evidência de justificativa técnica ou empresarial para a elaboração do PAR** [...] [grifou-se]

152. A falta de justificativa para a proposta do PAR ressoa tão evidente que foi objeto de questionamento específico a Paulo Roberto Costa. O diretor de abastecimento, responsável pela condução do projeto, afirmou que o presidente da Petrobras Sergio Gabrielli havia lhe solicitado a antecipação da partida da RNEST. O diretor de abastecimento acredita que a motivação para antecipar as obras e concluir a RNEST em 2010 tenha sido política, para, nas suas palavras, “*atender anseios do governador da época [...] e atender anseios da candidata da época*”.

153. Entre as diversas declarações prestadas por Paulo Roberto Costa que causam estupefação, ecoa a afirmação de que a existência de propina era do conhecimento de todos, apesar de os convencimentos serem técnicos nas reuniões de diretoria. Nas deliberações, sabia-se que se um diretor atrapalhasse uma determinada aprovação, em outro dia outro projeto de interesse dele poderia ser reprovado e esse fato seria, sem dúvida, considerado.

154. Mesmo desconsiderando a força desse depoimento, a fim de tornar válido o argumento de que os acusados desconheciam o esquema de corrupção e os pagamentos indevidos que ocorreriam com a aprovação do PAR, convém registrar que, ainda assim, tal argumento não lhes socorre, pois tal circunstância não é objeto de análise. A rigor, caso a SPS tivesse levado em consideração a ciência dos atos de corrupção pelos ora acusados, a imputação formulada seria muito provavelmente diversa por envolver aspectos relacionados ao dever de lealdade.

155. Ressalto, por fim, a alegação constante de diversas defesas no sentido de que pairava no âmbito da diretoria um clima de confiança entre os diretores e respeito às suas decisões, fundado no histórico e currículo de cada qual, de modo que a desconfiança de um projeto poderia causar nítido desconforto. Alegou-se, inclusive, que



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

essa confiança, somada à tecnicidade das matérias, tornaria inexigível conduta diversa dos diretores (diversa da aprovação do assunto da pauta).

156. A par da abrangência temporal e financeira dos desvios encontrados na Companhia em decorrência da Operação Lava-Jato, ousou não refutar nem a veracidade dessas afirmações nem a natureza dessa confiança. Não é necessário para a caracterização das infrações que lhes foram imputadas.

157. Ocorre que uma sadia confiança que possa existir no âmbito da diretoria não pode subverter a natureza colegiada de suas decisões e eliminar integralmente o devido escrutínio dos demais diretores sobre as matérias que são submetidas ao órgão plural, destacadamente na análise de matérias de natureza estratégica e encaminhadas com parecer negativo das áreas técnicas e contrariando a Sistemática Corporativa. Espera-se, ao menos, uma reflexão sobre tais aspectos e a apresentação de justificativa razoável para desconsiderar os sinais de alerta que lhes eram claramente perceptíveis.

158. Por tais razões, os diretores Almir Barbassa, Guilherme Estrella, Ildo Sauer, Jorge Zelada, Sérgio Gabrielli e Nestor Cerveró não empregaram, na aprovação do PAR da RNEST, o cuidado e a diligência que um homem ativo e probo deve empregar na administração de seus próprios negócios, nos termos do art. 153 da Lei de Sociedades Anônimas.

III.2.2. PROCESSO DECISÓRIO QUE DELIBEROU A MUDANÇA DE FASE DO PROJETO

159. Neste momento, cabe examinar se os diretores Almir Barbassa, Guilherme Estrella, Jorge Zelada, Sérgio Gabrielli, Graça Foster e Nestor Cerveró, assim como os membros do conselho de administração Guido Mantega, Fábio Barbosa, Francisco de Albuquerque, Jorge Gerdau, Luciano Coutinho, Sérgio Quintella, Sergio Gabrielli e Silas Rondeau, faltaram com o dever de diligência previsto no art. 153 da Lei nº 6.404/76 no processo decisório que autorizou a fase de execução do projeto RNEST.

III.2.2.1. PROCESSO DECISÓRIO NO ÂMBITO DA DIRETORIA

160. A Acusação atribuiu responsabilidade aos diretores da Petrobras por terem faltado com a diligência no processo decisório que aprovou, em 25.11.2009, a fase de execução do projeto RNEST. Segundo consta da peça acusatória, eles não teriam avaliado, com o cuidado exigido pelo padrão de conduta previsto no art. 153 da Lei nº 6.404/76, sinais de alerta que indicariam a inviabilidade do projeto.

161. Os acusados alegam que tomaram a decisão de maneira desinteressada, informada e refletida, motivo pelo qual a análise deveria restringir-se ao processo



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

decisório e não ao mérito da decisão, conforme estabelece pela regra da *business judgement rule*. Assim, ainda que a Companhia tenha incorrido em perdas, o administrador não poderia ser responsabilizado por elas.

162. Acrescentam que teriam tomado a decisão após amplo debate promovido entre as áreas técnicas da Companhia e analisado os posicionamentos técnicos, os riscos e as metodologias adequadas para o cálculo do VPL. A aprovação unânime indicaria que não haveria indícios capazes de levantar suspeitas quanto à viabilidade do projeto, até mesmo pelo fato de o VPL apresentado no estudo ter sido positivo.

163. Ao examinar a extensa documentação produzida neste processo e os principais argumentos apresentados, impõe-se afirmar, desde logo, restarem presentes elementos suficientes para comprovar que os administradores faltaram com o dever de diligência esperado nas circunstâncias.

164. De acordo com o apurado, Paulo Roberto Costa propôs à diretoria, em 03.09.2009, a mudança de fase do projeto informando no correspondente DIP que o investimento total para a construção da RNEST seria de US\$ 13,3 bilhões, com VPL de **US\$ 3,06 bilhões negativos** para o cenário de robustez, referência requerida pela Sistemática Corporativa, e (b) **US\$ 2,33 bilhões negativos** para o cenário de referência. Considerava ainda o início da operação do primeiro trem de refino em julho de 2012 e do segundo em dezembro do mesmo ano, previsão bastante distinta daquela aprovada consoante o PAR, que estabelecia o começo da operação para o mês de agosto de 2010.

165. Os pareceres técnicos anexos ao DIP alertavam que a avaliação do VPL deveria ter considerado o efeito das “refinarias *premium*”, projeto de construção de outras refinarias previsto no plano de investimentos da Petrobras que, por concorrer com a RNEST, reduzia ainda mais a atratividade do projeto (VPL de **US\$ 6,13 bilhões negativos**). Também destacavam a incerteza quanto à parceria com a PDVSA. Examinado o assunto, a diretoria determinou “*a reapresentação da matéria com os ajustes necessários*”, conforme constou da ata da reunião (fls. 4.208 a 4.311).

166. No retorno da matéria, em 25.11.2009, o DIP elaborado pela diretoria de abastecimento destacava que “*várias ações foram tomadas a fim de aprimorar os critérios de avaliação econômica do projeto*”. Essas ações diziam respeito à inclusão de (i) parcela referente à perpetuidade³¹; (ii) desonerações tributárias; e (iii) impacto da perda de mercado para terceiros, os quais somados tornavam o VPL do projeto RNEST **positivo em US\$ 76 milhões**, no cenário de referência. A documentação relativa ao assunto trazia gráfico demonstrando as variações de valor unitário decorrentes da inserção da perpetuidade, desonerações tributárias e perda de mercado, ou seja, as ações

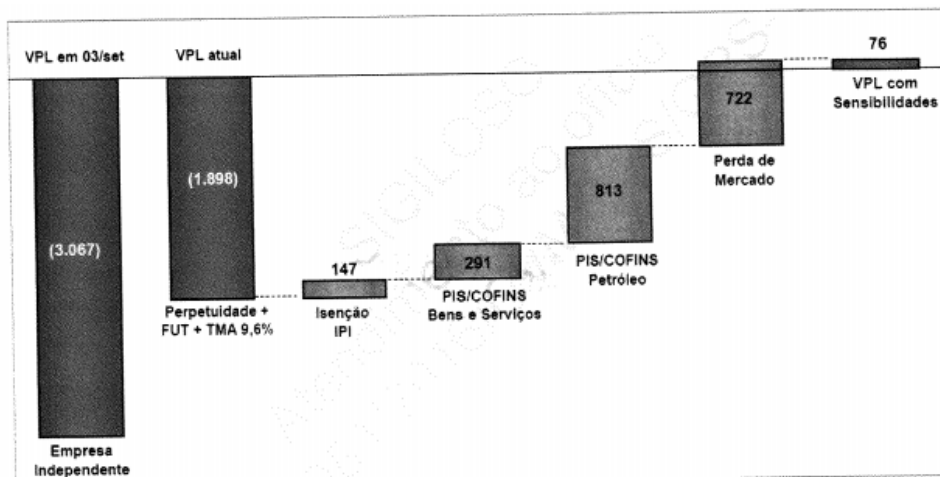
³¹ Valor residual do ativo ao final do período de análise econômica.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

tomadas pela diretoria de abastecimento para fins de melhorar a avaliação do investimento na RNEST, cuja reprodução está a seguir descrita (fls. 1.580 a 1.581):



167. Os pareceres técnicos contidos no DIP alertavam, mais uma vez, que a avaliação do VPL deveria ter considerado o efeito das “refinarias *premium*” e traziam alertas relevantes sobre as premissas recém adotadas: (i) o cenário não seria favorável à concessão das desonerações mencionadas na nova avaliação, sendo necessária a aprovação de lei federal para a concessão de parte dos benefícios; (ii) o conceito de perpetuidade não era tradicionalmente utilizado em projetos de refino, existindo diversos riscos associados a esta utilização; e (iii) o impacto da perda de mercado foi objeto de diversas ressalvas que tornavam o seu efeito bastante improvável.

168. Sobre os alertas contidos nos pareceres técnicos anexos ao DIP, cabe reproduzir, primeiramente, a manifestação do setor tributário da Petrobras sobre as desonerações previstas na nova avaliação da RNEST (fls. 1.510):

Efetuamos uma avaliação preliminar de alternativas de desoneração tributária adicionais e os respectivos impactos na avaliação econômica do projeto da RNEST. Ressaltamos que os valores apresentados foram estimados considerando os números globais do investimento e para uma futura negociação com o Governo Federal será necessário um detalhamento dos bens a serem abrangidos por tais incentivos.

Avaliamos:

- 1) a redução da alíquota do [...] IPI, de 5% (média) para 0%, sobre o fornecimento de todos os equipamentos, partes e componentes para construção da refinaria, o que representa cerca de US\$ 147 milhões em VPL. **Esse benefício poderia ser concedido por Decreto do Poder Executivo, porém ressaltamos que provavelmente será necessário negociar com os empreiteiros contratados a cessão dos direitos de fornecimento para que os fabricantes dos bens façam os fornecimentos diretamente para a RNEST.**



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

- 2) redução das alíquotas das contribuições PIS e COFINS a zero sobre todos os fornecimentos de bens e serviços para a construção da refinaria, o que representaria cerca de US\$ 291 milhões em VPL. **Neste caso, seria necessária a aprovação de lei federal para a concessão do benefício.**
- 3) tributação do petróleo adquirido pelos novos empreendimentos com alíquota de 5,6% de PIS/COFINS com possibilidade de creditamento pelo adquirente em 9,25%, gerando um ganho de 3,65% sobre as compras. **Este incentivo se encontra em fase de negociação com o Ministério da Fazenda, entretanto o cenário não é muito favorável para essa concessão. A estimativa deste benefício é de aproximadamente US\$ 780 milhões em VPL.** [grifou-se]

169. A área de estratégia e desempenho empresarial da Petrobras igualmente ressaltou as novas premissas inseridas no EVTE da RNEST, cabendo destacar os comentários referentes à perpetuidade (fls. 521):

PERPETUIDADE

Tradicionalmente, o conceito de Perpetuidade não é utilizado em projetos de investimentos. [...]

De forma geral, o valor da perpetuidade carrega um maior grau de incerteza quando com o fluxo de caixa explícito (para os anos iniciais do projeto). **Existem alguns riscos que merecem ser destacados quando da utilização da perpetuidade nas avaliações.** São eles:

Risco de estimativas – a estimativa de parâmetros (preços, mercado, necessidade de investimento, dentre outros) para períodos muito distantes no tempo conta com um menor grau de precisão. Utilizá-las na avaliação eleva a incerteza do valor final encontrado.

Risco tecnológico – este é, talvez, o risco mais relevante. Como a previsão da perpetuidade é considerada para um período muito distante no tempo (a partir de 2038), a [...] manutenção da competitividade do energético naquela data é de elevada incerteza. Neste período, outras tecnologias podem surgir, novas rotas de produção podem ser descobertas, etc. Enfim, as expectativas para o negócio podem ser totalmente alteradas num horizonte de tempo tão grande. Principalmente quando tratamos de combustíveis e energéticos, onde existe uma gama de estudos e projetos para desenvolver fontes alternativas ao petróleo. [...]

Conceitualmente, em mercados competitivos, a perpetuidade deve ser nula, uma vez que novos entrantes serão atraídos até o limite onde não houver mais VPL a ser capturado.

Vale ainda registrar um comentário final: o período utilizado pela Petrobras para avaliar projetos de refino é de 25 anos. Projetos que se tornam economicamente viáveis dentro deste período conferem maior segurança ao planejamento da Cia. Contar com períodos maiores para



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

viabilização do projeto implica em maiores riscos, uma vez que são registradas maiores incertezas nas variáveis chave da projeção. [grifou-se]

170. A área de planejamento financeiro emitiu parecer com ressalvas sobre a nova avaliação da RNEST, das quais reproduzo as seguintes (fls. 1539):

É importante frisar que as avaliações do PLANINV para este projeto não incluíram no Caso Base as refinarias Premium I e II do Sistema Petrobras, ou seja, não foram considerados nos indicadores deste projeto os efeitos das duas refinarias no pool da Petrobras.

[...] a inclusão das refinarias Premium no EVTE degrada consideravelmente o VPL diferencial, que passa a ser de US\$ 4.322 milhões negativos. O Caso Base do projeto deveria considerar a visão integrada dos projetos incluindo a perspectiva de ampliação do parque de refino. [...]

Considerando o projeto isoladamente, entendemos que o VPL negativo apresentado frente ao expressivo investimento requerido representa um ponto de atenção para a Companhia. Desta forma, sugerimos uma análise integrada (Portfólio Petrobras) do projeto para avaliar sua capacidade de geração de valor frente a outras alternativas.

Conforme determina a Sistemática Corporativa de Projetos de Investimento, recomendamos a realização de análise de risco econômico-financeiro do projeto para que sejam fornecidas mais informações para a tomada de decisão. [grifou-se]

171. A estratégia e desempenho empresarial também trouxe recomendações importantes para o exame da passagem de fase do projeto RNEST, algumas semelhantes às que trouxera na primeira reunião de diretoria (fls. 1.518):

RECOMENDAÇÕES

Avaliar a pertinência de aprovação do Projeto, neste momento, considerando os seguintes aspectos:

- A rentabilidade apresentada nos diversos cenários e casos analisados;
- A existência, ou não, de alternativas mais rentáveis para a produção no País de derivados com o padrão de qualidade a ser colocado pelo projeto (Diesel padrão Europeu);
- A existência, [sic] de alternativas mais rentáveis que promovam o balanceamento entre a Capacidade de Processamento e de Produção de Petróleo da Petrobras;
- O nível do investimento já comprometido;
- A possibilidade, ou não, de implantação de novos projetos de refino no País sem impacto na Refinaria do Nordeste.

Considerar, ainda, a pertinência de reavaliar o Projeto após conclusão das negociações com a PDVSA; [...]



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

Avaliar a postergação da entrada da segunda unidade de destilação atmosférica, considerando a incerteza em relação à oferta do petróleo venezuelano. Caso a postergação não seja viável, buscar a colocação do petróleo pesado brasileiro na segunda unidade na ocasião de indisponibilidade do petróleo venezuelano. [grifou-se]

172. Diante de tantos elementos que colocavam em xeque a confiabilidade do novo EVTE e, por consequência, a viabilidade da Refinaria, bem como a existência de recomendações para que alternativas fossem avaliadas, cabia à diretoria o dever de buscar esclarecimentos adicionais sobre essas questões até que estivesse segura de que estava lidando com a situação corretamente. O dever de diligência impõe aos administradores dever de cuidado que deveria ter ensejado maior escrutínio sobre as informações que lhes foram submetidas e sobre o prejuízo que possivelmente estava sendo imposto à Companhia, devendo, por isso, tomar providências necessárias para afastar tal risco.

173. Contudo, a formalização da reunião de 25.11.2009 não demonstrou ter havido reflexão sobre o assunto, tendo a ata da reunião registrado apenas que a “Diretoria Executiva aprovou as proposições formuladas” (fl. 1.580 a 1.581).

174. Nessas circunstâncias, incide sobre o administrador o dever de adotar providências a fim de verificar a validade daquelas informações fornecidas pela diretoria de abastecimento, responsável pelo projeto de investimento, de sorte a permitir uma avaliação confiável sobre as premissas que foram objeto de críticas pelas áreas corporativas da Petrobras. Importa destacar que os pareceres se constituíam em avaliação objetiva, confiável e independente do EVTE, merecendo, por isso, maior atenção dos administradores, que, simplesmente ignoraram as inconsistências técnicas ali descritas.

175. Não se está afirmando que os diretores deveriam desconfiar de antemão das proposições feitas pela diretoria de abastecimento, pois, como se sabe, os administradores podem confiar em informações recebidas pelos demais diretores e funcionários da companhia. Porém, esse direito de confiar deixa de prevalecer ante um sinal de alerta que desacredite a informação recebida, como se deu no presente caso. Nessa hipótese, não pode preponderar uma confiança absoluta na opinião dos seus pares, conforme alegado pelos acusados de que haveria muita confiança nas equipes que patrocinavam os projetos, devendo o administrador, nestas circunstâncias, adotar providências a fim de verificar a veracidade e exatidão da informação à luz dos questionamentos e críticas contidas nos já mencionados pareceres.

176. Neste passo, cabe afastar o argumento uníssono das defesas de que se estaria equivocadamente avaliando, em sede de julgamento, a observância do cumprimento do dever de diligência relativamente ao mérito da decisão negocial de investir recursos na construção da RNEST, pois o que está em exame não é a revisão sobre a decisão de



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

passar à fase de execução do projeto da RNEST e os resultados obtidos pela Companhia a partir da decisão tomada, mas o padrão de conduta adotado pelos administradores no procedimento que amparou a deliberação. E, neste particular, restou evidenciado que os diretores não agiram com diligência porquanto conduziram avaliação de investimento baseada em informações que se mostravam objetivamente duvidosas, cuja credibilidade restou bastante afetada pelos pareceres técnicos.

177. Em relação ao argumento dos acusados de que teria havido amplo debate sobre o assunto, inclusive com a retirada de pauta e posterior reapresentação da matéria, tendo faltado apenas o registro das discussões, importa consignar, uma vez mais, que uma simples ata de reunião resumida informando que tal decisão foi tomada por unanimidade não é suficiente para provar diligência. Deve-se avaliar se o dever de diligência está sendo cumprido em relação ao que objetivamente existe no processo decisório.

178. Ou seja, é preciso que haja documentação mínima comprovando as discussões e justificando a decisão especialmente quando se trata de uma companhia do porte da Petrobras, a maior companhia de capital aberto do país, discutindo se investe ou não mais de uma dezena de bilhões de dólares num empreendimento de elevados riscos. E, diante das ressalvas contidas nos pareceres técnicos e da ausência de justificativas para a tomada de decisão, não restou demonstrado que o processo de aprovação da mudança de fase do projeto RNEST foi hígido à luz do dever de diligência.

179. A esse respeito, cabe destacar que, conforme diversos depoimentos colhidos na fase investigativa do presente processo, as decisões da diretoria eram consensuais, não havendo registro de voto discordante. A regra era que, se houvesse oposição de um ou mais diretores em relação a um tema, o proponente retirava o assunto da pauta sem que houvesse o registro da ressalva ou descontentamento. As atas das reuniões, por sua vez, não eram descritivas, limitando-se a registrar somente as conclusões da deliberação. Sobre o tema, a presidente Graça Foster declarou que os registros das reuniões de diretoria eram insuficientes, dando a impressão de que seriam realizados desta forma para, nas suas palavras, “*não dizer nada mesmo*” (fls. 3.036 a 3.037 arquivo 03.09.15.117000.wmv, 19m45s).

180. Com efeito, a decisão foi tomada sem explicitar os motivos pelos quais se acreditava, apesar dos alertas, ser aquela a melhor decisão para suprir o mercado nacional com derivados de petróleo em relação a outras alternativas. Do mesmo modo, não havia registro das razões de não ter sido considerado o impacto das “refinarias *premium*” na avaliação do projeto, nem a razão de ter sido dispensada a análise de risco econômico-financeiro requerida pela Sistemática Corporativa. Tudo isso foi, como



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

visto, devidamente ressalvado nos pareceres técnicos encaminhados para suportar a decisão da diretoria.

181. Neste passo, é necessário receber com distanciamento os argumentos das defesas sobre: (i) os motivos pelos quais não foram incluídas as “refinarias *premium*” no cálculo do EVTE, (ii) a avaliação do custo afundado do projeto; (iii) a possibilidade de utilizar a perpetuidade; (iv) a probabilidade das desonerações tributárias; (v) a razoabilidade de se considerar a “perda de mercado” na avaliação da RNEST; ou (vi) o suposto avanço das tratativas com a PDVSA; pois não é possível verificar das provas constantes dos autos que a excepcionalidade dessas questões foi sequer considerada para a formação de convicção da diretoria na decisão do dia 25.11.2009. Além disso, os pareceres técnicos apresentados à diretoria suscitam fundadas dúvidas quanto à confiabilidade do uso dessas premissas no EVTE da RNEST.

182. No âmbito do exame de cumprimento do dever de diligência, a avaliação deve ser pautada de modo a verificar se os fundamentos expostos pelos administradores para a decisão tomada conseguem ser justificados, razoavelmente, pelas informações disponíveis e necessárias para a formação da convicção. E o processo de decisão ora em exame não possui qualquer documento que evidencie o uso pelos diretores dessas razões, motivo pela qual elas não podem ser levadas em consideração para avaliar a conduta dos acusados.

183. Cabe também afastar o argumento de Graça Foster de que determinados administradores teriam manipulado dados e documentos técnicos e, devido à falta de conhecimento técnico específico dos demais sobre o tema, conseguiram aprovar algumas pautas. Ocorre que as não-conformidades do EVTE da RNEST descritas nos pareceres e amiúdes mencionadas saltam aos olhos de um leitor minimamente atento e foram expressamente apontadas pelos técnicos, não exigindo a alegada especialização do administrador a fim de gerar um alerta.

184. Além disso, a própria acusada afirmou na fase investigativa do presente processo não ter acreditado no valor do “impacto da perda de mercado para terceiros”, cujo efeito montava mais de R\$700 milhões no EVTE, a demonstrar que ela não foi induzida a erro por dados falseados, mas aprovou, sem ressalva ou objeção, premissa que entedia irreal. A rigor, diante da passividade intencional da acusada, poder-se-ia eventualmente concluir inclusive pela omissão dolosa dela no presente caso. Nada obstante, tendo a Acusação preferido se restringir a apontar a omissão culposa de Graça Foster, tenho por amplamente demonstrada a violação ao art. 153 da Lei nº 6.404/76.

185. A bem da verdade, o que se verifica das provas dos autos é que os acusados aprovaram a passagem de fase do projeto RNEST com EVTE claramente em desacordo com os procedimentos da Companhia, ignorando todos os alertas das áreas corporativas da Petrobras, sem apresentar qualquer justificativa para que o tratamento de



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

excepcionalidade fosse concedido no presente caso, a demonstrar que eles não tomaram os cuidados que caracterizam o dever de diligência.

186. Por outro lado, concordo com o argumento das defesas de que a Sistemática Corporativa não seria de observância obrigatória, de forma que o não seguimento de seus preceitos não implicaria automaticamente na falta de diligência por parte dos diretores. Contudo, ao excepcionar políticas ou procedimentos desenvolvidos justamente para promover a eficiência operacional e reduzir riscos patrimoniais à companhia, o administrador deve justificar o tratamento diferenciado conferido às circunstâncias.

187. Nesta hipótese, deve-se demonstrar que as regras estabelecidas não foram simplesmente olvidadas ou afastadas para encobrir um ato ilícito, mas, sim, por uma razão de interesse da própria companhia, sob pena de se aceitar decisões prejudiciais aos interesses da companhia por desídia ou má fé. E a diretoria não apresentou justificativas para o tratamento de excepcionalidade que foi conferido ao EVTE da RNEST, decidindo a mudança de fase contrariamente à Sistemática Corporativa, que servia justamente para dar suporte à administração no processo decisório de sorte a reduzir incertezas e custos dos projetos de investimento.

188. Melhor sorte não merece o argumento de Sérgio Gabrielli de que seria impossível exigir a leitura de cada documento produzido pela Petrobras e a compreensão em profundidade dos diversos assuntos discutidos na diretoria, tendo em vista que haveria reuniões com mais de trinta assuntos em uma pauta, porquanto, ao invés de conduzir à conclusão que ele teria sido diligente no presente caso, revela a existência de procedimentos inadequados e insuficientes para o exercício ordinário das atribuições da diretoria da qual era presidente.

189. A esse respeito, ressalta-se que a Acusação demonstrou a existência de diversas falhas no processo decisório da Petrobras, tal como o encaminhamento de assuntos relevantes pouco tempo antes ou no mesmo dia da reunião e a existência de pautas semanais com dezenas de assuntos que, incluindo seus anexos, podiam chegar a até quinhentas ou mais páginas cada um. Tudo isso devidamente comprovado nos autos do presente processo é mais um indício da pouca atenção destacada pelos diretores às matérias relevantes da Companhia.

190. Ainda sobre o tema, cabe registrar que o dever de diligência do administrador deve ser avaliado notadamente em relação às decisões de maior relevo da companhia, pois elas têm potencial de causar maiores impactos nos resultados da sociedade. A construção de uma refinaria de mais de uma dezena de bilhões de dólares, após mais de 20 anos desde a construção da última, com o emprego de complexa tecnologia para processar grande volume de óleo pesado, dificuldade amplamente reconhecida pelos administradores neste processo, enquadra-se integralmente na



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

conceituação de decisão merecedora de especial cuidado por parte dos administradores. Contudo, não foi isso que restou comprovado no presente caso.

191. Por tais razões, os diretores Almir Barbassa, Guilherme Estrella, Ildo Sauer, Jorge Zelada, Sérgio Gabrielli, Graça Foster e Nestor Cerveró não empregaram, na aprovação da mudança de fase da RNEST, o cuidado e a diligência que um homem ativo e probo deve empregar na administração de seus próprios negócios, nos termos do art. 153 da Lei de Sociedades Anônimas.

III.2.2.2. PROCESSO DECISÓRIO NO ÂMBITO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

192. Os membros do conselho de administração Guido Mantega, Fábio Barbosa, Francisco de Albuquerque, Jorge Gerdau, Luciano Coutinho, Sérgio Quintella, Sergio Gabrielli e Silas Rondeau foram acusados pela SPS de terem faltado com o dever de diligência no processo decisório que autorizou a fase de execução do projeto RNEST.

193. Segundo a Acusação, após a aprovação pela diretoria da fase de execução do projeto, o status do projeto foi apresentado, em 17.12.2009, aos referidos membros do conselho de administração. Na oportunidade, o destacado aumento dos custos e as projeções do EVTE com VPL negativo da RNEST teriam sido mostrados aos conselheiros, que, apesar disso, emitiram orientação para a diretoria continuar as negociações para buscar melhorar o VPL e, após encerradas essas tentativas, retornar o assunto ao colegiado.

194. Diante disso, a Acusação concluiu que o conselho de administração não teria discutido a matéria à luz dos sinais de alerta relativos à inviabilidade da RNEST, ratificando a decisão da diretoria sem maiores discussões, o que caracterizaria violação ao dever de diligência previsto no art. 153 da Lei nº 6.404/76.

195. Os acusados, em síntese, alegam que não haveria que falar em ratificação da passagem à fase de execução do projeto RNEST, pois o conselho de administração não teria competência para deliberar avaliações ou passagens de fase de projetos de investimentos. O estatuto social da Companhia teria previsto funções distintas para o conselho de administração e para a diretoria, de sorte que o projeto de investimento seria de atribuição da diretoria, responsável pelo seu planejamento, aprovação, execução e acompanhamento.

196. A apresentação feita ao conselho de administração em 17.12.2009 teria sido apenas uma explanação do investimento na RNEST, na qual não teria sido tomada nenhuma decisão, mas apenas emitidas orientações gerais ao corpo de diretores para a condução do negócio.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

197. Acrescentaram que não haveria naquela ocasião sinais de alerta ou motivo suficiente para ensejar a interrupção do empreendimento, o qual seria de fundamental relevância para o parque de refino nacional. Apesar da ausência de sinais de alertas e de indícios de irregularidades dentro da Companhia, os acusados destacaram que, depois de discutido o projeto, solicitaram que a matéria retornasse para análise posterior, o que demonstraria a diligência do conselho.

198. Em que pese a relevância dos argumentos apresentados, eles não são capazes de afastar a caracterização da infração imputada aos acusados.

199. Primeiramente, cabe destacar que é incontroversa a competência dos diretores para planejar e executar os projetos de investimentos, em consonância com as orientações gerais definidas pelo conselho de administração no plano de negócios da Petrobras. Do mesmo modo, não é objeto de discussão que cabia à diretoria colegiada aprovar as etapas dos projetos de investimentos da Companhia, assim como suas correspondentes exigências e condições, de acordo com as regras previamente estabelecidas na Sistemática Corporativa.

200. O que se discute é a responsabilidade do conselho de administração por orientar o direcionamento estratégico das atividades empresariais da Companhia e fiscalizar a gestão dos negócios realizada pela diretoria, pois, além de decidir os rumos estratégicos da companhia, o conselho de administração é responsável por monitorar a diretoria para que ela siga, na gestão do dia a dia da companhia, o caminho estratégico previamente definido, a teor do que dispõe o art. 142 da Lei nº 6.404/76³².

201. Neste sentido, compete ao órgão máximo da administração a responsabilidade para discutir, aprovar e monitorar a: (i) estratégia de atuação da diretoria; (ii) estrutura de capital; (iii) aquisições e processo de reestruturação societária; (iv) contratação, avaliação e dispensa de diretores; (v) e estabelecimento de controles internos, incluindo políticas e limites de alçada, dentre outras responsabilidades³³.

202. A par disso, e diante da evidente relevância estratégica do projeto RNEST, não se pode afastar, de um lado, a iniciativa da diretoria de levar o assunto para o conhecimento e eventual orientação do conselho de administração, e, de outro, a competência do órgão máximo de administração para emitir orientações sobre o assunto.

³² Art. 142. Compete ao conselho de administração: I - fixar a orientação geral dos negócios da companhia; II - eleger e destituir os diretores da companhia e fixar-lhes as atribuições, observado o que a respeito dispuser o estatuto; III - fiscalizar a gestão dos diretores, examinar, a qualquer tempo, os livros e papéis da companhia, solicitar informações sobre contratos celebrados ou em via de celebração, e quaisquer outros atos; [...]

³³ EIZIRIK, Nelson. *A Lei das S/A Comentada*. 2ª ed. Vol. II. São Paulo: Quartier Latin, 2015, p. 290.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

203. Não obstante, a Acusação destacou que, em janeiro daquele ano (2009), o conselho de administração da Petrobras havia revisado o plano estratégico e aprovado o plano de negócios com a decisão de diminuir a alocação de recursos para o programa de investimentos, reduzindo proporcionalmente custos com investimentos. De acordo com a ata do conselho de administração nº 1.313, pauta 02, a redução deveria ser de, no mínimo, 20% nos projetos em fase I e II e 10% nos projetos em fase III e IV (fls. 5.160).

204. Deste modo, a aprovação pela diretoria da fase IV (execução) do projeto RNEST deveria seguir a nova diretriz de redução de custos emitida pelo conselho de administração. No entanto, verificou-se que a evolução do custo da refinaria tinha triplicado desde a previsão feita na aprovação da fase III, passando de US\$4,1 bilhões para US\$13,3 bilhões, não constando da deliberação feita pela diretoria referência à redução de custos determinada pelo conselho de administração (fls. 5.612).

205. A toda evidência, a aprovação pela diretoria da fase IV (execução) do projeto RNEST não se coadunava com a novel orientação emitida pelo conselho de administração. Deste modo, caso o assunto não fosse levado ao órgão máximo da administração da Petrobras, poder-se-ia cogitar que a diretoria estaria atuando em desacordo com as orientações emitidas pelo conselho de administração.

206. Sobre o tema, importa registrar que o presidente da Petrobras Sérgio Gabrielli declarou que a discussão sobre o projeto RNEST somente foi objeto de reunião com o conselho de administração a partir do momento que foi identificado o elevado custo para prosseguir na construção da refinaria (fls. 3.033 a 3.035).

207. Neste contexto, o status do projeto RNEST foi apresentado ao conselho de administração na reunião, de 17.12.2009, para detalhar a evolução do custo da Refinaria e as variações do EVTE segundo algumas premissas, cujos cenários, mesmo evidenciando a ausência das “refinarias *premium*”, apresentaram VPL negativos. Também foram destacadas as modificações realizadas no EVTE do projeto que o tornava marginalmente atrativo economicamente, ou seja, os acréscimos no VPL decorrentes da inclusão da perpetuidade, desonerações tributárias e perda de mercado descritas amiúdes no item anterior deste voto (fls. 3.839-3.846v).

208. Na apresentação feita ao conselho havia ainda uma lâmina específica para relatar importantes dificuldades de execução do projeto que “*coloca[va]m pressão adicional em prazos e investimentos*”. Por fim, a última folha da apresentação solicitava a aprovação da passagem da fase III para a fase IV e indicava que a diretoria iria buscar outros benefícios tributários ao projeto.

209. Após a apresentação, o conselho de administração fez registrar na ata que: “*visando elevar a rentabilidade do projeto, o Conselho de Administração emitiu*



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

orientações para a continuidade das negociações e determinou que o projeto retorne ao Colegiado para conhecimento, após a conclusão das negociações.”

210. Diante disso, não há como acolher a alegação de que os acusados foram diligentes naquela ocasião.

211. A apresentação feita pela diretoria ao conselho de administração demonstrava, com evidência solar, que o projeto teria elevados custos e riscos associados e, apesar disso, não traria, muito provavelmente, retorno econômico à Companhia, sinais de alerta suficientes para exigir dos membros do conselho de administração maiores indagações sobre o assunto. O dever de diligência impõe aos administradores a obrigação de verificar notadamente as informações que podem eventualmente causar prejuízos à Companhia.

212. No entanto, a formalização³⁴ da reunião não evidenciou a existência de questionamentos a respeito, nem mesmo a respeito das novas premissas utilizadas para melhorar o VPL. Também não há evidências de inquirição sobre qual poderia ser o impacto das “refinarias *premium*” no EVTE do projeto RNEST. Do mesmo modo, não é possível identificar se outras alternativas ao projeto foram debatidas pelo órgão colegial ou se houve discussão sobre eventual impacto no fluxo de caixa da Petrobras decorrente dos futuros desembolsos necessários para construir a Refinaria.

213. Diante disso, não podem ser acolhidas as razões apostas nas defesas sobre a regularidade das premissas utilizadas pela diretoria para melhorar o VPL porquanto não é possível verificar das provas constantes dos autos que tais questões foram minimamente consideradas naquela oportunidade. Além disso, o registro em ata da orientação emitida à diretoria consentindo com a continuidade do projeto não explicou o motivo por que a diretriz relacionada à redução dos custos de todos os projetos de investimentos da Petrobras não deveria ser cumprida no caso da RNEST.

214. Conforme já destacado neste voto, para excepcionar regras e procedimentos previamente estabelecidos, tal como a nova política de investimentos da Petrobras instituída em janeiro de 2009, o conselho de administração deveria justificar o motivo pelo qual o referido projeto mereceria o tratamento diferenciado conferido às circunstâncias. Em situações que tais, o administrador deve demonstrar que as orientações estratégicas não foram simplesmente esquecidas ou afastadas para encobrir um ato ilícito, mas sim por uma razão de interesse da própria Petrobras, sob pena de se aceitar decisões prejudiciais aos interesses da Companhia por desídia ou má-fé.

³⁴ Como se sabe, embora a ata possa ser lavrada sob a forma sumária, ela deve conter o registro de todas as deliberações e seus correspondentes fundamentos, bem como eventuais votos divergentes.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

215. Naquele momento em que se reduzia os investimentos com o evidente objetivo de proteger o fluxo de caixa da Petrobras, o conselho de administração não apresentou nenhuma justificativa para o tratamento de excepcionalidade que foi conferido ao projeto RNEST, que, por estar passando da fase III para a fase IV, deveria ter reduzido seu investimento em, no mínimo, 10%, conforme nova política de investimento.

216. Em verdade, ao invés de adequar o projeto à nova realidade financeira da Companhia, o conselho de administração permitiu, sem qualquer justificativa, que a diretoria pudesse gastar o triplo dos recursos previstos para o projeto RNEST quando da passagem da fase II para a fase III, ocorrida em 2007. A par disso, resta evidente que o conselho de administração não foi capaz de promover o alinhamento do direcionamento estratégico previamente estabelecido com a gestão dos investimentos realizados pela diretoria, a evidenciar falha em sua atribuição legal.

217. Como já mencionado, o cumprimento do dever de diligência deve ser pautado na verificação das informações disponíveis e necessárias para a formação da convicção, bem como nos fundamentos expostos pelos administradores para justificar a tomada de decisão.

218. E o processo de tomada de decisão ora em exame não possui evidências de que os conselheiros promoveram um debate mais minucioso a respeito dos eventuais problemas que a Petrobras poderia vir a enfrentar caso prosseguisse com o projeto. Ademais, não justificaram as razões pelas quais o investimento na RNEST não deveria cumprir a nova política de investimentos da Companhia. Tudo isso devidamente comprovado nestes autos revela que o processo de tomada de decisão relacionado ao investimento na RNEST não foi hígido à luz do dever de diligência no âmbito do conselho de administração.

219. Por tais razões, Guido Mantega, Fabio Barbosa, Francisco de Albuquerque, Jorge Gerdau, Sergio Gabrielli, Luciano Coutinho, Sergio Quintella e Silas Rondeau não empregaram o cuidado e a diligência que um homem ativo e probo deve empregar na administração de seus próprios negócios, nos termos do art. 153 da Lei de Sociedades Anônimas.

III.2.3. PROCESSO DE SUPERVISÃO DOS CONTROLES INTERNOS

220. Os membros do conselho de administração Dilma Roussef, Guido Mantega, Fábio Barbosa, Francisco de Albuquerque, Jorge Gerdau, Luciano Coutinho, Sergio Gabrielli e Silas Rondeau são acusados de não terem supervisionado devidamente os controles internos da Companhia, em infração ao art. 153 da Lei nº 6.404/76.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

221. Neste sentido, a Acusação apontou que, na reunião do conselho de administração de 20.10.2009, o comitê de auditoria relatou falhas recorrentes na contratação de serviços da Petrobras, recomendando a adoção de um plano de ação. Tal providência não teria sido adotada nos meses que se seguiram e, na reunião seguinte com pauta específica sobre as atividades de auditoria, o conselho de administração não teria feito cobranças sobre o assunto, permanecendo, no sentir da SPS, omissa frente aos apontamentos.

222. As defesas alegam, em resumo, que a adequação dos controles internos de uma Companhia envolveria uma evolução contínua e gradual, de modo que o espaço delimitado pela Acusação seria insuficiente para averiguar se as irregularidades estariam sendo aprimoradas ou não. O tempo delimitado pela Acusação não seria suficiente para verificar o êxito da política de controles internos, haja vista que sua aprovação teria ocorrido apenas em 13.04.2009. No caso, alegaram que a evolução e melhoria dos controles internos, em uma companhia do porte da Petrobras, envolvem grandes esforços, como a disseminação de princípios e regras aos funcionários e a alteração de novos sistemas de autorizações e aprovações.

223. Em seguida, afirmaram ter tomado outras medidas efetivas para a correção do problema, qual seja: (i) na reunião de 20.10.2009, teriam solicitado à diretoria o detalhamento, por área, das medidas destinadas ao tratamento das não-conformidades reportadas pelo comitê de auditoria na nota de 20.10.2009; e (ii) na reunião de 30.04.2010, teriam analisado e aprovado o plano anual de auditoria interna, depois de verificados aspectos de eficiência, eficácia e economia, bem como de conformidade às normas e legislações aplicáveis em diversas áreas da Petrobras.

224. Dessa maneira, os controles internos da Petrobras teriam sido acompanhados pelos conselheiros a partir do trabalho conjunto com a auditoria interna e com o comitê de auditoria, o qual elaborava relatórios trimestrais reportando as deficiências e a evolução dos trabalhos de aprimoramento para o conselho.

225. A argumentação trazida pelas defesas dos acusados não tem o condão de eximi-los de responsabilidade no presente caso.

226. Como já mencionado, cabe ao conselho de administração, na esfera deliberativa superior, planejar e orientar as atividades empresariais da Companhia, ao passo que compete à diretoria pôr em prática a gestão dos negócios sociais de modo a seguir o direcionamento estratégico estabelecido pelo conselho. No modelo de gestão adotado pela Lei das S/A, o conselho de administração tem também a função de supervisionar a gestão ordinária da diretoria para melhor realizar o objeto social visando ao interesse lucrativo da companhia.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

227. Para cumprir suas funções legais, compete ao órgão máximo da administração a responsabilidade para discutir, aprovar e monitorar os controles internos, que são estabelecidos para assegurar que os objetivos estratégicos serão alcançados. É por meio deles que se busca proteger o patrimônio da companhia, conferir exatidão e fidedignidade às informações financeiras, promover a eficiência operacional, e encorajar a obediência às diretrizes traçadas pela alta administração e às leis, normas e regulamentos³⁵.

228. Conforme descrito no relatório, em 20.10.2009, o comitê de auditoria emitiu nota para o conselho de administração sobre as atividades realizadas pela auditoria interna relativamente ao primeiro e segundo trimestre de 2009, cujos trechos estão reproduzidos a seguir (fls. 5.079 a 5.083):

[....]

Cabe destacar ao Conselho de Administração que **as atividades de contratação de serviços se constituíram, mais uma vez, no destaque negativo no quadro de irregularidades. Ocorreram não-conformidades nas atividades de suprimento de materiais, gestão de estoques, convênios, entre outras (atividades de gestão).**

Os destaques negativos das auditorias, ocorridos em atividades tipicamente de gestão, **autorizam o Comitê de Auditoria a sugerir ao Conselho de Administração que recomende uma vez mais à Administração da Companhia esforços no sentido de conscientizar toda a empresa da crescente importância dessas atividades, de promover treinamento continuado de todos os gerentes e empregados envolvidos e supervisionar cuidadosamente a gestão das unidades e gerências envolvidas de modo a preparar a Companhia para os desafios de seu crescimento.**

O Comitê de Auditoria sugere que a administração da Companhia avalie permanentemente a adequação da estrutura da Auditoria Interna frente aos planos de crescimento da empresa. [grifou-se]

229. O assunto foi levado ao conselho de administração no mesmo dia 20, constando o seguinte sobre o tema na ata da reunião (fls. 1.176 a 1.179):

[....] Na parte destinada aos assuntos do Comitê de Auditoria, o Conselheiro Fabio Colleti Barbosa, Presidente do Comitê de Auditoria, distribuiu aos Conselheiros presentes a Nota nº 31/2009 desse comitê, anexada à esta ata, que trata dos Relatórios de Atividades de Auditoria Interna do 1º e do 2º trimestres de 2009, e **destacou a recorrência das não-conformidades na área de contratação de serviços,**

³⁵ Financial Reporting Council (FRC) (2014). *Guidance on Risk Management, Internal Control and Related Financial and Business Reporting*. Disponível em <https://www.frc.org.uk/getattachment/d672c107-b1fb-4051-84b0-f5b83a1b93f6/Guidance-on-Risk-Management-Internal-Control-and-Related-Reporting.pdf>> Acessado em 02/06/2020.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

recomendando a elaboração de um plano de ação. O Conselheiro e Presidente da Petrobras José Sergio Gabrielli de Azevedo esclareceu que a Companhia já vem atuando no reforço dos controles, no treinamento dos Gerentes de contratos, no redimensionamento do quadro de Auditores e na redefinição dos processos e, por solicitação do Conselho de Administração, ficou de apresentar as medidas tomadas nas diferentes áreas, por Diretoria, contra as não-conformidades. [grifou-se]

230. Como se vê, embora o presidente do comitê de auditoria e também conselheiro Fábio Barbosa tenha solicitado a adoção de um plano de ação para reduzir a recorrência das não-conformidades, tal ação mais concentrada de combate ao problema não foi acatada, ficando o presidente da Petrobras incumbido de apresentar, por solicitação do conselho de administração, as medidas que segundo ele já estariam sendo tomadas contra as indigitadas não-conformidades.

231. Contudo, não foi possível identificar registro de nova discussão a respeito do tema por parte dos integrantes do conselho de administração, nem questionamento sobre as medidas supostamente tomadas, pela diretoria, para corrigir falha grave e recorrente nos controles internos da Petrobras. A Acusação bem andou em verificar que, em 30.04.2010, quando o conselho aprovou o “Plano Anual de Atividades de Auditoria – Exercício 2010”, tal questão não foi sequer abordada (fls. 5.074 a 5.077).

232. Diante disso, e da alegação de Sérgio Gabrielli de que um relato das atividades desenvolvidas por cada diretoria a respeito das atividades de controles internos não seria possível, dada a pauta estrita do conselho de administração, restou demonstrado que o assunto não retornou à discussão pelos conselheiros.

233. À luz do caso concreto, é forçoso reconhecer que fazia parte do dever de diligência dos membros do conselho de administração monitorar a qualidade e efetividade dos controles internos, notadamente quando alertados repetidas vezes sobre a inadequação das atividades de suprimento de materiais, gestão de estoques, entre outras atividades de gestão da Petrobras, os quais foram objeto de destacada ressalva pelo comitê de auditoria. Entretanto, o que se verifica dos autos é justamente o contrário: a falta de monitoramento da adequação dos controles internos relativamente ao tema.

234. Não se tratava, como visto, de uma falha pontual em um item da auditoria interna passível de ser rapidamente corrigido, mas de falha continuada e relevante em atividades tipicamente de gestão que envolvia todas as áreas da Petrobras, a demandar, como mencionado na nota emitida pelo comitê, elevado esforço de toda a Companhia. Nessas condições, a omissão completa do conselho de administração em verificar as medidas que estariam sendo tomadas pelas diretorias para evitar aquelas não-conformidades e, assim, buscar assegurar a eficiência operacional da Companhia e



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

reduzir o risco de expropriação demonstra que os conselheiros não agiram de acordo com a diligência esperadas nas circunstâncias.

235. Cabe ressaltar que a referida falha não decorria da ausência de uma política formal de controles internos, como parecem crer as defesas, mas da falta de empenho do conselho de administração de manter uma vigilância sistematizada sobre os atos de gestão que estavam mais vulneráveis a irregularidades, de modo a manter um ambiente de controles que pudesse promover a eficiência operacional e encorajar a obediência às leis, normas e regulamentos.

236. É certo que os membros do conselho de administração não eram responsáveis pela correção dos apontamentos feitos pela auditoria interna, muito menos pela elaboração de medidas para reduzir o problema, mas cabia a eles monitorar adequadamente o sistema de controles internos para que ações contra aquelas não-conformidades fossem realizadas, bem como apresentassem resultados satisfatórios para minimizar o problema, o que não restou demonstrado.

237. Ao procederem conforme apurado, os acusados contribuíram para que a má qualidade dos controles internos da Petrobras continuasse a permitir a ocorrência de irregularidades nas atividades de gestão, causando, assim, riscos para a integridade do patrimônio da Companhia, pois os controles internos buscam essencialmente assegurar que as operações da companhia sigam determinado padrão de modo a mitigar a ocorrência de possíveis desvios.

238. Nesta toada, ainda que os diretores da Petrobras tenham cometido fraudes, com a cooptação de funcionários e abuso de confiança, e que não fosse possível, em tese, identificá-las no momento de sua ocorrência, como alegam os acusados, é evidente que um sistema de controles internos inadequado para garantir a conformidade das atividades de gestão não somente permite um ambiente de descontrole e leniência com a ocorrência de descumprimento de regras, como também dificulta a sua detecção e posterior correção.

239. Diante disso, não pode prosperar a alegação feita pelas defesas de que teria havido responsabilização objetiva do conselho de administração por atos da diretoria, pois o referido órgão não está sendo acusado de ter praticado os atos de corrupção, mas de ter falhado em seu processo de vigilância geral sobre os atos de gestão praticados pelas diretorias, pois faz parte do dever de cuidado atribuído aos membros do conselho de administração assegurar o eficaz funcionamento dos sistemas de controles internos, pois, sem isso, a obrigação legal de fiscalizar a gestão dos diretores fica bastante enfraquecida.

240. E, como visto, os conselheiros não foram capazes de realizar a supervisão adequada dos controles internos da Petrobras à luz do padrão de diligência exigido pela



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

Lei nº 6.404/76, pois, mesmo após serem alertados, não se certificaram das medidas que estavam sendo tomadas e se elas eram suficientes para reduzir o impacto nas atividades de gestão das não-conformidades relatadas pela auditoria interna.

241. Nada obstante, registro que, diante da natureza, gravidade, amplitude e reiteração das condutas irregulares descritas neste processo não se sustenta a tese de que os membros do conselho de administração da Petrobras atuaram com a diligência deles esperada na adoção e supervisão das regras de controles internos proporcionais à maior companhia aberta brasileira.

242. Por tais razões, os membros do conselho de administração Dilma Vana Rousseff, Fabio Colleti Barbosa, Francisco Roberto Albuquerque, Guido Mantega, Jorge Gerdau Johannpeter, Luciano Galvão Coutinho, Silas Rondeau Cavalcante Silva e José Sergio Gabrielli de Azevedo violaram os seus deveres de cuidado previstos no art. 153 da Lei nº 6.404/76.

III.3 DESVIO DE PODER

243. Por fim, cabe examinar se a então presidente da Petrobras Graça Foster teria interferido indevidamente nos trabalhos da comissão interna responsável por apurar possíveis irregularidades nos procedimentos de contratação da construção da RNEST, em infração ao art. 154 da Lei nº 6.404/76. Segundo a SPS, a acusada teria, por meio de seus assessores, alterado o resultado final da apuração da comissão para retirar achados da auditoria relacionados à aprovação pela diretoria da fase IV do projeto RNEST, de cuja deliberação Graça Foster teria participado.

244. Em defesa, Graça Foster sustenta que a Acusação não poderia presumir, com base em uma simples conjectura, que a defendente quisesse alterar o resultado de investigações que ela própria teria solicitado a instauração. Destacou que a minuta comentada por ela não teria alterado os trabalhos da CIA RNEST, pois seria apenas um apontamento de que o trabalho não deveria fugir de seu escopo inicial. Acrescenta que inexistem, nos autos, qualquer demonstração de sua ingerência para que determinadas conclusões da investigação tivessem sido retiradas da minuta.

245. Examinando as provas dos autos, tenho que a SPS não conseguiu comprovar a sua tese acusatória.

246. O primeiro indício trazido pela Acusação para demonstrar a ingerência indevida da acusada é a indicação de uma pessoa ligada à Graça Foster, sua assessora L.M.S., para participar da CIA RNEST. Ocorre, entretanto, que esse fato, por si só, não pode ser considerado evidência suficiente de que a acusada estaria querendo influenciar os trabalhos de apuração.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

247. Como relatado, a comissão interna de apuração instaurada em 25.04.2014 tinha por objetivo avaliar os procedimentos de contratação da construção da RNEST (3.049 e 3.050), de modo que as investigações a serem iniciadas não envolvessem, a toda evidência, atos praticados pela acusada, mas sim executados no âmbito da diretoria de abastecimento e da diretoria de serviços da Petrobras. Ou seja, não havia naquele momento incompatibilidade entre o objeto da investigação e a atuação de Graça Foster como administradora da Petrobras que pudesse macular a indicação de sua assessora para compor a CIA, consoante normatização que disciplinava as comissões da Companhia (fls. 3.038-348).

248. Aliás, ainda sobre a participação de L.M.S. na CIA, a declaração de Graça Foster (fls. 3.036-3.037) de que a indicação de pessoas ligadas à presidência, ao contrário de prejudicar a independência, daria poder à comissão para inquirir diretores e presidentes de subsidiárias (05mm10ss) foi na mesma direção do depoimento do integrante da comissão P.F. (fls. 2.922), ao declarar que o papel da L.M.S. *“foi muito colaborativo para que se tivesse acesso irrestrito à documentação”* (47mm20ss).

249. Com efeito, de acordo com os depoimentos tomados pela SPS, os integrantes da comissão declararam terem tido acesso a todos os documentos solicitados, sem que houvesse embaraço de suas atividades de apuração.

250. Ademais, considerando a gravidade dos acontecimentos revelados pela “Operação Lava Jato”, com grande repercussão na imprensa, cabe reconhecer os argumentos da defesa de que seria esperado que a presidente da Petrobras acompanhasse de perto as apurações da CIA, para tomar ciência dos fatos investigados e certificar-se do progresso efetivo dos trabalhos.

251. Neste sentido foi também a declaração da assessora da presidente L.M.S. ao afirmar que reportava a Graça Foster o que entendia relevante, tal como a convocação de um gerente executivo diretamente envolvido nos atos de corrupção. No momento em que relatou fatos apurados relacionados aos aditivos dos contratos e ao EVTE da RNEST, Graça Foster teria, segundo a assessora, queixado-se da ampliação do escopo, dizendo que daquele jeito o trabalho não terminaria, orientando-a a *“manter o escopo, o escopo é até o contrato”*. Disse ainda que Graça Foster fez comentários no relatório relativamente a sua compreensão, pois ela iria explicá-lo ao conselho de administração (fls. 3.003- 3.004).

252. Graça Foster (fls. 3.036-3.037) não negou ter procurado saber das apurações e que teria orientado seus assessores a se aterem ao escopo das investigações, uma vez que, no seu sentir, a “Operação Lava Jato” não estaria interessada no EVTE da Refinaria (19mm00ss e seguintes).



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

253. Neste ponto, cabe destacar que é incontroverso que Graça Foster acompanhou o desenrolar das apurações, orientou para que os membros da comissão mantivessem o escopo da investigação, bem como fez comentários em uma minuta de relatório da comissão, cujo teor foi objeto de discussão no âmbito da CIA. Do mesmo modo, é inegável que o fato de a presidente ter feito comentários na minuta gerou desconforto entre os membros da comissão, conforme os integrantes declararam em seus respectivos depoimentos.

254. Contudo, a partir desses fatos, não restou evidenciado que ela *“agiu deliberadamente para alterar o resultado final da CIA ao impor, por meio de seus assessores, seu entendimento do que era o ‘escopo’ do trabalho”*, exorbitando suas prerrogativas de presidente da Petrobras, conforme concluiu a Acusação.

255. Isto porque, com relação ao escopo, o integrante da comissão P.F. declarou que a discussão era compreensível, pois o objeto da CIA não era, de fato, verificar o processo decisório da Companhia (27mm35ss). Do mesmo modo, ele afirmou que não seria claro se os aditivos faziam parte ou não do escopo da CIA e que certamente a comissão não deveria investigar assuntos não incluídos em seus objetivos. Desse modo, prossegue P.F., os integrantes da comissão teriam acordado em colocar os aditivos em anexo ao relatório, pois os aditivos estariam, segundo suas palavras, em um *“limiar de interpretação”* (39mm40ss).

256. Na mesma direção foi o depoimento do integrante da comissão G.L.G. (fls. 3.001-3.002) ao declarar que a decisão de retirar os aditivos do corpo do relatório e colocá-los em anexo foi tomada em consenso pelos membros da CIA (6mm20ss e seguintes) e que tal decisão não diminuiu o valor do trabalho da comissão (42mm00ss e seguintes). Também declarou que não houve interferência da presidente Graça Foster nos trabalhos da comissão (04mm33ss).

257. Isso demonstra que havia fundadas dúvidas entre os integrantes da comissão de qual seria a abrangência das investigações e o que deveria constar, ao final, do relatório da CIA. Além disso, apesar do possível desconforto que a posição defendida pela assessora da presidente pudesse causar nos demais integrantes da comissão, a decisão final foi tomada, segundo os depoimentos colhidos, em consenso por seus membros.

258. Nesta toada, embora não se possa negar o caráter inconveniente da acusada Graça Foster ter feito comentários na minuta do relatório da comissão, não é possível afirmar, com a convicção necessária para uma condenação, que esses comentários tenham tido efeito modificativo nas conclusões da comissão. Também não restou demonstrado que Graça Foster tenha ferido a independência da CIA, obstaculizado as investigações ou frustrado os objetivos da referida comissão, de modo a ser possível caracterizar o desvio de poder de que trata o art. 154 da Lei das S/A.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

259. A propósito, cabe reconhecer que o relatório produzido pela CIA apenso às fls. 1.243 e seguintes do presente processo é destacado elemento de prova pelo qual foi possível evidenciar a falta de justificativa para amparar a deliberação que aprovou o PAR da RNEST, assim como identificar suas consequências deletérias para a Companhia, colaborando sobremaneira para a elucidação dos fatos irregulares relacionados à construção da Refinaria.

260. Por todo exposto, tenho que os elementos de prova colacionados pela SPS não são suficientes para demonstrar que a acusada logrou obstaculizar a investigação da CIA para satisfazer o seu interesse pessoal, em detrimento dos interesses da Petrobras, não restando, por isso, configurados os requisitos de dolo e culpa necessários para a caracterização do ilícito.

IV. CONCLUSÃO

261. Por todo o exposto, com fundamento no art. 11 da Lei nº 6.385/76, considerando a gravidade das infrações, os antecedentes dos Acusados, os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade e a capacidade econômica dos infratores, assim como a alta dispersão acionária da Companhia e grande volume de negócios, além dos danos à imagem da Petrobras e do mercado de valores mobiliários, voto pela condenação de:

- a. **Almir Guilherme Barbassa³⁶, Guilherme de Oliveira Estrella, Ildo Luís Sauer, José Sérgio Gabrielli de Azevedo, Nestor Cuñat Cerveró³⁷ e Renato de Souza Duque**, na qualidade de diretores estatutários da Petrobras, **à penalidade de multa pecuniária individual no valor de R\$400.000,00 (quatrocentos mil reais)**, por terem faltado com o seu dever de diligência, ao aprovar o Plano de Antecipação da Refinaria, em infração ao art. 153 da Lei nº 6.404/76.
- b. **Almir Guilherme Barbassa, Guilherme de Oliveira Estrella, Maria das Graças da Silva Foster, José Sérgio Gabrielli de Azevedo e Jorge Luíz Zelada³⁸**, na qualidade de diretores estatutários da

³⁶ O acusado **Almir Guilherme Barbassa** foi condenado ao pagamento de multa de R\$300 mil no âmbito do PAS nº RJ2014/03402, julgado pelo Colegiado da CVM em 13.12.2018. O recurso interposto pelo acusado contra essa decisão encontra-se pendente de julgamento no CRSFN.

³⁷ O acusado **Nestor Cuñat Cerveró** foi condenado à inabilitação temporária por 15 anos para o exercício de cargo de administrador ou de conselheiro fiscal de companhia aberta, assim como ao pagamento de multas que somam R\$1,2 milhão no âmbito do PAS nº 08/2016, julgado em 16.12.2019.

³⁸ O acusado **Jorge Luiz Zelada** foi condenado à inabilitação temporária por 18 anos para o exercício de cargo de administrador ou de conselheiro fiscal de companhia aberta e ao pagamento de multa de R\$500



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Petrobras, à **penalidade de multa pecuniária individual no valor de R\$400.000,00 (quatrocentos mil reais)**, por terem faltado com o seu dever de diligência, ao aprovar a passagem do projeto RNEST à fase IV, em infração ao art. 153 da Lei nº 6.404/76.

- c. **José Sérgio Gabrielli de Azevedo, Fabio Colletti Barbosa, Francisco Roberto de Albuquerque, Guido Mantega, Jorge Gerdau Johannpeter, Luciano Galvão Coutinho, Sergio Franklin Quintella e Silas Rondeau Cavalcante Silva**, na qualidade de membros do conselho de administração da Petrobras, à **penalidade de multa pecuniária individual no valor de R\$400.000,00 (quatrocentos mil reais)**, por terem faltado com o seu dever de diligência, ao participarem do processo de decisão que aprovou a passagem do projeto RNEST à fase IV, em infração ao art. 153 da Lei nº 6.404/76.
- d. **Dilma Vana Rousseff, José Sérgio Gabrielli de Azevedo, Fabio Colletti Barbosa, Francisco Roberto de Albuquerque, Guido Mantega, Jorge Gerdau Johannpeter, Luciano Galvão Coutinho e Silas Rondeau Cavalcante Silva**, na qualidade de membros do conselho de administração da Petrobras, à **penalidade de multa pecuniária individual no valor de R\$300.000,00 (trezentos mil reais)**, por terem faltado com o seu dever de diligência na supervisão dos controles internos da Petrobras, em infração ao art. 153 da Lei nº 6.404/76.
- e. **Renato de Souza Duque**, na qualidade de diretor de engenharia e serviços da Petrobras, à **penalidade de inabilitação temporária pelo prazo de 15 (quinze) anos**, para o exercício do cargo de administrador ou conselheiro fiscal de companhia aberta, por ter violado o seu dever de lealdade, ao votar favoravelmente pela aprovação da passagem do projeto RNEST à fase IV, em troca de vantagens indevidas, em infração ao art. 154, §2º, c) da Lei nº 6.404/76 c/c art. 155, *caput* da Lei nº 6.404/76.
- f. **Paulo Roberto Costa**, na qualidade de diretor de abastecimento da Petrobras:
- i. à **penalidade de inabilitação temporária pelo prazo de 15 (quinze) anos**, para o exercício do cargo de administrador ou conselheiro fiscal de companhia aberta, por ter violado o seu dever

mil, no âmbito do PAS nº 09/2016, julgado em 16.12.2019. O recurso interposto pelo acusado contra essa decisão encontra-se pendente de julgamento no CRSFN.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

de lealdade, ao propor e votar favoravelmente pela aprovação do Plano de Antecipação da Refinaria, em troca de vantagens indevidas, em infração ao art. 154, §2º, c) da Lei nº 6.404/76 c/c art. 155, *caput* da Lei nº 6.404/76.

- ii. **à penalidade de multa pecuniária no valor de R\$500.000,00 (quinhentos mil reais)**, por ter violado o seu dever de lealdade, ao propor e votar favoravelmente pela aprovação da passagem do projeto RNEST à fase IV, em troca de vantagens indevidas, em infração ao art. 154, §2º, c) da Lei nº 6.404/76 c/c art. 155, *caput* da Lei nº 6.404/76.

262. Voto também pela **absolvição de Maria das Graças Silva Foster**, na qualidade de presidente da Petrobras, da acusação de desvio de poder que lhe foi formulada neste processo.

É como voto.

Rio de Janeiro, 24 de agosto de 2020.

HENRIQUE BALDUINO MACHADO MOREIRA
DIRETOR RELATOR



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM Nº 05/2016

(Processo Eletrônico SEI nº 19957.010647/2019-97)

Reg. Col. nº 1404/2019

Acusados:	Almir Guilherme Barbassa	José Sérgio Gabrielli de Azevedo
	Dilma Vana Rousseff	Luciano Galvão Coutinho
	Fábio Colletti Barbosa	Maria das Graças Silva Foster
	Francisco Roberto de Albuquerque	Nestor Cuñat Cerveró
	Guido Mantega	Paulo Roberto Costa
	Guilherme de Oliveira Estrella	Renato de Souza Duque
	Ildo Luís Sauer	Sergio Franklin Quintella
	Jorge Gerdau Johannpeter	Silas Rondeau Cavalcante Silva
	Jorge Luiz Zelada	

Assunto: Apurar possível inobservância de deveres fiduciários de administradores da Petrobras na construção da Refinaria Abreu e Lima. Infrações aos artigos 153, 154, §2º, “c”, 155, e 163, I, da Lei nº 6.404/1976.

Relator: Diretor Henrique Machado

Voto: Diretor Gustavo Machado Gonzalez

MANIFESTAÇÃO DE VOTO

I. INTRODUÇÃO

I.1. Resumo das divergências

1. Preparei esta manifestação de voto para registrar três divergências com relação ao voto proferido pelo Diretor Relator.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil - Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

2. A primeira divergência se refere ao alcance do artigo 1º, §2º, da Lei nº 9.873/1999, que, em caráter excepcional, substitui o prazo prescricional quinquenal ordinariamente aplicável para o exercício de ação punitiva pela administração pública federal pelos prazos previstos na lei penal “quando o fato objeto da ação punitiva da Administração também constituir crime”. Em linha com a jurisprudência dessa casa¹, entendo que, no presente processo, o prazo prescricional da lei penal somente pode ser aplicado às infrações de falta com o dever de lealdade para com a Companhia imputadas a Paulo Roberto Costa e a Renato de Souza Duque, pois tais condutas são as únicas que, ao mesmo tempo, configuram infração administrativa e ilícito penal. Assim, entendo prescrita a acusação de falta de diligência feita contra Renato de Souza Duque e demais integrantes da diretoria da Petrobras² na aprovação, em 08.03.2007, do Plano de Antecipação da Refinaria (“PAR”), pois a reunião ocorreu mais de cinco anos antes do primeiro ato praticado pela área técnica apto a interromper o prazo prescricional em relação a essa infração.

3. A segunda divergência se refere ao mérito da acusação de falta de diligência formulada contra os diretores e membros do conselho de administração da Petrobras que participaram das reuniões desses órgãos em que se tratou da mudança de fase do projeto RNEST. Trata-se de decisão de conteúdo nitidamente negocial e que deve ser analisada à luz da regra da decisão negocial (*business judgment rule*), uma vez que a Acusação não trouxe evidências de má-fé, desvio ou fraude. Pelos motivos a seguir detalhados, não me parece possível concluir, com base nas informações constantes dos autos, que a decisão questionada não foi, *sob o ponto de vista do procedimento*, tomada de modo informado, refletido e desinteressado.

4. A terceira e última divergência se refere ao mérito da acusação de falta de diligência na supervisão dos controles internos da Petrobras. Embora não tenha dúvidas quanto à responsabilidade do conselho de administração por zelar para que a companhia tenha controles internos eficazes, parece-me que a Acusação, nesse caso, construiu o seu raciocínio de trás para a frente, partindo da constatação de que a companhia sofreu vultuosos prejuízos em contratos para, a partir daí, concluir que havia uma falha sistemática que poderia ser,

¹ PAS CVM nº 08/2016 e PAS CVM nº 09/2016, ambos de minha relatoria e julgados em 16.12.2019, e PAS CVM nº 14/2010, relatado pelo Diretor Henrique Machado e julgado em 03.03.2020.

² Os termos iniciados em letra maiúscula utilizados nesta manifestação de voto e que não estiverem aqui definidos têm o significado que lhes foi atribuído no relatório apresentado pelo Diretor Relator.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil - Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

inclusive, imputada à falta de diligência do conselho. Creio que existe uma lente específica para sindicatar o dever de fiscalizar do conselho de administração e que a acusação, no caso, não sobrevive a um exame feito a partir do teste apropriado.

1.2. Breves considerações iniciais

O que julgamos nesse caso e no que consistem as acusações de falta de diligência

5. O caso em análise decorre de apurações feitas pela área técnica da CVM para verificar se o insidioso esquema fraudulento descortinado pela Operação Lava-Jato envolveu violações aos dispositivos legais e regulamentares cujo cumprimento cabia a esta autarquia fiscalizar.

6. Os processos com esse *pedigree* vêm recebendo uma atenção que raramente é dispensada aos processos desta casa. Creio que essa notoriedade não é inerentemente positiva ou negativa, muito embora ela traga a reboque desafios adicionais, tanto para o julgamento do caso quanto para a sua compreensão e comunicação.

7. Por esse motivo, antes de explicar em pormenores as razões das minhas divergências, quero relembrar no que consiste – *e no que não consiste* – este caso.

8. Começo ressaltando que não há uma correspondência perfeita entre as ações criminais da Lava-Jato e os processos administrativos instaurados pela CVM. Ao contrário, os processos instaurados nesta e naquela instância se distinguem tanto no que se refere à identidade dos acusados, quanto no tocante às condutas apuradas.

9. Essa falta de identidade pode ser creditada a dois fatores: **(i)** em primeiro lugar, ao fato de que nem toda conduta tipificada como crime consiste, também, em uma infração administrativa (sobretudo de competência da CVM), sendo a recíproca também verdadeira; **(ii)** em segundo lugar, ao fato de que a lei atribui à CVM competência para sancionar irregularidades praticadas por um conjunto restrito de pessoas: “administradores, membros do conselho fiscal e acionistas de companhias abertas, [os] intermediários e [os] demais participantes do mercado”³.

10. Assim, não deve causar espanto que certas pessoas tenham sido acusadas apenas na esfera penal ou na esfera administrativa. E, o que é mais importante para as discussões que

³ Art. 9º, V, da Lei nº 6.385/1976.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil - Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

serão travadas a seguir, é necessário entender que nem todas as acusações formuladas pela área técnica da CVM estão relacionadas aos crimes apurados na Operação Lava-Jato.

11. Este processo ilustra bem o que acabo de dizer, pois envolve sete acusações⁴, das quais apenas duas estão diretamente relacionadas a condutas consideradas criminosas pela Operação Lava-Jato. Trata-se das acusações formuladas contra Paulo Roberto Costa e Renato de Souza Duque de violar aos artigos 154 e 155 em razão de terem, na qualidade de diretores estatutários da Companhia, aprovado, em troca de vantagens indevidas, a passagem do projeto RNEST à fase IV e, no caso de Paulo Roberto da Costa, também pela aprovação do PAR. Com relação a essas acusações, acompanho o voto do Diretor Relator.

12. As minhas divergências se referem justamente a acusações que não estão diretamente associadas à prática de um crime, ao concurso para a prática de um crime ou mesmo à prática voluntária de qualquer irregularidade administrativa. São imputações de falta de diligência formuladas contra administradores que, segundo a própria Acusação, não participaram nem de qualquer modo contribuíram voluntariamente para a prática dos atos de corrupção. Cabe ressaltar que as conclusões da área técnica nesse aspecto estão em linha com as das autoridades do Ministério Público e do Poder Judiciário, que se debruçaram longamente sobre os fatos aqui analisados e, até o presente momento, não ofereceram denúncia criminal em desfavor dos demais diretores pelos fatos analisados neste processo.

13. Compreender no que consistem e no que não consistem as acusações de falta de diligência formuladas contra os diretores da Petrobras neste processo é suficiente para demonstrar a absoluta improcedência de alguns argumentos que vez por outra surgem em comentários sobre os julgamentos dos processos da CVM relacionados aos escândalos da Lava-Jato. Por exemplo, o de que qualquer decisão que não a condenação exemplar dos acusados de falta de diligência denotaria tolerância com administradores coniventes com a fraude ou mesmo partícipes de esquemas ilícitos. Ora, não se pode em hipótese alguma admitir esse tipo de argumento, uma vez que ele pressupõe condenar pessoas por

⁴ Considerando separadamente as acusações feitas aos diferentes órgãos/pessoas: (1) diligência na aprovação do PAR pela Diretoria; (2) diligência na aprovação da fase IV pela Diretoria; (3) diligência na aprovação da fase IV pelo C.A.; (4) diligência na supervisão dos controles internos pelo C.A.; (5) lealdade na aprovação do PAR por Paulo Roberto Costa; (6) lealdade na aprovação da fase IV por Paulo Roberto Costa e Renato Duque; e (7) desvio de poder por Maria das Graças Silva Foster.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil - Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

irregularidades que não lhes foram imputadas, o que, a toda evidência, não se admite no Estado de Direito.

14. Assim, ainda que, em nosso íntimo, acreditemos que os administradores acusados por falta de diligência (ou ao menos alguns deles) concorreram, ainda que de modo negligente, para a prática dos graves crimes que acarretaram vultosos prejuízos à Petrobras e à economia brasileira, não podemos julgar essas pessoas com base em conjecturas ou notícias de jornal; nosso dever, repito, é analisar as imputações efetivamente formuladas à luz das provas constantes dos autos.

Os riscos dos casos notórios

15. O que acabo de dizer não deveria causar nenhuma surpresa. Afinal de contas, o julgamento de um processo sancionador consiste no exame de uma acusação específica a partir das provas constantes dos autos. Há, contudo, um terceiro elemento que ainda não foi mencionado, mas que é igualmente importante para a segurança jurídica: a aplicação consistente das normas de direito aplicáveis.

16. Com efeito, de pouco valeria que o julgador não pudesse inovar com relação ao que disse a acusação e ao que consta nos autos se lhe fosse permitido reinterpretar as normas sempre de modo diferente, conforme o resultado que desejasse atingir no caso concreto. O Direito não se faz de trás para a frente, seguindo o senso comum.

17. E é por esse motivo que o julgamento de casos rumorosos tem desafios próprios, que decorrem da força que o senso comum exerce em todos nós, inclusive nós julgadores. Ele trabalha para que nos sintamos comprometidos a chegar a uma determinada decisão, independentemente de como julgaríamos aquele mesmo caso se não estivéssemos sujeitos àquela influência.

18. Nesse ponto, lembro o célebre voto vencido do Justice Oliver Wendell Holmes:

“Great cases like hard cases make bad law. For great cases are called great, not by reason of their importance in shaping the law of the future, but because of some accident of immediate overwhelming interest which appeals to the feelings and distorts the judgement. These



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

immediate interest exercise a kind of hydraulic pressure which makes what previously was clear seem doubtful, and before which even well settled principles of law will bend.”⁵

19. O Direito não pode vergar em função do peso de um caso. Assim, a revolta que escândalos como o da Petrobras nos causa (justificadamente) como cidadãos, não nos autoriza, no papel de julgadores, a alterar a maneira como consistentemente julgamos.

20. Esses comentários não devem ser de modo algum interpretados como críticas aos argumentos constantes do voto do Relator – voto que, aliás, é mais um testemunho do modo cuidadoso e minudente com que o Diretor Henrique Machado analisa os seus processos. Eles buscam, em verdade, registrar algumas das dificuldades que tive na análise do caso e as razões que me levaram, ao final, a divergir em duas questões de mérito. Isto porque minhas reflexões acerca do modo como acusações de dever de diligência devem ser analisadas acabaram por me levar a concluir, contrariamente ao que me pareceu em um primeiro contato com os feitos, que condenar os administradores acusados por violação ao artigo 153 da Lei nº 6.404/1976 seria julgar essas acusações de modo diferente daquele com que a CVM vem consistentemente, já há muitos anos, analisando outros casos similares (ainda que indubitavelmente menos famosos).

21. Explicarei melhor esse ponto nas Partes III e IV deste voto, em que examino as acusações de falta de diligência na mudança de fase do projeto RNEST e na supervisão dos controles internos, especialmente nas seções III.1 e IV.2, em que discuto os padrões de revisão adequados para cada uma dessas acusações. Antes é necessário explicitar a minha divergência relativa à incidência da prescrição.

II. PRESCRIÇÃO DA ACUSAÇÃO DE FALTA DE DILIGÊNCIA NA APROVAÇÃO DO PAR: IMPOSSIBILIDADE DO USO DOS PRAZOS PRESCRICIONAIS DA LEI PENAL PARA FATOS QUE NÃO CONSTITUEM CRIME

II.1. O uso dos prazos prescricionais da lei penal nos processos administrativos sancionadores: considerações iniciais

22. Segundo a Lei nº 9.873/1999, a pretensão punitiva da Administração Pública Federal prescreve em cinco anos contados da data da prática do ato ou, no caso de infração

⁵ Northern Securities Co. v. United States, 193 U.S. 197, 400-411 (1904).



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil - Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado (artigo 1º, *caput*). Excepcionalmente, “quando o fato objeto da ação punitiva da Administração também constituir crime, a prescrição reger-se-á pelo prazo previsto na lei penal” (artigo 1º, §2º).

23. A Lei Penal, por sua vez, não estabelece um prazo prescricional único. Esse é calculado com base na sanção penal em abstrato, nos termos do artigo 109 do Código Penal⁶, ou seja, varia de acordo com o crime imputado.

24. Durante anos, prevaleceu o entendimento de que a existência de um inquérito policial ou de uma ação penal seria pré-requisito para que a administração pública pudesse se utilizar do prazo prescricional penal nos processos administrativos sancionadores. Recentemente, os tribunais superiores adotaram nova interpretação sobre o tema, passando a entender que a autoridade encarregada de conduzir o processo administrativo poderia considerar os prazos da lei penal independentemente de haver alguma movimentação na esfera criminal.

25. A nova interpretação fundamenta-se na autonomia das instâncias e no fato de que “o lapso prescricional não pode variar ao talante da existência ou não de apuração criminal, justamente pelo fato de a prescrição estar relacionada à segurança jurídica. Assim, o critério para fixação do prazo prescricional deve ser o mais objetivo possível – justamente o previsto no dispositivo legal referido –, e não oscilar de forma a gerar instabilidade e insegurança jurídica para todo o sistema”⁷.

26. É importante destacar que as decisões dos tribunais superiores não discutem o uso dos prazos prescricionais da lei penal em processos administrativos sancionadores regidos pela Lei nº 9.873/1999, mas em ações disciplinares contra servidores públicos civis da União, das autarquias e das fundações públicas federais, regidas pela Lei nº 8.112/1990. Consolidou-se, contudo, o entendimento de que as conclusões daqueles julgados sobre os requisitos para incidência do artigo 142, §2º, da Lei nº 8.112/1990 valeriam, também, para

⁶ Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no §1º do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se: I - em vinte anos, se o máximo da pena é superior a doze; II - em dezesseis anos, se o máximo da pena é superior a oito anos e não excede a doze; III - em doze anos, se o máximo da pena é superior a quatro anos e não excede a oito; IV - em oito anos, se o máximo da pena é superior a dois anos e não excede a quatro; V - em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois; VI - em 3 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano.

⁷ STJ, EDv nos Embargos de Divergência em REsp nº 1.656.383 – SC (2015/0262731-9), Primeira Seção, Rel. Ministro Gurgel de Faria, j. em 27.06.2018.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil - Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

a incidência do artigo 1º, §2º, da Lei nº 9.873/1999. Afinal de contas, os fundamentos daquelas decisões – autonomia das instâncias e segurança jurídica – são igualmente válidos para discussões sobre os processos administrativos sancionadores e, o que é bastante importante, os dispositivos de ambos os diplomas legais têm, ao menos no que lhes é mais essencial, conteúdo equivalente.

27. Dito isso, o fato de as decisões dos tribunais superiores terem se referido ao uso do prazo prescricional da lei penal em processos disciplinares contra servidores públicos não autoriza a concluir que os prazos da lei penal podem ser aplicados a condutas que não configurem crime. Ao contrário. Afinal de contas, o 142, §2º, da Lei nº 8.112/1990 é bastante claro ao estabelecer que “os prazos de prescrição previstos na lei penal aplicam-se às infrações disciplinares capituladas também como crime”.

28. Vê-se, portanto, que a recente mudança na interpretação dos tribunais superiores não tem real relevância para a análise acerca do alcance do artigo 1º, §2º, da Lei nº 9.873/1999 que tem sido travada nos casos instaurados pela CVM a partir de informações obtidas na Operação Lava-Jato. A uma, porque nesses casos a atuação da CVM se iniciou após as apurações na esfera criminal, a partir de documentos produzidos naquela instância. A CVM, é importante destacar, não fez nenhuma alegação de que crimes não apurados na esfera penal foram praticados, mas buscou se valer do prazo prescricional dos crimes apurados na esfera criminal também para condutas que, no julgamento da área técnica – e também do Ministério Público e do Poder Judiciário –, não configuraram crime. A duas, porque a tese acusatória não se baseia em uma independência de instâncias para aplicação dos prazos prescricionais da lei penal, mas na aplicação dos prazos penais a condutas que não configuram crime.

29. Sobre esse ponto, até onde sei, os tribunais superiores ainda não se manifestaram expressamente, muito embora me pareça claro que a mudança de entendimento acima referida foi apenas para reconhecer a autonomia das atividades administrativas para subsumir condutas aos tipos penais e, nesse caso, aplicar os prazos prescricionais da lei penal. Tenho plena convicção de que, se vierem a enfrentar esse ponto, os tribunais chegarão à mesma conclusão que vem prevalecendo nesta casa. Afinal de contas, a tese acusatória gera instabilidade e insegurança jurídica para todo o sistema, justamente os problemas que o atual entendimento dos tribunais superiores buscam remediar. É o que buscarei demonstrar na próxima seção deste voto.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil - Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

II.2. O uso dos prazos prescricionais da lei penal nos processos administrativos sancionadores: inteligência do artigo 1º, §2º, da Lei nº 9.873/1999

30. Há uma divergência na CVM quanto ao alcance do artigo 1º, §2º, da Lei nº 9.873/1999. Em linha com a área técnica, o Relator defende que o “fato” a que a lei se refere remete ao contexto fático em que o ilícito foi praticado e que, portanto, quando há um crime, o prazo de prescrição da ação penal pode ser estendido, inclusive, para os acusados na esfera administrativa cujas condutas, mesmo em tese, não configuram crime. De outro lado, a maioria do Colegiado entende que o artigo 1º, §2º, da Lei nº 9.873/1999 aplica-se apenas aos fatos que, ao mesmo tempo, violam um comando administrativo e a lei penal⁸.

31. A análise dos precedentes acima referidos indica que a divergência decorre, sobretudo, da interpretação do que seria “fato” para fins do disposto no §2º do artigo 1º da Lei nº 9.873/1999. Não há dúvidas de que a regra do artigo 1º, §2º, da Lei nº 9.873/1999 aplica-se somente ao fato que, simultaneamente, é punível nas esferas administrativa e penal. O texto da lei não admite outra interpretação: “quando o fato objeto da ação punitiva da Administração também constituir crime”.

32. A lei não se refere, contudo, a qualquer fato, mas ao fato objeto da ação punitiva da administração que constitui crime. Assim, a interpretação do §2º do artigo 1º da Lei nº 9.873/1999 deve ser conduzida a partir de duas questões. Qual o fato objeto da ação punitiva da administração? E quando esse fato constitui crime?

33. Começando pela primeira questão, noto que o artigo 1º, §2º, da Lei nº 9.873/1999 não se refere à *apuração administrativa*, mas à *ação punitiva* da administração. Não se trata de uma mera questão de precedência. No âmbito da CVM, apuram-se os fatos – e o vocábulo, aqui, pode ser interpretado em sua acepção geral – para verificar se existem indícios de autoria e materialidade que suportem uma acusação. O fato objeto da ação punitiva da administração é necessariamente uma conduta que viole dispositivos legais ou regulamentares sujeitos à fiscalização da CVM. Toda acusação da CVM está – ou deveria estar – associada a uma conduta, comissiva ou omissiva, violadora de uma lei ou de um normativo. É esse o fato objeto da ação punitiva da administração.

⁸ V. as já referidas decisões nos PAS CVM nº 08/2016, 09/2016 e 14/2010.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil - Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

34. Não há, portanto, necessária identidade entre o fato objeto da apuração administrativa e o fato objeto da ação punitiva da CVM. Em muitos casos, a área técnica conclui, ao final da apuração, pela inexistência de irregularidades ou, ao menos, de provas suficientes para formular a acusação. Pode, ainda, concluir pela ocorrência da extinção de punibilidade. Em outras situações, as áreas técnicas concluem pela existência de uma infração a dispositivos legais e regulamentares sujeitos à fiscalização da CVM. As acusações estão nesse grupo, mas vale lembrar que nem toda infração apurada resulta em uma acusação – a pretensão punitiva pode estar prescrita, ou a área técnica pode concluir pela “pouca relevância da conduta, a baixa expressividade da ameaça ou da lesão ao bem jurídico tutelado e a possibilidade de utilização de outros instrumentos ou medidas de supervisão que julgarem mais efetivos”⁹.

35. Sabe-se, ademais, que nem toda conduta que configura infração administrativa constitui, também, um ilícito penal. Assim, a CVM quando apura uma irregularidade pode se deparar com fatos que somente caracterizam infrações administrativas, fatos que constituem crimes, mas que não caracterizem infração administrativa relacionada ao mercado de valores mobiliários¹⁰, ou, por fim, fatos que, simultaneamente, configuram infração administrativa e um ilícito penal. O texto da lei não deixa dúvida de que somente essa última hipótese – “quando o fato objeto da ação punitiva da Administração também constituir crime” – que está coberta pelo artigo 1º, §2º, da Lei nº 9.873/1999.

36. Assim, não se pode dizer que a regra do §2º do artigo 1º da Lei nº 9.873/1999 abarca todos os fatos objeto de apuração administrativa sob pena de se alterar o conteúdo da lei. Do mesmo modo que o intérprete não pode distinguir onde a lei não distingue, ele também não pode equiparar onde a lei diferencia. O prazo prescricional previsto na lei penal somente se aplica no âmbito administrativo quando o fato objeto da ação punitiva da administração – que, como visto, é conduta, comissiva ou omissiva, violadora de uma lei ou de um normativo

⁹ Artigo 9º, § 4º, da Lei nº 6.385/1976.

¹⁰ Nesses casos, o dever da Autarquia se encerra com a comunicação dos fatos às autoridades competentes. A esse respeito, o artigo 9º da Lei Complementar nº 105/2001 – “Quando, no exercício de suas atribuições, o Banco Central do Brasil e a Comissão de Valores Mobiliários verificarem a ocorrência de crime definido em lei como de ação pública, ou indícios da prática de tais crimes, informarão ao Ministério Público, juntando à comunicação os documentos necessários à apuração ou comprovação dos fatos. (...) §2º Independentemente do disposto no caput deste artigo, o Banco Central do Brasil e a Comissão de Valores Mobiliários comunicarão aos órgãos públicos competentes as irregularidades e os ilícitos administrativos de que tenham conhecimento, ou indícios de sua prática, anexando os documentos pertinentes.”



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil - Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

sujeitos à fiscalização, no caso em tela, da CVM – também constitui crime.

37. E assim, chegamos à segunda questão: quando o fato objeto da ação punitiva da administração também constitui crime? A resposta necessariamente está associada à conduta, pois ainda que o conceito de fato que constitui crime fosse mais amplo – mas desde já adianto: não é –, o fato objeto da ação punitiva da administração, como visto, é sempre uma conduta e o dispositivo em comento aplica-se, somente, ao fato que, ao mesmo tempo, é objeto da ação punitiva da administração e constitui crime.

38. Dito isso, não vejo como entender que o fato que constitui crime possa ser qualquer outra coisa que não uma conduta. Por estarmos falando de crime, devemos necessariamente nos socorrer no Direito Penal, que emprega o vocábulo “fato” para se referir a uma conduta humana, decorrente de uma ação ou omissão, expressamente proibida pela lei – fato típico, antijurídico e culpável¹¹. É esse, portanto, o fato que configura crime¹².

39. A tese vencida peca por se prender à acepção comum do vocábulo “fato”, ignorando que, no dispositivo, é utilizado em sua acepção técnica. O texto da lei é sempre o ponto de partida para a atividade exegetica, mas o bom hermeneuta não ignora que certos termos são empregados na linguagem jurídica com um significado específico. Sobre esse ponto, vejam

¹¹ “Da exposição feita sobre o bem jurídico protegido e das conclusões a que então se chegou, extrai-se, sem muito esforço, que, substancialmente, o crime é um fato humano que lesa ou expõe a perigo bens jurídicos (jurídico-penalmente) protegidos. Essa definição é, porém, insuficiente para a dogmática penal, que necessita de outra mais analítica, apta a pôr à mostra os aspectos essenciais ou os elementos estruturais do conceito de crime. E dentre as várias definições analíticas que têm sido propostas por importantes penalistas, parece-nos mais aceitável a que considera as três notas fundamentais do fato-crime, a saber: ação típica (tipicidade), ilícita ou antijurídica (ilicitude) e culpável (culpabilidade). O crime, nessa concepção que adotamos, é, pois, ação típica, ilícita e culpável. (...) Do que foi dito, conclui-se que a base fundamental de todo fato-crime é um comportamento humano (ação ou omissão). Mas para que esse comportamento humano possa aperfeiçoar-se como um verdadeiro crime será necessário submetê-lo a uma tríplice ordem de valoração: tipicidade, ilicitude e culpabilidade. Se pudermos afirmar de uma ação humana (a ação, em sentido amplo, compreende a omissão, sendo, pois, por nós empregado o termo como sinônimo de comportamento, ou de conduta) que é típica, ilícita e culpável, teremos um fato-crime caracterizado, ao qual se liga, como consequência, a pena criminal e/ou medidas de segurança.” TOLEDO, Francisco de Assis. *Princípios Básicos de Direito Penal*. 5ª ed. Saraiva: São Paulo, 1994, pp. 80-82.

¹² Paulo José da Costa Jr. destaca que “fato” é um termo empregado para se referir ao aspecto material do crime: “Principiaremos por convergir nossa atenção para a conduta (ativa ou omissiva), primeiro turno conectável da relação referida. A seguir o evento, termo derivado da conduta, enquanto consequência que a ela se atribui. Por último, o nexo causal objetivo, que relaciona antecedente e consequente. A soma destas três componentes (conduta, evento e nexo causal) constitui o fato, que é o aspecto ou material do crime”. COSTA Jr, Paulo José da. *Curso de Direito Penal*. Vol. I. 1ª ed. Saraiva: São Paulo, 1991, p. 41.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

o que diz Larenz:

“Os termos que obtiveram na linguagem jurídica um significado específico (...) são usados nas leis, na maioria das vezes, com este significado especial. Deste modo eliminam-se inúmeras variantes de significado do uso linguístico geral e o círculo dos possíveis significados, adentro do qual se há-de proceder a selecção com base noutros critérios, estreita-se em grande medida. Com o esclarecimento do uso linguístico jurídico preciso, a interpretação pode, em certas ocasiões, chegar ao seu termo, a saber, quando nada indicie no sentido de que a lei se desviou, precisamente nesta passagem, daquele uso”¹³.

40. O próprio verbo empregado no §2º do artigo 1º da Lei nº 9.873/1999 – constituir – reforça a conclusão de que o vocábulo “fato” se refere a uma conduta específica e não a toda e qualquer conduta praticada por quem quer que seja em determinado contexto. Se o legislador tivesse tido a intenção de abarcar, naquela regra, todas as condutas relacionadas a um determinado “fato” (aqui entendido em seu significado literal e não em sua acepção técnica), o verbo teria que ser outro, como por exemplo “envolver”, pois, a toda evidência, o contexto fático não pode constituir crime.

41. Diante de todo o exposto, penso que a análise textual do §2º do artigo 1º da Lei nº 9.873/1999 demonstra que, ao contrário do que alega a tese vencida, a interpretação aqui defendida – e que vem prevalecendo na CVM – não distorce o significado do vocábulo “fato” empregado no citado dispositivo; ao revés, é a outra tese que, para defender uma interpretação literal, distorce não só todo o resto do comando como, também, subverte a lógica do direito penal.

42. Uma análise sistemática da legislação também evidencia que essa é a interpretação mais consistente. A expressão “quando o fato constituir crime” é de uso bastante comum pelo legislador, bem como o de outras expressões que contenham verbos com o mesmo significado, como considerar ou configurar. Por exemplo, o Código Penal determina que “ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixa de considerar crime” (artigo 2º). O mesmo diploma prevê diversos tipos penais aplicáveis “se o fato não constitui crime mais grave” (artigos 132, 163, 218-C, 238, 314, 325 e 337), norma idêntica à prevista no artigo 154-A que utilizou o termo conduta: “se a conduta não constitui crime mais grave”. O teor

¹³ LARENZ, Karl. *Metodologia da Ciência do Direito*, 3ª ed. Lisboa: Fundação Calouste Gulbekian, 1997, P. 452.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil - Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

desse último dispositivo é forte evidência de que a legislação penal muitas vezes emprega “fato” e “conduta” como equivalentes. Também no direito administrativo, a Lei nº 8.112/1990 prevê que “quando o fato narrado não configurar evidente infração disciplinar ou ilícito penal, a denúncia será arquivada, por falta de objeto” (artigo 144, parágrafo único).

43. A jurisprudência também confirma essa interpretação. Veja-se que as decisões do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal Regional Federal da 2º Região citadas pelo Relator expressamente se referem a condutas:

STJ

ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE. **CONDUTA** TAMBÉM TIPIFICADA COMO **CRIME**. PRESCRIÇÃO. CÓDIGO PENAL. PENA EM ABSTRATO. OBSERVÂNCIA. (EDv nos EREsp 1656383/SC, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 27/06/2018, DJe 05/09/2018)

TRF 2º Região

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMPROBIDADE. RECEITA FEDERAL. FAVORECIMENTO ILÍCITO. RECEBIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. FUNDAMENTAÇÃO. PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA. (...) 5. No tocante à alegada prescrição, considerando que as **condutas** narradas pelo MPF, **imputadas à agravante, também são tipificadas como ilícito criminal**, é aplicável à espécie o comando contido no art. 142, I, §2º da Lei nº 8.112/90 e art. 109, II do Código Penal, haja vista que, conforme apontou o Juízo a quo, “os fatos narrados pelo MPF também se encontram tipificados no Código Penal, artigos 288, 317 e 333”, que apresentam pena máxima, em abstrato, de 12 (doze) anos de reclusão. (...) (Agravado de Instrumento 0003078-77-2018.4.02.0000, Rel. ALCIDES MARTINS, 5ª TURMA ESPECIALIZADA, julgado em 12/07/2018, DJe 16/07/2018)

44. As decisões acima referem-se à regra de substituição da Lei nº 8.112/1990 (art. 142), já mencionada na seção anterior deste voto. Embora, como já mencionado em outra oportunidade¹⁴, entenda que, a despeito das diferentes redações, o artigo 1º, §2º, da Lei nº

¹⁴ Nos julgamentos dos PAS 08/2016 e 09/2016, destaquei que “não me parece adequado concluir que o termo ‘fato’ deva ser interpretado de modo extensivo com base na contraposição entre o texto do artigo 1º, §2º, da Lei nº 9.873/1999 e o do artigo 142 da Lei nº 8.112/1990, segundo o qual ‘os prazos de prescrição previstos na lei penal aplicam-se às infrações disciplinares capituladas também como crime’. A meu ver, a divergência decorre de um aperfeiçoamento de redação nas leis mais recentes – e aqui me refiro não só à Lei nº 9.873/1999



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil - Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

9.873/1999 e o artigo 142 da Lei nº 8.112/1990 têm essencialmente o mesmo alcance¹⁵, lembro que a Primeira Seção do STJ também equiparou o “fato” a uma conduta ao analisar a Lei nº 9.873/1999:

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. FRAUDE EM LICITAÇÃO. SANÇÃO DE INIDONEIDADE PARA LICITAR. RESTABELECIMENTO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. NÃO-OCORRÊNCIA. AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. NÃO-OBSERVÂNCIA. SEGURANÇA CONCEDIDA. (...) 3. De acordo com o art. 1º, § 2º, da Lei 9.873/99, quando o fato objeto da ação punitiva da Administração também constituir crime, a prescrição rege-se pelo prazo previsto na lei penal. No caso, a conduta supostamente praticada enquadra-se no tipo penal do art. 90 da Lei 8.666/93, que prevê a pena de detenção de 2 a 4 anos. Nessa hipótese, o art. 109, IV, do CP prevê que o prazo prescricional é de 8 anos. Dessa feita, considerando que a lesão ao direito ocorreu em 01.10.2000 (assinatura do contrato) e que o processo administrativo foi iniciado em 11.09.2008, deve-se afastar a alegativa de prescrição. (STJ, Primeira Seção, MS 15.036/DF, Rel. Ministro Castro Meira, julgado em 10/11/2010, DJe 22/11/2010)

45. O Relator adverte, com razão, que a interpretação do texto legal não deve levar ao vago e inexplicável. Concordo com a advertência, mas entendo que ela é mais um argumento que milita em favor da tese que defendo e que vem prevalecendo neste Colegiado. O artigo 1º, §2º, da Lei nº 9.873/1999 é regra excepcional, que traz, para o direito administrativo sancionador, prazos de direito penal. Ora, a tese de que a regra de substituição da Lei nº 9.873/1999 aplica-se não só a condutas que simultaneamente se subsumam em tipos administrativos e penais, mas a todas as condutas ligadas por circunstâncias fáticas, inviabiliza a utilização da regra penal no direito administrativo.

46. Nesse sentido, cabe repisar que a Lei Penal não estabelece um prazo prescricional único para todos os crimes. O prazo varia de acordo com o crime imputado, sendo calculado com base na sanção penal em abstrato. Ou seja, se não há crime, não há como aplicar a regra do §2º do artigo 1º da Lei nº 9.873/1999, pois os prazos prescricionais da lei estão

como também à Lei do CADE (Lei nº 12.529/2011, artigo 46) – e não da suposta intenção do legislador de ampliar o alcance da regra relativa ao prazo prescricional de modo a nela não só abranger a conduta que configura crime, como também outras condutas praticadas naquele mesmo contexto.”

¹⁵ As diferentes redações permitem a interpretação de que o artigo 142 da Lei nº 8.112/1990 exige correspondência entre o tipo administrativo e o tipo penal. No caso da Lei nº 9.873/1999, essa questão não se coloca: o §2º do artigo 1º aplica-se sempre que a mesma conduta preencha os requisitos necessários para configurar um crime e um ilícito administrativo. Volto a esse ponto no final desta seção II.2.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil - Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

indissociavelmente ligados aos tipos penais.

47. Essa modulação do prazo prescricional da ação penal de acordo com a gravidade abstrata da conduta visa a resguardar a relação de proporcionalidade que deve haver entre a gravidade da conduta e o prazo que o Estado tem para exercer o direito de punir. Em outras palavras, quanto maior o grau de reprovabilidade da conduta, maior o prazo de prescrição. O artigo 1º, §2º, da Lei nº 9.873/1999 segue a mesma lógica e se fundamenta na compreensão de que, em linhas gerais, se um fato é tipificado também como ilícito penal, então o seu grau de reprovabilidade é maior do que se configurasse tão somente uma infração administrativa¹⁶.

48. Assim, ainda que fosse possível aplicar os prazos prescricionais da lei penal a condutas que não configuram um crime – como visto, não é –, o resultado alcançado violaria frontalmente o princípio da proporcionalidade. A proporcionalidade do prazo prescricional é juízo de competência do legislador; no caso da lei penal, o prazo prescricional varia de acordo com o crime imputado, sendo maior para os crimes considerados mais graves. Aplicar os prazos prescricionais da lei penal a condutas que não configuram crime, além de impossível – pois os prazos da lei penal são calculados conforme a pena base e, a toda evidência, a lei penal não prevê penas para condutas que não se subsumem a um tipo penal –, inova perigosamente em relação ao regime instituído na lei.

49. Alguns exemplos ajudam a ilustrar a questão.

50. Imaginem, por exemplo, que dois sujeitos (A e B) praticaram um mesmo ilícito administrativo, que não corresponde a nenhum tipo penal. No caso de B, tem-se que, no mesmo “contexto fático”, outro agente (C) praticou uma conduta que configurava simultaneamente um ilícito administrativo e um crime, cujo prazo prescricional, segundo o Código Penal, é de 12 anos. É correto que os prazos prescricionais aplicáveis a A e B sejam distintos? Em caso afirmativo, sob qual fundamento?

¹⁶ Nesse sentido, Norma Parente: “O segundo prazo de prescrição, especial, estabelece regras de prescrição diferenciadas em função das peculiaridades de que se revestem os ilícitos administrativos que também constituem crime, que exigem um tratamento individualizado e distinto dos demais ilícitos, dada a gravidade da conduta do agente que, além de desrespeitar os comandos administrativos, invadiu com sua ação também a legislação penal. Em tais hipóteses os prazos de prescrição são distintos e seguem-se as regras prescricionais previstas na legislação penal atinentes à conduta violada”. PARENTE, Norma Jonssen. Mercado de Capitais. In: CARVALHOSA, Modesto (coord.). *Tratado de Direito Empresarial*. Vol. VI. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 697.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

51. Segundo a tese da Acusação, a resposta é sim e o fundamento é que a conduta de C, que não se comunica com a conduta de B (exceto pelo fato de elas terem transcorrido no “mesmo pano de fundo”), atrai para B o prazo prescricional alongado da lei penal. Note-se que não se está aplicando para B o prazo da lei penal – a conduta de B não é crime -, logo a lei penal não se aplica. A tese acusatória flerta, portanto, com a responsabilidade por fato de outrem, o que não se admite em sede de processo sancionador.

52. Para o segundo exemplo, vamos por um momento admitir que fosse correto e razoável alterar a regra de prescrição contra um agente que praticou um ilícito administrativo em razão de um crime praticado por um terceiro, mas imaginar que, no mesmo contexto em que A infringiu uma norma administrativa, um quarto sujeito – vamos chama-lo de D – praticou um crime, cujo prazo prescricional é de 20 anos, mas que não configura um ilícito administrativo. Como dizer nesse caso que “o fato objeto da ação punitiva” também constitui crime? E, se não dizer, como justificar que o prazo prescricional para A seja inferior ao de B, quando o prazo prescricional para o crime praticado por D era superior ao do crime praticado por C?

53. Por fim, há um exemplo já discutido nos precedentes em que dentro de um mesmo “contexto fático” três sujeitos praticam infrações administrativas independentes, sendo que duas delas correspondem, também, a tipos penais cujas penas máximas são de 4 e 10 anos. No caso dos crimes, o prazo prescricional será de 8 e de 16 anos, respectivamente. Qual desses prazos prescicionais deve ser considerado para aquela conduta que somente configura um ilícito administrativo? O menor? O maior? Uma média?

54. Quanto mais reflito sobre o assunto, mais me convenço de que a tese da Acusação não se sustenta independentemente do olhar pelo qual é examinada. O Relator sustenta que não se pode reinterpretar o dispositivo legal sob o argumento de que se trata de norma desproporcional. Novamente concordamos com esse ponto, mas o argumento que venho defendendo – e que felizmente tem prosperado – tem, como ponto de partida, a constatação de que a tese da Acusação está equivocada sob o ponto de vista da regra positivada. A falta de proporcionalidade alcançada pela tese vencida é apenas mais um argumento que demonstra que há apenas uma interpretação possível para o artigo 1º, §2º, da Lei nº 9.873/1999: a que ele se aplica apenas aos fatos que, ao mesmo tempo, violam um comando administrativo e a lei penal.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

55. Assim, em linha com os precedentes da CVM, concluo que o artigo 1º, §2º, da Lei nº 9.873/1999 aplica-se apenas aos fatos que, ao mesmo tempo, violam um comando administrativo e a lei penal.

56. Antes de passar à análise do caso, gostaria de enfrentar dois outros argumentos.

57. O primeiro é o de que a interpretação do artigo 1º, §2º, da Lei nº 9.873/1999 abrange somente condutas que configuram, simultaneamente, ilícitos penais e administrativos imporia à CVM um ônus descabido de conhecer em detalhes a lei penal. Essa responsabilidade existe, mas não decorre do posicionamento prevalecente na CVM, mas sim do entendimento dos nossos tribunais superiores de que a CVM, em sua atividade sancionadora, tem autonomia para concluir se os fatos que constituem infração aos dispositivos legais e regulamentares que, segundo a lei, lhe cabe fiscalizar, também constituem crime, independentemente da instauração de processo penal.

58. Dado que os prazos prescricionais da lei penal são calculados com base na sanção penal em abstrato prevista para cada crime, a única forma de a Autarquia se valer de sua autonomia para aplicar a regra do §2º do artigo 1º da Lei nº 9.873/1999 é conhecendo os tipos penais e as demais regras que disciplinam a matéria. Como disse em outra oportunidade:

“Não questiono a extensão do desafio que a interpretação prevalecente impõe à CVM – e não só às áreas técnicas, mas também ao Colegiado. Afinal de contas, as conclusões quanto à incidência do artigo 1º, §2º, da Lei nº 9.873/1999 e ao(s) prazo(s) prescricional(is) a ser(em) aplicado(s) – o plural aqui é importante, pois, tendo em vista a forma como a lei penal disciplina o cálculo do prazo prescricional, é possível que, em um mesmo processo, tenhamos que lidar com prazos variados – são potenciais matérias de defesa e a decisão final, na sede da CVM, caberá sempre ao Colegiado. Esse enorme desafio é a contrapartida para a autonomia dada aos órgãos administrativos; são os ônus e bônus da interpretação que hoje prevalece nos tribunais superiores.”

59. Ainda que a tese vencida efetivamente tivesse aplicação mais simples para a administração pública – espero ter demonstrado que essa facilidade é apenas aparente, pois ela na verdade traz a reboque uma série de problemas insolúveis –, esse fato não teria o condão de tornar correta uma interpretação equivocada.

60. O segundo ponto que gostaria de ressaltar é que que não se exige, para fins de



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil - Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

aplicação do artigo 1º, §2º, da Lei nº 9.873/1999, que exista simetria perfeita entre uma infração administrativa e um tipo penal. Em razão do atual entendimento do STJ sobre o artigo 1º, §2º, da Lei nº 9.873/1999, adiciona-se à rotineira atividade da CVM de subsumir fatos à norma administrativa, também a de subsumir os mesmos fatos à norma penal. Digase de passagem, não se analisa se a norma administrativa mantém correspondência com a norma penal ou se com ela guarda semelhança, mas apenas se os fatos que caracterizam uma infração administrativa se amoldam também a um tipo penal.

61. Essa observação é importante, pois muitas das normas legais e regulamentares cujo cumprimento cabe à CVM supervisionar se valem de conceitos abertos: é o caso, por exemplo, dos deveres fiduciários dos administradores e dos tipos da Instrução CVM nº 8/1979. Assim, é possível que duas condutas que caracterizem infração a um mesmo dispositivo legal ou regulamentar se amoldem a tipos penais distintos ou, alternativamente, que apenas uma delas constitua crime, embora ambas sejam, no âmbito da CVM, capituladas da mesma forma.

II.3. O caso dos autos

62. Feitas essas observações, passo ao exame da preliminar de prescrição da pretensão punitiva da CVM no tocante às acusações relacionadas a irregularidades na aprovação, pela diretoria da Petrobras, do PAR.

63. A matéria foi aprovada pela diretoria em **08.03.2007**, mais de cinco anos antes, portanto, do primeiro ato praticado pela área técnica apto a interromper o prazo prescricional para as acusações relacionadas a diversos episódios de corrupção apurados na Operação Lava-Jato (a emissão do ofício nº 560/2014, 20.10.2014).

64. A área técnica invoca o artigo 1º, §2º, da Lei nº 9.873/1999 e defende que o prazo prescricional para as acusações relacionadas à aprovação do PAR seria de 16 (dezesseis) anos. O prazo prescricional foi calculado com base no crime de corrupção passiva, prescrito no artigo 317 do Código Penal¹⁷ e cuja prática, nas ações penais instauradas no âmbito da Lava-Jato, foi imputada apenas àqueles que ativa e voluntariamente participaram das

¹⁷ Art. 317 - Solicitar ou receber, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida, ou aceitar promessa de tal vantagem: Pena – reclusão, de 2 (dois) a 12 (doze) anos, e multa.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

práticas espúrias.

65. Embora a matéria tenha sido deliberada em uma reunião da diretoria, a própria Acusação separa os diretores em dois grupos, aos quais imputa condutas distintas. De um lado, Paulo Roberto Costa, réu confesso no âmbito da Operação Lava-Jato, foi acusado de agir de forma desleal e em desvio de poder, valendo-se do cargo para receber vantagens indevidas, em infração ao artigo 154, § 2º, “c”, combinado com o artigo 155, *caput*, ambos da Lei nº 6.404/1976.

66. Já os demais diretores foram acusados por uma conduta culposa: falta de diligência no exame da matéria, em infração ao artigo 153 da Lei nº 6.404/1976. Vale ressaltar que a Acusação não apontou nenhum tipo de contribuição voluntária desse conjunto de acusados com as práticas dolosas cometidas por Paulo Roberto Costa¹⁸. Assim, não há se falar em concurso de pessoas¹⁹, o que leva à autonomia das infrações.

67. Mais ainda, segundo a própria narrativa acusatória, a alegada infração ao dever de diligência caracterizaria tão somente uma conduta negligente. Em assim sendo, nosso exame deve começar pelo parágrafo único do artigo 18 do Código Penal, segundo o qual “salvo os casos expressos em lei, ninguém pode ser punido por fato previsto como crime, senão

¹⁸ A Acusação registra que Nestor Cerveró e Renato Duque também teriam recebido vantagens indevidas em razão do exercício do cargo, na forma descrita pela apuração criminal, mas não logrou obter evidências do recebimento indevido deles quando da aprovação do PAR, em 08.03.2007 (itens 143 e 146 do relatório de acusação – fls. 5.632).

¹⁹ Nas palavras de Cezar Roberto Bitencourt, para a teoria monista ou unitária adotada pelo CP, “o fenômeno da codelinquência deve ser valorado como constitutivo de um único crime, para o qual converge todo aquele que voluntariamente adere à prática da mesma infração penal. No concurso de pessoas todos os intervenientes do fato respondem, em regra, pelo mesmo crime, existindo, portanto, unidade do título de imputação”. (BITENCOURT, Cezar Roberto. *Tratado de direito penal: Parte Geral*. v. 1. 17. ed. São Paulo: Saraiva, 2012. p. 540.) Da mesma maneira, Nelson Hungria já lecionava: “Decisivo, em relação ao conceito unitário de participação criminosa, sob o aspecto jurídico-penal, é o vínculo psicológico que une as atividades em concurso, ou seja, a vontade consciente de cada co-partícipe referida à ação coletiva. Se inexistir tal vínculo, o que se dá é a denominada autoria colateral, na qual, se qualquer das atividades convergentes (mas desconhecidas umas das outras) realiza, sozinha, o resultado final, por este não responderão as demais”. HUNGRIA, (Nelson; FRAGOSO, Heleno. *Comentários ao Código Penal*, Vol. I, arts. 11 a 27, 5ª ed., Forense, Rio de Janeiro, 1978. Páginas 398 e 399). Diante da ausência de provas e mesmo de acusação quanto à adesão voluntária dos demais diretores à obra criminosa imputada a Paulo Roberto Costa, as condutas imputadas aos primeiros devem ser consideradas autônomas em relação à conduta do segundo.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil - Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

quando o pratica dolosamente”²⁰.

68. Nesse sentido, vale pontuar que a conduta dos demais diretores poderia se amoldar, quando muito, ao crime de peculato culposo praticado por ocupante de função de direção em sociedade de economia mista, nos termos do artigo 312, §2º, e do artigo 327, §2º, ambos do Código Penal²¹⁻²².

69. Vale notar que o prazo de prescrição penal em abstrato do crime de peculato culposo é de 4 (quatro) anos, uma vez que a pena máxima cominada é de 1 (um) ano de detenção aumentada de um terço (artigo 109, V, do Código Penal). Ou seja, ainda que se entenda que as condutas dos demais diretores devem ser enquadradas no referido crime, a pretensão punitiva do Estado estaria prescrita quando o escândalo se tornou público.

²⁰ Art. 18 - Diz-se o crime: I - doloso, quando o agente quis o resultado ou assumiu o risco de produzi-lo; II - culposo, quando o agente deu causa ao resultado por imprudência, negligência ou imperícia. Parágrafo único - Salvo os casos expressos em lei, ninguém pode ser punido por fato previsto como crime, senão quando o pratica dolosamente.

²¹ Art. 312 - Apropriar-se o funcionário público de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou particular, de que tem a posse em razão do cargo, ou desviá-lo, em proveito próprio ou alheio (...) Peculato culposo. (...) § 2º - Se o funcionário concorre culposamente para o crime de outrem: Pena - detenção, de três meses a um ano.

Art. 327 - Considera-se funcionário público, para os efeitos penais, quem, embora transitoriamente ou sem remuneração, exerce cargo, emprego ou função pública.

§ 1º - Equipara-se a funcionário público quem exerce cargo, emprego ou função em entidade paraestatal, e quem trabalha para empresa prestadora de serviço contratada ou conveniada para a execução de atividade típica da Administração Pública.

§ 2º - A pena será aumentada da terça parte quando os autores dos crimes previstos neste Capítulo forem ocupantes de cargos em comissão ou de função de direção ou assessoramento de órgão da administração direta, sociedade de economia mista, empresa pública ou fundação instituída pelo poder público.

²² Sobre o assunto, cito novamente Bitencourt: “Ocorre o peculato culposo quando funcionário público concorre para que outrem se aproprie, desvie ou subtraia o objeto material da proteção penal, em razão de sua inobservância ao dever objetivo de cuidado necessário (§2º). No caso, o funcionário negligente não concorre diretamente no fato (e para o fato) praticado por outrem, mas, com sua desatenção ou descuido, propicia ou oportuniza, involuntariamente, a que outrem pratique um crime doloso, que pode ser de outra natureza. Nesse sentido, procuramos deixar claro que, como se tem reiteradamente afirmado, não há participação dolosa em crime culposo e vice-versa. Com efeito, o funcionário público responde, na modalidade culposa, pela inobservância do dever objetivo de cuidado, isto é, por sua negligência, deixando o objeto material desprotegido, ao facilitar, ainda que inadvertidamente, que terceiro pratique outro crime contra o patrimônio público que, em razão de seu cargo, deveria proteger. Não há, convém destacar, participação da ação culposa do funcionário na conduta dolosa do terceiro, que pode ou não ser outro funcionário público, inexistindo, por conseguinte, qualquer vínculo ou liame subjetivo entre ambos. Há, na verdade, uma espécie de autorias colaterais.” BITENCOURT, Cezar Roberto. *Tratado de Direito Penal: Parte especial: dos crimes contra a administração pública e dos crimes praticados por prefeitos*. V. 5, 3a. ed. - São Paulo: Saraiva, 2009, p. 15.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil - Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

70. Diante do exposto, chego a duas conclusões sobre as imputações relativas à aprovação do PAR:

- (i) a infração ao dever de diligência imputada aos demais diretores (artigo 153 da Lei nº 6.404/1976), conforme narrado pela peça acusatória, não constitui crime ou, quando muito, poderia configurar o crime de peculato culposo, cujo prazo prescricional é, inclusive, inferior ao prazo quinquenal administrativo; e
- (ii) essa infração, no caso concreto, é autônoma em relação à acusação de desvio de finalidade e infração ao dever de lealdade (artigos 154 e 155 da mesma lei) imputada a Paulo Roberto Costa.

71. Em resumo: no caso concreto, o “fato” que constitui crime, nos termos do §2º do artigo 1º da Lei nº 9.873/1999, não pode ser entendido como a aprovação do PAR na reunião da diretoria da Petrobras. Este é somente o contexto fático em que ocorreram dois grupos de condutas diferentes. O entendimento do Relator peca ao desconsiderar que o conceito de crime se relaciona umbilicalmente a condutas individualmente consideradas e que a responsabilidade administrativa é sempre subjetiva.

72. Assim, com base nesses fundamentos, entendo que o prazo prescricional de 16 anos, previsto na lei penal, é aplicável somente às condutas de falta ao dever de lealdade imputadas a Paulo Roberto Costa e a Renato de Souza Duque e não às condutas culposas dos demais diretores²³.

73. Com relação aos diretores acusados de falta de diligência na aprovação do PAR na reunião da diretoria da Petrobras, reconheço que a punibilidade está fulminada pelo decurso do prazo prescricional de cinco anos, não sendo aplicável, no caso, o prazo previsto no §2º do artigo 1º da Lei nº 9.873/1999, tendo em vista a ausência da prática de ilícito penal que a justifique.

²³ Aqui incluído o próprio Renato de Souza Duque, eis que em relação à aprovação do PAR, ele responde por falta de diligência.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil - Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

III. AS ACUSAÇÕES DE FALTA DE DILIGÊNCIA NA MUDANÇA DE FASE DO PROJETO RNEST: DE QUE VALE A REGRA DA DECISÃO NEGOCIAL?

III.1. Rápidas considerações sobre as (ainda pouco discutidas) diferenças entre os padrões de conduta e os padrões de revisão

74. O primeiro passo a se tomar quando se analisa uma acusação contra um administrador por alegada violação aos deveres fiduciários é definir qual o padrão de revisão a ser utilizado.

75. Os deveres e responsabilidades dos administradores são regulados no Capítulo XII, Seção IV, da Lei nº 6.404/1976. Como aponta Luis Antonio Sampaio Campos, a lei societária “não se filiou exclusivamente a um critério sintético ou analítico para tratar da matéria, de sorte que ao mesmo tempo em que há deveres genéricos, há condutas e responsabilidades específicas – ou mesmo implícitas – indicadas ao longo da lei”²⁴. Ou seja, coexistem na lei deveres específicos, com conteúdo bem definido, e deveres gerais, com conteúdo propositadamente pouco determinado.

76. O dever de diligência é um dos deveres expressos sob a forma de uma cláusula geral. A lei societária se refere genericamente a um *standard* de conduta, deixando ao intérprete e ao aplicador ampla margem de discricionariedade na delimitação do conteúdo específico do dever de diligência. Quando bem utilizada, essa flexibilidade mostra-se de suma importância, na medida em que permite que o conteúdo do dever de diligência seja aferido à luz das circunstâncias do caso concreto.

77. No entanto, essa mesma flexibilidade pode, também, dar margem a arbítrios e interpretações irrazoáveis, que exigem do administrador mais do que o razoável e, por isso mesmo, podem gerar efeitos indesejados, como o afastamento de bons administradores e a inibição da tomada de risco pelas sociedades empresárias. Se o risco é inerente à atividade empresarial, há, necessariamente, que se reconhecer que administradores leais e diligentes muitas vezes tomam, sem saber, más decisões²⁵.

²⁴ CAMPOS, Luiz Antonio Sampaio. “Deveres e responsabilidades dos administradores”. In: LAMY FILHO, Alfredo; BULHÕES PEDEREIRA, José Luiz (Org.). *Direito das Companhias*. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2017, p. 792.

²⁵ Sobre esse ponto, vale reproduzir a lição de Bernard S. Black: “My favorite story, when I explain the business judgment rule in transition countries, where lawyers often believe that directors should be liable for bad



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil - Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

78. Já os padrões de revisão foram inicialmente desenvolvidos pelos tribunais encarregados de analisar o eventual descumprimento, pelos administradores de sociedades, dos padrões de conduta²⁶. Enquanto os padrões de conduta, positivados na lei em termos propositadamente amplos, descrevem genericamente como os administradores devem se portar no exercício de suas funções, os padrões de revisão estabelecem critérios para avaliação do cumprimento desses *standards* gerais em situações específicas²⁷.

79. Sobre o assunto, vale transcrever a lição de Melvin Aron Eisenberg:

“A standard of conduct states how an actor should conduct a given activity or play a given role. A standard of review states the test a court should apply when it reviews an actor's conduct to determine whether to impose liability or grant injunctive relief.

decisions, goes like this. Imagine a company whose business strategy consists of, this year, spending \$10 billion to build several new factories, to sell products they haven't yet developed, to customers they don't yet have. The strategy will succeed only if the market grows by at least 30% this year, and if their engineers can turn plans for new products into real products on time. If they succeed, they will do the same thing next year, only on a larger scale. If they fail, the factories will sit idle, and the equipment in them will be obsolete within five years. The chief executive officer of the company has been quoted in the business press, where he describes this strategy as being like driving a car at 150 kilometers per hour, along a winding mountain road, in the dark, with the lights out, trying not to crash.

This strategy is guaranteed to crash, sooner or later. The company's managers just don't know when. When the crash comes, do we want a judge to look at this strategy, and the CEO's explanation, and hold the directors personally liable for the damage? If we are ever going to hold directors liable for negligence, this is a pretty good case for doing so. Or do we want to allow directors to take wild risks, in the hope of achieving wild success? The business judgment rule lets directors take risks, even wild risks.

There is a twist to this story. The company is Intel, which is one of the world's most successful companies. The CEO who described his business strategy as like driving at high speed down a mountain road in the dark is Andy Grove. Intel in fact crashed last year. It was, after all, only a question of when they would crash, not if. But Intel is still a big, successful company, and long-term investors are very happy with their investment.” BLACK, Bernard S. *The Principal Fiduciary Duties of Boards of Directors - Presentation at Third Asian Roundtable on Corporate Governance Singapore* (2001). Disponível em <https://www.oecd.org/corporate/ca/corporategovernanceprinciples/1872746.pdf>.

²⁶ Pode-se, contudo, ver no direito comparado uma tendência a uma maior posituação dos padrões de revisão, nomeadamente, para restringir as hipóteses em que decisões negociais podem ser sindicadas no mérito – em outras palavras, para positivar a *business judgment rule*. Nesse sentido, cf. p. ex. recentes alterações nas leis societárias alemã e portuguesa.

²⁷ “Very briefly, a standard of conduct tells the actor how to behave, while a standard of review tells the reviewing court how to decide whether the actor should be held liable. Often, the two standards coincide. (...) In corporate law, however, the standards diverge: the standard of conduct is much higher than the standard of review. In other words, the law demands more of directors than it thinks appropriate to enforce.” VELASCO, Julian. “Fiduciary Principles in Corporate Law”. In: CRIDDLE, Evan J.; MILLER, Paul B.; SITKOFF, Robert H. (Eds.). *The Oxford Handbook of Fiduciary Law*. Nova York: Oxford University Press, 2018, p. 63.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil - Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

In many or most areas of law, these two kinds of standards tend to be conflated. (...)

The conflation of standards of conduct and standards of review is so common that it is easy to overlook the fact that whether the two kinds of standards are or should be identical in any given area is a matter of prudential judgment. Perhaps standards of conduct and standards of review in corporate law would always be identical in a world in which information was perfect, the risk of liability for assuming a given corporate role was always commensurate with the incentives for assuming the role, and institutional considerations never required deference to a corporate organ. In the real world, however, these conditions seldom hold, and the standards of review in corporate law pervasively diverge from the standards of conduct. A byproduct of this divergence has been the development of a great number of standards of review in this area. In the past, the major standards of review have included good faith, business judgment, prudence, negligence, gross negligence, waste, and fairness. An important new development has been the emergence of intermediate standards of review.”²⁸

80. Os dois principais padrões de revisão utilizados para analisar a atuação dos administradores são **(i)** a regra da decisão negocial (*business judgment rule*), que preconiza uma análise das decisões sob uma ótica procedimental, e **(ii)** a regra da justiça integral (*entire fairness*), que preconiza que o julgador, em certas situações consideradas de maior potencial de abuso, avalie se o negócio foi justo tanto quanto à negociação (*fair dealing*) quanto ao preço (*fair price*)²⁹.

81. A regra da decisão negocial é o mais importante dos padrões de revisão³⁰. Pode-se, inclusive, dizer que foi a partir da necessidade de se criar esse padrão de revisão mais

²⁸ EISENBERG, Melvin Aron. “The Divergence of Standards of Conduct and Standards of Review in Corporate Law”. In: 62 *Fordham Law Rev.* 437 (1993). Disponível em: <https://ir.lawnet.fordham.edu/flr/vol62/iss3/1/>. Último acesso em 26.10.2020.

²⁹ Sobre a lógica de se estabelecer regimes mais ou menos intrusivos e os efeitos que soluções procedimentais podem ter na fixação dos padrões de revisão, remeto-me aos votos que proferi nos PAS CVM nº 19957.003190/2019-64, j. em 26.05.2020 (Rel. Pres. Marcelo Barbosa) e PAS CVM SEI 19957.010686/2017-22 (RJ2017/5122), j. em 07.07.2020, de minha relatoria.

³⁰ A doutrina, em especial a norte-americana, diverge quanto à natureza da *business judgment rule*, havendo quem a considere uma presunção, um padrão de diligência, uma regra de abstenção ou um padrão de revisão. Para um resumo dessa discussão, v. SMITH, D. Gordon. “The Modern Business Judgment Rule”. In: HILL, Claire A.; SOLOMON, Steven Davidoff (Eds.). *Research Handbook on Mergers and Acquisitions*. Cheltenham (Reino Unido): Edward Elgar Publishing, 2016.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil - Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

deferente às decisões negociais que os padrões de revisão desenvolveram certo grau de autonomia em relação aos padrões de conduta aos quais se associam.

82. Por que a *business judgment rule* é tão importante? Para compreender a importância da regra, é necessário, em primeiro lugar, reconhecer as características que diferenciam as decisões negociais de outras decisões. O administrador dirige um negócio, no qual os acionistas aportaram recursos na expectativa de lucros. A condução dos negócios sociais envolve a tomada de uma série de decisões de risco, para as quais não há resposta ótima³¹, muitas vezes em curtos intervalos de tempo.

83. Não há retorno sem risco. E o sistema da lei societária reconhece que a tomada de decisões arriscadas pelas sociedades empresárias é fundamental para o desenvolvimento dos seus negócios e, em última instância, da economia do país³².

84. Adicionalmente, somos mal equipados para julgar eventos pretéritos. Temos que analisar as condutas à luz das circunstâncias da época em que foram praticadas, mas nossos vieses cognitivos, especialmente o chamado viés de retrospectiva, inevitavelmente nos levam a exagerar a previsibilidade de fatos passados³³.

³¹ Sobre esse ponto, vale citar os juristas lusitanos Ricardo Costa e Gabriela Dias Figueiredo: “Ao contrário de outros sujeitos que desenvolvem uma atividade *profissional ou técnica*, os administradores não podem contar com modelos de comportamento *consensualmente aceites pela coletividade* – ensinamentos inequívocos, práticas ou *leges artis* generalizadamente aceites, modelos profissionais de competência –, a fim de os poder invocar para proteger as próprias escolhas e demonstrar a razoabilidade de suas decisões. Não há *guide lines*, cada decisão é *única*, na maior parte dos casos há várias alternativas de atuação, não há a priori uma decisão ótima.” COSTA, Ricardo; DIAS, Gabriela Figueiredo. “Comentários ao Artigo 64”. In: ABREU, Jorge M. Coutinho de (Coord.). *Código das Sociedades Comerciais em Comentário*, Vol. 1. 2ª Edição. Coimbra: Editora Almedina, 2017, p. 781.

³² Como bem disse a Diretora Ana Dolores Novaes: “A atividade econômica seria seriamente prejudicada se o sistema judiciário e o regulador passassem o tempo todo julgando as ações dos administradores ex-post. É muito fácil apontar que uma decisão foi errada olhando pelo retrovisor do tempo. Mas a essência do mundo dos negócios é tomar riscos. E aplicar o conjunto de informações e crenças que se apresentam em um determinado momento para decidir sobre fatos que gerarão efeitos sobre o futuro da companhia, futuro sobre o qual ninguém tem o controle.” PAS CVM nº RJ 2008/9574, j. em 27.11.2012.

³³ “Hindsight bias has pernicious effects on the evaluations of decision makers. It leads observers to assess the quality of a decision not by whether the process was sound but by whether its outcome was good or bad. Consider a low-risk surgical intervention in which an unpredictable accident occurred that caused the patient's death. The jury will be prone to believe, after the fact, that the operation was actually risky and that the doctor who ordered it should have known better. This outcome bias makes it almost impossible to evaluate a decision properly – in terms of the beliefs that were reasonable when the decision was made.” KAHNEMANN, Daniel. *Thinking, Fast & Slow*. 1ª ed. Nova York: Farrar, Straus and Giroux, 2011, p. 203.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

85. A soma desses fatores – o fato de não haver uma resposta ótima para as decisões empresariais, nem um parâmetro seguro para orientá-las, e nossa irresistível tendência a analisar decisões passadas em função dos resultados alcançados e não do processo empregado – criaria um risco gigantesco para os administradores, caso pudessem ser pessoalmente responsabilizados quando decisões negociais tomadas de boa-fé se mostrassem equivocadas, permitindo-lhes, assim, assumir riscos típicos da atividade empresária.

86. A *business judgment rule* existe justamente para blindar os administradores de responsabilidade contra apostas malsucedidas, conferindo-lhes segurança para, no espaço de discricionariedade da gestão, tomar decisões de risco no interesse da companhia. Esse padrão de revisão foi há muito reconhecido pela doutrina nacional³⁴ e incorporado pela CVM³⁵, que em reiteradas decisões consolidou o entendimento de que, salvo em situações bastante específicas, nomeadamente quando há evidências de má-fé ou fraude³⁶, não cabe ao julgador sindicá-lo o mérito de decisões negociais. Quando a *business judgment rule* é aplicável, deve-se somente averiguar se o processo que pautou a decisão foi conduzido de modo informado, refletido e desinteressado³⁷.

³⁴ V. p. ex. BRIGAGÃO, Pedro Henrique Castello. *A Administração de Companhias e a Business Judgment Rule*. São Paulo: Quartier Latin, 2017; PARENTE, Flávia. *O Dever de Diligência dos Administradores de Sociedades Anônimas*. Rio de Janeiro: Renovar, 2005; e RIBEIRO, Renato Ventura. *Dever de diligência dos administradores de sociedades*. São Paulo: Quartier Latin, 2006.

³⁵ Nesse ponto, vale referência aos votos proferidos pelo Diretor Pedro Marcilio nos PAS CVM nº 2005/1443 e 21/2004, j. respectivamente em 10.05.2006 e 15.05.2007. Embora esses votos não sejam os primeiros que reconheceram a aplicação da regra da decisão negocial, há nesses dois precedentes um importante esforço de sistematização do assunto, que os tornaram marcos na matéria.

³⁶ No voto que proferi no PAS CVM nº RJ2013/11703, pude desenvolver com mais vagar como os artigos 153 e 154 se complementam, destacando, em especial, a importância do juízo de racionalidade (ou logicidade) nos casos em que se discute possível desvio de poder. Não me parece, contudo, sequer possível argumentar que a decisão, no caso em análise, é irracional e não foi essa, de fato, a acusação imputada. V. tb. o já referido PAS CVM nº RJ 2005/1443, j. em 10.5.2006, Dir. Rel. Pedro Marcilio de Sousa.

³⁷ Cabe aqui nova referência ao celebrado voto do Diretor Pedro Marcilio no PAS CVM nº 2005/1443: “Para utilizar a regra da decisão negocial, o administrador deve seguir os seguintes princípios: (i) **Decisão informada**: A decisão informada é aquela na qual os administradores basearam-se nas informações razoavelmente necessárias para tomá-la. Podem os administradores, nesses casos, utilizar, como informações, análises e memorandos dos diretores e outros funcionários, bem como de terceiros contratados. Não é necessária a contratação de um banco de investimento para a avaliação de uma operação; (ii) **Decisão refletida**: A decisão refletida é aquela tomada depois da análise das diferentes alternativas ou possíveis consequências ou, ainda, em cotejo com a documentação que fundamenta o negócio. Mesmo que deixe de analisar um negócio,



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil - Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

87. Os conceitos de dever de diligência e de *business judgment rule* não têm identidade: o sarrafo do padrão de revisão foi, propositadamente, colocado em um nível inferior ao do padrão de conduta³⁸. Esse aspecto pode não só confundir aqueles não familiarizados com o direito societário como, também, por vezes contrariar nosso senso de justiça. Considerando os problemas associados à avaliação de decisões empresárias pretéritas, a regra da decisão negocial é um parâmetro permissivo. Provavelmente em razão do viés de retrospectiva, tenderemos a considerar que a *business judgment rule* é, em certos casos, excessivamente leniente. Nessas situações, resta lembrar que o respeito à referida regra é fundamental para a segurança do ambiente de negócios e que nada seria mais injusto do que poder trocar a régua em função do nosso julgamento subjetivo acerca do tamanho do que se mede.

III.2. Ausência de registro de discussões em ata e presunção de falta de diligência

88. Antes de analisar as acusações de falta de diligência, gostaria de tecer algumas considerações ao que me parece ser um perigoso flerte com a inversão do ônus da prova levado a cabo pela Acusação. Trata-se de considerar que a ausência de registro em ata de eventuais discussões sobre a matéria em deliberação ou os motivos pelos quais a decisão foi tomada denotaria a ausência de diligência dos administradores.

89. A Lei nº 6.404/1976 expressamente autoriza que as atas sejam lavradas na forma de sumário dos fatos ocorridos (art. 130, §1º) e a esmagadora maioria das companhias abertas brasileiras se vale dessa prerrogativa – em geral, descrevem-se de modo bastante genérico

a decisão negocial que a ele levou pode ser considerada refletida, caso, informadamente, tenha o administrador decidido não analisar esse negócio; e (iii) **Decisão desinteressada**: A decisão desinteressada é aquela que não resulta em benefício pecuniário ao administrador. Esse conceito vem sendo expandido para incluir benefícios que não sejam diretos para o administrador ou para instituições e empresas ligadas a ele. Quando o administrador tem interesse na decisão, aplicam-se os standards do dever de lealdade (duty of loyalty).”

³⁸ Nesse sentido, Julian Velasco comentando o clássico caso *Aronson v. Lewis* (1984): “*Aronson v. Lewis* lends some support to Johnson’s argument. Its classic formulation of the duty of care provides that a director must not only become informed but also put the information to good use. **This formulation implicitly recognizes that the standard of conduct (as opposed to the standard of review) for the duty of care is not concerned solely with empty procedural formalities.** Instead, the duty of care is about meaningful decisionmaking, which is aided by process but requires more. It requires an openness to the process that is incompatible with insincerity and conflicts of interest.” VELASCO, Julian. “How Many Fiduciary Duties Are There in Corporate Law?”. In: *Southern California Law Review*, vol. 83:1231, p. 1282. Grifos nossos. No mesmo sentido, COSTA, Ricardo; DIAS, Gabriela Figueiredo. *Op. Cit.*, p. 785; e ABREU, J.M. Coutinho; RAMOS, Maria Elisabete. “Comentários ao Artigo 71”. In: ABREU, Jorge M. Coutinho de (Coord.). *Op. Cit.*, p. 904.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil - Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

os assuntos submetidos à deliberação e a deliberação tomada e quando há registros de outras discussões, esses, no mais das vezes, são feitos de modo igualmente sintético. A questão vai além da lavratura em ata das assembleias gerais e reuniões dos órgãos da administração: de modo geral, as companhias guardam registro bastante sumarizado acerca dos assuntos tratados nessas reuniões e fora delas, muito embora me pareça que, ao longo dos últimos anos, há um salutar movimento de maior cuidado com a forma como os procedimentos relativos às decisões das sociedades são estruturados e registrados. Nesse ponto, a Petrobras está, inclusive, em situação melhor do que outras companhias, pois produzia e arquivava material detalhado antes de cada reunião.

90. Penso que a pobreza dos registros societários é uma prática problemática: em caso de questionamento, os investigados invariavelmente alegam, e não sem razão, que suas decisões negociais somente podem ser revistas sob uma ótica procedimental, mas em muitas vezes não conseguem demonstrar o processo pelo qual as decisões atacadas foram tomadas – isto é, evidenciar que o processo decisório foi, sob o ponto de vista do procedimento, informado, refletido e desinteressado. Dito isso, parece-me que, de modo geral, a ausência de registros detalhados não é apta a demonstrar nem a diligência nem a falta de diligência do administrador.

91. Afinal de contas, cabe à Acusação o ônus de demonstrar a ausência de diligência por parte dos administradores. Entender que a ausência de registro das razões do administrador, por si só, é prova de ausência de diligência leva, na prática, a uma inversão do ônus da prova, inadmissível em sede de processo sancionador.

92. Embora acredite que o que já expus é mais do que suficiente para encerrar essa questão, há um argumento de outra ordem que também me parece relevante. Considerando que a esmagadora maioria dos registros das reuniões ainda hoje é feita na forma de sumário, mas que há uma preocupação crescente de melhoria na forma de se documentar (ainda que não em ata) o processo decisório, deve-se ter cuidado para, no afã de se apurar responsabilidades, não se acabar legitimando o argumento, que ainda é muito forte, de que, ao se fazer os registros, “menos é mais”.

93. No caso em tela, não vejo como, a partir da falta de registros mais detalhados acerca de como os administradores se portaram ao discutir e deliberar as matérias questionadas possa ser considerada como prova de ausência de diligência. Conforme reconhecido pela



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil - Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

própria Acusação, “[a]s atas das reuniões da DE não eram descritivas, limitando-se a registrar somente as conclusões delas resultantes. Portanto, os comentários dos diretores sobre as pautas não se faziam constar nas referidas atas. Tampouco havia qualquer decisão no sentido de gravar ou de registrar, de alguma forma, as discussões que existiam nos encontros.” (item 45, fls. 5.604). Vê-se, portanto, que os registros questionados estavam em linha com o que autoriza a lei societária e com o que era habitualmente feito pela Petrobras.

III.3. Uma análise da diligência dos diretores à luz da *business judgment rule*

94. Passo enfim à análise das acusações de falta de diligência formuladas contra os diretores e membros do conselho de administração da Companhia que analisaram a mudança de fase do Projeto RNEST. A análise não inclui as acusações formuladas contra os diretores acusados de infração aos artigos 154 e 155 da lei societária, com relação às quais eu acompanho o voto do Diretor Relator.

95. Feita essa introdução, noto que as decisões referentes a investimentos em novos projetos têm conteúdo tipicamente negocial. Recordo, também, que a (correta) opção da área técnica de separar os administradores em dois grupos decorreu justamente do fato de não haver evidência que suporte uma acusação de que os administradores acusados de falta de diligência contribuíram (ao menos conscientemente) para a prática dos desvios. Trata-se, portanto, de uma alegação de falta de diligência relacionada a uma decisão negocial. Assim, em linha com a orientação pacífica desta CVM, devemos analisar a diligência unicamente a partir de uma perspectiva procedimental – verificar, em resumo, se a decisão foi informada, refletida e desinteressada.

96. Começando pelo último requisito para aplicação da regra da decisão negocial – decisão desinteressada –, noto que não há nos autos qualquer elemento que indique que os diretores e conselheiros tinham algum interesse pessoal na matéria. Resta, portanto, verificar se a decisão foi tomada de modo informado e refletido.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil - Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

97. Compulsando os autos, encontro evidência de que os diretores não só dispunham de farta informação³⁹ como a analisaram – tanto que na primeira oportunidade em que o assunto foi submetido à diretoria decidiu-se não deliberar sobre a matéria e solicitar ajustes⁴⁰.

98. A Acusação evita discutir a conduta dos acusados à luz da *business judgment rule*; antes, ataca a decisão tomada sobretudo em razão dos riscos apontados no material fornecido aos administradores.

99. Noto, em primeiro lugar, que os pareceres técnicos que acompanhavam o DIP 327/2009, apesar de indicarem os riscos do negócio, alguns fazendo recomendações a serem seguidas pela Companhia, também apontavam para a sua viabilidade. Como exemplo, o parecer tributário afirmava serem as “premissas aderentes à legislação tributária” (fls. 1.512) e o parecer de estratégia e desempenho empresarial informava: “O Projeto, em termos operacionais, representa um impacto bastante positivo para o sistema de abastecimento nacional” (fls. 1.516). Assim, apesar de apontarem os riscos, os pareceres técnicos não invalidavam a conclusão do DIP, não sendo, portanto, prova de falta de diligência do tomador da decisão.

100. Na minha avaliação, o relatório de inquérito atribui maior peso aos alertas de risco do que às vantagens apontadas nos documentos que foram disponibilizados aos diretores, em típico viés de retrospectiva. Além disso, ignora-se o fato de que, naquele momento, o projeto já estava em um grau de maturidade tal que o seu cancelamento tinha o potencial de gerar ainda mais custos para a Companhia. O item 10 do DIP 327/2009 afirmava que “em função do estágio atual de implantação do projeto podem ser considerados custos afundados da ordem de US\$ 1,5 bilhão, levando em conta todas as implicações contratuais existentes (por exemplo, multas). Assumindo esta consideração, o valor nominal do investimento remanescente para implantação do projeto seria de US\$ 11,862 bilhões e o incremento de VPL associado de US\$ 1,184 bilhão” (fls. 1.456).

³⁹ O DIP 327/2009, de 25.11.2009, que fundamentou a proposta de passagem do projeto RNEST à fase IV, foi acompanhado do Relatório Executivo de PSD da Fase III do projeto, além dos pareceres DIP TRIBUTÁRIO/PTR/ABAST 88/2009, DIP Estratégia/API 111/2009, PLAFIN, Análise Econômico-Financeira de FEL-3 e SMS.

⁴⁰ Conforme destacado no voto do Relator (item 162), a diretoria decidiu, em 03.09.09 (fls. 4.207), que a matéria referente à mudança de fase do projeto fosse reapresentada após ajustes os quais foram realizados pelas áreas técnicas da própria Companhia.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

101. Assim, dizer que os diretores no caso não foram diligentes pois não reagiram aos sinais de alerta trazidos pelas áreas implica um grave erro conceitual: confundir a assunção consciente de riscos com desleixo com sinais de alerta. Os chamados *red flags* são indicativos de anomalias e irregularidades e não apontamentos de riscos empresariais⁴¹; entender de modo diverso significa negar, por via indireta, a defesa da *business judgment rule* e pavimentar caminho para a responsabilização dos administradores pela eventual materialização dos riscos inerentes à atividade empresária⁴². Equiparar a assunção consciente de risco com falta de atenção a sinais de alerta é manifestação típica do viés de retrospectiva da acusação e recomenda cautela adicional ao julgador.

102. De fato, entendo que os elementos constantes dos autos indicam que a diretoria, após debater o assunto, deliberou de modo informado e refletido⁴³ acerca da matéria, fiando-se na recomendação da área especialista⁴⁴, consubstanciada no DIP.

103. É importante perceber que a Acusação de fato não faz uma verdadeira análise procedimental, mas adentra no exame do mérito de uma decisão negocial. Ora, a *business judgment rule* requer que a diligência dos administradores em questões empresariais seja, a princípio, sindicada unicamente em uma perspectiva procedimental.

104. É da acusação o ônus de trazer evidências de má-fé, desvio ou fraude, ou de mostrar que a decisão empresarial não era racional ou que não foi, *sob o ponto de vista do procedimento*, tomada de modo informado, refletido e desinteressado. A Acusação não se desincumbiu desse ônus: ao contrário, disse não haver prova de que os diretores e

⁴¹ Na ausência de demonstração de que havia algum alerta de irregularidade nos pareceres técnicos, para que se considere que a diretoria estava diante de verdadeiros *red flags*, ao menos deveria ter restado demonstrado que os riscos associados ao projeto em tela diferiam dos riscos usualmente encontrados em projetos de similar complexidade realizados pela Companhia, o que, a meu ver, não foi feito pela Acusação.

⁴² Nesse sentido, v. itens 150-151 do voto que proferi no julgamento do PAS nº RJ2014/13977.

⁴³ O fato de a deliberação registrada na ata ter sido sintética (“A Diretoria Executiva aprovou as proposições formuladas”, fls. 1.581) – aliás, como todas as deliberações da referida ata –, não nos leva irremediavelmente à conclusão de que a decisão não foi refletida, como parece crer a Acusação. A quantidade de assuntos complexos levados à deliberação da diretoria de uma companhia como a Petrobras não pode ser ignorada numa avaliação sob a ótica procedimental. A própria Acusação afirma que “o número de pautas analisadas em cada reunião era elevado. Em 2004, havia em torno de quinze pautas semanais, mas em 2010, cada reunião chegou a avaliar cinquenta pautas.” (item 40 do relatório de acusação – fls. 5.604).

⁴⁴ O direito de se fiar no assessoramento de terceiros (*right to rely on others*) é um argumento válido de defesa, tendo ampla acolhida na doutrina e na jurisprudência desta CVM. Sobre esse ponto, reporto-me ao que disse no PAS CVM nº RJ2014/8013, quando busquei dar alguma sistematização à matéria.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

conselheiros acusados de falta de diligência voluntariamente contribuíram para a prática dos gravíssimos desvios, acusando-os, portanto, de uma conduta negligente, sem, contudo, demonstrar porque a conduta dos acusados não satisfaria os requisitos da regra da decisão negocial.

105. Diante de todo o exposto, voto pela absolvição dos diretores acusados de falta de diligência na mudança de fase do projeto RNEST.

III.4. A conduta dos membros do conselho de administração (também à luz da *business judgment rule*)

106. Os membros do conselho de administração da Petrobras também foram acusados de falta de diligência (art. 153) por não terem obstado – ou ao menos questionado – a evolução do Projeto RNEST por ocasião da reunião de 17.12.2009. Assim como no caso dos diretores, entendo que não existem nos autos elementos que nos autorizem concluir que os referidos conselheiros não foram diligentes no tocante à matéria. A bem da verdade, embora entenda que a acusação contra os diretores se baseia em um justificado desconforto com o atuar daqueles administradores – ainda que, como visto, não veja como a acusação possa subsistir a um exame verdadeiramente feito sob a ótica procedimental –, julgo que a acusação contra os membros do conselho de administração ignora os diferentes papéis desses dois órgãos, não só à luz do que dispõe a lei societária como também (ou principalmente) da dinâmica da Petrobras.

107. Em primeiro lugar, discordo da tese da Acusação de que o assunto teria sido levado ao conselho de administração para ratificação. A ata da RCA de 17.12.2009 registra que o conselho de administração assistiu a diversas apresentações sobre projetos em andamento – RNEST, Alpha, Esmeralda e Sintagma, para citar apenas alguns. Assim, tenho para mim que o fato de a diretoria ter feito uma apresentação ao conselho sobre RNEST não pode ser interpretado como uma submissão da matéria à aprovação/ratificação.

108. O registro em ata de cada apresentação é bastante sintético, em consonância, aliás, com o estilo adotado em toda a ata, a qual indica o tema de cada apresentação, as pessoas responsáveis por apresentar o assunto e, quando o caso, as orientações do conselho sobre o tema. No caso da RNEST, a ata registra que, ao final da apresentação, “o Conselho de Administração emitiu orientações para a continuidade das negociações e determinou que o



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

projeto retorne ao Colegiado para conhecimento”. Noto que, segundo a ata, o conselho fez recomendações também em outros itens constantes da pauta de apresentações. Ou seja, não há nada na ata que nos permita concluir que as discussões sobre o Projeto RNEST foram diferentes, em forma ou em natureza, daquelas travadas no âmbito das demais apresentações feitas naquela RCA.

109. Também não vejo como extrair essa conclusão unicamente a partir do título do último slide utilizado na apresentação do Projeto RNEST, que no título diz: “em face do exposto, propõe-se...”. Ao contrário, parece-me que a tese acusatória é, nesse ponto, injusta e perigosa, e que esse tipo de elemento não pode sustentar uma acusação.

110. Segundo o estatuto social da Petrobras vigente à época, cabia à diretoria planejar, aprovar, executar e acompanhar os processos de investimento. A Sistemática Corporativa estabelecida pela diretoria dividia o ciclo de vida dos projetos em cinco fases, com requisitos para passagem de nível, incluindo alçadas específicas, não havendo nenhuma previsão de envolvimento do conselho de administração nessas deliberações, a qualquer título que seja.

111. É claro que isso não afasta, contudo, as competências legais do conselho de administração, que incluem “fixar a orientação geral dos negócios da companhia” e “fiscalizar a gestão dos diretores” (v. incisos I e III do artigo 142 da Lei das S.A.). Nessa dinâmica, é óbvio que o conselho de administração não estava impedido de opinar sobre os assuntos que lhe eram apresentados e que a diretoria não poderia simplesmente ignorar as orientações do conselho, órgão hierarquicamente superior (responsável, inclusive, por eleger e destituir os diretores da companhia, nos termos do inciso II do artigo 142 da lei societária).

112. Assim, entendo que os argumentos da Acusação, de que o assunto teria sido levado ao conselho de administração para ratificação, e da defesa, de que a matéria não seria de competência do conselho contam, cada um, apenas parte da história. É claro, como já disse, que o conselho de administração poderia dar orientações à diretoria mesmo com relação aos assuntos que não estavam incluídos na pauta como itens para “deliberação formal” e que tais orientações teriam que ser consideradas pela diretoria. Mas esse fato não nos autoriza a concluir que qualquer assunto apresentado ao conselho de administração se torna, automaticamente, uma matéria do conselho. Os deveres legais do conselho de administração, definidos em termos propositadamente vagos, precisam ser interpretados de maneira realista, sob pena de se criar padrões irreais de comportamento que, ao final, tendem a ter como único



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

efeito concreto desestimular bons profissionais a aceitarem ocupar esses cargos. Consequentemente, não me parece razoável esperar que o conselho de administração se debruçasse em cada um dos assuntos que lhe eram apresentados com a mesma profundidade dedicada aos temas levados para sua deliberação.

113. Nos termos do artigo 153, o administrador atua de modo diligente quando emprega cuidado e diligência no exercício de suas funções. A diligência se refere, portanto, ao modo pelo qual o administrador desempenha as suas funções; consequentemente, deve necessariamente ser perquirida à luz da função desempenhada pelo administrador.

114. Nessa perspectiva, não se pode esquecer que cabe à diretoria representar a companhia em negócios relevantes. Ainda que o negócio seja levado ao conselho de administração, mesmo para aprovação, o grau de revisão é diferente, inclusive em razão do fato de o referido conselho poder se fiar nas informações fornecidas pela diretoria⁴⁵. Permito-me aqui repisar o que disse no julgamento do já referido PAS CVM nº RJ2014/13977, que também analisava a responsabilidade da administração por fraudes em contratos relevantes:

“O dever de diligência dos conselheiros de administração não lhes impõe o dever de analisar pormenorizadamente os instrumentos contratuais e demais documentos relativos às matérias que lhe são submetidas. Entender de forma diversa significa ignorar o tamanho e a complexidade de tais documentos, o ritmo da marcha empresarial e pressupor, de forma equivocada e injusta, que todos os conselheiros têm conhecimento técnico especializado para formar um juízo próprio acerca desses documentos. A praxe empresarial, é importante que se diga, é outra, com os conselheiros muitas vezes deliberando sobre operações complexas com base em materiais preparados por diretores e seus subordinados e assessores, indicando os principais termos e pontos do negócio a ser deliberado.”

115. Assim, parece-me no mínimo irrazoável equiparar a diligência esperada dos diretores em uma reunião convocada para deliberar sobre a aprovação de uma mudança de etapa em um projeto relevante da diligência esperada dos conselheiros de administração em uma apresentação sobre o *status* do projeto. Não havia sinal de suspeita e o conselho de administração sequer recebeu o DIP e demais documentos submetidos à diretoria quando da

⁴⁵ V. p. ex. PAS CVM nº 32/99, j. em 05.12.2001, PAS CVM nº RJ 2002/1173, j. em 02.10.2003, e PAS CVM nº RJ 2014/8013, j. em 31.07.2018.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil - Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

aprovação da matéria. E ainda que tivesse recebido, não se pode esperar que o conselho refaça os cálculos de laudos e pareceres que lhe são apresentados.

116. Ressalto, por fim, que as respostas dos conselheiros aos ofícios da área técnica indicam que eles discutiram os pontos com os diretores e consideraram as respostas convenientes. A Acusação, a meu ver, não analisa a conduta dos conselheiros à luz das circunstâncias da época, mas a partir do que ela, Acusação, conhecia após extensa investigação. E, o que é mais grave, mais uma vez se imiscui no exame do mérito sem qualquer justificativa que nos autorize a superar um exame da matéria sob o ponto de vista procedimental.

117. Diante de todo o exposto, não vejo como dizer que as decisões atacadas, *sob o ponto de vista do procedimento*, não foram tomadas de modo informado, refletido e desinteressado. Voto, portanto, também pela absolvição de todos os membros do conselho de administração acusados de falta de diligência na mudança de fase do projeto RNEST.

IV. SUPOSTA OMISSÃO/PASSIVIDADE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO QUANTO AOS CONTROLES INTERNOS: ANALISANDO O DEVER DE MONITORAMENTO EM SUA PERSPECTIVA ORGANIZACIONAL

IV.1. Sobre a alegada prescrição

118. Dilma Vana Rousseff, Guido Mantega, Fábio Colletti Barbosa, Francisco Roberto de Albuquerque, Jorge Gerdau Johannpeter, Luciano Galvão Coutinho, José Sérgio Gabrielli de Azevedo e Silas Rondeau Cavalcante Silva, membros do conselho de administração da Petrobras, foram acusados de não se certificarem de que as correções necessárias às deficiências nos controles internos da Companhia estavam sendo de fato implementadas, a despeito das reiteradas manifestações do comitê de auditoria, em violação ao dever de diligência estabelecido no artigo 153 da Lei nº 6.404/1976.

119. Nesse sentido, a Acusação afirma que, desde 2006, o comitê de auditoria demonstrava preocupações sobre os controles internos da Companhia, que foram apresentadas ao conselho de administração em reuniões de 11.08.2008 e 13.04.2009. Outra manifestação nesse sentido ocorreu na 1.323ª reunião do conselho de administração, em 20.10.2009, quando o comitê de auditoria apresentou com destaque “a recorrência das não-conformidades na área de contratação de serviços, recomendando a elaboração de um plano



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

de ação”. Segundo a Acusação, “[n]ão há registro de nova discussão a respeito do tema, tampouco de questionamento por parte dos então integrantes do conselho, após essa data. Mesmo em 30.04.2010, ou seja, mais de seis meses após, na 1.331ª Reunião do CA (...), a questão das deficiências de controles internos não foi abordada”⁴⁶.

120. A alegada infração tem caráter permanente, uma vez que, segundo a tese acusatória, a omissão se protraiu no tempo até, pelo menos, 30.04.2010. Nesse caso, incide o artigo 1º, parte final, da Lei nº 9.873/1999 – o prazo de prescrição quinquenal deve ser contado a partir da data em que a infração permanente cessou⁴⁷. Assim, o prazo para a CVM exercer sua pretensão punitiva com relação a essas matérias se encerraria em 30.04.2015, salvo na ocorrência de uma das hipóteses legais de interrupção.

121. O Colegiado já decidiu que as portarias que determinam a instauração de inquérito administrativo não delimitam de modo exaustivo o escopo dos trabalhos de investigação e, conseqüentemente, o que pode ser objeto de uma eventual acusação. Sobre essa questão, assim se manifestou a então Diretora Relatora Maria Helena Santana no Processo Administrativo Sancionador no PAS CVM nº 02/03:

“A Portaria tem por objetivo estabelecer linhas gerais para a atuação da Comissão de Inquérito, motivada por indícios de ocorrência de ilícitos em determinado episódio (...). Não se trata, portanto, de despir de poderes a Comissão, restringindo sua atuação única e exclusivamente às suspeitas inicialmente levantadas, fechando-lhe os olhos a outros ilícitos que possam eventualmente ter ocorrido. Há de se convir que, num procedimento investigatório, não é possível prever o que irá surgir e, caso surjam evidências de outros ilícitos, é dever da Comissão apurá-los”⁴⁸.

122. Embora a área técnica possa, no processo de apuração, avançar para temas não previstos na portaria da instauração do inquérito, a contagem do prazo prescricional relacionada a cada conjunto de fatos somente é interrompida por atos inequívocos de apuração daqueles fatos. Nesse sentido, o Colegiado já reconheceu a ocorrência de prescrição quando novos fatos passam a ser apurados depois do prazo prescricional

⁴⁶ Item 316 e seguintes da peça acusatória (fls. 5.683/5.687).

⁴⁷ Ressalto, contudo, que o prazo prescricional passou a fluir já em data anterior para os acusados que deixaram o conselho de administração antes de 30.04.2010.

⁴⁸ PAS CVM nº 02/03, j. em 24.01.2007, Dir. Rel. Maria Helena Santana.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

aplicável. Nesse sentido, vale mencionar o voto do Diretor Relator Marcos Pinto no julgamento do PAS CVM nº 23/05, j. em 02.10.2007, e, também, o voto que proferi no julgamento do PAS CVM nº 05/2012, j. em 27.08.2019, quando ressaltei que

[A]inda que a acusação possa abranger fatos não previstos na portaria de instauração de inquérito administrativo, isso não significa que todo e qualquer fato novo que a área técnica venha a apurar estará, automaticamente, abarcado pela investigação original. O prazo para prescrição da pretensão punitiva somente é interrompido nas hipóteses do artigo 2º da Lei nº 9.873/1999, dentre as quais ressalto o ato inequívoco que importe em apuração dos fatos. A toda evidência, a apuração de certos fatos não interrompe a prescrição da pretensão punitiva referente a outro conjunto de fatos.

123. A Lei nº 9.873/1999 qualifica o ato de apuração que é apto a interromper a prescrição: ele deve, necessariamente, ser **inequívoco**⁴⁹. Do mesmo modo que não se pode exigir que já no início da fase inquisitória a CVM especifique os autores e normas infringidas pelas condutas que serão apuradas – afinal de contas, busca-se nessa fase justamente coletar elementos de autoria e materialidade⁵⁰ – é necessário que haja uma conexão **inequívoca** entre os fatos que se buscava apurar e outras condutas, sob pena de se alterar o conteúdo do inciso II do artigo 2º da Lei nº 9.873/1999.

124. Assim, entendo que os primeiros atos de apuração praticados pela CVM tiveram o condão não só de interromper a prescrição da pretensão punitiva relativa a diversos atos de corrupção praticados por administradores e funcionários no contexto de certos projetos como, também, das acusações de alegada falta de diligência diretamente relacionadas àqueles projetos – embora, como ressaltado anteriormente, os prazos prescricionais para as condutas que também constituem crimes sejam distintos do prazo prescricional quinquenal aplicável às condutas que configuram, apenas, um ilícito administrativo.

125. A situação da acusação baseada na suposta omissão do conselho de administração da Petrobras quanto aos controles internos é diferente, pois não guarda relação direta com os

⁴⁹ Segundo o Dicionário Houaiss, “não equívoco ou ambíguo; evidente, explícito, manifesto”. HOUAISS, Antônio; VILLAR, Mauro de Salles. *Dicionário Houaiss da língua portuguesa*. 1. Ed., 1ª reimpressão com alterações. Rio de Janeiro: Objetiva, 2009, p. 1077.

⁵⁰ V. PAS CVM nº RJ 2015/9443, j. em 04.06.2019, Dir. Rel. Flavia Perlingeiro.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil - Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

fatos inicialmente investigados⁵¹. Não vejo como construir um suposto elemento de conexão sob o fundamento de que “tivesse sido o conselho diligente na implementação de controles internos eficazes, a fraude não teria sido praticada” – esse tipo de argumento, no meu sentir, reflete um perigoso viés de retrospectiva e um olhar indevido para o cumprimento das obrigações de supervisão, mas deixo esse ponto para o exame do mérito. Assim, não me parece correto entender que o fato de a CVM ter, em outubro de 2014, iniciado a apuração de irregularidades em contratos, no contexto do escândalo de corrupção que vinha à tona, tem o poder de interromper o prazo prescricional de uma alegada conduta culposa relacionada a controles internos.

126. Não se pode admitir que a instauração de um processo com escopo genérico seja apta a interromper o curso do prazo prescricional de fatos específicos, que não se relacionam diretamente ao objeto inicial da apuração. Qualquer outra interpretação dá espaço para o arbítrio da Administração Pública, estimulando-a, ao menos nas fases iniciais de apuração, a delimitar o objeto da sua análise em termos cada vez mais vagos com o objetivo de preservar, ao máximo, sua pretensão punitiva e subvertendo a regra da prescritibilidade e o princípio da separação das pretensões.

“Princípio da separação das pretensões – A interrupção limita-se à pretensão que está em causa, e não se estende a qualquer outra que se irradie da mesma relação jurídica que é *res reducta*; nem se opera a respeito de outra pessoa que aquela que pratica o ato interruptivo.”⁵²

127. Dito isso, compulsando os autos verifico que já em dezembro de 2014 a área técnica da CVM investigava a eficiência e segurança dos controles internos da Petrobras. Nesse sentido, chamo atenção para o Ofício/CVM/SEP/GEA-1/nº 623/2014⁵³, que, em razão de matéria veiculada no Jornal do Comércio do Rio Grande do Sul, solicitou à Companhia informações e documentos acerca de deficiências e ineficácias em controles internos. Entendo ser irrelevante o fato de aquele primeiro esforço de apuração ter se dado em outro

⁵¹ Item 348 da peça de acusação: “Cabe, contudo, pontuar que, como a deficiência de controles internos não se relaciona diretamente com as contratações e condução do projeto RNEST (...)” (fls. 5.691).

⁵² PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. *Tratado de Direito Privado*, t. 6. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013, pp. 401-402. Grifos nossos.

⁵³ Fls. 2.038 do PAS nº 06/2016.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil - Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

processo administrativo⁵⁴, pois o que se analisa é a pretensão punitiva da CVM e o referido ofício me parece um inequívoco ato de apuração sobre os controles internos da Petrobras.

128. Assim, voto pela rejeição da preliminar de prescrição da pretensão punitiva da CVM no que se refere a essa acusação.

IV.2. Analisando o dever de monitoramento em uma perspectiva organizacional

129. Passo, por fim, ao exame do mérito da acusação referente à suposta omissão/passividade do conselho de administração quanto aos controles internos.

130. Gostaria de começar parabenizando a área técnica por trazer o assunto ao debate. Com efeito, a esmagadora maioria de casos analisados pelo Colegiado para apurar alegadas falhas do conselho de administração no cumprimento do seu mandato legal de fiscalizar a gestão dos diretores (art. 142, III) decorre da constatação de uma falha pontual, ainda que grave. Salvo em situações bastante específicas, o Colegiado consistentemente absolve o conselho de administração dessas acusações, por entender que o dever de supervisão tem natureza sintética e não analítica, não requerendo, portanto, que o conselho de administração revise todos os atos praticados pela diretoria.

131. Muito mais raros são os casos em que se discute o dever de supervisão em uma perspectiva organizacional, muito embora essa me pareça a abordagem mais adequada para discutir o papel e, consequentemente, a responsabilidade do conselho de administração nesses casos⁵⁵. Começo, portanto, registrando que o conselho de administração tem responsabilidade por implementar controles internos⁵⁶ (ou ao menos de assegurar que eles existam) que levem ao seu conhecimento, por exemplo, potenciais problemas relacionados à viabilidade da empresa, conformidade com a legislação aplicável e performance financeira, como, também, de tomar medidas para assegurar que o sistema funcione de modo adequado.

⁵⁴ Note-se que, de todo modo, consta dos autos deste PAS o Memo/CVM/GEA-3/nº 078/2014 (fls. 17), que, em seus itens 29 e 30, faz justamente referência ao Ofício/CVM/SEP/GEA-1/nº 623/2014 e à investigação sobre deficiências de controles internos.

⁵⁵ O tema também é de extrema importância para os participantes do mercado de valores mobiliários, como corretoras, administradores fiduciários, gestoras, casas de análise e agência de *rating*. Sobre esse ponto, cf. PAS CVM nº 19957.002587/2017-77, j. em 13.08.2019.

⁵⁶ A extensão e a complexidade desses controles dependerão, naturalmente, de diversos fatores, como o porte da companhia, o seu setor de atuação e a complexidade das suas atividades.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil - Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

132. Nesse sentido, Otavio Yazbek ressalta que, “na atualidade, falar em dever de monitoramento é falar também em dever de constituição de estruturas adequadas de gestão e controle”⁵⁷. Na mesma direção, José Ferreira Gomes defende que, no direito português, o dever de vigilância do conselho de administração incluiria **(i)** um poder-dever de obtenção de informação e de inspeção, **(ii)** um dever de avaliação da informação obtida e, por fim, **(iii)** um poder-dever de reagir às irregularidades detectadas⁵⁸, conclusões que me parecem também aplicáveis ao regime brasileiro.

133. Tão importante quanto esse reconhecimento acerca da responsabilidade do conselho de administração pelos controles internos é admitir nossas limitações para julgar fatos pretéritos e, conseqüentemente, a necessidade de se estabelecer critérios razoáveis para se julgar a responsabilidade dos conselheiros nos casos em que tais controles vierem a se mostrar falhos – na verdade, precisamos, inclusive, nos policiar para distinguir situações em que se está diante de um sistema de controle estruturalmente falho das situações em que, porquanto sempre falíveis, os controles internos falharam.

134. Não se trata de uma questão meramente semântica, pois mesmo os controles mais eficazes não são à prova de bala. Assim, o simples fato de se constatar a existência de um problema que deveria ter sido evitado pelos controles internos não é suficiente para concluir que os controles existentes à época em que o problema ocorreu não eram efetivos. Essa advertência é muito mais fácil de se descrever do que de se adotar: temos uma irresistível tendência a raciocinarmos como engenheiros de obra pronta, acreditando que os problemas passados eram muito mais previsíveis do que realmente eram e, o que é pior, que nos comportaríamos de modo diferente (invariavelmente melhor) caso fôssemos nós vivenciando aquela mesma situação que julgamos *a posteriori*.

135. A fim de evitar abusos, é fundamental, portanto, estabelecer qual o padrão de revisão adequado para analisar se os membros do conselho de administração foram diligentes no cumprimento do seu dever legal de monitoramento⁵⁹. Nesse ponto, parece-me importante

⁵⁷ YAZBEK, Otavio. “Representações do Dever de Diligência na Doutrina Jurídica Brasileira: um Exercício e Alguns Desafios”. In: KUYVEN, Luiz Fernando Martins (Org.). *Temas Essenciais de Direito Empresarial: Estudos em Homenagem a Modesto Carvalhosa*. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 956.

⁵⁸ GOMES, José Ferreira. *Da Administração à Fiscalização das Sociedades: a Obrigação de Vigilância dos órgãos da Sociedade Anônima*. Coimbra: Almedina, 2017, pp. 181-182.

⁵⁹ Sobre o conceito de padrão de revisão, v. seção III.1 deste voto.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil - Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

mais uma rápida referência ao direito norte-americano, pioneiro no reconhecimento dos deveres do conselho em implementar controles internos e adotar medidas para se assegurar da sua confiança. Esse entendimento é relativamente recente e ganhou corpo sobretudo a partir da célebre decisão do caso *In Re Caremark International Inc. Derivative Litigation* em 1996⁶⁰. Até então, o entendimento prevalecente era de que o papel esperado do conselho de administração era reagir a sinais de alerta levados a sua atenção, ainda que, por vezes, se criticasse a postura excessivamente passiva dos conselheiros⁶¹.

136. No caso *Caremark*, a *Court of Chancery* de Delaware reconheceu que o *board* poderia ser responsabilizado, não por prejuízos sofridos pela companhia e nem em razão de más decisões por ele tomadas (sujeitas à proteção da *business judgment rule*), mas por omissões no exercício do dever de supervisão. Consagrou-se, então, o entendimento de que caberia ao *board* avaliar, de boa-fé, se os controles internos da companhia seriam, conceitual e estruturalmente, adequados para assegurar que tempestivamente chegassem as informações apropriadas para o exercício da sua supervisão⁶².

137. Ao mesmo tempo em que confirmou a existência dessa dimensão sistêmica do dever de supervisão do conselho de administração, a decisão em *Caremark* ressaltou que as hipóteses de responsabilidade devem ser excepcionais – apenas quando há falta de boa-fé, que pode ser depreendida a partir de um descaso sistemático do conselho com a existência

⁶⁰ *In Re Caremark International Inc. Derivative Litigation* (Del. Ch. 1996).

⁶¹ *V. Graham v. Allis-Chalmers Manufacturing Co.* (Del. 1963).

⁶² Sobre esse aspecto, vale transcrever trecho do clássico voto do então Chancellor William T. Allen: “In light of these developments, it would, in my opinion, be a mistake to conclude (...) that corporate boards may satisfy their obligation to be reasonably informed concerning the corporation, without assuring themselves that information and reporting systems exist in the organization that are reasonably designed to provide to senior management and to the board itself timely, accurate information sufficient to allow management and the board, each within its scope, to reach informed judgments concerning both the corporation's compliance with law and its business performance.

Obviously the level of detail that is appropriate for such an information system is a question of business judgment. And obviously too, no rationally designed information and reporting system will remove the possibility that the corporation will violate laws or regulations, or that senior officers or directors may nevertheless sometimes be misled or otherwise fail reasonably to detect acts material to the corporation's compliance with the law. But it is important that the board exercise a good faith judgment that the corporation's information and reporting system is in concept and design adequate to assure the board that appropriate information will come to its attention in a timely manner as a matter of ordinary operations, so that it may satisfy its responsibility.” *Caremark*, § 970.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil - Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

de controles internos e sistemas de reporte ao conselho⁶³.

138. Esse caráter excepcional das hipóteses de responsabilização foi desde então reforçado em diversas decisões, nas quais salienta-se que os casos baseados em falhas no dever de supervisão estão entre os mais difíceis de prevalecer⁶⁴ – e isso em casos que, via de regra, tratavam da responsabilidade do conselho de administração por estabelecer controles para prevenir que a companhia e suas controladas atuassem em desconformidade com a lei ou fraudassem seus registros contábeis. Com efeito, os tribunais norte-americanos são ainda mais restritivos ao discutir a aplicação da doutrina de *Caremark* às decisões empresarias, inclusive relacionadas ao gerenciamento de risco, por entender que não se pode, sob o pretexto de discutir o dever de monitoramento, rever o mérito de decisões empresariais, incluindo a avaliação dos riscos a elas inerentes⁶⁵⁻⁶⁶.

139. Em linha com a experiência internacional, as poucas decisões da CVM que analisam

⁶³ Transcrevo outra passagem da opinião do Chancellor Allen no caso *Caremark*: “Failure to monitor: Since it does appear that the Board was to some extent unaware of the activities that led to liability, I turn to a consideration of the other potential avenue to director liability that the pleadings take: director inattention or “negligence”. Generally where a claim of directorial liability for corporate loss is predicated upon ignorance of liability creating activities within the corporation, as in *Graham* or in this case, in my opinion only a sustained or systematic failure of the Board to exercise oversight—such as an utter failure to attempt to ensure a reasonable information and reporting system exists—will establish the lack of good faith that is a necessary condition to liability.” *Caremark*, § 971. A Suprema Corte Delaware foi ainda mais clara ao analisar o caso *Stone v. Ritter*, 911 A.2d 362, 370 (Del. 2006), quando se registrou que eventual responsabilidade por infração ao dever de investigar dependeria da constatação de que os responsáveis “knew that they were not discharging their fiduciary obligations”, o que só poderia ser feito nos casos em que “(a) the directors utterly failed to implement any reporting or information system or controls; or (b) having implemented such a system or controls, consciously failed to monitor or oversee its operations”. *Stone v. Ritter*, 911 A.2d 362, 370 (Del. 2006). Sem pretender aqui trazer um panorama completo da jurisprudência norte-americana – e, como mencionarei mais adiante, os chamados *Caremark cases* voltaram a estar em bastante evidência nos últimos anos por conta de algumas decisões –, registro que, ao contrário de *Caremark*, os casos mais recentes (aí incluído *Stone v. Ritter*) costumam analisar a questão sob a lente do dever de lealdade e não do dever de diligência. V. *Guttman v. Huang*, 823 A.2d 492 (Del. 2003).

⁶⁴ Nesse sentido, o Chancellor Allen indicou no caso *Caremark* que casos que buscam responsabilizar os conselheiros por falhas nos controles internos estariam dentre os mais difíceis de prevalecer (“The theory here advanced is possibly the most difficult theory in corporation law upon which a plaintiff might hope to win a judgment.”), observação que tem sido consistentemente reforçada em julgamentos posteriores (v. p. ex. os já mencionados *Guttman v. Huang* e *Stone v. Ritter*).

⁶⁵ V. p. ex. In re Citigroup Inc. Shareholder Litig., 2009 WL 481906 (Del. Ch. 2009). Cf. ainda BAINBRIDGE, Stephen. “Caremark and Enterprise Risk Management”. In: *UCLA School of Law, Law-Econ Research Paper* No. 09-08. Disponível em: <https://ssrn.com/abstract=1364500>. Último acesso em 27.10.2020.

⁶⁶ E nesse ponto, remeto-me ao que disse na seção III.3 acima.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil - Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

o dever de fiscalização dos administradores em uma perspectiva sistêmica demonstram que a responsabilização dos administradores é cabível somente em situações bastante específicas.

140. Com efeito, pode-se ver nos dois principais precedentes acerca da matéria – os casos Sadia⁶⁷ e Telemig⁶⁸ – uma abordagem bastante cuidadosa acerca da responsabilidade dos administradores de fiscalizar a conduta de terceiros. A condenação dos administradores no PAS nº 18/2008 foi justificada em razão de os controles terem sido desenhados de modo patentemente equivocado, o que foi considerado suficiente para demonstrar a negligência do conselho⁶⁹. Já no PAS nº 24/06, o Colegiado absolveu o diretor da área em que haviam ocorrido as irregularidades diante da demonstrada existência de sistemas e da baixa representatividade das falhas, consideradas episódicas e, portanto, insuficientes para demonstrar a violação de uma obrigação relacionada a sistemas e procedimentos. Sobre esse ponto, transcrevo trecho do voto do Diretor Relator Otavio Yazbek:

“21. (...) [C]lara a impropriedade da tentativa de equiparação, sem maiores cuidados, do padrão de comportamento da *business-judgment rule* ao presente caso. Se não por outro motivo porque, ao proceder dessa maneira, ignora-se que o dever de diligência não se resume ao dever de tomar decisões negociais diligentes, envolvendo, também, toda uma dimensão voltada à supervisão das atividades da companhia, à qual não se aplicam os mesmos parâmetros (i.e., se se trata de decisões tomadas de maneira informada, refletida e desinteressada).

22. Essa interpretação, é bom salientar, em nada inova ou contraria os precedentes da CVM. Não se está negando a aplicabilidade, ao direito brasileiro, da racionalidade subjacente à *business-judgment rule*, presente tanto na doutrina quanto nas decisões norte-americanas e mesmo naquelas tomadas por esta autarquia. O exercício feito acima pretende, apenas, distinguir com maior clareza as hipóteses em que se deve aplicar esta racionalidade (ainda que com alguns temperamentos) de outras cujo reexame reclama ponderações de ordem distinta.

⁶⁷ PAS nº 18/2008, j. em 15.12.2010, Dir. Rel. Alexsandro Broedel Lopes.

⁶⁸ PAS nº 24/06, j. em 13.02.2013, Dir. Rel. Otavio Yazbek.

⁶⁹ Nesse sentido, o Dir. Rel. Alexsandro Broedel Lopes concluiu “que os conselheiros descumpriram o dever de diligência, ao negligenciar com relação às falhas no desenho do sistema de controle, tendo, por isso, deixado observar aos deveres de se informar e monitorar os controles internos da Sadia e, conseqüentemente, os atos praticados pela Diretoria Financeira e as operações realizadas.”



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

23. E o presente caso é uma delas. Aqui estamos tratando com algo diferente de uma decisão negocial – decisões sobre controles internos são decisões organizacionais de outra ordem.

24. **Em casos como esse, mais do que uma ênfase no procedimento, a apuração da conduta dos administradores, ao que me parece, deve passar pela análise concreta da forma pela qual se ‘procedimentalizaram’ as atividades dentro da sociedade.** Há que se avaliar se os procedimentos criam uma razoável segurança para as atividades da companhia e, para que isto aconteça, é **necessário verificar se a ‘procedimentalização’ dos controles internos é razoável e adequada.** No presente voto, e dado o enfoque proposto pela acusação, **me concentrarei na verificação de falhas sistemáticas ou totais.”** (sem grifos no original)

141. O dever de monitoramento do conselho de administração não pode ser avaliado pela *business judgment rule*, uma vez que não envolve uma decisão negocial⁷⁰, mas deve ser visto à luz do dever geral de diligência, como uma obrigação de meio e não de resultado⁷¹. Em certa medida, ele se assemelha a uma decisão empresarial, na medida em que não há um único modo de os administradores se desincumbirem da sua função fiscalizatória e que as avaliações retrospectivas devem, portanto, respeitar decisões tomadas dentro do espaço de discricionariedade que a lei reconhece⁷². Assim, em linha com os precedentes da própria CVM e com a experiência do direito comparado, entendo que a responsabilidade do conselho de administração por constituir estruturas adequadas para supervisionar a diretoria – e, mais genericamente, dos administradores por fiscalizar a conduta de terceiros – deve, a princípio, ser limitada a casos extremos, de falhas totais, permanentes ou sistemáticas.

142. Feita essa introdução, acredito que a acusação de falta de diligência no monitoramento dos controles internos, no caso concreto, não sobrevive a um exame feito à luz do padrão adequado para analisar a matéria.

143. Ressalto, de plano, que as provas constantes dos autos demonstram que a Companhia

⁷⁰ V. p. ex. PAS CVM nº 18/2008, j. em 15.12.2010; PAS CVM nº 24/06, j. em 13.02.2013; PAS CVM nº RJ 2014/13977, j. em 30.01.2020. Em artigo já mencionado, Otavio Yazbek defende, a meu ver com razão, ser necessário pensar em “novas formas de se aquilatar o cumprimento ou não dos deveres dos administradores, para o que se poderia cogitar soluções parecidas com a do *business judgment rule* (ressalvando-se que estas, como já apontado, não dão conta da necessidade de avaliação do quão “adequados” ou “suficientes” seriam os controles criados)”. YAZBEK, Otavio. *Op. Cit.*, p. 955.

⁷¹ No mesmo sentido, v. GOMES, José Ferreira. *Op. Cit.*, pp. 713 e ss.

⁷² Idem, p. 821.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil - Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

possuía controles internos, que eram sistematicamente avaliados pela auditoria interna, cujos trabalhos eram acompanhados pelo comitê de auditoria. Não há dúvidas, também, de que o comitê de auditoria periodicamente reportava ao conselho de administração os pontos de atenção relativos aos controles internos e que o conselho emitia orientações à luz das informações que lhe eram fornecidas.

144. A Acusação se concentra no exame da atuação do conselho de administração em um intervalo relativamente curto de tempo: entre outubro de 2009 e março de 2010 (v. item 351 da peça de acusação, fls. 5.692). O período selecionado tem início em uma reunião do conselho de administração (fls. 1.176-1.179), no qual o presidente do comitê de auditoria “destacou a recorrência das não conformidades na área de contratação de serviços, recomendando a elaboração de um plano de ação” e se encerra em outra reunião do conselho (fls. 5.074-5.077), que aprovou o plano anual de atividades de auditoria, sem qualquer registro de discussão acerca das deficiências de controles internos.

145. A data de início de apuração foi fixada em razão de a área ter entendido estar prescrita a pretensão punitiva da CVM para fatos praticados anteriormente. Não é possível, contudo, analisar a postura do conselho de administração de modo descontextualizado. Mesmo antes de outubro de 2009, o conselho discutia os controles internos da Companhia, tendo aprovado uma política específica para a matéria em 13.04.2009: a Política e Diretrizes de Controles Internos da Petrobras.

146. A forma como a Acusação se refere à referida política é prova patente de que a questão foi analisada pela área técnica sob uma lente equivocada. A peça acusatória considera a política um “ensaio de resposta”, criticada por não dar “uma abordagem definitiva para o problema, como se percebe pela continuação das deficiências, apontada ainda em outubro do mesmo ano” (item 339, fls. 5.689). E chega a dizer que as falhas reportadas ao conselho em outubro de 2009 – ou seja, apenas seis meses depois de a política ser aprovada – indicariam que essa era “inepta” (item 345, fls. 5.691).

147. Creio que nessas passagens transparecem três graves erros da Acusação, que explicam suas conclusões, mas que tornam impositiva a absolvição dos acusados.

148. O primeiro é tomar o dever de monitoramento como uma obrigação de resultados, quando é pacífico tratar-se de obrigação de meios.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil - Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

149. O segundo é ignorar que a diligência deve ser avaliada à luz da época dos fatos – e, nesse ponto, parece-me forçoso reconhecer que embora o *compliance* não seja novidade no Brasil, ele se desenvolveu de modo formidável sobretudo a partir (e, em larga medida, em razão) dos graves episódios descortinados pela Operação Lava-Jato.

150. O terceiro problema, na minha avaliação, é que a Acusação se baseia em expectativas bastante irreais, como se controles internos tivessem eficácia imediata e efetividade absoluta, quando se sabe que o processo de adoção de controles internos é complexo e demorado, demandando uma série de medidas, como, por exemplo, o treinamento dos funcionários, e que sempre estará sujeito a falhas e dependente de melhorias. Esse aspecto tem ainda maior relevância quando a companhia em questão é uma das maiores do mundo, com um número gigantesco de funcionários e colaboradores espalhados por diversas localidades.

151. É claro que o conselho de administração tem responsabilidade não só por fazer com que as informações cheguem ao seu conhecimento, mas também por dar tratamento à matéria. Dito isso, é mais do que esperado que as auditorias internas estejam sempre reportando deficiências e recomendando novas ações, especialmente em negócios maiores e mais complexos.

152. Especificamente com relação aos problemas reportados ao conselho de administração em outubro de 2009, noto haver registro de que, naquela reunião, o diretor presidente da Companhia descreveu ao conselho uma série de ações que estavam em andamento – como, por exemplo, o treinamento dos gerentes de contrato, o redimensionamento do quadro de auditores e a redefinição de processos – e que o conselho de administração solicitou o detalhamento, por área, das medidas destinadas ao tratamento das não-conformidades⁷³. Ou seja, ao contrário do que diz a Acusação, as evidências são de que a Companhia estava permanentemente trabalhando no aperfeiçoamento dos seus controles, com a supervisão do conselho de administração.

153. Por fim, tenho para mim que uma acusação dessa gravidade não pode estar baseada no fato de não haver registro, nas atas das reuniões do conselho subsequente, de discussões acerca da matéria. Conforme pontuei na seção III.2 deste voto, é praxe na Companhia que as atas descrevam de modo bastante genérico os assuntos submetidos à deliberação e a

⁷³ Fls. 1.176.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

deliberação tomada. Assim, embora considere que essa prática está longe de ser a ideal, não me parece justo que, a partir disso, deva-se presumir a ausência de diligência, pois isso levaria, na prática, a uma inversão do ônus da prova, inadmissível em sede de processo sancionador.

154. Reforço aqui a preocupação que já expressei em outros julgamentos quanto a construções excessivamente abrangentes do dever de fiscalizar, que fatalmente resultam na criação de expectativas irreais de comportamento e de parâmetros despropositadamente rigorosos de revisão. Condenar um conselho de administração sob o fundamento de que ele deveria ter feito mais e melhor, havendo prova de que esse órgão havia aprovado uma política de controles internos, periodicamente recebia informações acerca do funcionamento do comitê de auditoria e determinava a adoção de medidas é algo sem precedente nesta casa e sem amparo na doutrina e na jurisprudência, do Brasil⁷⁴ e do exterior⁷⁵.

155. Diante de todo o exposto, julgo de todo improcedente a acusação de falta de diligência do conselho de administração da Petrobras na supervisão dos controles internos da Companhia, razão pela qual voto pela absolvição dos acusados.

V. CONCLUSÃO

156. Diante do exposto, voto:

- (i) pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva da CVM no que se refere à imputação realizada em desfavor de Almir Guilherme Barbassa, Guilherme de Oliveira Estrella, Ildo Luís Sauer, José Sérgio Gabrielli de Azevedo, Nestor Cuñat Cerveró e Renato de Souza Duque, na qualidade de diretores estatutários da

⁷⁴ V. p. ex. o já mencionado caso Telemig (PAS nº 24/06).

⁷⁵ Na referida decisão do caso *Caremark*, o Chancellor Allen disse que casos daquela natureza estariam dentre os mais difíceis de provar e o histórico de decisões subsequentes veio a confirmar esse diagnóstico. Recentemente, os tribunais de Delaware se recusaram a arquivar sumariamente casos baseados em alegadas falhas de supervisão, o que causou bastante burburinho nos Estados Unidos. Cabe notar, contudo, que as decisões se basearam na aparente inexistência de sistema de controles. Sobre esse ponto, transcrevo trecho da opinião do então *Chief Justice* da Suprema Corte de Delaware, Leo Strine: “our focus here is on the key issue of whether the plaintiff has pled facts from which we can infer that Blue Bell’s board made no effort to put in place a board-level compliance system. That is, we are not examining the effectiveness of a board-level compliance and reporting system after the fact. Rather, we are focusing on whether the complaint pleads facts supporting a reasonable inference that the board did not undertake good faith efforts to put a board-level system of monitoring and reporting in place.” *Marchand v. Barnhill* - 212 A.3d 805 (Del. 2019).



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Petrobras, por falta ao dever de diligência, ao aprovarem o Plano de Antecipação da Refinaria;

- (ii) pela absolvição de Almir Guilherme Barbassa, Guilherme de Oliveira Estrella, Maria das Graças da Silva Foster, José Sérgio Gabrielli de Azevedo e Jorge Luiz Zelada, na qualidade de diretores estatutários da Petrobras, da imputação de terem faltado com o dever de diligência, ao aprovarem a passagem do projeto RNEST à fase IV;
- (iii) pela absolvição de José Sérgio Gabrielli de Azevedo, Fabio Colletti Barbosa, Francisco Roberto de Albuquerque, Guido Mantega, Jorge Gerdau Johannpeter, Luciano Galvão Coutinho, Sergio Franklin Quintella e Silas Rondeau Cavalcante Silva, na qualidade de membros do conselho de administração da Petrobras, da imputação de terem faltado com o dever de diligência, ao participarem do processo de decisão que aprovou a passagem do projeto RNEST à fase IV;
- (iv) pela absolvição de Dilma Vana Rousseff, Guido Mantega, Fábio Colletti Barbosa, Francisco Roberto de Albuquerque, Jorge Gerdau Johannpeter, Luciano Galvão Coutinho, José Sérgio Gabrielli de Azevedo e Silas Rondeau Cavalcante Silva, na qualidade de membros do conselho de administração da Petrobras, por falta ao dever de diligência na supervisão dos controles internos da Companhia; e
- (v) de acordo com o Diretor Relator em relação às demais imputações.

É como voto.

São Paulo, 3 de novembro de 2020

Assinado eletronicamente por

Gustavo Machado Gonzalez

Diretor



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
FOLHA DE ASSINATURA
DO VOTO DGG (DOC. SEI Nº 1132203)

Assina o Voto DGG, nos termos do Doc. SEI nº 1132203.

Gustavo Machado Gonzalez
Diretor Relator



Documento assinado eletronicamente por **Gustavo Machado Gonzalez, Diretor**, em 05/11/2020, às 18:27, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, informando o código verificador **1132205** e o código CRC **FA8121A0**.

*This document's authenticity can be verified by accessing https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, and typing the "Código Verificador" **1132205** and the "Código CRC" **FA8121A0**.*



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM Nº 05/2016

(Processo Eletrônico SEI nº 19957.010647/2019-97)

Reg. Col. 1404/2019

Acusados:	Almir Guilherme Barbassa	José Sérgio Gabrielli de Azevedo
	Dilma Vana Rousseff	Luciano Galvão Coutinho
	Fábio Colletti Barbosa	Maria das Graças Silva Foster
	Francisco Roberto de Albuquerque	Nestor Cuñat Cerveró
	Guido Mantega	Paulo Roberto Costa
	Guilherme de Oliveira Estrella	Renato de Souza Duque
	Ildo Luís Sauer	Sergio Franklin Quintella
	Jorge Gerdau Johannpeter	Silas Rondeau Cavalcante Silva
	Jorge Luiz Zelada	
Assunto:	Apurar possível inobservância de deveres fiduciários de administradores da Petrobras na construção da Refinaria Abreu e Lima. Infrações aos artigos 153, 154, §2º, “c”, 155, e 163, I, da Lei nº 6.404/1976.	
Relator:	Diretor Henrique Machado	
Voto:	Diretora Flávia Perlingeiro	

MANIFESTAÇÃO DE VOTO

1. Faço referência aos bem lançados votos proferidos pelo Diretor Relator Henrique Machado e pelo Diretor Gustavo Gonzalez, neste Processo Administrativo Sancionador (“PAS”), que trata da apuração de responsabilidade dos administradores da Petrobras¹ por supostamente terem inobservado seus deveres fiduciários em deliberações relativas ao projeto de construção da Refinaria Abreu e Lima (“Projeto RNEST” ou, simplesmente, “Projeto”), bem como de responsabilidade dos membros do conselho de administração (“CA”) por alegada falta de diligência na supervisão dos controles internos da Companhia.

¹ Os termos iniciados em letras maiúsculas e que não estiverem aqui definidos têm o significado que lhes foi atribuído no relatório apresentado pelo Diretor Relator.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

2. Tendo em vista que, respeitosamente, acompanharei apenas em parte o minucioso voto do Diretor Relator Henrique Machado e que acompanharei a manifestação de voto divergente do Diretor Gustavo Gonzalez em suas conclusões, divergindo, porém, de algumas de suas considerações, farei breves referências aos referidos votos, sem me estender sobre as razões com relação às quais não tenho entendimento divergente nem aspectos complementares a explicitar, a fim de não me alongar nesta manifestação.

I. PRELIMINARES

3. Inicialmente, com relação às preliminares suscitadas, reporto-me às razões e conclusões constantes do bem fundamentado voto do Diretor Relator, para acompanhá-lo, exceto no que tange às preliminares de prescrição que foram objeto de divergência, quanto às quais acompanho integralmente o voto do Diretor Gustavo Gonzalez.

4. Desse modo, voto pelo reconhecimento da prescrição da ação punitiva da CVM no que tange à acusação de inobservância do dever de diligência na aprovação, em 08.03.2007, do Plano de Antecipação da Refinaria - PAR, em face dos, à época, diretores estatutários da Petrobras, tendo em vista que a reunião em questão ocorreu mais de cinco anos antes do primeiro ato praticado pela área técnica apto a interromper o prazo prescricional e que entendo não ser aplicável, no caso, o disposto no §2º do art. 1º da Lei nº 9.873/1999, que trata da adoção do prazo prescricional previsto na lei penal².

II. MÉRITO

5. Divido essa seção em dois blocos. O primeiro trata do mérito da acusação de falta de diligência formulada contra os diretores e membros do CA da Petrobras que participaram das reuniões desses órgãos em que se tratou da mudança para a Fase IV (fase de execução) do Projeto RNEST. O segundo diz respeito ao mérito da acusação de falta de diligência pelos membros do CA na supervisão dos controles internos da Petrobras.

II.1 Da mudança de fase do Projeto RNEST para a Fase IV

6. Acompanho as conclusões do voto divergente proferido pelo Diretor Gustavo Gonzalez com relação ao mérito da acusação de falta de diligência formulada em face dos diretores da Petrobras que participaram da reunião da Diretoria Executiva de **25.11.2009**, em que deliberada a aprovação da mudança do Projeto RNEST para a Fase IV.

² Nesse tema, em acréscimo ao detalhado no voto do Diretor Gustavo Gonzalez, faço referência também à minha manifestação de voto nos julgamentos do PAS CVM 08/2016 e do PAS CVM 09/2016, em 16.12.2019.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

7. Entendo, porém, que também devem ser considerados outros aspectos fáticos que apontam para a absolvição dos referidos acusados, sobre os quais passo a discorrer.
8. Antes, porém, observo não haver divergência nos votos já lançados neste PAS (tampouco a meu ver) quanto a que (i) a mudança de fase do Projeto RNEST constitui decisão eminentemente negocial; (ii) a própria Acusação não apontou, quanto aos acusados por essa infração, existência de má-fé, desvio ou fraude; (iii) o padrão de revisão a ser adotado neste julgamento, consoante consolidado nos precedentes deste Colegiado, é o da revisão sob uma ótica procedimental; (iv) administradores estão protegidos pela regra da decisão negocial (*business judgment rule*) se suas decisões empresariais tiverem sido tomadas de modo informado, refletido e desinteressado; e (v) as condutas dos acusados devem ser analisadas à luz do que se sabia à época em que foram praticadas (isto é, antes das revelações trazidas pela chamada “Operação Lava Jato”).
9. Divergem, porém, os ilustres Diretores quanto a se houve, no caso concreto, processo decisório plenamente informado e sobretudo refletido, apenas não colocando em questão o fato de que se tratou de decisão desinteressada. Em especial, têm visões diferentes sobre se havia sinais de alerta capazes de exigir dos acusados indagações adicionais em atenção ao que seria deles esperado em observância do dever de diligência.
10. Entendo haver, portanto, complexidade no exame necessário para o julgamento deste caso, pois, se, por um lado, não nos cabe, como dito, analisar o mérito do conteúdo da documentação de suporte (e, portanto, também não cabe avaliar se eventuais ressalvas técnicas, em substância, eram ou não pertinentes ou superáveis); por outro lado, reconhecer que, em princípio, a CVM não pode entrar no mérito de decisões negociais tomadas pelos administradores, não significa dizer que não se deva analisar se houve reflexão no processo decisório, justamente porque é pressuposto para aplicação da regra da decisão negocial que a decisão tenha sido tomada de modo informado, refletido e desinteressado.
11. Assim, releva avaliar se restou evidenciado que não houve reflexão sobre os materiais apresentados, como sustenta a Acusação.
12. Nesse contexto, em adição ao salientado no voto do Diretor Gustavo Gonzalez, destaco alguns aspectos específicos sobre os fatos e documentação de suporte que amparam minha percepção quanto aos procedimentos adotados com relação à matéria, no âmbito da Diretoria Executiva e do CA, o que passo a fazer em tópicos separados.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

Do Processo Decisório da Diretoria Executiva - Aprovação da Mudança para a Fase IV

13. Constatado, primeiramente, que a Acusação não chegou a analisar o processo decisório sob a ótica procedimental. Não examinou sua cronologia nem detalhou os trâmites internos adotados, tampouco apresentou comprovação de que os diretores presentes à reunião de 25.11.2009 não estivessem a par das informações materialmente relevantes concernentes ao Projeto, constantes da documentação de suporte, ou que, estando delas cientes, as tivessem pura e simplesmente ignorado.

14. A esse respeito, a SPS parece ter partido de sua própria análise quanto ao mérito de tais informações para então concluir (i) que os acusados, por terem aprovado a passagem do projeto para a Fase IV, nos moldes propostos, necessariamente não teriam refletido sobre determinados alertas contidos naquelas informações; e (ii) que, se assim não fosse, cabia aos acusados comprovar que refletiram sobre tais alertas.

15. No caso, como havia farta documentação de suporte e os elementos tidos como alertas constavam da própria documentação, a questão que se coloca não é a de que os diretores não tenham buscado se informar, mas que, estando a informação disponível, os acusados teriam sido descuidados e displicentes em sua leitura e análise, acompanhando a proposição sem ter feito uma apreciação refletida dos riscos envolvidos.

16. Nesse contexto, é evidente a dificuldade a ser enfrentada quanto ao ônus probatório, por se tratar do processo mental de conhecimento e convencimento pelos próprios diretores, para a tomada de uma decisão negocial, em que, em princípio, pelas circunstâncias do caso, esses estão protegidos pela *business judgment rule*. Por sua vez, compete à Acusação³ o ônus probatório quanto a evidenciar que não houve reflexão sobre tais informações.

17. A Acusação tenta então se escorar na falta de registro dos debates e questionamentos na ata da reunião de 25.11.2009, sobre o que voltarei a tratar mais adiante, cabendo, contudo, de plano, reconhecer que não há norma a impor que, ao tomar uma decisão negocial, os

³ Nessa linha, apenas complementando as muitas referências doutrinárias já trazidas pelo voto do Diretor Gustavo Gonzalez, cite-se também: “A *business judgment rule* constitui, assim, uma presunção de que os administradores, no exercício de suas funções sempre agem da maneira que deles se espera. Caso tal presunção não seja derrubada, o julgador deverá respeitar a decisão negocial, não podendo invalidá-la, nem examinar sua razoabilidade ou substituí-la por outra que entenda mais adequada. Destarte, a presunção constitui imposição do ônus da prova a quem contesta a decisão negocial. Enquanto não houver indicativos de que a conduta do administrador se revestiu de má fé, falta de diligência ou desrespeito aos interesses sociais, tanto ele, quanto sua decisão deverão se manter incólumes. Portanto, exige-se daqueles que questionam a decisão que demonstrem de forma particularizada os fatos e motivos pelos quais não se deve aplicar a regra da decisão negocial” (ALVES, Giovani Ribeiro Rodrigues; SANTOS, Luccas Farias. Revista Jurídica Luso-Brasileira, Ano 5 (2019), n.º 5, p. 707).



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

diretores tivessem que produzir e manter registros dos alertas vislumbrados e dos motivos pelos quais não tivessem considerado necessário investigá-los. Logo, não parece adequado concluir pela materialidade e autoria da infração apenas em virtude da ausência de tais registros nesse sentido.

18. Não obstante, a formação do livre convencimento motivado do julgador pode se dar diante de prova indiciária, como há muito admitida pela jurisprudência da CVM, desde que não apenas por indício isolado, mas sim com base em um conjunto de indícios robustos e convergentes, sopesando, ainda, eventuais contraindícios existentes, a partir de uma análise casuística das circunstâncias e do contexto específico em que ocorridos os fatos.

19. Nesse sentido, importante elemento a ser levado em conta no julgamento deste PAS são as características do processo decisório efetivamente conduzido.

20. Com efeito, como restou demonstrado nos autos, a Petrobras mantinha, à época dos fatos (e ainda mantém), um processo de gestão de projetos de investimento bem definido, orientado pela Sistemática Corporativa de Investimentos da Petrobras (“Sistemática”), documento que apresentava diretrizes formais para essa atividade, uniformizando procedimentos, exigências e, notadamente, fluxos de informações a serem observados, que instruíam as decisões pertinentes aos referidos projetos⁴.

21. Ressalte-se que a própria Diretoria Executiva poderia acatar projetos não inteiramente conformados aos ditames da Sistemática, se assim entender adequado, no interesse da Companhia, sem que isso possa, por si só, ser interpretado como falta de diligência⁵. Observe que o fato de não ter sido registrada excepcionalização, embora não

⁴ Conforme consta do documento em questão: “*A Sistemática Corporativa de Projetos de Investimentos do Sistema Petrobras visa fornecer diretrizes para planejamento, aprovação e acompanhamento de projetos de investimento. (...) A Sistemática Corporativa de Projetos de Investimento adota abordagem na qual a tomada de decisão final para a execução do investimento é lastreada em um processo de sucessivas análises e aprovações. Esta concepção permite obter estimativas mais precisas de seus indicadores ao longo do ciclo de vida do projeto. A diferenciação e a obrigatoriedade de serem cumpridas todas as três fases referentes ao Planejamento do Projeto, Identificação de Oportunidade, Projeto Conceitual e Projeto Básico deve-se à: (...) 2. Padronização dos requisitos mínimos necessários a serem apresentados ao decisor, ao final de cada uma das fases, de modo a auxiliá-lo nas análises e decisões a serem tomadas em cada portão correspondente. (...) Ao final de cada uma das Fases de Planejamento (I, II e III) existe um Portão de Decisão ao qual estão associadas quatro opções para o projeto: 1. Cancelar - caso não seja mais viável ou este não se alinhe mais aos objetivos corporativos; 2. Adiar - caso haja mudanças temporárias no ambiente do negócio, onde novas informações poderão permitir que o projeto seja reativado no futuro; 3. Reciclar - caso haja necessidade de estudos adicionais antes do projeto seguir para a próxima fase; 4. Prosseguir - caso as análises realizadas sejam favoráveis*”. (grifamos)

⁵ Esse caráter não vinculativo da Sistemática foi destacado igualmente pela defesa de alguns acusados.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

reflita padrão de transparência desejável, ou mesmo exigível de uma sociedade de economia mista, não se traduz, de per se, em inobservância do dever de diligência.

22. De acordo a Sistemática e dentro das práticas da Companhia, a Diretoria Executiva deliberava sobre propostas das áreas gestoras dos projetos, consubstanciadas em um DIP⁶, devidamente acompanhado de um pacote de suporte à deliberação (“PSD”). Essa documentação, com o aval do diretor responsável, era encaminhada aos demais diretores, para que a matéria fosse em seguida pautada para deliberação pela Diretoria Executiva⁷.

23. Seguindo esse procedimento, a proposta de mudança do Projeto RNEST da Fase III (do projeto básico) para a Fase IV (de execução) foi encaminhada, pela primeira vez, à deliberação da Diretoria Executiva, na reunião de **03.09.2009**.

24. Para tanto, foi encaminhado pelo Diretor de Abastecimento aos demais diretores o DIP AB-CR 212/2009, de 03.09.2009 (“DIP 212”), acompanhado dos seguintes documentos, que compunham o respectivo PSD: (i) Relatório Executivo PSD Fase III⁸ (“Relatório Executivo” ou “RE”); (ii) Parecer do PLAFIN⁹; (iii) Parecer do SMS¹⁰; (iv) Análise Econômico-Financeira de FEL¹¹ (“AEF”); (v) DIP Tributário/PTR/ABAST 64/2009¹²; e (vi) DIP Estratégia/API 77/2009¹³.

⁶ Documento Interno do Sistema Petrobras.

⁷ Segundo a Sistemática: “9.3. *Aprovação de projetos – Portões 2 e 3 (...) O DIP solicitando a aprovação do projeto, devidamente assinado pelo Gerente Executivo da Área de Negócio responsável conjuntamente com o titular da Estratégia & Desempenho Empresarial, deverá ser emitido ao Diretor da Área responsável pelo projeto, que o colocará em pauta na reunião da Diretoria Executiva*”.

⁸ Conforme Índice de Revisões do RE, o documento original data de 01.07.2009, tendo sofrido quatro revisões, sendo a última em 03.09.2009. É possível inferir que o mesmo ocorria com relação aos demais documentos (i.e. representavam versões finais, por isso com a data da reunião da Diretoria, mas que derivavam de minutas anteriores, pois, claramente, não elaborados em um só dia), que estavam então atualizados até a data da reunião.

⁹ O Parecer do PLAFIN, datado de 03.09.2009, trazia, em resumo, o seguinte conteúdo: a) informações gerais do Projeto extraídas em quase sua totalidade do EVTE; b) análise econômica; e c) conclusões.

¹⁰ O Parecer do SMS, datado de 26.08.2009, concluía pela viabilidade do empreendimento, sob os aspectos de SMS, apresentando 44 recomendações de ações, considerando as especificidades do Projeto.

¹¹ A AEF, conduzida mediante uso da ferramenta PLANINV, se desenvolvia nas seguintes seções: a) Metodologia; b) Premissas Básicas; c) Investimento e Curva de Desembolso; d) Descrição do Empreendimento; e) Indicadores Econômicos; f) Análises de Sensibilidade; e g) Comparação com FEL-2.

¹² Esse DIP Tributário, datado de 02.09.2009, encaminhava o parecer quanto aos aspectos tributários do EVTE, com o seguinte conteúdo: a) Histórico; b) Análise Tributária, compreendendo (i) Premissas; (ii) Análise tributária do EVTE e (iii) Incentivos Fiscais; c) Aspectos tributários relativos ao contrato de compra e venda de petróleo, compreendendo (i) Petróleo Importado – Atendimento às Regras de Preços de Transferências; (ii) Petróleo Nacional – Distribuição Disfarçada de Lucros e (iii) Petróleo Nacional – Pagamento de Participações Especiais e Royalties; d) Incentivos Fiscais Adicionais; e) Recomendações; e f) Conclusão.

¹³ Esse DIP Estratégia, datado de 03.09.2009, encaminhava o parecer da Estratégia e Desempenho Empresarial sobre o Projeto Básico da RNEST; e estava dividido nas seguintes seções: a) Conclusões; b) Recomendações; c) Resultados; d) Aderência Estratégica; e) Descrição; e f) Premissas e Comentários.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

25. O DIP 212 consubstanciava a proposta a ser submetida à deliberação da Diretoria Executiva, suas justificativas e as principais informações sobre o Projeto. Continha, em suma, as seguintes informações: a) histórico do andamento do Projeto, a partir do estudo de FEL-1 do empreendimento; b) objetivos de cunho econômico¹⁴, estratégico¹⁵ e social¹⁶ do Projeto; c) justificativas para a alteração de fase do Projeto; e d) conclusão, em que os signatários do documento, em suas respectivas áreas de atuação, afirmam estar de inteiro acordo com os procedimentos até então adotados e as providências propostas na ocasião, que entendiam atender plenamente os interesses da Companhia.

26. O DIP 212 esclarecia, ainda que tinham sido obtidos pareceres das áreas corporativas da Companhia que dariam sustento ao disposto no documento. Propunha¹⁷, ao final, que fosse autorizada a mudança do Projeto RNEST para a Fase IV e ordenadas providências visando à obtenção de incentivos fiscais e desonerações tributárias referidos no DIP.

27. Quanto aos anexos do DIP 212, além dos pareceres corporativos, que, na visão da Acusação, continham os alertas que teriam sido simplesmente ignorados pelos diretores, destacava-se, ainda, o RE, que apresentava uma visão do Projeto, em termos de escopo, custo, prazo e economicidade, e fornecia a documentação de suporte à decisão acerca de sua continuidade¹⁸.

¹⁴ Suprimento da demanda nacional por diesel, nafta e GLP; aproveitamento de oportunidade de mercado existente no Norte e Nordeste; e ampliação da margem de refino.

¹⁵ Integração energética entre o Brasil e a Venezuela; criação de barreiras de entrada para potenciais competidores; importância para o suprimento de diesel 50 e 10 ppm de enxofre (Resolução CONAMA nº 403, de 11.11.2008) mitigando dependência externa e exposição da Companhia a riscos de flutuação de mercado.

¹⁶ Promoção do desenvolvimento da região nordeste, por meio do fortalecimento da indústria local e da geração relevante de empregos.

¹⁷ O DIP 212 foi assinado pelo gerente executivo do Abastecimento e pelo Diretor Gerente da Estratégia e Desempenho Empresarial. Em 03.09.2009, o acusado Paulo Roberto Costa, à época Diretor do Abastecimento, despachou no documento: “*À Diretoria Executiva*”.

¹⁸ O RE apresentava o seguinte conteúdo: a) Objetivo do relatório; b) Introdução contextualizando a produção de petróleo pesado no País e os méritos do Projeto quanto a esse aspecto; c) Premissa adotada quanto à parceria com a PDVSA; d) Objetivos de cunho econômico, estratégico e social para a implantação da Refinaria; e) Histórico do Projeto (Fase I, Fase II, PAR e Fase III); f) Considerações sobre licenciamento ambiental do Projeto; g) Considerações sobre o investimento total esperado de implantação do Projeto RNEST (Fase II); h) Aderência do Projeto ao Plano Estratégico Petrobras 2020/Plano de Negócios 2009-2013 e considerações sobre o Programa de Aceleração do Investimento (PAC); i) Reavaliação da viabilização da estratégia de partida da RNEST; j) Considerações sobre os principais processos licitatórios de implantação do Projeto e os problemas enfrentados; k) Estimativa do investimento total esperado do Projeto para implantação da RNEST (Fase III); l) Curva de avanço financeiro do investimento; m) Considerações sobre a escalada de preços entre as estimativas de investimento para implantação da RNEST entre a Fase II e a Fase III; n) Estimativa de custo operacional (Fase III); o) Principais marcos com base no cronograma esperado para a implantação da Refinaria; p) Análise econômico-financeira do cenário esperado para o projeto de implantação e aplicando estudos de sensibilidade; q) Limites para variação da estimativa de investimento esperado para a implantação da RNEST; r) Conclusões; e s) Lista de documentos encaminhados para compor o PSD.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

28. Segundo a Ata da **Reunião nº 4.773** da Diretoria Executiva (“Ata 4773”), ocorrida em **03.09.2009**¹⁹, houve a realização de apresentações, na primeira parte da reunião e, em seguida, foram submetidas 37 (trinta e sete) matérias à deliberação dos diretores, sendo que a última a ser apreciada foi a passagem de fase do projeto RNEST.

29. Na parte destinada às deliberações formais, a Ata 4773 da reunião reproduziu, basicamente, para cada pauta, os itens dos respectivos DIPs em que constaram as proposições submetidas à Diretoria Executiva pelas unidades interessadas, informando, então, se teria havido a aprovação da matéria e/ou alguma determinação adicional por parte dos diretores²⁰.

30. Em relação ao Projeto RNEST, constou na Ata 4773:

“Iniciada a reunião, passou-se à sua primeira parte, em que **foram feitas as seguintes apresentações, cujos temas foram objeto de debates:** (...) **“Refinaria do Nordeste”**, pelo Engenheiro de Processamento Sênior (...). Na segunda parte da reunião, no tópico das deliberações formais, foram examinados os seguintes assuntos, relatados ao Colegiado pelo Presidente e Diretores, de acordo com as respectivas áreas de contato: (...) **37) Pauta nº 911 – UNIDADE ABASTECIMENTO CORPORATIVO (AB-CR) - Empreendimento de Implantação da Refinaria Abreu e Lima S.A. (RNEST) - Fase IV (DIP-AB-CR-212/2009):** - O Diretor Paulo Roberto Costa submeteu à Diretoria Executiva a matéria da referência, propondo, no parágrafo 16 do DIP em apreço: 16.1) autorizar a Fase de Execução (Fase IV) do empreendimento de implantação da RNEST, nos termos dispostos no DIP em causa; 16.2) determinar que a unidade Tributário, em articulação com a Área de Negócio de Abastecimento, reforce sua atuação junto ao Ministério da Fazenda visando ampliar os incentivos fiscais mencionados no parágrafo 10 do DIP em questão; e 16.3) determinar que a unidade Tributário e a Área de Negócio de Abastecimento iniciem estudos em articulação com Ministério da Fazenda para proposição de programa de desonerações tributárias para novas unidades de Refino e Petroquímica no Brasil. **DECISÃO: - A Diretoria Executiva determinou a reapresentação da matéria com os ajustes necessários.”**

(grifos no original e aditados)

31. Como se vê, a Diretoria Executiva teria debatido sobre o projeto e então deixado de aprovar as proposições do DIP 212, solicitando os “*ajustes necessários*”. A referida ata não explicita quais ajustes teriam sido demandados pela Diretoria Executiva. No entanto, consta

¹⁹ Consta da ata que a reunião teve início às 12h e término às 21:35h.

²⁰ Em alguns casos, a matéria era considerada “mantida em pauta”, o que, segundo a Acusação e corroborado por algumas defesas, significaria, na prática, que haveria algum ajuste ou complemento no PSD. Também ocorria de a Diretoria Executiva impor condicionantes à aprovação. Ambas as situações foram observadas na reunião de 03.09.2009.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

do DIP AB-CR/RNE/PG 62/2009, de 18.11.2009, que a Diretoria Executiva teria determinado na referida reunião *“que várias ações fossem tomadas a fim de melhorar os indicadores econômicos do projeto”*²¹.

32. Com efeito, verifica-se que, após realizados estudos pelas áreas envolvidas, a proposta de aprovação de mudança de fase do Projeto RNEST foi reencaminhada à deliberação da Diretoria Executiva, na reunião de 25.11.2009, respaldada, porém, em novas análises e premissas.

33. O PSD relativo à proposta compreendeu, nessa ocasião, o DIP AB-CR 327/2009 (*“DIP 327”*)²², e seus anexos: a) Relatório Executivo PSD Fase III revisado (*“Novo RE”*); b) DIP Tributário/PTR/ABAST 88/2009; c) DIP Estratégia/API 111/2009; d) Parecer do PLAFIN revisado; e) Parecer do SMS; e f) Análise Econômico-Financeira de FEL3 revisada.

34. Ao comparar esses documentos com os submetidos em 03.09.2009, é possível constatar que foram feitas diversas alterações substanciais²³, não apenas nos DIPs, mas também, em grande extensão, no Novo RE e nos demais documentos acima referidos, à exceção apenas do Parecer do SMS, que foi o único a não sofrer alterações.

35. Com relação à reunião ocorrida em **25.11.2009**²⁴, cabe pontuar que, segundo a Ata da Reunião nº 4.786 da Diretoria Executiva (*“Ata 4786”*), houve a realização de apresentações sobre 5 (cinco) temas, na primeira parte da reunião, e, em seguida, foram submetidas 30 (trinta) matérias à deliberação, tendo novamente sido apreciada, por último, a passagem de fase do Projeto RNEST.

36. Sobre o tema, da Ata 4786 constou o seguinte registro:

“30) Pauta nº 1236 – UNIDADE ABASTECIMENTO CORPORATIVO (AB-CR) - Empreendimento de Implantação da Refinaria Abreu e Lima S.A. (RNEST) – Autorização Para Execução (Aprovação da Fase IV) – (DIP-AB-CR-327/2009 de 25-11-2009): - O Diretor Paulo Roberto Costa submeteu à Diretoria Executiva a matéria da referência, propondo, no parágrafo 14 do DIP em apreço: 14.1) autorizar a Fase de Execução (Fase IV)

²¹ O DIP em referência encaminhou o Novo RE e a nova avaliação econômico-financeira relativos à fase FEL-3 do Projeto às áreas corporativas, solicitando a apreciação e emissão de novos pareceres, de modo a permitir o encaminhamento da matéria para a reapreciação pela Diretoria Executiva.

²² O DIP 327 também é datado de 25.11.2009, dia em que ocorreu a respectiva reunião da Diretoria Executiva.

²³ Note-se, inclusive que, uma das alterações retratava mudança no próprio modelo de negócio do Projeto: (i) enquanto o DIP 212 (em seu item 9.2) referia-se a à análise de atratividade considerando dois modelos de negócio alternativos (i.e. por meio de empresa independente em sociedade com a PDVSA, em negociação; ou Unidade de Negócio do Sistema Petrobras; (ii) o DIP 327 (em seu Item 9.3) passou a dispor sobre a análise de atratividade considerando tão somente a implantação em sociedade com a PDVSA, em fase final de negociação entre os Governos do Brasil e da Venezuela, com previsão de conclusão até dezembro de 2009.

²⁴ Consta da ata que tal reunião teve início às 11:30h e término às 20:30h.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

do empreendimento de implantação da RNEST, nos termos dispostos no DIP; 14.2) determinar que a unidade Tributário, em articulação com a Área de Negócio de Abastecimento, **reforce sua atuação junto ao Ministério da Fazenda visando a obter a desoneração fiscal** mencionada no subparágrafo 9.7.1 do DIP em pauta, no que se refere ao petróleo; e 14.3) determinar que a unidade Tributário e a Área de Negócio de Abastecimento **continuem em articulação com Ministério da Fazenda para proposição de programa de desonerações tributárias** para novas unidades de Refino e Petroquímica no Brasil. **DECISÃO: - A Diretoria Executiva aprovou as proposições formuladas.**” (grifos no original e aditados)

37. Em que pese o referido registro na Ata 4786 não permitir, de fato, identificar se determinados aspectos do PSD foram objeto de reflexão e debate pela Diretoria Executiva, nessa segunda reunião, a meu ver, à luz do histórico dos fatos e documentos de suporte acima referidos, é possível concluir que a reanálise apresentada pela Unidade de Abastecimento Corporativo quanto à proposição de mudança para a Fase IV do Projeto RNEST foi determinante para o convencimento da Diretoria Executiva.

38. Mesmo que as alterações nos documentos que suportaram a referida decisão da Diretoria Executiva possam ser objeto de crítica, seja sob o aspecto técnico ou negocial, ou de questionamentos sobre se a decorrente melhora dos indicadores possa ter sido causada, em larga medida, por visões forçadas ou, ao menos, enviesadas; fato é que adentrar no exame do conteúdo de tais alterações implicaria, claramente, em revisão de mérito, o que não nos cabe fazer dentro do padrão de revisão a ser adotado neste julgamento, que, como dito, é procedimental. E, sob esse prisma, não identifico, nos autos deste PAS, evidência de que o processo decisório tenha se dado de modo negligente ou descuidado, que tenha sido desinformado e irrefletido.

39. No mesmo sentido, ainda que não tenham sido feitas outras alterações a fim de dar tratamento a determinadas ressalvas que persistiam em documentos anexos ao DIP 327 e que, inclusive, podiam configurar alertas com relação aos riscos envolvidos, naquele momento, na mudança de fase do Projeto RNEST ou de divergências conceituais ou metodológicas com relação às análises feitas, cabe reconhecer que tais ressalvas não foram omitidas nos novos pareceres, tampouco invalidavam a proposição, embora aumentassem o grau de risco associado à sua aprovação. A meu ver, também parece invadir o campo da análise de mérito da decisão negocial ou, no mínimo, que se esteja a incorrer em presunção não admissível no âmbito de um processo sancionador, reputar que, por não terem sido solicitadas e realizadas eventuais alterações em tais outros aspectos pertinentes a riscos ou à avaliação do Projeto, o processo decisório teria sido irrefletido.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

40. Por outro lado, seria irrealista esperar que tal ata, lavrada sob a forma de sumário, como permitido pela legislação societária, espelhasse debates e reflexões efetuados, ainda mais com relação a projetos complexos de companhias de grande porte²⁵.

41. Por conseguinte, diante do quadro fático-probatório delineado neste PAS, entendo que a Acusação não conseguiu se desincumbir do ônus probatório que lhe cabia quanto a evidenciar que não teria havido reflexão acerca das informações disponíveis. Assim, pelo exame do processo decisório *sob o prisma procedimental* aplicável na revisão deste caso, não alcanço convicção quanto à alegada falta de diligência dos diretores da Petrobras na aprovação da mudança do Projeto RNEST para a Fase IV.

Apreciação pelo Conselho de Administração - Mudança do Projeto para a Fase IV

42. Os membros do CA da Companhia foram acusados de terem faltado com diligência, quando da reunião de 17.12.2009, ao consentirem com a aprovação pela Diretoria Executiva da mudança do Projeto RNEST para a Fase IV, ignorando os sinais de alerta apresentados, em alegada infração ao disposto no art. 153 da Lei nº 6.404/1976. Também quanto a essa acusação acompanho o do voto do Diretor Gustavo Gonzalez, inclusive quanto ao entendimento de que o fato de a diretoria ter feito uma apresentação não pode ser interpretado como uma submissão da matéria para ratificação do CA, bem como que não foram considerados os diferentes papéis dos referidos órgãos nem sua dinâmica na Petrobras.

43. A rigor, a meu ver, não há que se falar em deliberação do CA acerca da aprovação da mudança de fase do Projeto RNEST, o que sequer seria matéria de sua competência estatutária²⁶. A conduta dos conselheiros pode também ser analisada sobre o prisma de eventual falta de diligência à luz das atribuições legais do CA, seja na orientação dos negócios da Companhia, seja na fiscalização da gestão dos diretores²⁷, o que, entretanto, não fez parte da narrativa acusatória, que reputou ter havido uma ratificação pelo CA.

²⁵ Sobre o tema, vale citar o seguinte trecho do voto da Diretora Relatora Ana Dolores Moura Carneiro de Novaes, proferido no julgamento do PAS CVM nº 2008/9574, em 27.12.2012: “*Quando o objeto da decisão dos administradores for complexo, controvertido, ou envolva partes relacionadas, é parte do dever de diligência dos administradores mostrarem que tomaram uma decisão de boa-fé e no melhor interesse da companhia. Uma simples ata de Conselho resumida informando que tal decisão foi tomada pode não ser suficiente para provar diligência. É preciso que haja suficiente documentação de suporte. Evidentemente, esta orientação deve ser seguida com bom senso pelas companhias em função de seu porte e da complexidade da situação concreta de forma a não travar as decisões de uma companhia*” (grifou-se).

²⁶ Aspecto já bem detalhado no voto do Diretor Gustavo Gonzalez.

²⁷ A Lei nº 6.404/1976, art. 142. Compete ao conselho de administração: I - fixar a orientação geral dos negócios da companhia; (...) III - fiscalizar a gestão dos diretores, examinar, a qualquer tempo, os livros e papéis da companhia, solicitar informações sobre contratos celebrados ou em via de celebração, e quaisquer outros atos; (...).



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

44. Ainda assim, mesmo que se considerasse que a acusação de falta de diligência subsistiria quanto à atuação do CA diante dos elementos levados ao conhecimento do órgão, por meio da referida apresentação realizada na reunião de 17.12.2009, o padrão de revisão a ser adotado seria o mesmo já referido, tendo em vista o conteúdo eminentemente negocial da matéria. Nesse contexto, releva destacar que o CA sequer recebeu os DIPs e demais documentos submetidos à Diretoria Executiva, tendo sido substancialmente diverso o processo de apreciação pelo CA do conteúdo da apresentação sobre o Projeto RNEST.

45. Como se observa da Ata da Reunião nº 1.326 do Conselho de Administração (“Ata CA 1326”)²⁸, foram realizadas, na parte inicial da reunião, após a solução de questões de ordem, seis apresentações sobre assuntos variados, tendo sido a primeira delas uma apresentação sobre o projeto RNEST. Em seguida às referidas apresentações, dez matérias, constantes das pautas 39 a 48, foram submetidas à “*deliberação formal*” do CA²⁹.

46. Observe-se o teor do trecho da Ata CA 1326 pertinente ao objeto deste PAS:

(...) Iniciada a reunião, na parte destinada às Questões de Ordem, foram aprovadas e assinadas as atas (...). Na sequência, foram feitas as **seguintes apresentações**: “**Refinaria Abreu e Lima – RNEST**”, pelo Gerente Geral de Planejamento Corporativo da unidade Abastecimento Corporativo, [A.M.F.], **com esclarecimentos do Conselheiro e Presidente da Petrobras** José Sérgio Gabrielli de Azevedo, **do Diretor de Abastecimento** Paulo Roberto Costa **e do Diretor-Presidente da Refinaria Abreu e Lima S.A. – RNEST**, [M.G.F.M.G.]. Visando **eleva a rentabilidade** do projeto, o **Conselho de Administração emitiu orientações** para a **continuidade das negociações** e determinou que o projeto retorne ao Colegiado para conhecimento, após a conclusão das negociações; (...)” **No tópico das deliberações formais** foram apreciados os seguintes **ASSUNTOS**: ----- **1) Pauta nº 39 – (...)**”
(grifos no original e aditados)

47. A prova dos autos indica, portanto, que a passagem do Projeto RNEST para a Fase IV foi apenas objeto de uma apresentação³⁰ ao CA e que, em vista das informações que lhe

²⁸ Consta da ata que a reunião teve início às 10h e término às 14:30h.

²⁹ Na parte da reunião destinada às deliberações formais, alguns assuntos também foram objeto de apresentações ao CA, que, em seguida, sobre eles decidiu. As deliberações do CA, em sua maioria, se deram nos termos dos resumos executivos que fundamentaram as proposições submetidas ao órgão.

³⁰ A apresentação, datada de 17.12.2009 e intitulada “Projeto de Implantação da Refinaria do Nordeste”, abordou, basicamente, os seguintes aspectos do projeto: a) objeto do projeto; b) produção esperada de diesel de baixo teor de enxofre e outros derivados do petróleo; c) gráficos comparando investimento e VPL para FEL-1 (2005) e FEL-2 (2006); d) ações de otimização do projeto e premissas atualizadas; e) desafios de execução (pressão adicional em prazos e investimentos; f) gráfico com curva de elevação do investimento entre FEL-1 e FEL-3; g) dificuldade na execução da terraplanagem; h) restrições do mercado fornecedor; i) gráficos com VPLs apresentados em setembro de 2009 à Diretoria Executiva; j) novos fatores avaliados, incluindo sensibilidades; k) quadros com fatores incorporados ao EVTE (TMA, perpetuidade e FUT); l) quadros com fatores analisados como sensibilidade; m) gráfico com aumento potencial do VPL (considerando novo EVTE



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

foram apresentadas, o CA emitiu orientações para a “continuidade das negociações” visando “elevar a rentabilidade do projeto”, o que demonstra que o CA considerou que a rentabilidade deveria ser aprimorada, reconhecendo espaço para melhorias no âmbito de negociações em curso que deveriam ser mantidas (e, de fato, estavam em andamento as negociações pertinentes aos esforços para confirmação das desonerações tributárias e à parceria com a PDVSA). Em suma, nos limites de sua atuação, parece-me que os conselheiros emitiram as orientações que entenderam pertinentes na ocasião quanto ao mérito do andamento do Projeto, cuja adequação mais uma vez não cabe à CVM aferir.

48. Desse modo, compartilho da visão de que não existem nos autos elementos que, *sob a ótica procedimental*, autorizem a conclusão de que os membros do CA não foram diligentes ao apreciar a matéria sem manifestar objeção à aprovação pela Diretoria Executiva da mudança de fase do Projeto RNEST.

II.2 Da supervisão pelo CA dos controles internos da Petrobras

49. Com relação à acusação em face dos membros do CA por não terem verificado correções necessárias para o bom funcionamento dos controles internos da Companhia, em alegada violação ao dever de diligência estabelecido no art. 153 da Lei nº 6.404/1976, também divirjo, respeitosamente, do voto do Diretor Relator e acompanho o voto pela absolvição dos acusados proferido pelo Diretor Gustavo Gonzalez, bem como suas razões pela rejeição da respectiva preliminar de prescrição.

50. No que tange às minudentes considerações apresentadas pelo Diretor Gustavo Gonzalez na análise do dever de monitoramento dos controles internos pelo CA em uma perspectiva organizacional, concordo que, evidentemente, se trata de obrigação de meio e não de resultado. Ressalvo, contudo, que, a meu ver, não cabe extrair do exame deste caso, a conclusão de que a responsabilização dos membros do CA por infrações da espécie caberia apenas em caráter excepcional “em casos extremos, de falhas totais, permanentes ou sistemáticas”. A meu ver, o conteúdo do referido dever deve ser aferido à luz das circunstâncias do caso concreto, ainda que, por óbvio, sem viés de retrospectiva e sem restringir-se apenas a um curto intervalo temporal, como feito pela Acusação neste caso.

e sensibilidades); n) aspectos importantes a considerar (integração econômica e energética da América do Sul, autossuficiência em diesel e atendimento ao mercado e desenvolvimento da região Nordeste; o) último slide se refere a proposta de aprovação da passagem do projeto da Fase 3 para a Fase 4 e a buscar, perante os órgãos competentes, novos benefícios tributários (não sendo esse slide final, entretanto, suficiente a meu ver, para configurar, de per si, uma submissão de proposta à aprovação do CA).



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

III. CONCLUSÃO

51. Por todo o exposto, acompanho o voto do Diretor Gustavo Gonzalez:

- (i) pelo reconhecimento da prescrição da ação punitiva da CVM em face de Almir Guilherme Barbassa, Guilherme de Oliveira Estrella, Ildo Luís Sauer, José Sérgio Gabrielli de Azevedo, Nestor Cuñat Cerveró e Renato de Souza Duque, na qualidade de diretores estatutários da Petrobras, com relação à imputação de inobservância do dever de diligência ao aprovarem o Plano de Antecipação da Refinaria (infração ao art. 153 da Lei nº 6.404/1976); e
- (i) quanto às demais acusações por inobservância do dever de diligência (infração ao art. 153 da Lei nº 6.404/1976), pela absolvição dos diretores estatutários e dos membros do Conselho de Administração da Petrobras, à época dos fatos que ensejaram às imputações que lhes foram dirigidas.

52. Quanto às demais imputações, reporto-me às razões constantes do detalhado voto do Diretor Relator, para acompanhá-las integralmente, assim como suas conclusões.

É como voto.

Rio de Janeiro, 03 de novembro de 2020.

Flávia Sant'Anna Perlingeiro

Diretora



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM Nº 05/2016

Reg. Col. nº 1404/2019

Acusados: Almir Guilherme Barbassa
Dilma Vana Rousseff
Fábio Colletti Barbosa
Francisco Roberto de Albuquerque
Guido Mantega
Guilherme de Oliveira Estrella
Ildo Luís Sauer
Jorge Gerdau Johannpeter
Jorge Luiz Zelada
José Sérgio Gabrielli de Azevedo
Luciano Galvão Coutinho
Maria das Graças Silva Foster
Nestor Cuñat Cerveró
Paulo Roberto Costa
Renato de Souza Duque
Sergio Franklin Quintella
Silas Rondeau Cavalcante Silva

Assunto: Apurar possível inobservância de deveres fiduciários de administradores da Petrobras na construção da Refinaria Abreu e Lima. Infração aos artigos 153, 154, §2º, “c”, 155, e 163, I, da Lei nº 6.404/1976.

Diretor Relator: Henrique Machado

MANIFESTAÇÃO COMPLEMENTAR DE VOTO

1. Iniciado o julgamento do processo em 24 de agosto de 2020, proferi voto pela condenação dos diretores da Petrobras por terem faltado com o dever de diligência na aprovação do PAR¹ e da passagem à fase IV do projeto da RNEST, em razão do comportamento por eles adotado em cada uma destas deliberações, o qual se demonstrou, conforme razões consignadas em meu voto, divorciado dos padrões de diligência esperados às circunstâncias.

¹ As abreviaturas aqui utilizadas seguem o mesmo padrão adotado na elaboração do relatório e voto.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

2. Na mesma linha, firmei convicção pela condenação do conselho de administração da Petrobras por falta de diligência no exame da aprovação pela diretoria da passagem à fase IV e na supervisão dos controles internos da Companhia, pois os conselheiros têm o dever de intervir nas operações sociais sempre que for necessário, respeitando os limites de sua competência.
3. Propus também a condenação dos diretores Paulo Roberto Costa e Renato Duque por terem aprovado etapas do projeto RNEST em troca de vantagens indevidas, em flagrante violação ao dever de lealdade.
4. Por fim, requeri a absolvição da diretora-presidente Graça Foster da acusação de desvio de poder formulada contra ela porquanto os elementos de prova se mostraram insuficientes para demonstrar que ela obstaculizou a investigação interna da Petrobras para satisfazer interesse pessoal, em detrimento dos interesses da Companhia.
5. Com o retorno do processo à pauta, após a devolução de vista do Diretor Gustavo Gonzalez e a manifestação de voto proferida pela Diretora Flávia Perlingeiro, e considerando a relevância deste julgamento como precedente desta Comissão, tenho como oportuno realizar algumas considerações a propósito de alguns dos novos argumentos sufragados pelos votos divergentes.
6. Registro que o faço com o firme propósito de ampliar o debate de elevado espírito público que historicamente esta Comissão promove sobre o assunto, cujo confronto de ideias é necessário para a melhoria do ambiente regulatório e, por consequência, para a evolução e a higidez do mercado de capitais brasileiro.
7. A reflexão principal que gostaria de provocar refere-se à utilização da regra da decisão negocial (“*business judgment rule*”) para afastar a aplicação cogente do rigoroso sistema de deveres fiduciários imposto ao administrador das companhias abertas. Ao enunciar minuciosamente tais deveres, o legislador buscou coibir e dissuadir comportamentos indesejados que pudessem causar prejuízos à coletividade social dada a importância das companhias para o desenvolvimento econômico e a responsabilidade dos administradores na gestão de recursos de terceiros advindos da poupança popular.
8. Assim, compete a esta Comissão debater o uso da regra da decisão negocial em harmonia com os deveres fiduciários estabelecidos em lei, especialmente o dever de diligência, de sorte a equilibrar o exercício do poder gerencial e a prevenção de abusos, sob pena de enfraquecer, em sede de julgamento, o sistema dos deveres fiduciários, em prejuízo do próprio regime jurídico aplicável às sociedades anônimas.
9. Com efeito, ao longo da evolução do entendimento doutrinário e jurisprudencial desta comissão, consagrou-se adequadamente o entendimento de que a análise da aderência de determinada conduta ao padrão de diligência previsto em lei



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

deve ser feita com foco no aspecto procedimental. Em apertada síntese, o que deve ser objeto de exame para aferir o cumprimento do dever de diligência é a forma segundo a qual o administrador se desincumbe de suas atribuições e não o resultado final de suas decisões², porquanto este está sujeito a diversas circunstâncias fora do controle do administrador.

10. Não seria mesmo possível admitir outra interpretação, uma vez que esta é a única que se coaduna com a natureza do dever de diligência. A aferição do cumprimento desse dever requer a verificação, em cada caso concreto, do emprego pelo administrador de esforços necessários e proporcionais para o alcance de determinado resultado. Eventual resultado insatisfatório não demonstra, portanto, falta de diligência.

11. Antes de prosseguir, assevero que não tenho a intenção de minimizar ou mesmo retirar a importância da *business judgment rule* como standard de revisão ou regra para enquadrar as hipóteses em que administradores responderão pessoalmente pelos prejuízos que causarem à sociedade anônima. Ela auxilia a compreensão de que a obrigação de um administrador é empreender os melhores esforços possíveis em sua atividade, de modo a buscar o melhor resultado possível para a companhia, e evita que administradores sejam coagidos a adotar posturas excessivamente conservadoras, em prejuízo do interesse social.

12. Diante da liberdade e discricionariedade que os administradores têm para gerir os negócios sociais, ainda que uma decisão possa causar prejuízo, tal adversidade, por si só, não caracterizará o inadimplemento de sua obrigação desde que o administrador tenha sido diligente no procedimento adotado para a perseguição do melhor interesse da companhia.

13. No entanto, diversas são as críticas relacionadas à formulação da *business judgment rule*, sua recepção pela Lei nº 6.404/76 e a sua correta aplicação pela CVM.

14. A doutrina discute a *business judgment rule* expondo que a sua aplicação é cercada de controvérsia em Delaware, onde existe bastante descontentamento quanto ao tratamento leniente conferido pelas cortes de justiça de Delaware aos administradores, sem mencionar as incertezas quanto à extensão da regra a diretores³. Do mesmo modo,

² Sobre o tema: CAMPOS, Luiz Antonio de Sampaio. Deveres e responsabilidades. In: LAMY FILHO, Alfredo; PEDREIRA, José Luiz Bulhões (Coords.). Direito das Companhias. 2ª Edição. Rio de Janeiro: Forense, 2017, p. 805; GONZALEZ, Jesus Quijano. La responsabilidad civil de los administradores de la sociedad anonima: aspectos sustantivos. Universidade de Valladolid, Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Salamanca, 1985, pp. 186/187.

³ “Cumpre refletir ainda, sobre a medida em que os contornos assumidos pela *business judgment rule* nos Estados Unidos devem modular a responsabilidade dos administradores no direito brasileiro. Por óbvio, a lei acionária brasileira não exige que seja aqui aplicada a regra da decisão empresarial nos moldes da atual jurisprudência de Delaware – embora, evidentemente, tampouco impeça que seja ela (ou qualquer outra) utilizada como fonte de inspiração. Há, com efeito, poucos traços mais característicos da cultura



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

há críticas quanto à concepção da regra da decisão negocial como padrão de revisão de conduta dos administradores de companhias⁴.

15. No que se refere à aplicação da regra da decisão negocial pela CVM, importante destacar o debate havido sobre o assunto no âmbito do Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional (“CRSFN”). No julgamento do recurso nº 10372.000141/2016-23, de 21 de agosto de 2018, o CRSFN convolou o arquivamento de uma acusação da CVM em multa justamente porque o fundamento da absolvição pelo descumprimento do dever de diligência amparou-se, equivocadamente, na regra da decisão negocial. Cabe, por oportuno, trazer à colação trechos do voto condutor do Conselheiro Relator Carlos Portugal Gouvêa:

Para afastar a violação do dever de diligência pelo acusado, a CVM pautou-se, resumidamente, nos 3 (três) parâmetros que, de acordo com a jurisprudência anterior da própria CVM, comporiam a regra de deferência à decisão negocial importada do direito estrangeiro, quais sejam, que para que a decisão seja conservada e o administrador não seja responsabilizado, deve ser tomada de forma (i) informada, (ii) desinteressada e (iii) refletida. [...]

No entanto, o estudo do conceito originário da *business judgment rule* como surgiu no direito estadunidense, particularmente na jurisprudência do Estado de Delaware, demonstrará claramente o equívoco da presente decisão, pois tal conceito é aplicado no direito

jurídica nacional do que a propensão ao recurso seletivo às soluções de direito estrangeiro. Contudo, importante razões de ordem jurídica, política e econômica aconselham cautela no transplante de soluções jurídicas consolidadas no contexto norte-americano. De um lado, há considerável margem para dúvidas sobre a eficiência do atual regime de responsabilidade civil dos administradores daquele país. Isso porque a jurisprudência societária de Delaware é sabidamente influenciada pelos interesses desse estado em atrair o maior número possível de companhias a fim de incrementar a sua arrecadação. Vigora nos Estados Unidos, como se sabe, um sistema de ‘competição regulatória’ em matéria societária, pois é lícito às companhias escolher livremente o seu estado de constituição e, por conseguinte, o sistema de direito societário aplicável. Embora o regime jurídico de Delaware, decorrente dessa dinâmica, seja mais favorável aos interesses dos acionistas do que o de outros estados, é nítida a sua preocupação em não desagradar demasiadamente os administradores – os quais, afinal, são responsáveis por propor o registro ou a migração para Delaware (assim também determinando, em última análise, a magnitude de suas receitas tributárias)”. Pargendler, Mariana. Responsabilidade Civil dos Administradores e *Business Judgment Rule* no Direito Brasileiro. *Revista dos Tribunais*, v. 953, 2015, p. 53.

⁴ “De uma forma ou de outra, a concepção da regra como um *standard of review* não escapa de críticas. Lori McMillan, usando como exemplo de aplicação dessa visão o caso Omnicare, Inc. v. NCS Healthcare, destaca que essa teoria cria duas infelicidades: (i) administradores que atuarem de boa-fé podem utilizar a *business judgment rule* como um escudo contra sua responsabilização pessoal; e (ii) a regra parece apenas rebaixar a régua de responsabilização da mera negligência para um padrão menor, como a negligência grave. O professor Stephen Bainbridge se junta aos críticos e afirma que enxergar a *business judgment rule* como um padrão de revisão faria com que a intervenção judicial deixasse de ser exceção para se tornar a regra. Seria, como ele diz, colocar a carroça na frente do cavalo, pois, caso se admita tal concepção, os juízes, em primeiro lugar, procurarão quebras nos deveres fiduciários para somente depois se absterem de avaliar a decisão tomada”. BRIGAGÃO, Pedro Henrique Castello. A Administração de Companhias e a Business Judgment Rule. São Paulo: Quartier Latin, 2017. p. 86 e 87.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

comparado de forma muito mais restritiva do que passou a ser aplicada pela CVM.

Inicialmente, a utilização do conceito da *business judgment rule* no caso presente pela CVM foi feita de forma fracionada, incidindo no primeiro problema mencionado acima. Digo fracionado, pois desconexo do resto do sistema de deveres fiduciários, conforme aplicado pelo direito societário estadunidense. **Em essência, a aplicação da *business judgment rule* pressupõe que os deveres fiduciários de diligência (*duty of care*) e lealdade (*duty of loyalty*) tenham sido observados.** [...]

Outro ponto relevante é que na jurisprudência estadunidense não se identifica a cisão trazida na jurisprudência da CVM entre decisão “informada” e “refletida”, na medida em que a reflexão que precede a decisão é subsumida no conceito de “informed decision”. **Uma interpretação adequada da língua inglesa nos faria necessariamente concluir que o que os juízes do Estado de Delaware buscaram dizer não foi apenas que a decisão deveria ser tomada com base em informações suficientes, mas que a decisão deveria ser tomada de forma também refletida e justificada.** Tal critério é demonstrado tanto pela existência de prova de que os administradores tinham informações, quanto de que deliberaram adequadamente sobre a questão.

Uma análise mais detalhada da jurisprudência estadunidense nos levaria a reconhecer tal sentido amplo do conceito de “informed decision”. De acordo com as cortes do Estado de Delaware, uma decisão será informada se for tomada com base em todos os fatos relevantes e disponíveis, no âmbito de um processo decisório cuidadoso e a extensão das informações necessárias é aquela que o administrador “racionalmente acredita ser apropriado naquelas circunstâncias”. Ou seja, não é apenas a informação, mas a própria interpretação da informação que é relevante. Logicamente se espera que, de um processo decisório em que o administrador se muniu de todas as informações relevantes e disponíveis, decorra uma decisão refletida. [...]

16. Como bem ressaltado no mencionado voto, a aplicação da regra negocial decorre do cumprimento dos deveres fiduciários e, não, o inverso. Do contrário, a *business judgment rule* afastaria a capacidade de avaliar o efetivo cumprimento pelos administradores dos deveres fiduciários estabelecidos na Lei nº 6.404/76.

17. A par disso, entendo, conforme jurisprudência desta Comissão⁵, que ao avaliar decisões negociais tomadas por administradores de companhias abertas, deve ser adotada, nos seus estritos limites, a presunção relativa contida na *business judgment rule* de que, ante a inexistência de fatos que demonstrem má fé, fraude, ou conflito de

⁵ PAS CVM nº 03/02, Rel. Norma Jonssen Parente, j. em 12.02.2004; PAS CVM nº RJ2008/9574, Rel. Ana Novaes, j. em 27.11.2012; e PAS CVM nº RJ2005/1443, Rel. Pedro Oliva Marcilio, j. em 10.05.2006.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

interesses do administrador, **e ante a inexistência de qualquer falha procedimental no respectivo processo decisório**, as decisões de um administrador devem, em princípio, ser consideradas regulares. **Isto é, tais decisões gozam da presunção relativa de que foram tomadas buscando o melhor interesse social**.

18. No caso dos autos, as provas demonstram inequivocamente que a decisão tomada pelos administradores da Petrobras, injustificadamente, não observou a Sistemática Corporativa, procedimento estabelecido para amparar o processo de tomada de decisão relativamente a projetos de investimentos. Restou sobejamente comprovada a falha procedimental no processo decisório estabelecido para a aprovação do PAR e para a aprovação da passagem à fase IV do projeto RNEST.

19. Além disso, havia diversos sinais de alerta a respeito da inviabilidade econômica do projeto e da pretensa parceria a ser firmada pela Petrobras com a PDVSA, assim como diversas recomendações e sugestões técnicas consignadas em pareceres técnicos. Tudo isso devidamente evidenciado nos autos é prova suficiente para demonstrar a irregularidade do comportamento dos administradores no processo decisório de aprovação do projeto RNEST.

20. No caso da aprovação da passagem à fase IV do projeto, não pode deixar de ser considerado que o assunto havia sido submetido à Diretoria em 03.09.2009 e não foi aprovado não porque havia necessidade de ajustes, mas pelo incontestável fato de que o projeto apresentava um VPL negativo em US\$3,067 bilhões e, em função disso, não poderia ser aprovado.

21. Daí a determinação, ressaltada pela Diretora Flávia Perlingeiro, de “*que várias ações fossem tomadas a fim de melhorar os indicadores econômicos do projeto*”, o que efetivamente foi feito e levado novamente à Diretoria Executiva em 25.11.2009. Ocorre que, tais ações, que elevaram o VPL do empreendimento para um valor marginalmente positivo de US\$0,076 bilhão, em uma análise expedita chegam a atrair o juízo de racionalidade, exposto pelo Diretor Gustavo Gonzalez.

22. Com efeito, não me parece haver qualquer base racional na consideração pela administração, como condição de aprovação do projeto, do valor de mercado que seria perdido para terceiros, em caso de não construção do empreendimento, elemento que contribuiu com US\$0,722 bilhão para o novo VPL. No mesmo sentido, outros condicionantes acrescentados à nova análise, sugerem uma tentativa artificial de fazer com que o VPL do empreendimento “virasse” para um valor positivo, como as desonerações tributárias, inclusão da perpetuidade nos fluxos de caixa futuros e o aumento do Fator de Utilização da refinaria para 96%⁶.

⁶ Conforme informações disponíveis na imprensa, o Fator de Utilização das refinarias da Petrobras alcançou uma média de 83% entre julho e setembro, alta em comparação com os 70% do segundo



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

23. Aprovar um projeto com esses condicionantes, com a devida vênia à bem elaborada argumentação do Diretor Gustavo Gonzalez, não passa por assumir conscientemente riscos empresariais, mas, sim, configura uma completa desconsideração dos flagrantes *red flags* indicando a inviabilidade do projeto

24. Diante de tantos elementos probatórios da culpa grave dos administradores da Petrobras, não deveria prevalecer, de acordo com a ampla jurisprudência desta Comissão, a presunção relativa conferida pela regra de decisão negocial de que aquelas decisões teriam sido tomadas no melhor interesse da Petrobras, pois a infração aos normativos internos da Petrobras e o descuido diante dos diversos sinais de alerta levantam fundadas dúvidas quanto à lisura e boa-fé da decisão tomada pelos administradores.

25. Assim, o emprego da *business judgment rule* para eximir a responsabilidade dos administradores em casos como o presente processo padece de, ao menos, dois problemas. Primeiro, afasta-se dos precedentes da Autarquia sobre o tema, alargando sobremaneira a extensão da regra da decisão negocial, motivo que já foi objeto de reforma pelo órgão recursal. Segundo, reduz, sem aparente fundamento, a rigidez do cumprimento do dever de diligência estabelecida pela lei das sociedades anônimas.

26. A regra deve ser utilizada com os devidos cuidados, de maneira muito mais restritiva, de modo a não responsabilizar o administrador que, mesmo de boa-fé, sem interesse ou conflito, **e ante a inexistência de qualquer falha procedimental no respectivo processo decisório,** ainda assim, toma decisão que causa prejuízo à companhia, conforme destaca a doutrina sobre o assunto⁷:

Ao cabo, a presunção constitui imposição do ônus da prova a quem contesta a decisão negocial. **Enquanto não houver indicativos de que a conduta do administrador se incumbiu de má-fé, falta de diligência ou desrespeito aos interesses sociais, tanto ele quanto a sua decisão manter-se-ão intactos e protegidos pela business judgment rule.** Em outras palavras, o administrador não será responsável e a decisão não será substituída ou invalidada. **Contudo, se o autor demonstrar que algum desses vícios está presente na atuação do réu, a presunção cai.**

[...] Nas situações em que a presunção é derrubada, o ônus da prova é transferido para os administradores réus, que deverão provar que a operação se deu de maneira totalmente justa aos interesses da companhia e de seus acionistas.

trimestre. No terceiro trimestre de 2019, o fator de utilização médio foi de 80%. Fonte: <https://valor.globo.com/empresas/noticia/2020/10/29/petrobras-refinarias-operam-com-utilizacao-acima-de-80percent-diz-ceo.ghtml>, acesso em 3.11.2020.

⁷ BRIGAGÃO, Pedro Henrique Castello. A Administração de Companhias e a Business Judgment Rule. São Paulo: Quartier Latin, 2017. p. 91.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

27. Assim, diante da falha no processo de tomada de decisão, emerge a necessidade de o administrador demonstrar que, apesar disso, ele ainda assim estaria perseguindo o melhor interesse da companhia. Em outras palavras, incumbia aos Acusados demonstrar que tinham boas razões técnicas para descumprirem as regras de governança corporativa e para ignorarem os sinais de alerta contidos nos pareceres. Neste contexto, tornava-se imperiosa a evidenciação de que a decisão foi tomada, a despeito de tudo isso, em consonância com o padrão de diligência exigido pela Lei nº 6.404/1976.

28. No caso vertente, resta incontroverso que os Acusados foram informados que atuavam em desconformidade com a Sistemática Corporativa e que foram informados por diversas áreas da Petrobras dos riscos da decisão de investimento. É de todo razoável pressupor que alertas dessa magnitude causaram reflexão por parte dos administradores e que eles até devem ter discutido o problema nas reuniões, como asseveram as defesas. Entretanto, diante da natureza estratégica do investimento e dos valores bilionários envolvidos, assim como da percuciência dos alertas técnicos, a tomada de decisão deveria ter sido justificada. Ocorre, contudo, que inexistem nos autos qualquer registro das discussões que alegam ter tido e, ainda mais grave, não há evidência de mínimas justificativas para as decisões tomadas.

29. Perceba-se, por evidente, que num contexto como o dos autos apenas uma justificativa válida da decisão permitiria avaliar a existência de “má-fé, fraude e desinteresse”. E, se assim tivesse ocorrido, independentemente do resultado do investimento, a adequação do procedimento formal de decisão teria atraído a presunção de que trata a *business judgment rule*.

30. Para além da prática ordinária das companhias e da permissão de registro sumário das decisões, a ideia de que decisões estratégicas e patrimonialmente relevantes de uma companhia possam contrariar os normativos internos e desconsiderar os riscos apontados por pareceres técnicos sem qualquer justificativa subverte a regra de decisão negocial. Mais do que isso, se traduzida em entendimento dominante, tais normativos e pareceres correm o risco de se tornarem atos pró-forma destinados ao cumprimento estéril de um procedimento burocrático voltado a proteger administradores contra a revisão administrativa e judicial de suas decisões, sempre que contrariarem a ambição legítima ou não da administração.

31. O quadro é ainda mais alarmante em se tratando de uma sociedade de economia mista, com controle acionário concentrado e ingerência estatal nos negócios privados. A Companhia, ainda que sujeita a regime jurídico híbrido, possui deveres de transparência, motivação e prestação de contas que restaram bastante olvidados no presente caso.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

32. Nesse ponto é impossível não lembrar do mencionado voto do Justice Oliver Wendell Holmes, que, também vencido, assim consignou:

“Great cases like hard cases make bad law. For great cases are called great, not by reason of their importance in shaping the law of the future, but because of some accident of immediate overwhelming interest which appeals to the feelings and distorts the judgment. These immediate interest exercise a kind of hydraulic pressure which makes what previously was clear seem doubtful, and before which even well settled principles of law will bend.”⁸

33. No caso vertente, os administradores aprovaram etapas do projeto RNEST apoiados em documentação que trazia informações que retiravam a credibilidade das premissas aprovadas. Deve-se reconhecer, neste particular, o menor grau de confiança de uma decisão respaldada em documentos divergentes, o que exige maior cuidado dos administradores para justificar a decisão. Reitero, em linha com o Voto que proferi, que a mera ata da reunião informando que determinado assunto foi aprovado, sem expor a razão pela qual tal decisão se deu contrariamente aos documentos técnicos que a suportava, não pode ser suficiente para provar a diligência dos Acusados.

34. Aliás, o fato de a ata ser lavrada sob a forma de sumário, como permitido pela legislação societária, não impossibilita que seja consignada a justificativa da decisão, tampouco obsta que outros documentos possam espelhar as discussões havidas sobre o assunto. Não posso deixar de mencionar que no julgamento do PAS CVM nº 2015/10667⁹, de minha relatoria, o acusado foi absolvido exatamente porque havia farta documentação a respeito dos debates e reflexões ocorridos no âmbito da diretoria, do conselho de administração e do conselho fiscal da Petrobras. Naquela oportunidade, o teor das discussões foi registrado pelos órgãos sociais da Petrobras e devidamente trazido aos autos pela defesa, o que foi preponderante para firmar minha convicção pela absolvição do acusado.

35. A exigência da formalização das decisões de companhias abertas e a impossibilidade de se considerar uma decisão refletida tendo por base alegações não comprovadas pelas defesas não é nenhuma inovação nesta CVM, tendo sido inclusive objeto de registro pelo Presidente Marcelo Barbosa¹⁰, que assim se posicionou sobre o tema:

⁸ Northern Securities Co. v. United States, 193 U.S. 197, 400-411 (1904).

⁹ Julgado em 07.02.2017.

¹⁰ PAS SEI nº 19957.005981/2016-86, j. em 19.11.2019.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

Antes de concluir, considero importante ressaltar, inclusive para reiterar orientação que aproveita a todos os administradores de companhias abertas, que, justamente porque a análise do cumprimento do dever de diligência recai sobre o processo que levou os administradores a tomarem determinada decisão, é parte deste dever que tais agentes demonstrem que efetivamente atenderam aos cuidados que deles se espera.

É salutar, portanto, que a administração das companhias abertas tenha por política a manutenção de registros suficientes para que se possa evidenciar as tratativas havidas a respeito de temas relevantes bem como os participantes envolvidos, **com a minúcia suficiente para que se permita compreender a evolução dessas discussões, providências consideradas e requeridas, justificativas apresentadas**, dentre outros elementos que permitam à própria companhia e, conforme o caso, a terceiros, averiguar a aderência das práticas de gestão e mesmo a aderência das condutas às exigências legais.

Não ignoro, por óbvio, que diversas informações constantes de discussões havidas no âmbito de órgãos de administração apresentam elevado grau de sensibilidade. Portanto, a preocupação externada no parágrafo anterior deve ser entendida com a devida dose de bom senso, de forma que os registros que venham a ser feitos sejam apenas aqueles razoáveis, observado um juízo de necessidade e conveniência. **No caso sob discussão, temos um exemplo claro de situação em que a insuficiência dos registros dificulta sobremaneira as defesas dos acusados, dentre outras consequências negativas.**

Ademais, considero que os esforços empreendidos pelos acusados **poderiam ter sido maiores quanto à formalização daquilo que alegaram ter considerado para a formação de sua convicção. A este propósito, chamo atenção para os argumentos apresentados pelas defesas de que a deliberação foi refletida, pois foi objeto de avaliação por cerca de um ano; que as negociações que a Companhia travava à época com seus credores no âmbito de sua recuperação judicial foram fundamentais para a decisão tomada; assim como que a alternativa de submeter o conflito à arbitragem foi desconsiderada em razão dos custos envolvidos.**

Esses aspectos claramente **poderiam ter conferido maior respaldo à higidez do processo decisório, mas não há nos autos qualquer documento que demonstre que de fato foram levados em conta pelos administradores, razão pela qual não entendo ser possível considerá-los na avaliação da conduta dos acusados.** No primeiro caso, por exemplo, desde a eleição dos conselheiros independentes até a efetiva deliberação em 17.11.2014, há um único registro das discussões que tiveram sobre o tema, em 30.04.2014, sem que fosse possível examinar se, após essa data, o assunto teria sido objeto de novas discussões.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Com relação aos dois últimos argumentos, tampouco consta, dos documentos que subsidiaram e documentaram a deliberação de 17.11.2014, que a conduta dos credores no curso da recuperação judicial, bem como os custos envolvidos no procedimento arbitral foram avaliados e considerados pelos administradores em seu processo de tomada de decisão.

36. Aliás, como claramente se observa, não se trata de inversão do ônus da prova, mas de sua correta distribuição no âmbito do processo, dado que cabe, de um lado, à acusação provar os fatos constitutivos da pretensão punitiva (materialidade e autoria), atribuição que, como visto, a Acusação se desincumbiu; e, de outro, à defesa, a prova quanto aos eventuais fatos que possam comprovar a ausência de culpa nas condutas apontadas irregulares, o que os Acusados não lograram demonstrar.

37. Diante da presente Acusação, pode-se afirmar que a alegação de inversão do ônus de prova em razão da necessidade de os Acusados comprovarem o quanto alegam é, no mínimo, incoerente com o sistema jurídico e contrária aos precedentes desta Comissão e às provas constantes do presente processo.

Termos que integram as razões do meu Voto.

Rio de Janeiro, 03 de novembro de 2020.

HENRIQUE BALDUINO MACHADO MOREIRA

DIRETOR RELATOR